

民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》 | 第1章 · 第2章 · 第3章 · 第5章 · 第11章

☐ 本周覆盖章节

第1章 民法概述 — 概念/调整对象/性质/渊源/适用（8节完整）

第2章 民法基本原则 — 八大原则完整展开（8节完整）

第3章 民事法律关系 — 一般原理/法律事实（事件vs行为）

第5章 自然人 — 权利能力/行为能力/监护/宣告失踪死亡/两户/住所

第11章 民事权利 — 概述/5种基本分类/主要类型/取得变更消灭/行使保护

☐ 2026年6月1日 - 6月6日 | 第一周复习 | 基于课本文整理

民法总论 · 第一周知识点总结

王利明《民法总则（第二版）》 | 2026年6月1日—6日 | 内容100%基于课本原文

第一章 民法概述

甲为某市政府，为改善市容市貌，甲决定对本市的城中村进行集中改造，甲将乙所在的城中村划入征收拆迁的范围，并计划在该城中村的位置建设一个大型商场，乙认为市政府的决策存在问题，因为建设商场并不属于公共利益的范畴，因此拒绝签订有关补偿安置协议，并向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院撤销甲的征收决定。法院认为，甲、乙之间的纠纷并不属于平等主体之间的民事纠纷，因此裁定驳回乙的起诉。

简要评析: 在该案中，双方争议的焦点是甲的征收决定的效力问题，依据《民法总则》第2条的规定，“民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系”。而该案的纠纷并不属于发生在平等主体之间的人身、财产纠纷，应当属于行政纠纷，因此，法院不应当将其作为民事案件受理。

第一节 民法的概念

一、民法的语源

民法作为调整平等主体之间的财产关系与人身关系的法律，在各国法律体系中都占据着重要地位。但“民法”一词并非我国固有的概念。关于民法的语源，许多学者认为，在我国，“民法”一词最早见于《尚书·孔氏传》。[1]在清末立法时，民政部奏文中称：“民法之称，见于尚书孔传。”这里提到的“民法”一词应为我国民法的辞源。不过，《尚书·孔氏传》中提及的民法一词，并非近代意义上的民法。至于古代法律典籍中出现的“民事”一词，也与现代民法中的民事一词有极大的差异。

据许多学者考证，私法意义上的“民法”一词出现于明治时代的日本，中文“民法”一词是由日文转译而来，而日文中“民法”一词究竟是译自法语还是荷兰语，目前仍有争议。[2]20世纪初叶上海南洋公学译书馆将《日本法规大全》（日本明治三十四年即1901年第三版）译成中文，其第三类法规为“民法”。光绪三十二年（1907年）修订法律馆参照南洋公学译本翻译完成《新日本法规大全》，对系统化的私法法典亦采用“民法”之称谓。[3]清末变法时，修律大臣沈家本聘请日本学者松冈义正等人起草大清民律草案，借鉴“民法”一词，结合“唐律”“明律”“清律”的传统称呼，自创“民律”一词。此后清末、民初民法典草案皆称“民律”草案。1926年，北洋政府曾起草一部民法草案，1929年南京国民政府颁布了《中华民国民法》总则编，中国近代立法在法律上正式使用了“民法”的称谓。

近代一些大陆法系国家所使用的“民法”一词（法文为droit civil，英文为civil law，德文为Bürgerliches Recht，荷兰文则为Burgerlyk Regt）皆由市民法（ius civile）转译而来。同时，因格劳秀斯编著国际法时，以万民法称之，故西方学者大都认为，罗马法的万民法为国际法的语源，而市民法则为民法的语源。词源上的“民法”都源于拉丁文的“市民法”[4]。在罗马法中，“市民法”是对罗马市民适用的法律总称，与“万民法（ius gentium）”相对应。市民法适用于罗马公民之间的关系，万民法主要适用于罗马公民与外国人之间的关系。但是，在查士丁尼制定《国法大全》时，罗马帝国对其境内的所有居民皆赋予市民权，导致市民法与万民法的融合。自中世纪以来，“市民法（ius civile）”一词成为罗马法的总称，西方学者称之为私法。中世纪的时候，市民法又与教会法相对应。法国大革命之后，市民被理解为公民，因而民法被认为是适用于全体公民的法律。

二、民法的两种含义

民法的概念应从形式意义与实质意义两方面加以理解。

（一）形式意义上的民法

形式意义上的民法就是指民法典。法典是按照一定体系将各项法律制度系统编纂在一起的法律规范的总和。而民法典就是指按照一定的体系结构将各项基本的民事法律制度加以系统编纂而形成的规范性文件。民法典的重要特点，首先表现在它是体系化、系统化的产物，满足了形式理性的要求，所以民法典属于民事法律中最高形式的成文法；其次，民法典是对基本民事法律制度的规定，所以民法典中大量存在的是普遍适用的基本民事法律规范。一些学者认为，“不管在哪里，民法典都往往被当作整个法律制度的核心”[5]。大陆法系国家，自19世纪法典化运动以来，基本上都制定了民法典，这也是大陆法系国家法律体系的主要标志。近代意义上的法典作为最高形式的成文法，是追求体系化与严密逻辑性的产物。民法典就是以体系性以及由之所决定的逻辑性为重要特征的，体系是民法典的生命。民法典必须满足形式合理性的要求，而这种形式的合理性很大程度上就体现在其体系的完整性之上。

自新中国成立以来，立法机关曾于1954年、1962年、1979年和1998年四次启动民法典的起草工作，但受当时的历史条件所限，民法典的制定始终未能完成。党的十八届四中全会决定提出“编纂民法典”，为我国民法典的制定提供了新的历史契机。由于民法典内容浩繁、体系庞大，涵盖社会生活的方方面面，因而，制定民法典首先需要制定一部能够统领各个民商事法律的总则。从我国民事立法的发展来看，虽然我国已经颁布了250部法律，其中半数以上都是民商事法律，但始终缺乏一部统辖各个民商事法律的总则。正是在这样的背景下，《民法总则》的制定不仅实质性地迈出了民法典的制定步伐，并成为民法典的核心组成部分，而且有力地助推了法律体系的完善。《民法总则》颁行后，未来民法典各分编的编纂都要与《民法总则》进行协调，并以《民法总则》所确立的立法目的、原则、理念为基本的指导，从而形成一部价值融贯、规则统一、体系完备的民法典。在它正式通过以后，我国就将存在形式意义上的民法，这所谓民法，就是指民法典。

（二）实质意义上的民法

实质意义上的民法是指所有调整民事关系的法律规范的总称，它包括民法典和其他民事法律、法规。我国虽然尚未颁行民法典，但已经颁行《民法总则》，而且民法典分则的相关部分也已经有相关的法律予以调整，只需要对这些民事单行立法进行整合，因此，我国目前虽不存在形式意义上的民法，但存在实质意义上的民法。

实质意义上民法的特点在于：一方面，其是调整平等主体关系的法律规范，而并不注重外在的形式。形式意义上的民法尽管是最高形式的成文法，但毕竟不能涵盖民事生活的全部，还必须存在大量的置于其他法律、法规中的民法规范。另一方面，实质意义上的民法不仅限于法律、法规，而且包括大量的其他规范性文件 and 司法解释，所以实质意义上的民法在法源上的意义更为宽泛。正是由于该原因，实质意义上的民法也被称为广义的民法。在我国，广义的民法是指所有调整民事关系的成文法和不成文法。它涵盖所有调整平等主体之间财产关系、人身关系和婚姻家庭关系的法律，包括民法总则、物权法、债和合同法、侵权责任法、知识产权法、婚姻法、继承法，以及公司法、证券法、保险法、海商法、票据法、破产法等，甚至包括行政法规中的民法性规范。

在考虑实质意义上的民法与形式意义上的民法的关系时，必须注意如下几个方面的问题：首先，有了实质意义上的民法并不能否定形式意义上的民法，因为必须通过民法典对实质意义上的民法进行归纳、整理，从而将基本的民事法律制度系统化。其次，即使将来制定了民法典，也无法排斥实质意义上的民法。实质意义上的民法不仅存在于行政法规、司法解释等规范性法律文件中，而且可以某一条或某几条的形式存在于在整体上属于公法的法律文件当中。再次，在民商合一的体例下，实质意义上的民法不限于传统意

义的民事法律规范，还包括各种商事特别法、商事法律规范。

三、我国民法的概念

我国《民法总则》第2条从民法的调整对象和任务的角度，给民法下了一个定义，即：民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系的法律规范的总和。这一定义科学地揭示了我国民法所调整社会关系的范围和任务，从而明确地划定了民法与其他法律部门的界限，解决了长期以来学理上对民法定义的争论。除此以外，《民法总则》第2条的规定还具有如下几方面的意义：

第一，确立了我国民法统一调整社会主义市场交易关系的基本法地位。根据《民法总则》第2条，我国民法统一调整平等主体之间的财产关系，而平等主体之间的财产关系实质上就是指商品关系或交易关系，因此，无论是何类民事主体，只要它们以平等的民事主体的身份从事交易，就应当遵循民法的规范，并受民法的调整。

第二，我国民法明确将人身关系作为其调整对象，突出了对人的尊重，体现了以人为本的理念。关于民法的调整对象，1986年《民法通则》第2条规定：“中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。”从该条规定来看，其将人身关系置于财产关系之后，但《民法总则》第2条人身关系调整至财产关系之前，这也宣示了民法对公民人身权利的保护，强调人身自由和人格尊严不受侵害，并以此作为民事立法的基础。

第三，奠定了民法典的体系基础。民法典的分则就是由调整人身关系和调整财产关系的具体法律构建起来的，所以，《民法总则》关于调整对象的规定也预设了民法典的分则体系，具体而言，人身关系主要分为两大类，即人格关系和身份关系，身份关系将表现为婚姻、继承编，而人格关系则应当表现为人格权编，财产关系将在分则中分别独立成编，表现为物权、合同债权编。可见，《民法总则》关于民法调整对象的规定实际上也奠定了我国民法典分则编纂体例的基础。

第四，《民法总则》第2条的规定也确立了我国的民商合一体制。我国《民法总则》并未根据主体或行为的性质区分普通民事主体和商事主体，并在此基础上规定不同的行为规则，即我国民法不分民商事关系。这不仅符合现代民事立法的趋势，而且消除了民商分离所产生的法律冲突的弊端。在《民法总则》确定的体制下，商法是作为民法的特别法而存在的，并未与民法相分立而独立存在。

四、民法的任务

民法在大陆法系国家的法律体系中具有举足轻重的地位。大陆法系也称为民法法系，以民法典为重要标志。民法作为规范市民社会的基本法，地位仅次于宪法，它确立了各类主体的基本行为规则，确定了市场经济运行的基本条件，所以也有“小宪法”之称。许多国家的法律汇编都将民法置于宪法之后。也正因为民法在大陆法系国家的法律体系中居于如此重要的地位，故大陆法系也被称为民法法系。《民法总则》第1条规定：“为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。”依据该条规定，我国民法的任务主要包括以下几点：

（一）保障民事权益

制定民法典的首要目的是要保护民事主体的合法权益。民法典常常被称为“私权保护法”“民事权利的宣言书”。它以确认、保障民事权益为基本宗旨。从民法典的内容和体系来看，保障民事权利是民法典体系结构安排中的红线和中心轴。总则就是按照“提取公因式”的方法，将民事权利保护的共性规则确立下来。有关自然人、法人和非法人组织的规定，就构成了民事权利的主体。有关民事权利的规定，就构成了民事权利的具体内容、体系以及民事权利的行使方式。有关民事法律行为和代理的规定，就确认了民事

权利行使所形成的法律关系。有关民事责任的规定，就是因侵害民事权利所应承担的民法上的后果。有关诉讼时效和期限的规定，就是民事权利行使的时间限制。《民法总则》通过构建完整的民事权利体系，强化了私权保障，也为法治建设奠定了重要的基石。法治的基本价值是“规范公权，保障私权”。法律的主要功能在于确认权利、分配权利、保障权利、救济权利，其价值在于保障私权、限制公权。《民法总则》构建了民事权利体系，弘扬了私权神圣和私法自治，强化了对人格尊严价值的保障，这些都为中国的法治建设提供了坚实基础与有力保障。《民法总则》全面保障私权，体现了当代中国的时代特征，回应了这个时代的现实需求。例如，该法首次在法律上正式确认隐私权，有利于日益被人们所重视的隐私权保护。又如，针对互联网和大数据等技术发展带来的侵害个人信息现象，规定了个人信息的保护。将个人信息明确为新的民事权益，是重视人格尊严的体现，也是尊重基本人权的体现。

（二）调整民事关系

每一个法律部门都有其特定的调整对象与适用范围，正是因为调整对象的不同才形成了特定的法域，并在此基础上构建了整个法律体系。尽管各国的法律体系各具特点，但基本上都以调整对象或调整方法为标准划分各个法律部门，我国法律体系的构建也不例外。民法之所以能够成为我国最重要的法律部门之一，首先是因为它具有特定的调整对象，主要包括：一是平等主体之间的人身关系，如因生命权、健康权、名誉权等的享有和行使而形成的关系就属于人格关系。二是平等主体之间的财产关系，如基于物权、债权而形成的关系。正是由于民法调整对象是平等主体之间的关系，决定了其主要通过任意法规范赋予当事人以私法自治的权利（主要是通过法律行为），并以此种方式调整平等主体之间的社会关系。还要看到，特定的调整对象决定了特定的调整方法。民法调整对象的特殊性决定了它要采用平等、有偿、自愿等调整方法，并以私法自治作为其基本的价值理念。

（三）维护社会和经济秩序

民法典被称为市民社会的百科全书和市场经济的基本法。民法调整的人身关系和财产关系涉及社会生活的方方面面，直接关系到人民群众的切身利益和社会的生产生活秩序，同每个民事主体都密切相关。民法通过规定完善的民商事法律制度的基本规则，引领经济社会发展，更好地平衡社会利益、调节社会关系、规范社会行为、维护社会经济秩序。[6]例如，民法所确认的财产权制度，就是维护社会和经济秩序的基本制度。中国古代就有“一兔走，百人追之；积兔于市，过而不顾，非不欲兔，分定不可争也”的说法。产权的目的就是明确财富的归属，明晰权利的主体，进而可以达到定分止争的效果。财富归属上的安定性是人类社会生活的前提，是人类的基本安全，也是保证人格发展的必要前提。完善产权保护制度是推动经济持续健康发展的保障。保护产权就是要形成恒产恒心。再如，民法的人身权制度就是要保障人们基本的人身安全，保障人格尊严。在当代人民群众的生活水平得到极大提高的情况下，我们应当将人格尊严的保障提高到重要的地位，如此，才能维护正常的社会秩序。

民法总则通过一系列制度和规则的完善，有力地维护了市场经济的法律环境和法治秩序。《民法总则》广泛确认了民事主体所享有的各项权益，规定了胎儿利益保护规则、民事行为能力制度、老年监护制度、英烈人格利益保护等，实现对人“从摇篮到坟墓”各个阶段的保护，每个人都将在民法慈母般爱抚的眼光下走完自己的人生旅程。民法总则确定了绿色原则，顺应了保护资源、维护环境的现实需要；该法在法律上明确宣告“民事主体的财产权受法律平等保护”，将有力地促进社会财富的创造；该法明确了法人的分类标准，丰富了法人的类型，确认了非法人组织的民事主体地位以及责任，将有力地激发市场主体的活力，促进社会经济的发展；该法完善了民事法律行为、代理和时效的相关规则，也将极大地促进市场法治环境的健全。

（四）适应中国特色社会主义发展要求

民法作为上层建筑，是服务于经济基础的。中国特色社会主义是在中国共产党领导下，立足基本国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，解放和发展社会生产力。我国《宪法》确认了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，同时规定国家实行社会主义市场经济。民法典被称为市场经济的基本法，其必然要维护我国基本经济制度，适应中国特色社会主义发展要求，促进社会经济的健康、有序发展。一方面，《民法总则》通过确认对财产权的平等保护，这体现了对多种所有制的财产权利进行平等保护的理念，有利于我国基本经济制度的完善。另一方面，民法总则立足于我国国情，从中国实际出发，解决中国的实际问题。民法总则是对我国民事立法、司法经验总结、提炼的结果，展现了新中国成立以来，尤其是改革开放以来的法治建设经验。民法总则确立了市场经济的基本法律制度，完善市场主体法律制度、市场交易法律制度等，有力地促进了中国特色社会主义市场经济法律制度的完善。

（五）弘扬社会主义核心价值观

社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核，是中华民族赖以维系的精神纽带和思想道德基础，是每一个中国人的精神给养，也是我们的宝贵精神财富和强大精神力量。习近平同志指出，富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标，自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向，爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则。它们共同构成了我国社会主义核心价值观的基本内容。《民法总则》第1条开宗明义地指明，我国民法典的立法目的之一，是要弘扬社会主义核心价值观。民法典立法将社会主义核心价值观融入全过程，弘扬中华民族传统美德，强化规则意识，增强道德约束，倡导契约精神，弘扬公序良俗。[7]

民法典对于社会主义核心价值观的弘扬，主要表现在如下几个方面：一是《民法总则》确认平等原则，强化了财产权的平等保护。这些都是法律面前人人平等原则的具体化，也是反对特权、反对歧视等社会现实的要求。二是《民法总则》确认自愿原则，贯彻私法自治理念，贯彻了“法无禁止皆自由”的精神。这实际上进一步弘扬了自由的理念。三是《民法总则》确认了诚实信用原则，要求从事民事活动，遵循诚信原则，秉持诚实、恪守承诺，大力提倡契约精神。这有利于强化人们诚实守信、崇法尚德，为维护社会正常的生活和交易秩序，推进法治建设，奠定良好的社会基础。四是《民法总则》确认了公序良俗原则，禁止滥用私权，要求行使民事权利的同时，也要履行民事义务，鼓励见义勇为和救助行为，致力于构建和睦的人际关系。这也有助于社会道德风尚的弘扬和传统美德的培育，也是社会文明的要求。五是《民法总则》确认了公平原则，要求民事主体合理确定其权利义务，避免当事人之间的权利义务失衡。这一原则实际上是“公正”价值的重要体现。总之，民法通过其基本原则、具体制度和规则的构建，为弘扬社会主义核心价值观发挥了重要作用。

第二节 民法的性质

一、民法是私法

在大陆法系国家和地区，许多学者在学理上大都是从公法和私法分离与对立的角度来界定民法的性质，如拉伦茨在《德国民法通论》中开宗明义地指出，“民法是私法的一部分”，“《德国民法典》是德国私法的基础”[8]。我国台湾地区学者也大都持有相同的看法。[9]“民法系私法之一部分，乃规律私人间一般社会生活关系之根本法”，“民法系人类社会生活之规范，约束人类私人间之关系”。

公法和私法的区分最初由罗马法学家乌尔比安提出，并为《学说汇纂》所采纳。但长期以来，关于公法和私法的分类标准极不统一，学界主要形成了三种不同的观点：

一是利益说，即根据法律保护的利益涉及的是公共利益还是私人利益来区分公法和私法。这种学说曾经是公、私法划分的重要标准，但20世纪以来，随着国家干预经济的发展和福利国家概念的流行，公共利

益与私人利益往往很难区分，故此种分类已经走向衰落。二是隶属说，也称为“意思说”，认为应根据调整对象是隶属关系还是平等关系来区分公、私法。[10]此说长期为学界通说，也为我国《民法总则》第2条所借鉴。但完全依隶属关系还是平等关系来区分公法和私法也有一定缺陷：在民法调整的身份法领域，也存在一定的隶属关系；在公法领域中，也出现了越来越多的平等关系，如政府采购契约、行政契约等。三是主体说。此种观点认为，应当以参与法律关系的各个主体为标准来区分公法和私法，如果这些主体中有一个是公权主体，即法律关系中有一方是国家或国家授予公权的组织，则构成公法关系。该学说为现代公法、私法区分的通说。[11]但这种分类也有一定缺陷。例如在现代社会，国家公权力机关也会以平等主体身份参与社会经济生活，该种行为的性质应如何界定？这就难以解释此种关系的性质。

本书认为，各种分类标准都是相对合理的，不可能存在一种绝对的划分标准。应当将社会关系的性质和主体的性质结合起来，作为区分公法和私法的标准。从原则上说，凡是平等主体之间的财产关系和人身关系都属于私法关系，而具有等级和隶属性质的关系属于公法关系；私法关系的参与主体都是平等主体，国家介入也是作为特殊的民事主体来参与的，而公法关系中必然有一方是公权主体，其参与社会关系也仍然要行使公权力。

在我国，区分公法和私法的意义是重大的。长期以来，我国一直否认公、私法的划分，认为在社会主义公有制下，国家广泛参与社会生活，经济关系和人身关系都有国家干预的色彩，所以社会主义国家的法律都具有公法性质，而不存在私法。这种观点显然是计划经济的反映，导致在实践中过分强调了国家利益和国家干预，漠视了私人利益和私人自主调整。此种否认公、私法分类的观点显然不符合我国社会主义市场经济的实践，也不利于社会主义民主政治的完善。区分公法与私法的意义主要体现在以下几个方面：

第一，私法领域中奉行的基本原理是私法自治，民事主体有权在法定的范围内根据自己的意志从事民事活动，通过法律行为构建其法律关系。在市场经济条件下“尽可能地赋予当事人行为自由是市场经济和意思自治的共同要求”[12]。民事关系特别是合同关系越发达、越普遍，则意味着交易越活跃，市场经济越具有活力，社会财富才能在不断增加的交易中得到增长。不仅私法给每个人提供了必要的发展其人格的可能性，而且由私法赋予的决策自由往往对主体而言更为有利。[13]

第二，在公法领域中，公共权力必须法定，“法无授权不可为（All is prohibited unless permissible）”没有国家法律的明确授权，公权力机关就不得任意从事行为。而在私法领域，奉行私法自治的理念，法无禁止即可为（All is permissible unless prohibited），其赋予了当事人广泛的自由。这两项原则也符合“规范公权、保障私权”的法治理念。

第三，区分公、私法有助于正确认定法律责任的性质。出现社会纠纷以后，如果涉及私法关系，产生的就是私法上的后果，即当事人个人之间的责任；如果涉及公法关系，则产生个人对国家如何负责的问题。[14]私法规范的是民事法律关系，而公法主要规范行政法律关系。私法强调对公民、法人的合法民事权利的保护，充分尊重民事主体在法定的范围内所享有的行为自由，尊重民事主体依法对自己的民事权利和利益所作出的处分[15]，而公法则更注重对民事关系的干预和对社会经济生活的管理。

第四，保障公民的基本人权不受侵犯。区分公法和私法，不仅为市场经济提供了必不可少的意思自治原则，而且为社会主义市场经济奠定了充分尊重主体的自由和权利的新的法治原则。[16]区分公、私法就是要确立私权神圣不可侵犯、国家应当充分地尊重和保障公民权利不可侵害的观念。公民私权不受侵犯，不仅包括在私法领域不受作为私法主体的第三人的侵犯，而且更为重要的是，也包括不受国家权力本身的不正当侵犯，这正是现代法治的重心之所在。

从民法的角度来看，区分公法和私法也有助于明确民法规范的基本属性。明确民法为私法，就是要在民法中尤其是在合同法中尽量减少强行性规范，努力扩大任意性规范的数量。在民法中，原则上当事人有约定时依约定，无约定时则依法律规定，当事人的约定要优先于法律的规定而适用。我国民事立法中要尽量减少有关国家行政机关的管理规则，减少对当事人从事合法的民事行为所施加的限制。有关对民事关系

进行限制和干预的规则应由公法而不是由民法予以规定。

最后需要指出的是，民法只是私法最主要的部分，不完全等同于私法，或者说，民法是私法的核心部分。[17]除民法之外，民事诉讼法、国际私法等，也应当属于私法的组成部分。

二、民法是市场经济的基本法

民法是市场经济的基本法。从历史沿革上看，民法始终是与商品经济或市场经济的发展紧密联系在一起。在古罗马时期，正是由于出现了较为发达的简单商品经济，罗马法才得以孕育、产生和完善。欧洲中世纪后期，资本主义商品生产和交换在封建的自然经济的空隙中产生和发展，导致了罗马法的复兴。1804年的《法国民法典》以罗马法为蓝本，巧妙地运用法律形式把刚刚形成的资本主义社会的经济规则直接翻译成法的语言，从而“成为世界各地编纂一切新法典时当做基础来使用的法典”[18]。19世纪末期，由于市场经济的发展，产生了资本主义成熟时期的法典代表——《德国民法典》。

从民法的内容来看，民法调整的财产关系实际上主要就是财产归属关系和财产流通关系。在市场经济条件下，财产归属关系是财产交易的前提，而交易的最终目的也是财产的归属转换。马克思在描述商品交换过程时指出：“商品不能自己到市场去，不能自己去交换。因此，我们必须找寻它的监护人，商品占有者……为了使这些物作为商品彼此发生关系，商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系，因此，一方只有符合另一方的意志，就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。可见，他们必须彼此承认对方是私有者。”[19]这就表明商品关系的形成必须具备三个条件：一是必须要有独立的商品“监护人”（所有者），二是必须要商品交换者对商品享有所有权，三是必须要商品交换者意思表示一致。这就是在交换过程中形成的商品关系的内在要求，与此相适应，形成了以调整财产所有和财产交换为目的，由民事主体、物权、债和合同等制度组成的具有内在联系的民法体系。

1. 主体制度。作为民法主体的当事人，大多是财产和其他权益的享有者、在动态中的交换者。这类主体的特征就在于它们的独立性，即意志独立、财产独立、责任自负。我国《民法总则》确立的自然人、法人、非法人组织就是关于这些独立的主体（自然人或法人）所必备的权利能力和行为能力等方面的规定，是交易关系当事人在法律上的反映。《民法总则》所确立的民事主体制度的适用范围十分宽泛，任何组织和个人，无论其在行政法律关系、劳动法律关系中的身份如何，也无论其所有制形式和经济实力如何，他们从事社会商品经济活动的主体资格皆由民法主体制度所确认，其合法权益受民法保护。

2. 物权制度。所有权和他物权制度是规范财产（动产和不动产）的所有和使用关系的基本制度。《民法总则》和《物权法》所确立的所有权制度是直接反映所有制关系的，但也和交易关系具有内在的联系。产权的初始界定是交易的前提，也是降低交易费用的重要条件。交易就其本质而言主要是所有权的让渡。所有权是商品生产和交换的前提，也是商品的生产和交换的结果。所有权在生产领域中的使用、消费就是商品生产，在流通领域中的运动就是商品交换，商品生产者从事生产和交换的前提条件，就是要确认其对劳动工具和劳动对象的占有、使用、收益和处分的权利，保障他们在交换中的财产所有权的正常转移。民法的他物权如土地使用权、经营权等既是市场经济赖以形成的重要基础和前提条件，也是市场经济的产物。

3. 债和合同制度。债和合同是财产交易在法律上的体现，是商品流通领域中最一般的、普遍的法律规范。债权制度大多是规范交易行为的，债的一般规则是规范交易过程、维护交易秩序的基本规则，而各类合同制度也是保护正常交换的具体规则。财产交换过程并不只是纯粹的买卖，还包括劳务的交换（诸如加工、承揽、劳动服务）、信贷、租赁、技术转让等合同形式，以及票据的流转、财产的抵押、资金的偿付等债的形式。它们都是单个的交换，都是债的具体表现，并受到民法债权制度的确认和保护。《民法总则》确认了合同之债、侵权损害赔偿之债、不当得利之债以及无因管理之债等多种债的类型，不仅完善了市

场经济的基本规则，而且为市场交易带来了巨大的方便，使它超出了地域的、时间的和个人的限制，从而有力地推动了财产的流转和交易的繁荣。

4. 客体制度。民法所确认的权利客体，也是适应交易的需要而产生和发展的。日本著名民法学家我妻荣认为，所有权制度变化的一个重要特点表现在物权关系和客体的结合。如不动产与附随不动产的权利成为一体；集合物作为单一的物权客体；构成一个企业的许多物的权利关系和事实关系结合而成为企业的财产，并能够作为一个物权的客体来看待。[20]权利和物结合，共同构成法律上的集合物并成为所有权的客体和某项交易的对象，表明交易的对象日益丰富以及对物的利用效率也不断提高。适应客体制度的发展需要，我国《民法总则》规定了物权的客体包括动产、不动产以及法律规定的权利，规定了对民事权利和民事利益的保护，规定了知识产权的客体，规定了数据、网络虚拟财产等，都可以作为民事权利的客体。这些规定扩张了法律所保护的客体范围，有利于丰富交易形式、提高交易效率。

民法是市场经济的基本法，这就意味着市场经济的建立和完善，离不开民法的支持；同时，民法制度也应当按照市场经济的内在要求来构建，应当符合市场经济的运行规律。如果我们要确认我国的经济是以平等等价和自由竞争、由市场引导生产要素自由流转和组合的市场经济，那么就应当充分贯彻意思自治、诚实信用、鼓励交易、公平正义等价值理念，尽量减少国家对经济生活的干预，加强对民事主体权利的保障。所以，市场经济的成熟很大程度上是以民商事规则的成熟为标志的。

三、民法是市民社会的基本法

市民社会（civil society）原指伴随着西方现代化的社会变迁而出现的，与国家相分离的社会自组织状态。汉语世界使用的“市民社会”一词，大体是由英文civil society一词转译而来。该词的最早含义可上溯至亚里士多德，其认为civil society一词，系指一种“城邦”（即Polis）[21]。黑格尔在《法哲学原理》一书中对国家与市民社会作出了明确划分，并提出了政治国家和市民社会的分离和对立。[22]黑格尔认为，社会生活领域中的个人都在市场法则之下追逐一己之私利，在这种由市民构成的社会中，各人由于利益上的差异性与彼此之间的互补性，形成了相互依存的关系。此种关系具有不受国家支配和控制的社会自主性。正是社会生活领域中的这一特征，使市民社会构成一种与国家相分离和相对应的独立自主领域。而基于市场关系的契约性人际关系以及在此基础上形成的社会自组织性，属于市民社会概念的最核心内容。[23]现代社会中的每个社会成员，既是市民社会的成员，也是国家的公民，其以市民社会成员的身份与他人形成各种民事关系以实现自己的权利，必然要求获得民法上的保护。正是从这个意义上说，民法是市民社会的权利典章，是市民社会中民事权利的保护神[24]，而市民社会的关系都要求通过民法的调整来实现市民社会的正常秩序。

民法作为市民社会的基本法，其所调整的人身关系和财产关系涉及社会生活的方方面面，直接关系到人民群众的切身利益和社会的生产生活秩序。我国《民法总则》从维护广大人民群众根本利益出发，完善了社会生活的基本规则：一方面，《民法总则》开宗明义地宣告，要以弘扬社会主义核心价值观为立法目的，倡导自由、平等、公正、法治等价值理念，并确认了诚实信用原则、公序良俗原则等基本原则，要求从事民事活动，秉持诚实、恪守承诺，这有利于强化人们诚实守信、崇法尚德，推进诚信社会建设。《民法总则》规定了民事权利行使和保护的规则，规定“民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务”（第131条），禁止滥用权利（第132条），为人们的交往活动提供了基本的准则。另一方面，《民法总则》广泛确认了民事主体所享有的各项权益，规定了胎儿利益保护规则、民事行为能力制度、老年监护制度、英烈人格利益保护等，实现对人“从摇篮到坟墓”各个阶段的保护。该法规定了民事责任制度，切实保障了义务的履行，并使民事主体在其私权受到侵害的情况下能够得到充分的救济。

四、民法是权利法

现代法治的精神是“规范公权、保障私权”，其重心在于对私权的全面确认和充分保障，而确认与保护权利必须依赖于民法功能的充分发挥。民法典被称为“民事权利的宣言书”，其最基本的职能在于对民事权利的确认和保护，这就使民法具有权利法的特点。一方面，从历史上看，民法就是为了对抗公权力的干预、保障公民权利不受侵犯而产生的。在民法的发展历史上，无论古罗马法、19世纪的法国民法如何主张个人本位，而现代民法又如何倡导团体本位；也无论不同历史时期、不同所有制的社会的民法所保障的权利在性质上存在何种区别，各个社会的民法都坚持了一个最基本的共性——以权利为核心，换言之，民法就是一部权利法。另一方面，民法体系的构建以权利为基本的逻辑起点。在民法总则中，主体制度实际上确认了权利的归属；法律行为与代理制度实际上是主体行使权利的行为；诉讼时效制度实际上是权利行使的期限；而民法分则完全是以权利为内容展开的，并分别形成了物权、债权、人身权等权利体系。我国民法确认的公民所享有的人身权、物权、债权、知识产权等，都是公民的基本权利，它们共同构成了民法的完整体系。此外，民法通过权利确认当事人的行为规则。权利表现为行为的自由，权利人行使权利是其依法享有的自由，但自由止于他人的权利，行使权利不得妨害他人的权利，所以我国民法确认了诚实信用、权利不得滥用等法律原则，对权利进行必要的限制，从而平衡权利的冲突和正确地解决人际纠纷。

我国《民法总则》的许多规定也反映了其权利法的特点。《民法总则》广泛确认公民享有的各项人格权、物权、债权、知识产权、亲属权、继承权等权利，使其真正成为“民事权利的宣言书”。《民法总则》继续采纳《民法通则》的经验，专设“民事权利”一章，集中地确认和宣示自然人、法人所享有的各项民事权利，充分地彰显民法对私权保障的功能。《民法总则》系统、全面地规定了民事主体所享有的各项人身、财产权益，尤其体现了当代中国的时代特征，回应了当今社会的现实需求。例如，该法首次正式确认隐私权，这有利于强化对隐私的保护。还应当看到，《民法总则》第126条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。”依据该条规定，不论是权利还是利益，都受到法律保护。这不仅与保护民事权益的基本原则相对应，而且为将来对新型民事权益的保护预留了空间，保持了对私权保护的开放性。保障私权就是为了更好地保障最广大群众的根本利益，保护人民群众对美好生活的向往。此外，由于私权的保护在一定程度上界定了公权行使的范围，从而也将起到规范公权的作用。

五、民法主要是实体法

按照法律规定的内容不同，法律可分为实体法与程序法。实体法一般是指规定主要权利和义务（或职权和职责）的法律，程序法一般是指保障权利和义务得以实施的程序的法律。[25]一般认为，民法是实体法，民事诉讼法是程序法。

民法作为实体法，既是行为规范，又是裁判规则。民法主要是行为规范，但也不限于行为规范，例如，民法关于权利能力的规定等就不是行为规范。民法作为行为规范主要具有两方面的功能：一是确立交易规则，二是确立生活规则。这就是说，一方面，作为交易规则为交易当事人从事各种交易行为提供明确的行为规则，使其明确自由行为的范围、逾越法定范围的后果和责任，从而对其行为后果产生合理预期。另一方面，作为社会生活的规则，它是人们长期以来生活习惯的总结，确立了人与人正常交往关系的规范，是社会公共道德和善良风俗的反映。按照民法的规则行为，有助于建立人与人正常和睦的生活关系，维护社会生活的和谐与稳定。

民法的规则也是司法机关正确处理民事纠纷所要依循的基本准则。“民法属于行为规范，对于此种规定如不遵守，而个人相互之间惹起纷争时，就得向法院诉请裁判，此时法院应以民法为其裁判之准绳。”[26]民法为司法裁判提供了一套基本的体系、框架、规范和术语，力求通过法律的制定使整个司法过程都处于法律的严格控制之下。此外，民法规则也对法官行使的自由裁量权作出了必要的限制。在民法中，裁判规范也可以分为两类：一类是具体的裁判规则，例如，关于继承权的享有，如果继承人没有表示接受或者放弃，则视为接受；另一类就是授予法官自由裁量权的基本规则和一般条款。在现代社会，法官不得以法无明文规定而拒绝接受对民事案件的裁判，也不得以法律规定不明确而拒绝援引法律条文。就民事案件的

裁判而言，法官所应依据的基本规则就是民法典，我国《民法总则》的颁布，实质性地推进了我国民法典编纂的进行，将有力推进我国民事立法的体系化，《民法总则》的颁布也为法官依法裁判民商事纠纷提供了基本的裁判依据。

第三节 民法的调整对象

一、民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系

民法的调整对象就是民法规范所调整的各种社会关系。根据我国《民法总则》第2条的规定，我国民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系。可见，民法调整的社会关系的本质特点在于其平等性，这是民法区别于其他法律部门的根本特点。所谓平等主体，是指主体以平等的身份介入具体的社会关系，而不是在一般意义上判断主体间的平等性。例如，国家和公民虽然在一般意义上不是平等关系，但只要在其相互间发生的具体法律关系中，是以平等的身份出现的，即可判断其具有平等性。平等是指在财产关系和人身关系中当事人的地位平等，并不涉及在政治关系中当事人的地位平等与否问题。

平等性主要表现在：第一，当事人参与法律关系时，其地位是平等的，任何一方都不具有凌驾或优越于另一方的法律地位。正是法律地位的平等，决定了当事人必须平等协商，不得对另一方发出强制性的命令或指示。第二，适用规则的平等。任何民事主体参与民事活动都要平等受到民事法律的拘束，不享有法外的特权，不能凌驾于法律之上，即“法律面前人人平等”。第三，权利保护的平等。在任何一方的权利受到侵害之后，他们都应当平等地受到民法的保护和救济。

民法主要调整平等主体间的关系，但这种关系也存在例外。一方面，在身份法领域，当事人之间的关系可能不是平等的，如父母子女之间的亲权关系、监护人与被监护人之间的监护关系等就不完全是平等的。另一方面，随着现代民法对实质正义的强化，在形式的平等之外，民法已开始强调对消费者、劳动者等弱势群体的保护，以实现形式平等与实质平等、机会平等与结果平等之间的协调。还应当看到，尽管在征收关系中，国家行使征收权本身不是平等主体之间的关系，但基于征收所产生的补偿关系可以理解为平等主体之间的关系，因此，我国《物权法》第42条也规定了征收制度。

二、民法调整平等主体之间的人身关系

（一）民法调整的人身关系的内容

各国民法都以人身关系作为其调整的重要内容，我国民法也不例外。所谓人身关系，是指没有直接的财产内容但有人身属性的社会关系。有人认为，“persoenliche Eigenschaft”可以简译为“人身”，而我国民法理论所言之“人身关系”，原本仅指“身份关系”，后来的人理解为包含所谓“人格关系”[27]。本书认为，我国民法中的身份关系具有特定的含义，它不包括人格关系。民法调整平等主体之间的人身关系，此处所谓的平等指的是法律地位的平等，而不是指具体的生活事实中的平等。例如，父母与未成年子女之间的关系在生活上管教与被管教的关系，但在民法中两者的法律地位是平等的。

人身关系是基于一定的人格和身份产生的，因此人身关系包括两类：

1. 基于自然人、法人和非法人组织的人格产生的人身关系。这些关系在民法上表现为自然人和法人的人格权，包括自然人的生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利，以及法人、非法人组织的名称权、名誉权、荣誉权等权利，此外，凡是属于《民法总则》第109条所规定的自然人的人身自由、人格尊严范畴的人格权益，都属于因人格而产生的人身关系。

2. 基于自然人、法人和非法人组织的一定身份产生的人身关系。身份关系是人们基于彼此间的身份而形成的相互关系。本书认为，可以将身份界定为民事主体在特定的社会关系中所具有的地位，具体包括：

一是在亲属关系中的地位。这类关系在民法上表现为公民的身份权，包括夫妻之间、父母子女之间、有扶养关系的祖父母与孙子女或外祖父母与外孙子女之间依法相互享有的身份权，以及因监护关系产生的监护权等。二是基于知识产权获得的地位，如自然人、法人和非法人组织通过智力创作活动取得著作、专利、商标而享有的人身权，以及公民享有的在发现权和发明权中的人身权。

（二）民法调整的人身关系的特点

第一，主要具有非财产性。按照传统观点，人身关系主要体现为主体的精神利益和道德上的利益，并不具有财产利益的属性，这也是其与财产关系的重要区别。人身关系本身不以财产为客体，也不以财产为内容，人身关系本质上不能用金钱加以度量、评价，人身关系受到侵害时也无法采取等价补偿的方式，而主要采用的是一种精神上的抚慰和对加害人的惩戒，以及对加害行为的排除等方式。[28]但随着经济社会的发展，许多人格权益也包含了经济价值，例如，个人可以通过许可他人利用其姓名权、肖像权等权利而获得经济利益。这一变化也对侵害人身权益的民事责任产生了一定的影响，即行为人在侵害他人人身权益时，受害人既有权请求其承担精神损害赔偿，也有权请求行为人承担财产损害赔偿。因此，民法所调整的人身关系主要具有非财产性，但在一些情形下，此种人身关系也具有一定的财产属性。

第二，专属性。人身关系中所体现的利益与人身是很难分离的，财产权利一般可以自由流通，但人身权利具有人身专属性，很难完全进入流通领域。也就是说，人身权作为一种整体性的权利是不能转让的。[29]当然，随着经济社会的发展，部分人身权益的人身专属性也有了一定的松动，即权利人可以许可他人利用其人身权益。一些人格权（如肖像和隐私权等）的权能不再像生命、健康、自由等权利那样，具有强烈的专属性和固有性，而是可以与主体依法发生适当的分离。在有的国家，个人人格标志中的经济价值也具有可流转性，如美国法上的公开权即属于财产权，能够进入流通领域。

第三，人格关系的固有性。人格关系中的利益大多是民事主体必备的利益，例如，生命、健康是民事主体与生俱来、终身享有的，否则，民事主体就很难享有人格独立与自由，甚至难以作为主体而存在。当然，身份关系不一定具有固有性，其以一定的社会关系为基础。[30]

民法对人身关系的调整，在价值上具有优先性，贯彻的是人本主义，其基本理念就是关爱人、尊重人，维护个人的人身自由和人格尊严。因此，我国《民法总则》第2条在规定民法的调整对象时，将人身关系置于财产关系之前，这也体现了对人身关系的重视。与古代、中世纪法律注重人身支配关系不同，现代民法更加注重对个人人身利益特别是人格利益的保护。例如，我国《民法通则》以专节的形式对公民所享有的各项人身权益作出了规定，《民法总则》在此基础上，也广泛确认了自然人、法人和非法人组织所享有的各项人身权益。当然，不能把某些调整交易关系的民法原则适用于人身关系，也不能把一些有关市场经济活动的法律规范适用于人身关系领域。

（三）民法调整的人身关系的意义

依据《民法总则》第2条的规定，人身关系是民法的重要调整对象，民法调整人身关系的重要意义在于：

第一，彰显了民法的本质特征。民法本质上是人法，民法的终极价值是对人的关爱，最高目标是服务于人格的尊严和人的发展。孟德斯鸠曾经有一句名言，“在民法慈母般的眼里，每一个个人就是整个国家”[31]。在人民群众的温饱问题解决，实现基本小康之后，对于人的尊严保护就应当提到一个更高的位置。我们的民法典应当充分体现对人的关爱，把对人的尊严、自由的保障提到更高的位置。法律关系本质上不过是人與人之间的关系，人是法律关系的主体，脱离了人，财产关系就失去了基本的承载。所以，民法调整人身关系，彰显了民法的本质特征。

第二，体现了21世纪的时代精神。21世纪是互联网、高科技时代，是信息社会，更是一个走向权利的世纪，所以21世纪的时代精神应该是强化对人的尊严和自由的保护。民法以人身关系为重要的调整对象，

我国《民法总则》通过全面确认个人所享有的各项人身权益，并设置相应的保护规则，有利于强化对个人人身权益的保护，这也体现了21世纪的时代精神。

第三，反映了现代法治的基本要求。保障私权是现代法治的核心内容，市民社会中基本的社会关系包括财产关系和人身关系。财产关系因民法的调整而表现为各类财产权，而人身关系作为与人身相联系并以人作为内容的关系主要包括人格关系和身份关系，在民法上应当表现为人格权和身份权。现代化的核心应当是以人为本，人格尊严、人身价值和人格完整应该置于比财产权更重要的位置，它们是最高的法益。[32]将调整人身关系作为民法的重要内容，也是现代法治的基本要求。

第四，有利于实现对人的全面保护。民法不仅要保护财产权，而且还要保护个人的人身权，这样才能形成对人的全面保护。一方面，民法应当强化对人格利益的保护。民法对人格利益的保护是其他法律手段无法替代的。例如，在侵害人格权的情况下，民法主要采用损害赔偿的方法，对受害人提供救济，这是其他的法律责任形式所不具备的。另一方面，民法应当强化对身份关系的保护。身份关系主要是亲属关系，而亲属关系从根本上来讲是私人间的私生活关系，因此，由以私法自治为其主要调整方法的民法来调整身份关系是非常合适的。[33]

三、民法调整平等主体之间的财产关系

（一）平等主体之间财产关系的概念和内容

根据《民法总则》第2条的规定，我国民法调整平等主体之间的财产关系。所谓财产关系，是指人们在产品的生产、分配、交换和消费过程中形成的具有经济内容的关系。财产关系是以社会生产关系为基础的，涉及生产和再生产的各个环节，包括各类性质不同的关系。根据我国《民法总则》第2条的规定，民法所调整的财产关系只是发生在平等的民事主体之间的财产关系。其特点在于：

第一，主体平等。平等性包括两个方面：一方面，是指民事主体在从事各种交易行为以及行使财产权利、利用和取得财产等方面，彼此之间在法律地位上是平等的。不论双方的经济实力差别如何悬殊，都不允许他方将自己的意志强加于人。另一方面，民事主体在从事各种交易活动时，都应当遵循公平、等价等原则，彼此间的关系应当是平等、互利的，当其财产利益受到损害时，应当得到同等价值的补偿。民法调整的财产关系大部分都应贯彻等价有偿的原则，不过，当事人依法形成赠与、借用、无偿保管等民事关系，也是法律所允许的。

第二，平等主体间的财产关系，包括财产归属关系和财产流转关系。财产归属关系是指财产所有人和其他权利人因占有、使用、收益、处分财产而发生的社会关系。财产流转关系是指因财产的交换而发生的社会关系。财产归属关系往往是发生财产流转关系的前提条件，财产流转关系通常又是实现财产归属关系的方法。这两种财产关系，又称为横向财产关系，都应该由我国民法调整。这是由我国社会主义市场的统一性以及民法对市场经济关系进行统一调整所决定的。

第三，民法调整的财产关系的重心是交易关系。所谓交易，是指独立的、平等的市场主体就其所有的财产或利益进行的交换。在民法上，交易的表现形式多种多样，其正常的形式是合同，其特殊形式是侵权损害赔偿和不当得利返还等。适应交易关系调整的需要，产生了产权的确认和保护的必要。从民法调整对象的性质来看，所谓平等主体之间的财产关系，主要指交易关系，交易关系也是典型的平等主体之间的财产关系。

（二）平等主体之间的财产关系的特征

民法调整的财产关系的首要特点，在于它是一种平等主体之间的财产关系。与身份关系相比较，该财产关系还具有下列特点：

第一，财产关系是一种以经济利益的计算为核心的关系。在市民社会中，民事主体作为合理的人，能够从自身利益出发设定、变更或终止财产关系，最终实现其个人利益的最大化。而身份关系不同，尽管有些身份关系与财产关系有密切的联系，但整体来看，它并不主要是一种经济上的利害关系。[34]

第二，财产关系充分体现了主体的自由意志。主体享有对其财产的处分权，并有权依其意志移转财产所有权权能。财产关系的产生、变更和消灭体现了法律给予主体充分的自由空间，国家尽量不予干预。但在身份关系中，当事人的意思自由要受到一定的限制。例如，法律对结婚、离婚、收养都进行了比较严格的限制，亲属法上许多权利，如监护权、亲权等，都具有专属性，不得随意抛弃和转让。尤其在现代社会，为了保护婚姻家庭关系中的弱者利益，法律逐渐加大了对婚姻家庭关系的干预，因此婚姻家庭法具有私法公法化的趋势。[35]

第三，财产关系具有很强的变动性。尤其是在市场经济社会，财产往往只有通过流转才能实现资源的合理配置，充分实现其价值，因此，财产关系总是处于一种变化之中。而身份关系则具有极大的稳定性，通常不会发生变动[36]，也不宜发生变动，其具有很强的人身专属性。

第四，就救济方式而言，财产关系遭受侵害时是用损害赔偿等财产性的救济方法来解决的；而亲属、婚姻等身份关系在受侵害时较多使用非财产救济手段，当然，依据《侵权责任法》第20条的规定，在部分人身权益遭受侵害的情形下，受害人也有权主张财产损害赔偿。[37]

第四节 民法的历史发展

一、民法起源于罗马法

罗马法，顾名思义，就是指罗马奴隶制国家施行的法律。它通常是指自罗马起源起至查士丁尼止的罗马法律。[37]古罗马时期，在自然经济的土壤上，简单商品经济得到了充分发展，从而产生了古罗马调整私人财产关系的发达的私法。在罗马的法学编纂方面，最有成效、影响最深远的是东罗马帝国皇帝查士丁尼的《国法大全》，即《查士丁尼法典》、《学说汇纂》、《法学阶梯》和《新律》。罗马法以高度抽象的方法表现了商品经济社会的一般形态或纯粹形态，反映了社会商品经济的正常要求，其内容主要包括：关于自然人和法人等权利主体的法律、物权法、债权法、婚姻家庭法、继承法等，已经涵盖了现代民法的主要内容。罗马法中的诸多制度，如人格制度、住所制度、时效制度、无因管理制度、不当得利制度、遗嘱继承制度、特留份制度等，仍是各国民法典中的基本民事制度[38]，所以至今，民法学者仍“言必称罗马”[39]。

二、从近代民法到现代民法

（一）近代民法及其特点

近代民法，是指经过17、18世纪的发展，于19世纪经欧洲各国编纂民法典而获得定型化的一整套民法概念、原则、制度、理论和思想的体系，在范围上包括德、法、瑞、奥、日本等大陆法系民法，也包括英美法系民法。[40]近代民法的主要特点表现在：

1. 抽象的人格平等。近代民法承认人格的平等，这是一种形式上的平等。近代的社会变革，使法律从身份的法、等级的法发展到平等的法、财产的法。独立、自由的个人只服从于国家，而不再依附于各种领主或封臣。梅因指出，“我们可以说，直到现在，进步的、社会的发展过程就是由身份到契约的过程”。《法国人权宣言》第1条就指出，人人生而平等。法国大革命后废除了封建社会的身份束缚，使个人获得了身份的自由。人们之间的关系完全按照契约设定，其他生产资料之上所形成的人身依附关系、基于土地的人身依附关系、领主与隶农之间的隶属关系、主人与奴仆之间的身份关系、师傅与徒弟之间基于手工业的关系都被解除，取而代之的是各种契约关系。[41]近代民法所调整、保护、关切的对象是抽象的人，它对

于民事主体仅作抽象的规定，而不作年龄、性别、职业等区分。在近代民法典中，人被作为抽象掉了种种能力的个人，并且是以平等的自由意思行动的主体被对待。这种处理致使在各种情况下从人与人之间实际上的不平等，尤其是贫富差距中产生的诸问题表面化，导致仅注重形式的平等，而未注重实质的正义。[42]

2. 无限制私有原则。从17世纪以来，私有权的自由和“契约自由”一直被哲学家和法学家认为是个人自由的重要内容。按照18世纪流行的自然法学说，人生来便具有不可改变的、不可让渡和不可分割的权利，这些权利就是自由和财产的安全，而“财产自由”和“契约自由”则是个人自由的必然结果。绝对私有原则，又称为无限制私有原则，它是指私人对其财产享有绝对的、排他的、自由处分的权利。1804年的《法国民法典》第544条规定，“所有权是对于物有绝对无限制地使用，收益及处分的权利”，就是对这一原则的准确表述。所有权不仅可以上及天空、下及地心，而且法律不能对所有权的内容进行实质性的限制，从而形成了一种绝对私有权的观念。

3. 契约自由。契约自由原则，是近代民法的一条基本原则。它主要包括：第一，契约必须由当事人自由意志彼此一致才能生效，契约可以优先于任意性规定而适用；第二，契约的内容由当事人自由决定；第三，契约的方式以及相对人的选择等由当事人决定，任何人无权干涉。《法国民法典》第1134条规定：“依法成立的契约，在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。”法典虽然规定了契约违反公共秩序和善良风俗无效，但是公共秩序和善良风俗的条款只是在例外的情况下才适用。《德国民法典》在法律行为、债和契约中都充分贯彻了“私法自治”和“契约自由”原则。“私法自治”是法律行为的原则，而“契约自由”是私法自治原则的体现。契约自由不过是意思自治原则的具体体现。

4. 过失责任原则，也称为自己责任原则。1804年的《法国民法典》第1382条规定：“任何行为使他人受损害时，因自己的过失而致行为发生之人，对该他人负赔偿的责任。”这一简短的条文是对罗马法债法中的过失原则的重大发展，由此确立了过失责任原则，该原则先后为大陆法系各国的民法典所沿袭。它不仅具有道德的价值，而且具有教育、惩戒和预防损害发生的功能。这一规定便形成了侵权损害赔偿的一般原则。正如法国民法典起草人塔里伯在解释民法时所指出的：“这一条款广泛包括了所有类型的损害，并要求对损害作出赔偿。”[43]“损害如果产生要求赔偿的权利，那么此种损害定是过错和谨慎的结果。”[44]但是，单一的过错责任不能包括各种类型的侵权损害，所以，《法国民法典》的起草者不得不在规定过错责任的同时，又规定了过错推定。

5. 近代民法注重维护形式正义。社会正义可以分为形式正义和实质正义。所谓形式正义就是注重抽象的法律地位的平等、自由，而不考虑当事人的地位、差异而造成的实质上的不平等。18世纪至19世纪的理性哲学认为，自由意志可以自然导向正义和公正，按照这一观点，当事人如果在协商中不能获得自己认为是平衡的条件，就可以不再协商，而另外去寻找订约伙伴。[45]因而合同自由与合同正义是不矛盾的。所以，18世纪至19世纪的近代民法在合同法中十分强调形式的正义而非实质的正义。形式的正义强调当事人必须依法订约，并严格遵守合同，从而实现契约的形式正义。至于订约当事人实际上是否平等，一方是否利用了自己的优势或者对方的急需等与对方订约，或者履行合同时是否因一定的情势变化而使合同的履行显失公平等，均不予考虑。拉德布鲁赫有一句名言：“民法典并不考虑农民、手工业者、制造业者、企业家、劳动者等之间的区别。私法中的人就是作为被抽象了的各种人力、财力等的抽象的个人而存在的。”[46]这就概括了近代民法的重要特点。

（二）现代民法及其特点

现代民法的演进发生于19世纪末期、20世纪初期。北川善太郎教授认为，现代民法，是近代民法在20世纪的发展与修正，与近代民法并无本质上的差别，是在近代民法的法律结构基础之上，对近代民法的原理、原则进行修正、发展的结果。[47]现代民法主要具有以下特征：

1. 对所有权的限制。在自由资本主义时期，以绝对的、不受限制的私有权为原则，其虽然对自由资本主义经济的发展起过推动作用，但是它过分强调个人利益而忽视了社会整体利益，加剧了个人利益与社会利益之间的冲突，阻碍了生产的社会化和大规模的经济建设，甚至导致了个人随意滥用其所有权而损害他人利益和社会利益的现象。因此，19世纪末期以来，社会的所有权观念日益发达，这种观念认为，法律保障所有权旨在发挥物的效用，使物达到充分利用并增进社会的公共福利，所有权的行使应当顾及社会公共利益，不允许个人滥用权利，损害他人利益和公共利益。同时，从维护社会公共利益出发，应对所有权作适当的限制。[48]例如，1919年德国《魏玛宪法》第153条第4项规定：“所有权负有义务，于其行使应同时有益于社会公益。”

2. 对契约自由的限制。自20世纪以来，资本主义自由竞争不断走向垄断。第二次世界大战以后，一些主要资本主义国家在其经济政策中相继采纳了凯恩斯主义，从而扩大政府职能，加强对经济的全面干预。在法律领域，合同自由原则因国家干预经济的加强而受到越来越多的限制，因此，对合同自由的限制成为20世纪以来合同法发展的一个重要趋向。为了限制垄断、平抑物价、维护竞争秩序，西方国家制定了许多反垄断和维护自由竞争的法律，这些法律本身就是对合同自由的限制。在合同法中对契约自由的限制，主要表现在强制缔约制度的产生、对格式条款和免责条款的限制、对某些特殊合同的形式作特殊要求，以及通过诚信原则等对合同关系进行干预等。[49]

3. 从单一的过错责任向归责原则多元化转化。随着20世纪以来社会生活的变化，危险事故频繁发生，受害人的权益经常容易受到侵害。这种变化不仅使过错归责理论的内容发生变异，使客观过错理论逐渐取代了主观过错理论，而且更突出地表现在归责原则的多元、分化方面，即归责原则理论本身呈现出从单一过错归责理论向多元归责理论演化的过程。[50]许多大陆法系国家都在特别法中采取严格责任，以保护受害人的利益，尤其是在交通事故、医疗事故以及航空器、核能的采用所引起的损害领域，逐渐扩大了严格责任的适用范围。归责原则的多元化对于向受害人提供充分的补救、缓和西方社会的矛盾、维护社会秩序起到了重要作用。

4. 更注重对实质正义的维护。现代民法更强调维护实质正义。自20世纪以来，社会经济结构发生巨变，社会组织空前复杂、庞大，贫富差别日益突出，社会生产和消费规模化，公用事业飞速发展，消费者、劳动者等弱势群体保护的问题凸显出来。市场经济的高度发展使民事主体之间在交易过程中的实质平等成为一个严重的问题。因此，强化对消费者的保护，维护实质正义成为民法的重要发展趋势。[51]随着现代社会的发展，民法中更应当关注实质正义的实现和具体权利能力的建构。[52]此外，随着民法人文关怀理念的发展，侵权法的许多规则也越来越彰显对人的关怀与保护，如在保护范围方面，侵权法从传统上主要保护物权向保护人格权、知识产权等绝对权的扩张；在损害的分担方面，责任的社会化分担也是侵权损害承担的重要趋势。合同法也越来越多地彰显民法的人文关怀理念。例如，消费者合同概念的出现，就是为了实现对消费者的特别保护。

5. 人格权产生并日益受到重视。两次人类社会的世界大战，尤其是第二次世界大战，对世界各国人民造成了极大的伤害，战争带来的生灵涂炭使战后世界各国人民权利意识与法治观念觉醒，人们愈来愈强调对作为社会个体的公民之间的平等、人格尊严不受侵犯以及人身自由的保护。这就极大促进了20世纪中叶的世界各国人权运动的巨大发展。面对轰轰烈烈的人权运动，世界各国民商法都作出了回应，一般人格权观念在某些国家得到了立法与司法的承认与保护，一些新型的人格利益被上升为人格权并受到法律严格的保护。同时，隐私权也逐渐受到法律认可，而且其内涵在不断扩张，不仅包括个人的秘密不受非法披露，也包括个人的生活安宁、内心的宁静不受他人的非法干扰。[53]此外，精神损害赔偿制度也日益完善，在19世纪还被严格限制适用的精神损害赔偿责任，在20世纪得到了急剧的发展，不仅使人格权获得了极大的充实，而且为受害人精神的痛苦提供了充分的抚慰。

6. 侵权法的独立与扩张。在传统的债法模式中，侵权法与合同法等法律共同构成债法的基本支撑。在债法这个体系中，由于侵权法本身类型化特征不够突出，条款非常简略，因而债法主要是以合同法为中心构建起来的，侵权法在整个民法体系中的地位并不突出。19世纪各国民法关于侵权责任的规定都非常简约。例如，1804年《法国民法典》当初仅仅规定了5个条文。自20世纪以来，随着人权保护的加强、工业社会的发展、风险社会的来临，侵权法在分配风险、救济受害人方面发挥着日益重要的作用，侵权法的适用范围也在逐渐扩张。例如，《荷兰民法典》第6. 3节（第162条以下）专门规定了侵权责任，包括过错责任、危险责任、严格责任以及公平责任。我国也颁布了独立的《侵权责任法》，而且即将在我国未来民法典中独立成编。

7. 民法的商法化趋势。民法的商法化现象，不仅是指民法和商法正趋于统一，形成民商合一的趋势，更重要的表现是商法的一些原则和精神被民法采用。一是商法的效率原则在民法中得到充分体现。二是对权利外观的保护，传统民法主要探求当事人真实意思，而商法注重权利外观的保护。但现代民法通过公信原则、善意取得、表见代理等制度也形成了对权利外观的保护。[54]三是传统民法注重意思主义，并不强调形式，而商法注重形式要件。但现代民法在某些合同领域，如房地产买卖合同也注重形式要件。有些学者将此种现象称为“形式主义的复兴（renaissance de formalisme）”[55]。

8. 交易规则的一体化趋势。近几十年来，对民法影响最为深远的原因乃是经济的全球化。20世纪以来，特别是“冷战”结束之后，世界市场的格局逐步形成，经济趋同化快速发展，作为交易的共同规则的合同法以及有关保险、票据等方面的规则日益国际化，两大法系的相应规则正逐渐融合。例如，1980年的《联合国国际货物销售合同公约》的制定，熔两大法系的合同法规则于一炉，初步实现了合同法具体规则的统一。1994年，国际统一私法协会组织制定了《国际商事合同通则》，其尽可能地兼容了不同文化背景和不同法系的一些通用的法律原则，同时还总结和吸收了国际商事活动中广为适用的惯例和规则，其适用范围比前述公约更为广泛，交易规则一体化的趋势日益明显。

三、我国民法的发展及未来

中国古代实行“诸法合一、民刑不分”，并没有形成近代意义上的民法。清末变法时，清政府于1911年制定了第一次民律草案。辛亥革命以后，国民政府的修订法律馆在北京开始了民律草案的起草工作。1925年，草案完成，史称第二次民律草案。以后，南京国民政府于1929年5月30日颁布民法典总则；1929年11月22日颁布了债编；1929年11月30日颁布了物权编；1930年12月26日颁布了亲属编和继承编。

新中国建立以后，曾几次制定民法典。1986年4月12日，第六届全国人民代表大会第四次会议正式通过了《民法通则》，这是我国第一部调整民事关系的基本法律，也是我国民事立法发展史上的一个新的里程碑。随着改革开放的深化和市场经济的发展，我国陆续制定了一系列规范市场活动的民事基本法。例如，1999年的《合同法》统一了我国的合同法律制度，建立和完善了市场交易的基本规则和原则；2007年颁行了《物权法》，对所有权、用益物权、担保物权等物权制度作出了全面规定；2009年颁行了《侵权责任法》，对民事权利进行了更加周密的保护；我国立法机关还先后制定了《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》等法律，完善了市场主体法律制度；颁布了《婚姻法》《收养法》《继承法》等法律，建立和完善了婚姻家庭制度；为保护知识产权，先后颁布实施了《专利法》《商标法》和《著作权法》，这些法律都是我国民法的重要组成部分，其颁行是完善我国民事立法体系的重要步骤。

2014年，十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确提出要“加强重点领域立法”，特别是“加强市场法律制度建设，编纂民法典”。2017年3月15日，第十二届全国人民代表大会第五次会议审议通过了《民法总则》，实质性地推进了我国民法典的编纂进程。《民法总则》的颁行正式开启了民法典编纂的进程。民法总则是民法典的总纲，纲举目张，整个民商事立法都应当在民法总则的统辖下具体展开。《民法总则》颁行后，民法典各分编的编纂都要协调好与《民法总则》的

关系，并以其所确立的立法目的、原则、理念为基本的指导，从而形成一部价值融贯、规则统一、体系完备的民法典。《民法总则》不仅奠定了民法典分则制度设计的基本格局，而且为整个民事立法的发展确定了制度基础。《民法总则》从中国实际出发，借鉴两大法系的先进经验，充分反映了我国改革开放和市场经济发展的现实需求，立足于中国国情并解决现实问题，体现了鲜明的时代性，充分彰显了时代精神和时代特征。《民法总则》构建了完整的民事权利体系，强化了私权保障，使其真正成为“民事权利的宣言书”。《民法总则》完善了市场经济的法律规则，有力地助推法治社会建设，其颁行具有重要的历史意义。

当然，《民法通则》《合同法》《物权法》《侵权责任法》等重要法律的颁行都还只是在制定我国民法典的道路上迈出的坚实步伐，我国毕竟还没有制定出一部民法典。目前，在《民法总则》颁行之后，立法机关正在加紧民法典分则的制定，力争在2020年颁行一部符合中国国情、面向21世纪的民法典。

第五节 民法与商法

一、商法的概念及历史发展

商法，又称商事法，可分为形式意义上的商法和实质意义上的商法。形式意义上的商法，专指在民法典之外的商法典以及公司法、保险法、破产法、票据法、海商法、证券法、信托法等单行法；实质意义上的商法，指一切有关商事的规则。

近代的商法是在11世纪前后，随着欧洲商业的兴起而发展起来的。在这个时期，欧洲一些商业发达的城市都云集着一批专司买卖的商人，他们组成了商人公会（merchant guild），独立地订立自治规约和处理商人的纠纷，在此基础上逐渐形成了商人习惯法。1673年，法国国王路易十四以国王的名义颁布了第一个商事法，即《陆上商事条例》，共计112条，其中包括公司、票据、破产等内容。1881年法国又公布了《海事条例》，类似于现在的海商法。

从19世纪开始，商法开始在大多数大陆法系国家作为一个独立的法律部门出现，并已开始法典化。1804年拿破仑制定了《法国民法典》，并于1807年制定了《法国商法典》，这两个法典的制定标志着民商分立体系的形成。目前，有四十多个国家有自己独立的商法典。

商品经济的发展使商业职能与生产职能密切结合，导致商人企业化，生产者亦成为商人，商人的特殊利益逐步消失，这一变化大大动摇了民商分立的经济基础，同时，为了立法技术的科学性，近代和当代许多国家与地区开始推行民商法的统一。随着目前经济全球化的发展，许多国家为消除外贸障碍，使商品和货币交易更简便易行，也都要求法律集约化，使民法和商法统一起来。民商合一适应了社会经济发展的需要，反映了社会化大生产的要求，因而具有一定的进步意义。所以，近几十年来，许多国家和地区颁布的民法典都实行民商法统一模式。1929年，国民党政府制定“民法总则”时，曾经召开专题会议讨论民法与商法的关系，胡汉民等在“民商合一提案审查报告书”中指出，从历史沿革、社会进步、世界交通、立法趋势、人民平等、编订标准、编订体例及民商关系诸方面列举了8项理由进行论证。[56]

新中国成立以来，我国法律体系中不存在商法部门。改革开放以来，我国市场经济得到了迅速发展，客观上需要制定一些在大陆法系传统被称为商法的法律，包括公司法、票据法、保险法、海商法和破产法等。我国已颁布了《公司法》《企业破产法》《合伙企业法》《证券法》《保险法》等，尽管在其性质上存在争议，但多数学者认为其属于商法。那么商法是否为独立的法律部门呢？本书认为，我国实行民商合一的立法体例，在我国法律体系中，只存在独立的民法部门，并不存在一个商法部门，各个商事法律不过是民法的特别法。我国民法作为调整社会主义市场经济活动的基本法，是千千万万种交易关系的抽象化的法律表现。而调整市场经济关系的商事法规不过是民法原则在具体领域中的体现，是民法规范在某些经济活动中的具体化。民法和商事法律之间是基本法与补充基本法的单行法规之间的关系。确切地说，所谓商事法律也是民事法律。只有坚持民商合一，才能使我国民事立法体系系统化，保证我国法律体系的和谐统一。

二、民商合一体制

所谓民商合一，是指不区分民法和商法，而将民事法律规范统一适用于各种民商事关系，在形式上，通常民商合一是指并不制定独立的商法典，而将民事规范广泛适用于调整所有平等主体之间的法律关系；而民商分立则意味着严格区分民法与商法，基于主体或者行为性质的不同，在民法典之外，还要独立制定商法典，采用和民事法律不同的行为规范。[57]民商分立的体制最早起源于法国。到了20世纪初，瑞士制定了民法典，在民法典中包括了公司法、商业登记法等商法的内容，从而实现了民商合一的立法体例。[58]

我国《民法总则》明确采纳了民商合一的体例。[59]民商合一体例并不一定追求法典意义上的合一，其核心在于强调以民事规则统一适用于所有民商事关系，统辖商事特别法。民法典总则的制定本身是民事法律体系化的根本标志。我国民法典的编纂坚持民商合一的体制，即从民法典总则到民法典分则，再到商事特别法，从而形成一个完整的民商合一的内在逻辑体系。《民法总则》与各个商事法律构成了一个有机的整体，二者之间是普通法与特别法之间的关系，也就是说，在出现商事纠纷后，首先应当适用商事特别法，如果无法适用商事特别法，则可以适用《民法总则》的规则。

我国《民法总则》实际上是采纳了民商合一的立法体制，具体来说：

第一，民法总则确认的基本原则可以普遍适用于民商事活动。我国《民法总则》确认的基本原则，可以适用于商事交易关系。总则中规定的意思自治，可以把商法、商事特别法所应体现的基本原则都囊括其中。民法总则是对民法典各组成部分及对商法规范的高度抽象，诸如平等原则、自愿原则、诚实信用原则、公平原则和等价有偿原则等，均应无一例外地适用于商事活动。

第二，《民法总则》没有区分商人和非商人，而是规定了统一的民事主体制度，《民法总则》中规定的自然人、法人、非法人组织实际上既包括民事主体，又包括商事主体。例如自然人中就包括了商自然人，法人中就包括了营利法人，非法人组织包括个人独资企业、合伙企业。

第三，《民法总则》没有采用商行为的概念，而采用了统一的民事法律行为的概念与制度，民事法律行为包含共同行为、决议行为、双方法律行为、单方法律行为，从而可以涵盖各类商行为（如公司决议行为、制定章程的行为等）。至于商主体从事的商事活动，也完全可以依据民事法律行为的一般规则认定其成立和效力。

第四，没有区分商事代理和民事代理。民商分立的主要特征就是区分了民事代理和商事代理。我国《民法总则》规定了统一的代理制度，相应的代理规范可以适用于各种法律关系之中。

第五，构建统一的诉讼时效制度。我国民法总则中的诉讼时效制度适用于所有民商事领域，未区分民法中的时效与商法中的时效，因此，其属于统一的时效制度。

总之，《民法总则》采纳民商合一体制，从而使民法总则真正发挥统辖商事特别法的功能，并真正实现民商事法律的体系化。

第六节 民法和其他法律部门的区别

一、民法和宪法

宪法是国家根本大法，是社会主义法律体系的基础，宪法与民法虽然是两个不同的法律部门，但两者之间也存在密切的联系，作为国家根本法的宪法，是民法的制定依据，尤其是宪法关于公民基本权利的规定是民事权利的上位法依据。因此，我国《民法总则》在第1条开宗明义地规定“根据宪法，制定本法”，这一规定包含如下含义：一方面，表明宪法具有最高的法律效力，民法典的规范不得与宪法的规定相抵触。在我国，宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程，是保障国家统一、民族团结、经济发展、社会

进步和长治久安的法律基础。要维护法制的统一，首先必须保障宪法的实施，维护宪法的权威。[60]另一方面，表明民法典规范的价值和效力来源于宪法规定。[61]这就是宪法学者所说的“法源法定”。梁启超曾言：宪法“为国家一切法度之根源”[62]。在民法典编纂过程中，相关规则的设计应当立足于宪法文本，遵守宪法的规定。[63]我国《宪法》第5条规定：“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。”这也表明，民法典的制定必须符合宪法的原则和精神。此外，宪法对于民法的解释、适用也具有重要的指导意义。在一些国家，法官可以直接援引宪法的精神解释民法规则，借助于“基本权利的直接第三人效力”“基本权利对民法的辐射作用”等原理，直接在民事关系中以宪法规范来保护基本权利。在另外一些国家，虽然不承认宪法的直接第三人效力，但法官可以借助一般条款和基本原则，将宪法的规范适用于具体的法律关系之中，这就是基本权利的间接第三人效力。[64]在我国，虽然宪法尚不具有可司法性，法官也不能直接援引宪法裁判民事案件，但在司法实践中，法官仍然可以以宪法规范作为价值指导，选择适用民法裁判规则，并对民法规范进行合宪性解释，也可以援引宪法作为论证依据。民法作为重要的法律部门，其具有贯彻宪法规则与原则的作用，例如，民法通过保护民事主体的各项人格权益，有利于落实宪法关于人格尊严保护的规定。

但作为两个不同的法律部门，民法和宪法也存在较大的区别：

第一，性质不同。宪法本质上是公法，民法属于私法。宪法主要规制国家机关的行为，而民法主要规范私主体的行为。[65]宪法所建立的法秩序不同于民法的。前者主要包含国家机构的设置，国家机关的权力和义务，这里虽然会涉及个人的权利和利益，但并不直接。而民法所建构的法秩序则主要包含平等私主体之间的关系，与个人的权利和利益直接相关。

第二，调整对象和调整方法不同。宪法主要调整国家和公民之间的关系，而民法则是调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律。因为这一原因，所以并非所有宪法上的权利都可以转化为民事权利，也并非所有的民法问题都涉及宪法：因为宪法基本权利大多是公法上的权利。而民法典所保护的权利仅限于私权，而不包括所有的公法上的权利。[66]

第三，义务的性质不同。宪法义务虽然对公民也有约束力，但宪法所设定的许多义务主要是针对国家的，并不能直接规制公民的行为，而是要求国家机关制定相关的法律法规，为公民的行为规范提供法律依据。基于宪法的保护义务，相应的国家机关有义务依据宪法所规定的基本权利制定具体的法律法规，在部门法的层面对基本权利提供充分保护。而民法所设定的义务主要针对民事主体，每个民事主体都负有遵守的义务。基于这一原因，民事主体违反民法义务时并不一定导致其违反宪法义务。

第四，涉及的范围不同。宪法的调整范围涉及多个法律部门，并不仅仅局限于民法。一方面，宪法所确定的权利并不仅仅涉及民事领域，一些权利也无法都转化为民事权利，一般而言，只有那些体现了特定主体的私益、具有私法上可救济性的权利，才有必要具体化为民事权利。例如，《宪法》所确认的公民所享有的宗教信仰自由就应当通过行政法予以保障，无法转化为民事权利。再如，《宪法》所确认的公民所享有的劳动的权利，就主要应当通过社会法予以保障。另一方面，宪法所确认的权利需要多个部门法共同予以保障，而不能仅靠民法。例如，在国家公权力机关违法行使权力侵害公民依据宪法上享有的财产权和人身权时，则必须通过行政诉讼法和国家赔偿法的规定给予保护。再如，如何防止个人数据信息被泄露，保护公民的通信秘密，还需要国家通过制定个人信息保护法等规定加以贯彻落实。

二、民法和行政法

行政法就是国家通过各级行政机关管理国家政治、文化、教育、劳动人事、卫生等事务的法律规范的总和，是规范国家机关行为并发挥其组织、指挥、监督和管理职能的法律形式。行政法是我国法律体系中的一个重要部门。

在采公、私法划分的国家中，行政法属于典型的公法，与作为私法的民法在理论上是完全不同的。行政法调整一定的行政关系，这种关系与民法调整的一定范围的财产关系和人身关系是不同的，表现在：

第一，行政关系主要是根据国家意志产生的，国家对各个领域的组织、指挥、监督和管理都体现了国家权力的运用，而民事关系主要是基于民事主体的自主自愿而产生的。

第二，在行政关系中，必有一方是国家行政管理机关。任何行政关系都是在国家行政管理活动中产生的。而民事关系的主体主要是公民和法人，国家只是在例外的情况下才成为民事主体。

第三，行政关系具有隶属性。在行政关系中，国家行政管理机关处于领导者和指挥者的地位，并以自己的意志规定另一方主体的行为，而另一方则处于被领导的地位，故行政关系是按照指令和服从原则建立起来的隶属关系。而民法调整的社会关系是平等主体之间在等价有偿、平等互利的基础上形成的。

第四，民法和行政法的调整方法是不同的。民法具有任意性，民法中的大多数规范，特别是债和合同法规范是任意性规范，当事人的意思可在合法的前提下优先于任意法而适用。而行政法多为强行法，一般不允许第三人通过协商来改变法律的规定。

第五，行政权和民事权利的性质不一样。表现为：一方面，在行政关系中，行政机关所享有的行政权是由国家授予的，直接体现着国家的意志和利益。行政权往往与行政机关的职责密切联系，并且与特定的主体不可分离。而民事权利一般是与权利人本身的意志和利益是相联系的，大多数民事权利可以依法由权利人抛弃、转让和继承。另一方面，行政权从内容上来说，通常体现的是一种国家或社会利益，而民事权利主要体现的是民事主体的私人利益。行政权必须依法行使，而就民事权利而言，权利人依法可以行使，也可以不行使，其不行使权利一般不应承担任何责任。还要看到，行政权本身具有国家强制性。当主体另一方不履行法定义务时，行政机关可依据其权力，强制义务人履行义务。而在民事关系中，当义务人不履行义务时，权利人一般只能通过民事诉讼或仲裁的程序请求司法或仲裁机构处理和解决纠纷，促使义务人履行义务。

三、民法和经济法

在20世纪20年代末30年代初，原苏联著名法学家斯图契卡首先表述了与民法并存的经济法（经济行政法）的观点，他把国家采用行政手段管理生产和产品分配的法规统称为经济行政法。在20世纪50年代末期，苏联以B. B. 拉普捷夫和B. K. 马穆托夫为代表的现代经济法学派提出了“纵横统一”的经济法观点，认为经济法作为一个独立的法律部门调整纵向和横向统一的经济关系，调整在统一的国家所有制、统一的计划和经济核算关系基础之上的计划组织因素和财产因素结合的经济关系。[67]我国在1979年开始出现经济法概念，经济法学也蓬勃兴起。迄今为止，我国法学界对经济法的调整对象和调整范围问题存在不同的见解，主要有以下几种观点[68]：

一是纵横统一的经济法观点。这一观点认为，我国经济法调整纵向和横向统一的经济关系。经济法的调整范围是：国家和经济组织之间的经济管理关系、经济组织之间的经济关系和经济组织内部的经济关系。

二是综合经济法观点。这一观点认为，经济法调整的并非特定的经济关系，而是在经济活动中发生的性质不同的具体经济关系。经济法只是对诸种经济关系的综合调整，而不是一个独立的法律部门。经济法主要包括经济行政法、经济民法、劳动法以及刑法等部门法中涉及经济内容的规范，其调整方法也是综合性的。

三是计划经济法观点。这一观点认为，经济法并不调整全部的纵向经济关系，而只是调整社会主义计划经济中的各种经济关系。

四是学科经济法观点。这一观点认为，经济法并没有自己特殊的调整对象和调整方法，不是一个独立的法律部门，而只是一门学科。经济法作为一门学科的任务，就是要研究、运用各个法律部门的手段，综合调整社会主义经济关系，以避免法律部门在调整经济关系过程中的不协调现象。

本书认为，经济法一词具有双重含义：一是指调整经济关系的所有经济法律规范，在这个意义上使用的经济法概念通常又称为经济立法。二是指调整特定的经济关系的法律部门，即作为独立的法律部门的经济法。在这个意义上所说的经济法，就是国家行政权力作用于经济领域，国家行政机关对国民经济实行组织、管理、监督、调节的法律规范的总称，它主要调整纵向的、具有行政隶属特征的经济管理关系。从这个意义上说，经济法也称为经济行政法。[69]经济法和民法在调整对象上的主要区别在于：

第一，经济法调整的经济管理关系是国家在管理经济活动中所产生的关系，其内容包括计划、组织、调节、监督等多方面。由于这种关系主要发生在有隶属关系的上下级之间，所以也称为纵向的关系。而民法的调整对象主要是发生在平等主体之间的财产关系和人身关系，民法不仅调整经济关系，也调整非经济关系，民法调整的社会关系的主要特点在于其平等性。

第二，经济法调整的经济管理关系是按指令和服从原则建立起来的行政隶属关系，所以经济法规范大多是强制性规范，违反该规范所产生的责任大多是行政责任。而民法的调整对象是民事主体之间在平等协商基础上建立起来的平等关系，故民法以任意性规范为主，违反民法的规定主要产生民事责任。由此决定了经济法主要采取指令和服从的调整方法，而民法主要采取意思自治的调整方法。

第三，经济法调整的经济管理关系是以全社会需要为宗旨的关系，它主要协调的是市场主体的利益和国家利益、公共利益的冲突，其目的在于维持良好的市场秩序，实现特定的公共政策。而民法主要协调民事主体之间的关系，目的在于保护单个民事主体的合法权益。

四、民法和社会法

社会法是调整由个人基本生活保障而衍生的相关社会关系的法律规范的总称。社会法是近几十年来发展起来的、跨越公法和私法的法律部门，其内容主要包括劳动法、社会保障法、社会救助法等法律。社会法以保护社会大众和弱势群体为宗旨，在缓和社会矛盾、维护社会稳定方面发挥着重要的作用。民法与社会法之间具有密切联系：一方面，二者都强调对弱势群体的保护。随着民法人文关怀精神的彰显，其越来越强调对人的保护，其与社会法一样，都强调对社会弱势群体的保护。另一方面，二者在功能上具有一定的互补性。社会法强调对人的保障，注重维护社会稳定，民法尤其是侵权法也注重对受害人的救济，在民法无法为受害人提供充分的救济时，社会法可以对受害人提供补充性的保护。

社会法和民法的主要区别在于：第一，从法律性质上说，民法是私法，以维护民事主体的私人利益为主要目标。尽管现代民法已经从个人本位向社会本位演进，为了维护社会公共利益也加强了对私人关系的干预，但毕竟民法维护的主要还是私人利益。而社会法作为以维护社会公共利益为其主要目标的法律，在性质上并不是私法，它的目的在于建立较为完备的社会保障制度，维护社会全体成员的共同福利，谋求社会大众共同福利的增进，因此其兼具公法与私法的双重性质。[70]第二，民法以私法自治为原则，表现出较强的任意法的特性；而社会法主要是强行法，它不允许当事人之间自由设立权利义务。例如，就社会保险而言，尽管存在自愿险，但更多的是法定的强制险。当然，社会法中也有自治的内容，如劳动合同中部分内容也允许当事人自由约定。第三，民法注重维护形式正义，而社会法则更注重维护实质正义。民法调整的是平等主体之间的关系，而社会法不以平等主体之间的社会关系为起点，而以实质平等的价值理念构建社会法的规则体系，尤其是注重保护弱势群体的权益。[71]第四，民法的许多规则，如债与合同、物权制度、知识产权制度等，都具有创造财富的功能，而社会法主要具有满足社会成员的基本生活需要的财富分配功能。第五，社会法以保护公民的生存权为目标，即实现社会保障的根本目的就是使公民获得基本的生存条件。而民法不仅要保护民事主体的生存权，而且还要保护民事主体参与市民生活所应当享有的各种权

利。[72]

五、民法与民事诉讼法

民事诉讼法是用来调整当事人、法院及其他诉讼参与人之间实施诉讼活动以及由此形成的诉讼关系的法律规范的总称。马克思曾经指出：“审判程序和法二者之间的联系如此密切，就像植物的外形和植物的联系，动物的外形和血肉的联系一样。审判程序和法律应该具有同样的精神，因为审判程序只是法律的生命形式，因而也是法律的内部生命的表现。”[73]可见，民法和民事诉讼法是相互依赖、密不可分的。一方面，民法所规定的实体规则在很大程度上决定了民事诉讼法的规则设计。例如，就侵权责任而言，民事诉讼法所规定的举证责任分配规则应当以《侵权责任法》的规定为基础。另一方面，民事诉讼法可以从程序上起到对民事权利的全面保障作用，为民事权利提供了规则化、体系化的程序保护规则。法谚云，救济走在权利之前，民事权利的实现需要民事诉讼的保障，如果诉讼程序的设置无法保障民事权利的实现，那么实体法中的权利也就变成无源之水、无本之木，也难以真正实现。

当然，作为不同的法律部门，民法和民事诉讼法也存在如下区别：

第一，性质不同。民事诉讼法是程序法，旨在规范民事主体实现其民事权利的民事诉讼程序。而民法是实体法，旨在规范民事主体之间实体的民事权利义务关系。实体法和程序法虽然紧密联系，但基本内容和基本原则都各自不同。[74]与此相应，民法属于私法，而民事诉讼法属于公法，因为后者以规范国家司法权的行使作为其重要内容。

第二，调整对象不同。民法调整民事主体之间的人身关系和财产关系，而民事诉讼法是调整民事诉讼活动和诉讼关系的法律，以规范诉讼程序和诉讼关系为对象，以公正、适当解决纠纷为目的。民法主要调整实体权利义务关系，而民事诉讼法主要规范当事人、法院和诉讼关系人实施的民事诉讼法律关系。[75]民法主要是任意法，以当事人意思自治为原则；而民事诉讼法为强行法，采纳程序法定主义。

第三，从立法目的来说，民法主要考量实体正义，民法中的正义除了具体的法律规范内容外，还需要综合考虑社会、历史、经济等多种因素，通过价值衡量对当事人直接的权利义务进行分配才能实现。民事诉讼法虽也以保护民法上的实体权利为目的，但其所追求的是程序正义，其以诉讼规则为准则，以法律事实为依据。当然，这并不是说两者是截然对立的。一方面，法官在追求程序正义的同时，在裁判时也需要考量多种社会因素，即将实体法中的实质正义纳入裁判的考量之中。另一方面，程序正义是通向实质正义的必经之路，程序正义是看得见的正义，只有充分维护程序正义，才能真正实现当事人权利的平等保护。

第七节 民法的渊源

民法的渊源是指民事法律规范借以表现的形式，它主要表现在各国家机关根据其权限范围所制定的各种规范性文件之中。正是从这个意义上说，合同、章程等民事法律行为本身并不是法源。民法的渊源主要体现在立法、司法裁判和行为规则方面，它包括裁判规则和行为规则两个方面。

一、宪法

宪法是国家的根本法，由全国人民代表大会制定，具有最高的法律效力。毫无疑问，宪法作为国家的根本大法，理应成为民法的渊源，宪法中关于社会主义建设的方针和路线的规定、关于财产所有制和所有权的规定、关于公民基本权利和义务的规定等，都是调整民事关系的重要法律规范，因此，《民法总则》第1条规定：“为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。”

但是，宪法规范能否在裁判中引用，一直存在争议，对此有两种观点：一是肯定说。此种观点的主要理由是：宪法具有最高效力，是民法制定的依据，宪法中的相关规定是调整民事关系的重要法律规范。[76]二是否定说。此种观点认为，应当将渊源理解为可以作为裁判基准的法律规范。由于宪法不能成为裁判规范，故应当将宪法排除在民法渊源之外。[77]学界曾经就宪法的司法化问题发生过争议，2009年最高人民法院发布的《关于裁判文书引用法律、法规等规范性文件的规定》（以下简称《引用法律规定》）第4条规定：“民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。对于应当适用的行政法规、地方性法规或者自治条例和单行条例，可以直接引用。”从该条规定来看，并没有将宪法列入民事裁判文书可以引用的范围之列。因此，依据该规定，法官在裁判民事案件中，不得直接援引宪法裁判案件。但是，这并不意味着，裁判文书不能援引宪法。一方面，宪法可以成为裁判中说理论证的重要依据。另一方面，法官在裁判过程中，如果因适用法律出现复数解释，在此情况下就应当以宪法的原则、价值和规则为依据，确定文本的含义，得出与宪法相一致的法律解释结论。通过合宪性解释来确定法律文本含义时，通常采取选择或排除的方式。这就是说，如果某个解释结论符合宪法，就应当选择其作为解释结论；如果所作的解释结论违反了宪法，就应当予以排除。通过这种方式，使文本的含义能够与宪法保持一致，由此可以让宪法规范在民法中得到贯彻。

二、民事法律

民事法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定和颁布的民事立法文件，是我国民法的主要表现形式。民事法律主要由两部分组成：一是民法总则、民法通则以及合同法、物权法、侵权责任法、涉外民事关系法律适用法、婚姻法、收养法、继承法等民事基本法以及专利法、商标法、著作权法。二是商事特别法。在商事特别法方面，我国已制定了公司法、保险法、海商法、破产法、票据法、证券法等法律。可见，我国民事立法的基本规则已经建立，但仍然需要制定一部民法典予以完善。上述民商事法律都是民事法律的重要组成部分，也是裁判中应当依循的基本规则，法官可以直接援引这些法律裁判案件。

三、国务院发布的行政法规

国务院是最高国家行政机关，它可以根据宪法、法律和全国人民代表大会常务委员会的授权，制定、批准和发布法规、决定和命令，其中有关民事的法规、决定和命令，是民法的重要表现形式，其效力仅次于宪法和民事法律。例如，2007年2月6日国务院颁布的《商业特许经营管理条例》，2011年1月21日国务院颁布的《国有土地上房屋征收与补偿条例》等都是重要的民法渊源，在处理民事案件时，法官也可以援引这些行政法规裁判案件。

四、行政规章

根据《立法法》的规定，行政规章是指国务院各部委以及各省、自治区、直辖市的人民政府和省、自治区的人民政府所在地的市以及设区市的人民政府根据宪法、法律和行政法规等制定和发布的规范性文件。一些行政规章也包含调整民事关系的内容，其也可能成为民事裁判的依据。关于行政规章在司法裁判中的运用，《引用法律规定》第4条并没有将其规定为民事裁判可以直接引用的裁判规范，但从该司法解释第6条的规定来看，对行政规章而言，法官“根据审理案件的需要，经审查认定为合法有效的，可以作为裁判说理的依据”。从该条规定来看，在民事裁判中，行政规章并不能直接作为裁判依据，而需要经过法院的审查认定。当然，在特殊情况下，如果法律对行政规章的适用作出了明确规定，则其也可以成为民事裁判的依据。[78]

五、最高人民法院的司法解释

最高人民法院是我国的最高审判机关，依法享有监督地方各级人民法院和各专门人民法院的审判工作的职权。我国《宪法》没有授予最高人民法院立法权，但是全国人民代表大会常务委员会《关于加强法律解释工作的决议》第2条规定：“凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题，由最高人民法院进行解释。”《人民法院组织法》第33条也规定了这种解释权。从法理的角度来看，司法解释并不属于法律体系的组成部分，但司法解释已经成为我国各级审判机关在处理案件中的裁判规则，并被当事人直接援引，甚至法院的裁判都直接援引司法解释。所以，司法解释事实上已经成为法律渊源。

在此需要讨论的是，最高人民法院发布的指导性案例是否属于法律渊源？所谓指导性案例，是指由最高人民法院确定并发布的、对全国法院审判、执行工作具有指导作用的案例。[79]2010年11月26日，最高人民法院发布了《关于案例指导工作的规定》，从而建立了案例指导制度。该制度对于保障裁判的统一、规范法官自由裁量、保障法律的准确适用等都具有十分重要的意义。根据《关于案例指导工作的规定》第7条，指导性案例的效力是“各级人民法院在审判类似案件时应当参照”。可见，指导性案例并不是法律渊源，不能直接作为裁判依据，只是可以在判决书说理部分来加以使用。从这个意义上讲，指导性案例可以成为法院裁判说理的理由。

六、地方性法规或者自治条例和单行条例

地方性法规是指地方各级人民代表大会、地方各级人民政府在宪法、法律规定的权限内所制定、发布的决议、命令、法规等规范性法律文件。地方性法规虽然在效力范围上具有从属性，且在适用范围上具有地域局限性，但地方性法规是地方国家权力机关依据宪法的授权而制定的法规，同样具有法的效力，其中调整民事关系的内容属于民法的渊源。

自治条例和单行条例也可以成为民法的渊源。所谓自治条例，是指民族自治地方的人民代表大会依据宪法和法律，结合当地民族自治地区特点所制定的、管理自治地方事务的综合性法规。所谓单行条例，是指民族自治地方的人民代表大会及其常务委员会在宪法和法律所规定的自治权范围内，结合民族地区的特点，就某方面具体问题所制定的法规。《引用法律规定》第4条规定：“民事裁判文书应当引用法律、法律解释或者司法解释。对于应当适用的行政法规、地方性法规或者自治条例和单行条例，可以直接引用。”依据这一规定，自治条例和单行条例也可以成为民事裁判的依据，成为民法的渊源。

需要指出的是，行政法规和地方性法规虽然可以成为民法渊源，但其不能直接作为判断合同效力的依据。最高人民法院《合同法司法解释一》第4条规定：“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”

七、国际条约和国际惯例

国际条约是两个或两个以上的国家就政治、经济、贸易、军事、法律、文化等方面的问题确定其相互权利义务关系的协议。国际条约的名称包括条约、公约、协定、和约、盟约、换文、宣言、声明、公报等。国际惯例也称为国际习惯，分为两类：一类为属于法律范畴的国际惯例，具有法律效力；另一类为属于非法律范畴的国际惯例，不具有法律效力。[80]按照《国际法院规约》第38条，国际惯例是指“作为通例（general practice）之证明而经接受为法律者”。因此，国际惯例主要是指前一种类型。《民法通则》第142条规定：“涉外民事关系的法律适用，依照本章的规定确定。中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的，适用国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的，可以适用国际惯例。”可见，我国签订或加入的国际条约以及国际惯例也可以成为我国民法的渊源。

关于国际条约的效力问题，目前仍有争议[81]，应当指出的是，国际条约优先于国内法而适用的效力，主要是针对涉外民事关系而言的，而国内的民事关系原则上仍受国内法调整，不应当盲目地扩张国际条约的适用范围。根据《民法通则》第142条的规定，国际惯例的适用只限于中国法律和中国缔结或者参加的国际条约没有规定的情况。显然，其效力低于中国法律，只有在不违背我国法律规定的前提下，才可适用。

八、不违背公序良俗的习惯

所谓习惯，是指当事人所知悉或实践的生活和交易习惯。所谓生活习惯，是指人们在长期的社会生活中形成的习惯。所谓交易习惯，是指交易当事人在当时、当地或者某一行业、某一类交易关系中，所普遍采纳的，且不违反公序良俗的习惯做法。我国是幅员辽阔的多民族国家，在少数民族聚居的地区，生活习惯在民法渊源中具有一定的意义。例如，1951年最高人民法院西南分院《关于赘婿要求继承岳父母财产问题的批复》中指出：如当地有习惯，而不违反政策精神者，则可酌情处理。《民法总则》第10条规定：“处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。”当然，习惯要成为民法渊源，并成为裁判的依据，其必须经过“合法性”判断，即不得违反法律的强制性规定和公序良俗。

1. 不违反法律的强制性规定。不论是作为具体裁判规则的习惯，还是用于填补法律漏洞的习惯，都应当与其他法律渊源保持一致性，而且其内容都不得违反法律的强制性规定。违反法律强制性规定的习惯不能作为漏洞填补的依据。例如，按照有的地方的习俗，“拜师学艺期间，马踩车压，生病死亡，师傅概不负责”[82]。此类习惯显然与我国现行法中雇主应当对雇员在执行工作任务中遭受的人身伤害承担赔偿责任且当事人不能约定免除人身伤害的赔偿责任的法律规则之间存在冲突。还有的地方的习俗规定，寡妇不得改嫁，这显然不符合《婚姻法》的规定，不得作为民法的渊源。

2. 不违反公序良俗。《民法总则》第10条规定习惯不得违背公序良俗。因为公序良俗是从民族共同的道德感和道德意识中抽象出来的，公序良俗在内涵上是由社会公共秩序、生活秩序以及社会全体成员所普遍认许和遵循的道德准则所构成的，它是中华民族传统美德的重要体现，也是维护社会安定有序的基础。习惯作为法律渊源，能够弥补法律规定的不足，使法律保持开放性，但如果习惯本身与法律规则和公序良俗相冲突，甚至与整个社会公认的伦理道德观念相冲突，将其引入法律渊源体系，则可能导致体系违反的现象，也会破坏现有的法秩序。因此，只有符合公序良俗原则和国家整个法治精神的习惯，才可以被承认为习惯法；反之，对于那些违背公序良俗，和一国整体法治精神相违背的习惯将不会被承认为习惯法。例如，个别地方的习惯不允许嫁出去的女儿享有继承权、允许买卖婚姻、对宗族械斗者予以奖励、对违反族规者实行肉体惩罚甚至加以杀害等，这些陈规陋习不仅不能成为法律渊源，而且应当被法律所禁止，因此，法官在适用这些习惯时，应当通过法律规定和“公序良俗”对其内容和效力进行审查。[83]

依据《民法总则》第10条，采纳“有法律依法律，无法律依习惯”的规则，也就是说，当存在具体法律规则时，应当优先适用该具体的法律规则，而不能直接适用习惯法；此处所说的“法律”是指具体的法律规则，而不包括法律的基本原则。只有不存在具体的法律规则时，法官才能考虑适用习惯法。

关于法理能否作为民法渊源的问题，值得探讨。法理实际上是法律上的道理，是形成某一国家全部法律或某一部门法律的基本精神和学理。法理可以有多方面的理解，它既可以包括对法律规则的解释，也包括自然法的规则，还包括学理的内容，所以，法理是一个广义上的概念。在许多国家，法理可以成为民法的渊源，例如，《瑞士民法典》第1条规定：“（1）凡依本法文字或释义有相应规定的任何法律问题，一律适用本法。（2）无法从本法得出相应规定时，法官应依据习惯法裁判；如无习惯法时，依据自己如作为立法者应提出的规则裁判。（3）在前款的情况下，法官应参酌公认的学理和实务惯例。”我国台湾地区“民法”第1条也规定：“民事，法律所未规定者，依习惯；无习惯者，依法理。”我国《民法总则》并没有

将法理规定为民法渊源，毕竟法理不具有行为规则和裁判规则的性质与功能，只不过是学者的见解而已。当然，在民事审判中，法官应当参考法理，尤其是应该把法理作为裁判说理的重要依据和内容，因为法理本身就是对社会生活与审判实践的经验总结。

第八节 民法的适用

一、民法的适用范围

民法的适用范围，是指民事法规在何时、何地、对何人发生法律效力。民法的适用范围，也是民法的效力范围。正确了解民事法律规范的适用范围，是准确适用民事法律规范的重要条件。从内容上看，民法的适用范围包括时间上的适用范围、空间上的适用范围和对人的适用范围。

（一）民法在时间上的适用范围

民法在时间上的适用范围，是指民事法律规范在时间上所具有的法律效力。具体来说包括两个方面：民法的生效和民法的失效。民事法律规范开始生效的时间通常有以下两种情况：一是自民事法律颁布之日起生效，二是民事法律通过并颁布以后经过一段时间再开始生效。一般来说，民法的效力自实施之日发生，至废止之日停止。我国《民法总则》第206条规定：“本法自2017年10月1日起施行。”采纳的就是此种做法。当然，法律规范何时开始实施，可以由法律规范本身规定，也可以由制定法律的机关以命令或决议予以规定。如果立法对法律规范效力的停止时期不加规定，应认为法律一直有效，直至法律明文废止或修改时才停止生效。也有少数法律规范在公布之时即规定了停止生效的日期。

民事法律规范对其实施前发生的民事关系有无溯及既往的效力，是民法在时间上效力的一个重要问题。法律是否溯及既往，是指新的法律颁布实施后，对它生效之前发生的事件和行为是否适用。如果适用，即具有溯及力；如果不适用，即不具有溯及力。[84]一般的原则是新法没有溯及既往的效力。法律不得溯及既往的根据在于：在法律尚未公布之前，人们只能按照旧的法律实施行为，而依据旧的法律所作出的任何行为都是合法的。如果在新的法律颁布以后，新的法律产生推翻人们依据旧的法律所实施的行为的效力，就会打破人们对依据法律而行为的后果的预期。所以，法律不溯及既往的原则，旨在提醒人们遵守法律。如果人们按照现行的法律去行为，由此形成的各种法律关系却被未来的法律所否定，也不利于社会关系的稳定和保障法律的权威性。[85]

当然，法律不溯及既往不是绝对的，在某些情况下，民事法规也可以作出有溯及力的规定，但需以有明文规定为限。最高人民法院《民法通则意见》第196条规定：“1987年1月1日以后受理的案件，如果民事行为发生在1987年以前，适用民事行为发生时的法律、政策，当时的法律、政策没有具体规定的，可以比照民法通则处理。”一般来说，在民事领域，例外情况下实行法律溯及既往原则，必须采取有利追溯原则，即这种溯及既往对各方当事人都是有利的，且不损害国家利益和社会公共利益。

（二）民法在空间上的适用范围

民法在空间上的适用范围，是指民事法律规范在地域上所具有的效力。任何国家都是根据主权、领土完整和法制统一的原则，来确定各种法律、法规的空间效力范围的。空间效力一般可以分为域内效力和域外效力。《民法总则》第12条规定：“中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。”该条对我国民事法律在空间上的适用范围作出了规定。

所谓域内效力，是指一国的法律效力可以及于该国管辖的全部领域。根据《民法总则》第12条的规定，在我国领域内的民事活动，除法律另有规定外，都适用我国的法律。因此，就民事领域而言，我国民事法律规范的效力及于我国主权管辖的全部领域，但在确定某一个具体民事法律法规的效力时，由于制定、颁布民事法规的机关不同，民事法规适用的空间范围也不相同。这大体上有两种情况：（1）凡属全国人民

代表大会及其常务委员会、国务院及其所属各委、部、局、署、办等中央机关制定并颁布的民事法规，适用于中华人民共和国的领土、领空、领海，以及根据国际法、国际惯例应当视为我国领域的一切领域，例如我国驻外使馆，我国航行或停泊于境外的船舶、飞机等。（2）凡属地方各级立法机关根据各自的权限所颁布的民事法规，只在各该立法机关管辖区域内发生效力。

所谓域外效力，是指法律在其制定国管辖领域以外的效力。[86]在现代社会，法律一般不能当然产生域外效力，但是随着国际交往的发展，为保护国家和公民、法人的利益，也可以在例外情况下规定域外效力。例如，《海洋环境保护法》第2条第3款规定：“在中华人民共和国管辖海域以外，造成中华人民共和国管辖海域污染的，也适用本法。”

（三）民法对人的适用范围

民法对人的适用范围，就是民事法律规范对于哪些人具有法律效力。一国法律的对人效力，存在两种不同的理论：一是属人主义，不论其处于国内或国外，只要该人具有本国国籍，属本国国民即适用本国的法律，不论其所在何处均可适用。[87]二是属地主义，即以领土主权为原则，以地域为标准，确定法律对人的拘束力。凡是居住在本国领土之内的人，无论其国籍属于本国还是外国，均受本国法律的管辖。[88]从《民法总则》第12条规定来看，其对属地主义作出了规定，但没有对属人主义作出规定。

本书认为，民法应当为属人主义预留空间。民法对人的适用范围主要有以下几种不同的情况：（1）我国民法对居住在中国境内的中国公民或设立在中国境内的中国法人，具有法律效力。中国公民、中国法人在中国领域内一律适用中国法律。（2）我国民法对居留在我国境内的外国人、无国籍人和经我国政府准许设立在中国境内的外国法人，原则上具有法律效力。（3）居留在外国的我国公民，原则上应适用所在国的民法，而不适用我国民法。例如，我国《民法通则》第143条规定：“中华人民共和国公民定居国外的，他的民事行为能力可以适用定居国法律。”这尽管是对确定行为能力的法律所作的规定，但也包含了一种含义，即居住在国外的中国公民，其从事民事活动应当适用所在国的法律。但是，依照我国民法的特别规定和我国缔结或参加的国际条约、双边协定以及我国认可的国际惯例，应当适用我国民法的，仍然适用我国民法。

二、民法适用的基本原则

法的适用，有广义和狭义之分。广义的法的适用是指运用法律规范调整社会关系。[89]它包括法的遵守和司法适用。而狭义的法的适用，就是司法适用，即法院和仲裁机构依据法定职权和法定程序行使司法权、适用法律处理具体案件的专门活动。[90]本书采狭义的法的适用的概念。

由于民法法源的多元化，民法的适用应当遵循一定的原则，以便准确适用法律。具体说来，民法的适用应当遵循以下基本原则：

（一）上位法优先于下位法原则

所谓上位法优先于下位法原则，是指在效力较高的规范性法律文件与效力较低的规范性法律文件相冲突的情况下，应当适用效力较高的规范性法律文件。法谚有云：“上位法优于下位法。”（Lex superior derogate legi inferiori）该原则主要适用于位阶具有高低之分的规范。上位法和下位法的界定，主要是从三个方面来确定的：第一，从法源或法律的位阶而言，如果一个较低的规范来源于一个较高的规范，或者一个较低的规范是根据一个较高的规范而制定的，则前者可称为下位法，后者可称为上位法。第二，从制定机关来看，如果将数个法律、法规和规范性文件相比较，某个规范性文件的制定机关的地位高于另一个规范性文件的制定机关，那么处于高位阶的机关制定的规范性文件在效力上称为上位法，反之则称为下位法。第三，从立法等级效力来看，某一个位阶高的法律的效力优于位阶低的法律的效力，则前者被称为上位法，后者被称为下位法。

上位法优先于下位法原则在我国的具体表现形式是：第一，宪法具有最高的效力。我国《立法法》第87条规定：“宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。”第二，法律的效力低于宪法但高于其他任何法规和规范性文件。《立法法》第88条规定：“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。”第三，行政法规的效力高于地方性法规、规章。国务院制定的行政法规的效力高于各个部委和地方政府制定的规章，以及地方人民代表大会制定的地方性法规。第四，地方性法规的效力高于地方政府制定的规章。《立法法》第89条规定：“地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章。省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的设区的市、自治州的人民政府制定的规章。”

在民法的适用中，法官首先应当努力寻找上位法，如果上位法与下位法之间有冲突，那么应当优先适用上位法。但是，如果上位法规定的原则较为抽象，下位法的规定对上位法作了补充和细化，两者之间又不发生冲突和矛盾，则可以同时适用上位法和下位法。

（二）新法优先于旧法原则

法谚有云：“后法优于前法。”（*Lex posterior derogate priori*）这就是新法优先于旧法的原则，即同一事项已有新法公布施行时，旧法当然废止。[91]我国《立法法》第92条也规定：“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章……新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。”该原则主要适用于同一位阶的规范之间，也就是说针对两个具有同等级别的法律时所适用的规则。[92]当然，如果在新普通法中明文规定修改或废止特别法，则新普通法优于特别法。[93]新法优先于旧法原则适用于两种情况：一是如果新法颁布后，旧法已经被废止，则自然应当适用新法；二是新法颁布以后，旧法没有被废止，则旧法继续有效，但如果两部法律所涉及的内容相同或相似，则应当适用新法。

《民法总则》生效后，需要妥当处理其与《民法通则》及其他民事单行法之间的关系。关于《民法总则》与《民法通则》之间的关系，原则上应当按照新法优先于旧法的原则，即凡是《民法通则》与《民法总则》规定不一致的，都要适用《民法总则》。就《民法总则》与其他民事单行法之间的关系，如与知识产权法等法律的关系，原则上，凡是民事单行法已经作出特别规定的，尤其是在《民法总则》中设置了引致条款的，则应当通过该引致条款，适用民事单行法的规定。但如果《民法总则》所作出的规定改变了民事单行法的规则，则应当适用《民法总则》的规定。例如，《民法总则》第123条扩张了知识产权客体的范围，则在确定应受保护的知识产权客体的范围时，应当适用《民法总则》的规定。

（三）特别法优先于普通法原则

在法理上，根据法律的适用范围有无限制，法律可以分为普通法和特别法。民事普通法，是指适用于全国领域、规定一般事项，并且无适用的时间限制的民事法律。民事特别法，是指适用于特定区域、规定特定的事项，或在适用时间上有限制的民事法律。在具有相同等级效力的法律之间，特别法应当优先于普通法而适用。这也就是法谚所说的：“特别法优于普通法”（*Lex specialis derogate legi generali*）。对此，我国《立法法》第92条规定：“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定……”按照这一规则，法院在适用民事法律规范时，对同一事项在确定可适用的法律规则时，应当考虑如下几点：第一，在不同的法律之间，民事特别法优先于民事普通法而适用。例如，有关公司法人的取得条件问题，应当先适用《公司法》的规定，在《公司法》没有规定时才适用《民法通则》关于法人制度的规定。第二，关于总则和分则之间的关系，如果两者规定的是同一事项，原则上分则的规定应当优先于总则的规定。例如，有关买卖合同中的违约责任的确定，应当优先适用分则中关于买卖合同的规定，然后才能适用总则关于违约责任的规定。第三，如果在同一个条款中包含了一般规则和特别规则时，特别规则要优先于一般规则适用。第四，例外规定优先于原则规定原则，就是指对于特定事项，如果有例外规定，就应当适用例外规定，而排除原则规定的适用。

《民法总则》第11条规定：“其他法律对民事关系有特别规定的，依照其规定。”这就明确确认了特别法优先于普通法的原则。具体来说，一是民事特别法优先于民法总则。民法总则虽然要统辖各个单行民事法律，但是在法律适用上，民事特别法的规定属于特别规定，应当优先适用。例如，知识产权的相关问题应当先适用《著作权法》《专利法》《商标法》等法律的规定，在上述法律没有就某事项作出规定时，才适用民法总则的规定。二是商事特别法应当优先于民法总则。我国已经颁布了《公司法》《票据法》《证券法》等一系列商事特别法，与《民法总则》相比，其规定也属于特别规定，应当优先适用。

就民法典总则与民法典分则的关系而言，其也应当属于民事普通法与民事特别法的关系。民法典总则在性质上属于民事普通法，而民法典分则在性质上即属于民事特别法，因此，在民法典分则作出特别规定的情形下，应当先适用该特别规则，而不能直接适用民法典总则的规则，只有民法典分则未作出规定的情形下，才能适用民法典总则的规则。还需要指出，同一法律内部也可以根据法律规范的内容而区分民事普通法和民事特别法。例如，《民法总则》第18条第1款规定：“成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。”这一条款系一般规定，应为民事普通法。该法第18条第2款规定：“十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”这一条款系特殊规定，应为民事特别法。

需要指出的是，就特别法和普通法的关系而言，如果新普通法已经修改了旧特别法，则不应当适用特别法优先于普通法的规则，而应当适用新法优先于旧法的规则。例如，《民法总则》的多个条款都修改了《合同法》的规则，此时，就应当适用《民法总则》的规则，而不应当再适用《合同法》的规则。

（四）强行法优先于任意法

法律规范大体可分为任意法规范和强行法规范两种。所谓任意法规范，是指当事人可以通过约定排除其适用的规范，任意法规范允许当事人在法律规定的范围内自由作出约定。当事人之间的意思表示可以具有优先于任意法规范而适用的效力。债法中的规范大多是任意性的。

所谓强行法规范，是指当事人不能通过其约定加以改变的规范。强行法规范可分为强制性规定与禁止性规定两种：强制性规定，指命令当事人应为一定行为之法律规定。禁止性规定，指命令当事人不得为一定行为之法律规定。禁止性规定与强制性规定是不一样的。[94]根据史尚宽先生的观点，“令行”，则为“强制规定”；“禁止”则为“禁止规定”，与其对应的是任意法（任意性规定）。[95]此种区分在法律上的意义主要在于，违反禁止性规定通常应宣告无效；如果违反强制性规定，可以通过适当方式予以弥补，不必宣告无效，但如果不能弥补，应宣告无效。《民法总则》第153条第1款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。”该条对法律、行政法规的强制性规定作出了规范，法律、行政法规的强制性规定在性质上属于强行法，其在效力上优于任意法，因此，对某一事项，如果强行法已经作出规定的，任意法不得再发挥作用，法官也可以直接援引强行法的规定对案件作出裁判。但如果强行法、任意法分别规定的是不同的事项，则不存在两种规范冲突的问题，也自然不存在何者优先的问题。

思考题

1. 试述民法的调整对象。
3. 比较实质意义上的民法和形式意义上的民法。
4. 试述民法与宪法的关系。
5. 简述民法与商法的关系。
6. 简述习惯在民法中的地位。
7. 如何理解现代民法的发展趋势。

8. 简述民法适用范围的含义及分类。

9. 简述民法适用的基本原则。

[1] 龙卫球. 民法总论. 北京: 中国法制出版社, 2001: 13.

[2] 穗积陈重指出: “‘民法’一语, 自箕作麟祥博士以其翻译法语 ‘droit civil’ 以来, 开始被普遍使用, 所以我们原以为这是箕作博士始创的译语。但是当就此问题请教箕作博士时, 博士解释说, 这是采用了津田先生《泰西国法论》说载录之单词, 不是自己的发明。于是又去请教津田先生, 先生回答说, 这个单词是他作为荷兰语 ‘Burgerlyk Regt’ 的译语而新创的。” 穗积陈重. 法窗夜话. 东京: 河山书房。转引自叶孝信主编. 中国民法史. 上海: 上海人民出版社, 1993: 2.

[3] 张生. 民国初期民法的近代化. 北京: 中国政法大学出版社, 2002: 4.

[4] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 15.

[5] 艾伦·沃森. 民法法系的演变及形成. 李静冰译. 北京: 中国政法大学出版社, 1992: 191.

[6] 李建国. 关于《中华人民共和国民法总则（草案）》的说明（2017年3月8日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上的讲话）。

[7] 李建国. 关于《中华人民共和国民法总则（草案）》的说明（2017年3月8日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上的讲话）。

[8] 卡尔·拉伦茨. 德国民法通论. 上册. 王晓晔等译. 北京: 法律出版社, 2003: 1.

[9] 陈杭雄. 民法总则新论. 台北: 三民书局, 1982: 9.

[10] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 11.

[11] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 12.

[12] 江平. 市场经济和意思自治. 中国法学, 1993 (6) .

[13] 迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 14.

[14] 谢怀栻. 外国民商法精要. 北京: 法律出版社, 2002: 51-52.

[15] 梁慧星. 民法总论. 北京: 法律出版社, 1996: 29.

[16] 刘海年等编. 依法治国, 建设社会主义法治国家. 北京: 中国法制出版社, 1996: 25.

[17] 卡尔·拉伦茨. 德国民法通论. 上册. 王晓晔等译. 北京: 法律出版社, 2003: 8.

[18] 马克思恩格斯选集. 3版. 第4卷. 北京: 人民出版社, 2012: 611.

[19] 马克思恩格斯选集. 3版. 第2卷. 北京: 人民出版社, 2012: 127-128.

[20] 我妻荣. 物权法. 东京: 岩波书店, 1995: 2.

[21] 邓正来. 国家与社会. 成都: 四川人民出版社, 1997: 25.

[22] 黑格尔. 法哲学原理. 范扬, 张企泰译. 北京: 商务印书馆, 1961: 174.

[23] 萧功秦. 市民社会与中国现代化的三重障碍. (香港) 中国社会科学季刊, 1993 (10) .

[24] 胡宝海, 王晓君. 民法上的人. 北京: 中国社会科学出版社, 1999: 3.

[25] 沈宗灵主编. 法理学. 北京: 高等教育出版社, 1994: 332.

[26] 郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 15.

[27] 徐国栋. “人身关系”流变考（上）. 法学, 2002 (6) .

- [28]杨立新. 人身权法论. 北京: 人民法院出版社, 2002: 63.
- [29]张俊浩主编. 民法学原理. 北京: 中国政法大学出版社, 1991: 138.
- [30]陈民. 论人格权. 法律评论, 第28卷第8期.
- [31]孟德斯鸠. 论法的精神. 下册. 张雁深译. 北京: 商务印书馆, 1997: 190.
- [32]张文显. 法治与国家治理现代化. 中国法学, 2014 (4) .
- [33]宋豫主编. 国家干预与家庭自治: 现代家庭立法发展方向研究. 郑州: 河南人民出版社, 2011: 11.
- [34]谢怀栻. 外国民商法精要. 3版. 北京: 法律出版社, 2014: 138-139.
- [35]夏吟兰. 论婚姻家庭法在民法典体系中的相对独立性. 法学论坛, 2017 (4) .
- [36]谢怀栻. 外国民商法精要. 3版. 北京: 法律出版社, 2014: 138-139.
- [37]朱塞佩·格罗索. 罗马法史. 黄风译. 北京: 中国政法大学出版社, 1994: 4.
- [38]吴汉东. 罗马法的传播与法律科学的繁荣. 法商研究, 1994 (6) .
- [39]郭明瑞, 房绍坤, 唐广良. 民商法原理 (一). 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 31.
- [40]梁慧星. 从近代民法到现代民法. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第7卷, 北京: 法律出版社, 1997.
- [41]我妻荣. 债权在近代法中的优越地位. 王书江等译. 北京: 中国大百科全书出版社, 1999: 9.
- [42]星野英一. 私法中的人. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第8卷. 北京: 法律出版社, 1997: 156.
- [43]Jean Limpeus. International Encyclopedia of Comparative Law. vol. IX. Torts. Chapter 2. Liability for Ones Own Act. J. C. B Mohr (Paul Siebeck, Tübingen), 1975.
- [44]Denis Tallon. International Encyclopedia of Comparative Law. vol. XI. Torts. Introduction. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck, Tübingen), 1974. pp. 71-72.
- [45]尹田. 法国现代合同法. 北京: 法律出版社, 1995: 24.
- [46]拉德布鲁赫. 法学导论. 米健译. 北京: 中国大百科全书出版社, 1997: 66.
- [47]北川善太郎. 关于最近之未来的法律模型. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第6卷. 北京: 法律出版社, 1997: 286-287.
- [48]施启扬. 民法总则. 修订8版. 北京: 中国法制出版社, 2010: 19.
- [49]施启扬. 民法总则. 修订8版. 北京: 中国法制出版社, 2010: 20.
- [50]邱聪智. 庞德民事归责理论之评介. 台大法学论丛, 第11卷第2期.
- [51]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 362-363.
- [52]星野英一. 私法中的人. 王闯译. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第8卷. 北京: 法律出版社, 1997: 185-186.
- [53]Basil S. Marksini. Protecting Privacy. Oxford University Press, 1999. pp. 36-37.
- [54]刘保玉, 郭栋. 权利外观保护理论及其在我国民法典中的设计. 法律科学, 2012 (5) .
- [55]海因·克茨. 欧洲合同法. 上卷. 周忠海等译. 北京: 法律出版社, 2001: 114.
- [56]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 44-45.
- [57]赵万一. 论民法的商法化与商法的民法化. 法学论坛, 2005 (4) .
- [58]谢怀栻. 外国民商法精要. 3版. 北京: 法律出版社, 2014: 57-58.

[59]李建国.关于《中华人民共和国民法总则(草案)》的说明(2017年3月8日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上的讲话).

[60]胡康生.学习宪法 忠于宪法 维护宪法权威.中国人大,2009(5).

[61]韩大元.由《物权法(草案)》的争论想到的若干宪法问题.法学,2006(3).

[62]梁启超.政论选.北京:新华出版社,1994:26.

[63]叶海波.“根据宪法,制定本法”的规范内涵.法学家,2013(5).

[64]苏永钦.合宪性控制的理论与实际.台北:月旦出版公司,1994:80.

[65]赵万一.从民法与宪法关系的视角谈我国民法典制订的基本理念和制度架构.中国法学,2006(1).

[66]王泽鉴.民法学说与判例研究.第2册.台北:自版,1996:218页以下;孙森焱.民法债编总论(上).台北:自版,1979:210.

[67]马穆托夫.调整经济关系的各种法律主张.苏维埃国家与法,1979(5):30.

[68]以下观点请参见王家福等.中国经济法诸论.北京:法律出版社,1987.

[69]有关经济行政法的观点,参见梁慧星,王利明.经济法的理论问题.北京:中国政法大学出版社,1986.

[70]郑尚元.社会法的定位和未来.中国法学,2003(5).

[71]郑尚元.社会法的定位和未来.中国法学,2003(5).

[72]林嘉.社会保障法的理念、实践与创新.北京:中国人民大学出版社,2002:23.

[73]马克思恩格斯全集,第1卷.北京:人民出版社,1956:178.

[74]张卫平.民事诉讼法学方法论.法商研究,2016(2).

[75]张卫平.民事诉讼法学方法论.法商研究,2016(2).

[76]魏振瀛主编.民法.4版.北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2010:14.

[77]梁慧星.民法总论.3版.北京:法律出版社,2007:26页以下;龙卫球.民法总论.北京:中国法制出版社,2001:38页以下;马俊驹,余延满.民法原论.3版.北京:法律出版社,2007:29.

[78]例如,《侵权责任法》第58条规定:“患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;(三)伪造、篡改或者销毁病历资料。”依据该条规定,如果因医疗机构违反行政规章的规定造成患者损害的,则推定医疗机构有过错。因此,在此种情形下认定医疗机构的过错时,法官即可以依据行政规章的规定作出裁判。

[79]《关于案例指导工作的规定》第2条规定:“本规定所称指导性案例,是指裁判已经发生法律效力,并符合以下条件的案例:(一)社会广泛关注的;(二)法律规定比较原则的;(三)具有典型性的;(四)疑难复杂或者新类型的;(五)其他具有指导作用的案例。”

[80]黄进.国际私法.北京:法律出版社,1999:82.

[81]一个国家所参加的国际条约是否能够具有国内法的效力,对此有三种不同的观点:一是纳入说,即认为国际条约直接具有国内法的效力,不需要经过立法程序即可在国内直接适用;二是转化说,即认为国际条约必须首先通过立法程序纳入国内法,成为国内法的组成部分才能适用;三是折中说,即认为应当根据不同情况,确定国际条约是否可以直接发生国内法的效力,或者必须经过国内立法机关的特别程序才

能适用。本书赞成第三种观点。

[82]汤建国, 高其才主编. 习惯在民事审判中的运用. 北京: 人民法院出版社, 2008: 288.

[83]广东省高级人民法院民一庭, 中山大学法学院. 民间习惯在我国审判中运用的调查报告. 法律适用, 2008 (5) .

[84]公丕祥主编. 法理学. 上海: 复旦大学出版社, 2002: 384.

[85]高鸿钧. 现代法治的困境及其出路. 法学研究, 2003 (2) .

[86]公丕祥. 法理学. 上海: 复旦大学出版社, 2002: 383.

[87]郑玉波. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 27.

[88]郑玉波. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 27.

[89]梁慧星. 民法总论. 3版. 北京: 法律出版社, 2007: 274.

[90]孙国华, 朱景文主编. 法理学. 北京: 法律出版社, 1999: 315.

[91]郑玉波译解. 法谚 (一). 台北: 三民书局, 1984: 8.

[92]郑玉波. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 27.

[93]史尚宽. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 16.

[94]王泽鉴. 民法实例研习. 民法总则. 台北: 三民书局, 1996: 234.

[95]史尚宽. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 329-330.

第二章 民法的基本原则

“购买黄沙纠纷案”: 甲、乙之间订立了一份购买黄沙合同, 合同约定因建造两栋大楼急需黄沙, 甲向乙购买黄沙30车, 每吨价格300元。合同订立后, 黄沙价格开始上涨, 乙不愿如数供货, 在交货期到来后, 乙安排二辆“130”型货车, 装了2车黄沙 (每车装载2吨), 送到甲处, 并要求以“130”型车为标准, 计算交货数量。甲认为, 尽管合同规定交货数量为30车, 但应以“东风牌”大卡车作为计算标准, 每车装载4吨, 共120吨。为此, 双方发生争议, 协商未果, 甲遂向法院起诉, 要求乙承担违约责任。

简要评析: 诚实信用原则是民法的基本原则, 应当适用于民法的各个部分, 该案属于合同纠纷, 从合同订立前到合同履行完毕后, 当事人都应当遵循诚实信用原则履行自己的义务。在该案中, 乙的行为显然有违诚实信用原则的要求: 一方面, 乙在订约以后, 鉴于黄沙价格已经上涨, 曾要求甲减少供货数量, 当此要求被拒绝以后, 乙便以合同没有规定明确的计算标准为由, 以“130”型货车送货, 实际上, 乙的目的在于减少交货数量。另一方面, 乙明知按当地的交易习惯, 以车为计量单位的, 车的含义通常是指“东风牌”大卡车。乙为了减少交货, 故意以“130”型车送货, 该行为显然有违诚实信用原则。

第一节 民法基本原则概述

民法的基本原则是民法的主旨和基本准则, 是制定、解释、适用和研究民法的出发点, 它贯穿于整个民法制度和规范之中, 是民法的本质和特征的集中体现, 也是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断标准。民法的基本原则不直接涉及当事人的具体权利、义务。从规范的性质来看, 民法上关于基本原则的规范是强行性规范, 不允许当事人排除适用。通过基本原则的适用, 法官享有了一定的自由裁量权, 有助于克服审判的机械性, 并进行创造性司法活动。当然, 民法有具体规定时首先应当适用具体规定, 只

在没有具体规定时，才可以适用民法关于基本原则的规定作出裁判。

在民事案件中，法官不得以法无明文规定而拒绝裁判，但法官在裁判案件中，有具体规定的，应当援引具体规定，而不应援引基本原则裁判。法官的职责在于“你给我事实，我给你法律”，此处所说的法律主要是指具体的法律规则，而非法律的基本原则。从我国司法实践来看，有的法官在能够找到具体的法律规则时，并不适用该具体规则，而直接援引抽象的法律原则裁判，采取此种做法主要是为了避免出现法律适用的错误，因为援引具体法律规则裁判可能会发生错误，但法律原则具有较高的抽象性和普遍适用性，而且存在较大解释空间，因而，法官在援引基本原则裁判时，可以很容易地连接案件裁判的大、小前提，从而在形式上实现“依法裁判”。因此，援引法律基本原则裁判，似乎任何时候都不会有错。但这种做法给予法官过大的自由裁量权，因为基本原则的内涵十分宽泛，较为抽象，几乎可以适用于各类纠纷。在司法裁判过程中，法官如果抛开具体规定而直接援引法律原则裁判，本身就违背了立法目的，很难说是真正地依法裁判；尤其是援引基本原则裁判难以保障法官依法、公正地作出裁判，有效地限制法官的自由裁量权，所以，应当严格限制法官在裁判中援引基本原则。本书认为，法官在裁判中援引基本原则应当注意如下几点：

第一，有具体规则必须适用具体规则，而不能适用基本原则。因为在法律就某事项作出具体规定时，表明立法对该事项已经做了更为精细的安排，此时，法官直接援引基本原则裁判，本身就违背了立法的目的；而且法官援引的规定越具体、与案件联系越紧密，对于法官的自由裁量的限制就越多，案件的裁判就越精确。尤其应当看到，在司法三段论中，作为案件裁判大前提的法律规范应当包含构成要件和法律效果两个部分，但基本原则本身既不包含具体的构成要件，也不包含具体的法律效果，通常难以作为案件裁判的大前提予以适用。

第二，基本原则可以与具体的规则结合起来适用。由于基本原则都体现了立法的价值和精神，所以，基本原则可以和具体的规则结合起来，从而可以用于解释具体规则适用的合理性。例如，在确定合同效力时，公序良俗原则和违反公序良俗无效的规则可以结合适用。但应当指出的是，在同时适用基本原则与具体规则的情况下，基本原则不能直接作为裁判依据，其只能作为裁判说理的依据，法官裁判只应援引具体的法律规则。

第三，在法律规定不明确时，基本原则可以用于提供解释指引。基本原则展现了立法者的价值判断，能够为法官裁判案件提供具体的价值指引。因此，在具体的法律规则存在两种或者两种以上合理的解释时，基本原则可以为法官进行解释的选择提供价值指引。

第四，在存在法律漏洞时，基本原则可以用于填补法律漏洞。在存在明显漏洞的情况下，争议的案件没有具体的规则可供援引，法官又不能拒绝裁判，此时，法官应当以基本原则作为填补法律漏洞的依据。从大陆法系国家的法律发展来看，正是在法官运用基本原则解释法律中发展出了缔约过失责任、情事变更原则、一般人格权、附保护第三人效力的契约等制度，从而使法律与社会生活相协调^[1]，使古老的民法焕发了新的生机。当然，由于基本原则的内涵十分宽泛、抽象，在各种法律漏洞填补方法中，其应当属于兜底性的法律漏洞填补方法。

第二节 民事权益受法律保护原则

一、民事权益受法律保护原则的内涵

《民法总则》第3条规定：“民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。”本条确立了民事权益受法律保护的原则。从我国《民法总则》的规定来看，民事权利受法律保护原则包括如下几方面内涵：

第一，民法主要保护人身、财产等权益。《民法总则》系统、全面地规定了民事主体所享有的各项人身、财产权益。从保护公民财产权利的角度来看，《民法总则》首次在法律上使用了“平等”保护民事主体物权的表述，这是对《物权法》的重大完善。该法对知识产权的客体进行了详尽的列举，扩张了知识产权的保护范围，进一步强化了对知识产权的保护。该法强化了对英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉的保护，有助于弘扬公德、维护良好的社会风尚。当然，从《民法总则》的规定来看，其所保护的民事权益范围虽然非常宽泛，但并非所有的权益都受到民法的保护，一些公法上的权利，如劳动权、受教育权，主要受公法保护，民法保护的主要是私权，其中以人身、财产权益为基本内容。

第二，民法不仅保护权利，而且保护利益。也就是说，不论是权利还是利益，都受到法律保护。我国《民法总则》第3条采用“其他合法权益”这一表述，这就意味着，不论是权利还是利益，都受到法律保护。这为将来对新型民事权益提供保护预留了空间，保持了民法总则规则的开放性。从我国《民法总则》的规定来看，其多个条款都使用了“权益”的表述，如《民法总则》第126条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。”依据该条规定，不论是权利还是利益，都受到法律保护。这不仅与保护民事权益的基本原则相对应，也保持了民法保护权益范围的开放性。任何组织和个人都不得非法侵害他人的合法权益，也不得非法干预权利人行使权利。例如，任何人不得非法查封、扣押、没收公民的合法财产。

第三，对新型民事权益进行保护。在民事权益受法律保护原则的指导下，我国《民法总则》强化了对新型民事权益的保护，体现了当代中国的时代特征，回应了当今社会的现实需求。例如，该法首次正式确认隐私权，有利于强化对隐私的保护。再如，针对互联网和大数据等技术发展带来的侵害个人信息现象，《民法总则》规定了个人信息的保护规则，维护了个人的人格尊严，必将有力遏制各种“人肉搜索”、非法侵入他人网络账户、贩卖个人信息、网络电信诈骗等现象。

第四，在民事权益受到侵害时，民法主要通过民事责任对权利人进行救济。在权利人的权利受到侵犯时，权利人可以依法请求有关行政机关给予保护，也可以诉请人民法院或仲裁机构予以判决或仲裁。

民事权益受法律保护是民法最重要的原则，之所以要将该原则作为民法的首要原则[2]，主要原因在于：一方面，民法是权利法。民法总则被称为民事权利宣言书，正如英国学者彼得·斯坦所指出的：“权利的存在和得到保护的度，只有诉诸民法和刑法的一般规则才能得到保障。”[3]另一方面，近代民法典的体系，就是权利体系。[4]“民法是作为权利的体系而被构建的”[5]，民法总则的体系是以私权为“中心轴”而展开的，其所规定的民事主体（自然人、法人、非法人组织）是民事权利的享有者和民事义务的承担者，各项民事权利是私权完整的内容和结构，民事法律行为是行使私权而从事的行为，而民事责任既是因侵害私权而产生的法律后果，也是保障私权实现的强有力手段。在构建了完整的民事权利体系之后，《民法总则》为分则的制定也奠定了基础，因为民法典分则实际上是按照物权、合同债权、亲属权、继承权、人格权以及因侵害民事权利而产生的侵权责任等内容展开的。《民法总则》将系统、全面地确认和保护各项民事权利，构建民事权利体系，弘扬私法自治，强化对人格尊严价值的保障。因此，对权利的保护是整个民法的中心任务。

二、民事权益受法律保护原则的意义

我国立法历来重视对个人的人身和财产权益进行保护。例如，《民法通则》第5条规定：“公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。”该条对个人民事权益受法律保护的原则作出了规定。除《民法通则》外，《侵权责任法》也对个人的权益保护作出了规定，该法第2条规定：“侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。”在总结上述立法经验的基础上，《民法总则》第3条对民事主体合法权益受法律保护的原则作出了规定，而且从该条所处的位置来看，其仅次于“立法目的”和“

调整对象”，应当属于最为重要的民法基本原则。

《民法总则》继续采纳《民法通则》的经验，专设“民事权利”一章，集中地确认和宣示自然人、法人所享有的各项民事权利，充分地彰显民法对私权保障的功能。《民法总则》在全面保障私权方面呈现出许多亮点，在民事权利保护方面，不仅充分体现了时代性，而且保持了民事权益保护范围的开放性。也正是因为这一原因，《民法总则》也被称为“民事权利的宣言书”。《民法总则》全面确认和保护民事权益的主要意义在于：

第一，保障私权有利于更好地保障最广大人民群众的根本利益，保护人民群众对美好生活的向往，充分实现人民的福祉，促进个人的全面发展。在广大人民群众物质生活条件得到极大改善、个人财产不断增加的情况下，对财产安全的保护显得更为重要。同时，《民法总则》强化对个人人身权益的保护，也有利于保护个人的人格尊严。

第二，奠定法治社会的基础。法治内在地包含着“规范公权、保障私权”的价值目标，法律的主要功能在于确认权利、分配权利、保障权利、救济权利。因此，法律需要规定权利的范围，而权利实现本身也是法治价值的重要体现。[6]一方面，保障私权的功能主要是由民法典来实现的，只有通过民法典全面确认和保护私权，才能为法治社会建设奠定基础。另一方面，私权制约着公权的范围，规定私权的范围有利于明确公权的边界，进而有利于防止政府对私权的不当干预，有力地规范公权，并使民事主体在其私权受到侵害的情况下能够得到充分地救济。

第三，保障私权有利于全面维护个人的行为自由。保障私权一方面需要通过民法典等一系列法律规范全面确认个人所享有的各项人身权益和财产权益，而且应当系统规定私权的救济机制，全面保障私权。同时，保障私权还意味着要尊重个人的“私法自治”，其本质上是尊重个人的自由和自主，即充分发挥个人在现代社会治理中的作用。与公权力“法无明文规定不可为”相反，私权的行使是“法无禁止即可为”，即只要是法律没有明文规定禁止个人进入的领域，按照私法自治原则，个人均有权进入。这既有利于节约国家治理成本，也有利于增加社会活力，激发主体的创造力。

第三节 平等原则

一、平等原则的概念和意义

所谓平等原则，是指民事主体在法律地位上是平等的，其合法权益应当受到法律平等保护。我国《民法总则》第4条规定：“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。”民事主体地位平等原则是我国民法将平等主体之间的财产关系和人身关系作为其调整对象的必然体现。民法的平等原则集中反映了民法所调整的社会关系的本质特征，也是全部民事法律制度的基础。

从比较法上来看，由于平等原则通常是在宪法中规定的，因而，有的国家民法典并没有直接对平等原则作出规定，但也有国家在民法典中对平等原则作出了规定。例如，《法国民法典》第8条规定：“所有法国人均享有民事权利。”该条实际上确立了民法的平等原则。有的国家民法典并没有明确规定平等原则，但相关规则也被解释为平等原则。例如《德国民法典》第1条规定：“人的权利能力始于出生完成之时。”该条虽然规定的自然人权利能力开始的时间，但其宣示了一切自然人从出生完成之时均具有权利能力，因此，一般认为，其也在法律上确认了权利能力一律平等的重要原则。[7]我国立法历来将平等原则作为一项重要的民法基本原则。例如，《民法通则》第3条规定：“当事人在民事活动中的地位平等。”《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”《物权法》第4条规定：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。”以上法律均将平等原则作为重要的基本原则，这也是从民法调整对象出发所产生的一项基本原则。在民法上，采纳该原则的主要意义在于：

第一，集中体现了民法的调整对象和调整方法的特点，表现了民法的基本价值理念。因为民法的调整对象是平等主体之间的财产关系和人身关系，所以必须运用平等原则来确定民法调整社会关系的方法和特点，以及在发生了民事违法行为以后的责任方式。

第二，充分反映了市场经济的本质要求，并构建市场经济秩序的基础。市场经济最本质的特征就体现在主体之间的平等性上。在市场经济社会，参与市场的各个主体作为合理的人，为了实现其利益的最大化，就不可避免地存在利益的冲突与矛盾，而且在单个主体利益与社会公共利益之间又存在冲突和矛盾，为此必须明确各类市场主体的平等地位。[8]因为交易天然地要求交易双方的地位是平等的，在利益上是等价的，否则就不可能产生公平的竞争，从而也不可能形成有序的市场经济秩序。

第三，体现了现代法治的基本精神，有助于建设社会主义的政治文明。现代法治社会以贯彻“平等原则”为特征，而公民在法律面前的平等，必然要求具体体现为民法所确认的主体的平等地位和责任自负原则、造成损害应根据损益相当的准则进行赔偿的原则、对公民和法人的合法权益平等保护的原则等。平等原则最本质的内涵就是人格的平等，它是对封建等级制度的否定，也是对宗法制度下人与人的依附关系的否定。平等原则构建了市场经济的基础，在政治层面上也是最为根本的原则，正是在平等的基础上才产生了近现代社会的各项民主制度。切实遵行民法的平等原则，才能够真正消除封建残余和特权思想，建立社会主义政治文明。

第四，有利于强化对财产的平等保护，促进社会财富的增长。平等原则不仅要强调对公有财产的保护，而且要求将对个人财产所有权的保护置于相当重要的位置。对国内财产进行一体化保护，有利于实现“有恒产者有恒心”所体现的一种利益期待，鼓励人们创造社会财富，满足社会投资的需求，实现社会财富的增长和经济的繁荣。

二、平等原则的内容

平等原则主要包括如下内容：

第一，人格的平等。人格平等就是在法律上不分尊卑贵贱、财富多寡、种族差异、性别差异，而一律认为人与人的抽象人格是平等的。我国《民法总则》第14条明确规定：“自然人的民事权利能力一律平等。”民事权利能力与生俱来，为公民终身享有，并且公民的民事权利能力在范围上是平等的。除法律特别规定的以外，任何单位和个人不得限制和剥夺公民的民事权利能力。

第二，在具体的法律关系中当事人的法律地位平等。尤其是在合同关系中，无论参与合同关系的当事人在事实上是否具有隶属关系或不平等的地位，在合同关系中当事人都是完全平等的。平等原则还表现在民事主体在民事法律关系的产生、变更和消灭上，必须平等协商，任何一方当事人不得将自己的意志强加给另一方当事人。

第三，对各类民事主体的平等对待，包括强势意义上的平等对待和弱势意义上的平等对待。所谓强势意义上的平等对待，是指尽可能避免对人进行分类，以对所有群体给予平等待遇。而弱势意义上的平等对待，是指针对不同情况的区别对待。[9]在法律上，这意味着凡被法律视为相同的人，都应当以法律所确定的方式来对待。[10]例如，合同法既确定了合同自由原则，又兼顾合同正义，而合同正义的实现就建立在弱势意义上的平等对待的基础上。

第四，在补救方法上，也要充分贯彻平等性。无论主体在所有制、经济实力等方面存在何种差异，当其权利受到侵害时，法律都给予一体保护。就民事权利保护而言，任何主体都不能比其他主体享有更多的特权，即便公有财产从政治层面上讲神圣不可侵犯，但在民法中它也应与私人财产受到同等的保护。从损害的角度看，应当按照实际损害给予救济，而不能因人而异。此外，在民法上，民事主体地位的平等性，决定了在民事责任方式上，应当贯彻损失填补原则，以弥补受害人的损失为宗旨，一般不能对加害人的行为施以类似于公法上的惩罚性措施。当然，在追究了民事责任以后，并不影响对违法者追究其他公法上的

责任，这两种责任并行不悖。

应该指出，民事主体在法律地位上的平等，不等于在实际的民事法律关系中，每个当事人所享有的具体的民事权利和承担的民事义务都是一样的。在具体的民事法律关系中，各个当事人根据法律和自身的意志，享有不同的权利和义务。

第四节 意思自治原则

一、意思自治原则的概念

意思自治也称为私法自治，是指民事主体依法享有在法定范围内广泛的行为自由，并可以根据自己的意志产生、变更、消灭民事法律关系。意思自治原则具体体现为合同自由、婚姻自由、家庭自治、遗嘱自由等民法的具体规则。从比较法上看，各国都十分重视保障个人的意思自治。例如，《法国民法典》第1134条规定：“依法订立的契约在当事人之间具有相当于法律的效力。”该条最直接地体现了私法自治的精神。在我国《民法总则》中，该原则被称为“自愿原则”，该法第5条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”尽管在民法的各部分（身份法和财产法、物权法和债权法）中的强度不同，但意思自治原则作为民法的一项基本原则，贯彻于整个民法之中，体现了民法最基本的精神。该原则在民法中的重要作用和地位表现在：

第一，该原则奠定了民法作为市民社会基本法的地位。市民社会与政治国家的分离，导致了公法与私法的分立。公法的重要特点表现在规范的强制性方面，私法的重要特点表现在规范的任意性上，私法的任意性即主要体现在意思自治原则上。[11]

第二，该原则最直接地反映了市场经济的本质需要。一方面，市场经济条件下“尽可能地赋予当事人的行为自由是市场经济和意思自治的共同要求”[12]。正是因为私法充分体现了意思自治原则，才能赋予市场主体享有在法定范围内广泛的行为自由，并能依据自身的意志从事各种交易和创造财富的行为。另一方面，如何优化配给有限的自然资源是市民社会存在的经济基础，而通过意思自治在市场中分配资源是市场经济的基本运作规律。

第三，该原则是推进国家治理能力现代化的一种重要方式。人类的历史已经证明人类不可能完全认识社会，不可能对社会的一切问题都作出预先的判断。因此，我们不能指望有万能的立法者在立法时能对社会主体的一切行为都作出圆满的安排，而只能赋予各个民事主体自主决定其事务的意志自主和自由。每个民事主体作为一个理性的人，都是自己利益的最佳判断者，法律赋予其广泛的行为自由，他们可以在法定的范围内自主地安排好自己的事务，并维持社会的和谐稳定。

意思自治与私法自治基本上是同义语，但两者也有一定的区别，意思自治与私法自治的关系表现在：前者是后者的重要组成部分，但不完全等同。因为私法自治是私法领域中的最基本原则，而意思自治是民事实体法中的基本原则。

二、意思自治原则的内容

意思自治原则的内涵主要体现在如下几方面：

1. 赋予民事主体在法律规定范围内广泛的行为自由

意思自治的实质就是允许当事人在法律规定的范围内，自主决定自己的事务，自由从事各种民事行为，最充分地实现自己的利益。具体而言：

（1）民事主体有权依法从事某种民事活动和不从事某种民事活动。也就是说，在民事领域，除了法律另有规定之外，当事人是否从事某种行为或不行为，是否行使某种权利或不行使权利，完全应当由当事人

自由安排。

(2) 民事主体有权选择其行为的内容和相对人。当事人可以通过平等协商，为自己设定权利和承担义务，当客观情况发生变化以后，可以依法变更权利和义务的内容。当事人之间的协议一经合法成立，就具有法律效力，并可以改变民法的任意性规定。

(3) 民事主体有权选择其行为的方式。民事主体从事法律行为，有权对口头形式、书面形式、公证等方式作出选择。但法律、法规要求采取某种特殊的形式，必须采取该形式。

(4) 民事主体有权选择补救方式。通常情况下，受害人能够选择对自己最为有利的要求不法行为人承担责任的方式，即便受害人选择不适当，除非他受到了不正当的影响，否则也应当由该受害人自己负担不利的后果。例如，《民法总则》第186条规定：“因当事人一方的违约行为，损害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。”

2. 允许民事主体通过法律行为调整他们之间的关系

意思自治一个重要的意义就在于，允许主体在从事民事行为，尤其是从事民事法律行为时，通过其自己的意志产生、变更和消灭民事法律关系。这就是民法中的任意性调整方法。该方法的特点在于，它并不确立具体的行为准则，而只是划定了一个界限和范围，要求民事主体在该范围之内自主行为。

3. 确立了行政机关干预民事主体的行为自由的合理界限

根据意思自治原则，法无明文禁止即为自由，因此，民事主体在法定的范围内享有广泛的自由，也就是说，只要不违反法律、法规的强制性规定和公序良俗，国家就不得对其进行干预。意思自治原则划定了民事主体和行政机关的权限，确定了二者之间的正确关系。

三、对意思自治的限制

任何意思自治都不是绝对的自由，而是相对的、有限制的自由。19世纪由于个人主义思潮的盛行，意思自治原则曾经被绝对化，但自20世纪以来，随着垄断的加强，国家加强了对经济领域的干预。以私法自治为核心的民法的三大原则都已经受到不同程度的限制，尤其是对合同自由的限制表现得尤为突出。甚至在家庭法领域，过去极少提倡国家干预，现在也出现了社会化、公法化的趋势。例如，监护职能的社会化等都表现了这样一种趋势。[13]

第五节 公平原则

一、公平原则的概念

所谓公平原则，是指民事主体应本着公平、正义的观念实施民事行为，司法机关应根据公平的观念处理民事纠纷，民事立法也应该充分体现公平的理念。在罗马法中，就有一项重要规则，即“无论任何人都不得基于他人的损害而受有利益”（nam hoc natura aequum est neminem cum alterius derimento et iniuria fieri locupletiores）[14]，这实际上体现的也是公平原则。从比较法上看，有的国家对公平原则作出了规定，例如，《瑞士民法典》第4条规定：“依本法所作的裁判，或判断具体状况，或认定重要原因是否存在时，法官应根据法理公平裁判。”我国民法历来将公平原则作为基本原则。我国《民法总则》第6条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。”这就在法律上明确确认了公平原则。

民事活动应当遵循公平原则，即应将公平原则确定为一项基本原则。其特点表现为：

第一，公平原则本身是民事活动的一项基本原则。民事主体在从事民事活动的过程中，应当按照公平的观念正当行使权利和履行义务。例如，在合同订立后，应当从顾及对方当事人的利益的角度出发，进行

充分的准备。在权利的行使过程中，要充分顾及他人的利益，不得滥用权利。

第二，公平原则是民事活动的目的性的评价标准。这就是说，任何一项民事活动，是否违背了公平原则，需要从结果上是否符合公平的要求来进行评价。如果交易的结果形成当事人之间极大的利益失衡，除非当事人自愿接受，否则法律应当作出适当的调整。所以，公平原则更多地体现了实质正义的要求。

第三，公平原则是法官适用民法应当遵循的重要理念。民法最充分体现了公平正义的要求，这是民法最基本的价值理念。法官应当依据社会的一般公平正义观念进行司法活动。不过，正是因为公平原则过于抽象，所以它只能作为一种理念，而不能替代具体的民法规则。

公平原则体现了现代法治的精神，古罗马法学家凯尔苏斯（Celsus）曾言：“法乃公正善良之术（Jus est ars boni et aequi）。”自此以后，公平正义成为法律固有的属性。公平正义是一切法律所追求的价值，是法律的精髓和灵魂。正义体现了某种秩序的内在要求，是构建普适性秩序的内在需要。换言之，法律作为行为规范，以调整社会关系为目的，必然以公平正义作为其基本价值。当然，公平概念的内涵是动态的、发展的。随着时代的发展，人们对公平的认识也会产生相应的变化。所以，公平内涵的确定应当紧密结合社会历史发展潮流。

二、公平原则在民法中的具体体现

公平原则要求将公平的理念贯彻在整个民事法律制度的设计当中，以价值的均衡为标准配置当事人之间的权利、义务。我国《民法总则》不仅确认了公平原则是民法的基本原则，而且多个条款都反映了公平原则的基本要求。例如，该法第151条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”这就确立了显失公平制度。再如，该法第183条规定：“因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可以给予适当补偿。没有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。”该条确认了侵权责任中的公平责任，这实际上是公平原则的具体化。公平原则在民法中具体体现为如下几个方面：

公平原则在合同法中运用得最为广泛，《合同法》第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。”这主要是因为商品交换本身就要求遵守价值法则，体现公平、平等的要求。公平原则在合同法中又表现为如下几个方面：

（1）等价有偿原则。我国《民法通则》第4条规定，民事活动应当遵循等价有偿的原则。等价有偿原则，是指民事主体在从事民事活动时要按照价值规律的要求进行等价交换，实现各自的经济利益。按照这一原则，除了法律另有规定或者当事人另有约定之外，取得他人财产利益或者获得他人提供的劳务者，都应提供相应的对价。

不过，等价有偿原则不能作为整个民法的基本原则，它主要是合同法领域中的基本原则，它是公平原则在合同法中的作用，在亲属法等领域很难适用。

（2）情事变更原则。所谓情事变更，是指合同有效成立以后，非因当事人双方的过错而导致了一定情事的变化，致使合同不能履行或如果履行将显失公平，因此根据公平原则，当事人可以请求变更或者解除合同。但我国《合同法》并未采纳这一原则，只是在相关司法解释中确认了情事变更的规则。[15]

（3）显失公平制度。所谓显失公平是指一方在订立合同时，由于情事紧迫或者缺乏经验，而订立了对自己明显不利的合同。在出现显失公平的情况以后，当事人有权请求撤销或变更该合同。尽管我国《合同法》根据公平原则承认显失公平为合同撤销的原因，但在实践中对该规定的适用应当从严掌握，不能将正常的交易风险都作为显失公平看待。在法律上将显失公平作为可变更、可撤销的合同，是因为在从事民事行为时，一方利用了对方的无经验或者是利用了自己的优势地位，从而导致民事主体之间的利益关系失衡

。自愿的显失公平不影响民事法律行为的效力。

(1) 在添附制度中的运用。所谓添附，是指不同所有人的物结合在一起，形成不可分离的物或具有新质的物。添附发生后，需要根据添附规则确定财产的归属，这时就需要具体适用公平原则。例如，取得添附物的人应当补偿失去该物的人的损失；尤其是在损失不能确定的情况下，只能根据公平原则进行补偿。

(2) 在相邻关系中的运用。在相邻关系中，一方应当容忍另一方不动产所有人或使用人权利的必要延伸，为其行使权利提供必要的便利。其存在的基础实际上是公平原则。同时，相邻关系的具体规则也体现了公平原则。例如，所有人应当容忍来自他人的轻微损害等。

(1) 公平责任原则。公平责任，又称衡平责任（Billigkeitshaftung），是指当事人双方在对造成损害均无过错的情况下，由人民法院根据公平的观念，在考虑当事人的财产状况及其他情况的基础上，责令加害人对受害人的财产损失给予适当补偿。《民法通则》第106条第3款关于“没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任”的规定和第132条关于“当事人对造成损害都没有过错的，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任”的规定，是公平责任原则的重要法律依据。

(2) 损害赔偿。根据完全赔偿原则，一方给另一方造成损害的，行为人应当赔偿因其行为给另一方造成的损失，加害人的赔偿数额应与受害人的损失相符。完全赔偿原则是公平原则的具体体现。

(3) 损益相抵。所谓损益相抵，又称损益同销，是指受害人基于损失发生的同一原因而获得利益时，应在其应得的损害赔偿额中扣除其所获得的利益部分。这一规则尽管是损害赔偿的减轻规则，但它是公平原则在损害赔偿责任中的具体应用。

公平原则作为一种基本的价值，应当体现在立法、司法及法学研究中。公平原则也是一项重要的司法原则，既适用于合同责任，也适用于侵权责任。公平原则作为一项“弹性”很强的原则，给予司法人员一定的自由裁量权，使他们能够针对案件的具体情况，公平合理地处理民事纠纷。

第六节 诚实信用原则

一、诚信原则的历史发展

在民法中，诚信原则是一项重要的原则，该原则常常被称为民法特别是债法中的最高指导原则或称为“帝王规则”（Königliche Lehrnorm），君临法域。[16]《民法总则》第7条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”这就在法律上确认了诚信原则。

诚实信用原则起源于罗马法。在罗马法的诚信契约中，债务人不仅要依照契约条款，更重要的是要依照其内心的诚实观念完成契约所规定的给付。欧洲中世纪的教会法也规定，个人一旦作出允诺，便应当履行。根据教会法，谎言、伪证和虚假的誓言都是“言语上的罪过”，不遵守其话语和承诺者应当受到惩罚，违背誓言的行为构成一种不法状态，应当受到法律的制裁。[17]1804年的《法国民法典》第1134条规定，契约应依诚信方法（de bonne foi）履行。1863年的《萨克逊民法典》第158条规定：“契约之履行，除依特约、法规外，应遵守诚信。依诚实人之所应为者为之。”

在历史上，诚实信用原则主要适用于债之关系，至20世纪，西方国家日益借助于诚信原则解释法律和契约，诚信原则的适用范围不断拓宽，突破了债之关系而扩展到民法各个法域，包括物权法、亲属法、继承法，任何人在行使权利、履行义务时都应当依诚实信用原则为之，因而被称为民法中的“帝王规则”。例如，1907年《瑞士民法典》第2条规定：“无论何人，行使权利、履行义务，均应依诚信为之。”这就将诚信原则的适用，由债权债务关系，扩展到一般权利和义务。《德国民法典》第242条规定：“债务人有权义务照顾交易习惯，以诚实信用所要求的方式履行给付。”在德国，法院曾经运用该原则去解决第一次世界大战后随着经济崩溃、通货膨胀和货币贬值而发生的极其重要的经济和社会问题[18]，并利用这一原则解

决第二次世界大战后改革币制发生的问题。《日本民法典》第1条规定：“（1）私权必须适合公共福祉。（2）权利行使及义务履行必须遵守信义，以诚实为之。（3）权利不许滥用。”诚信原则对于缓和西方社会的各种矛盾、维护社会的稳定，起到了重要作用。可以说，自20世纪以来，诚信原则在民法中得以普遍运用，是民法发展的重要标志。

从比较法上来看，诚信原则不仅是普遍适用于民法的重要原则，同时，它也是法官解释民法的重要依据。在我国，诚信原则是民法中重要的基本原则，应适用于民法的整个领域，民事主体行使任何民事权利、履行任何民事义务，都应当遵守这一原则。诚信原则不仅是适用于债和合同法的重要准则，而且广泛适用于物权法等领域。

《民法总则》第7条确定诚信原则，弘扬了社会主义核心价值观中的诚信价值，确立了最基本的商业精神和最低限度的商业道德。只有树立全社会诚实守信的道德观念，才能建立诚信社会，维护正常的生活秩序和经济秩序，并为法治的推行奠定良好的基础。诚然，诚信原则是对伦理观念的法律确认，但这并不是说诚信原则只是一项道德原则。诚信原则将道德规范确认为法律原则以后，已成为法律上的一项重要原则。在法律上，诚信原则属于强行法规范，当事人不得以其协议加以排除和规避。

二、秉持诚实、恪守承诺

秉持诚实，是指当事人要真实、真诚，在合同订立中，要如实披露相关订约信息，告知相关真实情况，不坑蒙拐骗，不欺诈他人。在物权的行使中，也要秉持诚信，不得滥用物权。“诚者自然，信是用力，诚是理，信是心，诚是天道，信是人道，诚是以命言，信是以性言，诚是以道言，信是以德言”（《性理大全·诚篇》）。为人诚实是我国传统文化的重要组成部分，我国商业习惯也历来将诚实守信、童叟无欺作为重要的商业道德。《民法总则》所确立的诚信原则首先就要求民事主体在民事活动中依诚信而为，同时，《民法总则》在相关制度中也进一步具体化了诚信原则。例如，该法第146条第1款规定：“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。”第149条规定，第三人实施欺诈行为使一方在违背真实意志的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道的，则受欺诈方有权请求撤销。上述两个规则都是新增加的，表明该法进一步要求行为人实施民事法律行为时要秉持诚实。

恪守承诺就是指严守契约和允诺。严守合同（*Pacta sunt servanda*）、信守允诺（*Solus consensus obligat*）曾被认为是自然法的基本规则，也是基本的商业道德。中国古代历来就有“民有私约如律令”的说法。古时商鞅立木为信、季布一诺千金，曾被传为佳话。古人历来提倡“君子一言，驷马难追”，“言必行，行必果”，儒学曾将“信”与“仁、义、礼、智”并列为“五常”，使其成为具有普遍意义的最基本的社会道德规范之一。守诚信、重允诺是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。今天，诚信已经成为社会主义核心价值观的重要组成部分，我国《民法总则》从维护社会主义核心价值观和市场秩序出发，必然要求民事主体从事民事活动时诚实守信，恪守承诺。《民法总则》第119条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。”依据这一规定，当事人在订立合同后，只要合同合法有效，就应当严格按照合同履行，非依法律规定和当事人约定，不得擅自变更或者解除合同。合同就是当事人之间的法律，其对当事人应当具有严格的拘束力。一方在向对方作出单方允诺之后，也应当严格遵守允诺，不得随意违背允诺损害对方的信赖利益。

秉持诚实、恪守承诺是维护正常的市场秩序的前提和基础。市场经济的有序运行要求建立保护产权、严守契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管的法律制度。在市场经济社会，市场正是由无数的交易组成，只有当事人之间订立的合同能够得到履行，才能保证交易的有序进行。诚实信用原则是基本的商业道德，也是信用经济的基础。正是从这个意义上讲，契约精神也是构建市场的基础。严守契约不仅仅在市场经济社会的建设中意义重大，其在法治社会的构建中也居功至伟。“重合同、守信用”也是维护正常的社会和谐有序的基础。只有强化人们诚实守信的观念，督促当事人认真履行合同，才能保护交易的秩

序，保障社会安定有序。

三、诚信原则的主要功能

诚信原则的基本功能在学理上可以概括为四项机能，即法具体化机能、正义衡平机能、法修正机能、法创设机能。[19]本书认为，诚信原则具有如下内容和功能：

（一）确立行为规则的功能

诚信原则不仅是一项抽象的法律原则，而且依据该原则可以产生各种具体的民事义务，这主要表现在如下几个方面：

1. 在合同法领域，依据诚信原则产生的附随义务成为合同义务的重要来源。它主要表现在：第一，在合同订立过程中，当事人应当依据诚信原则履行先契约义务，否则应当承担缔约过失责任。第二，在合同订立以后履行期到来之前，当事人应当按照诚信原则的要求，做好各种履约的准备工作。第三，合同履行期到来以后，当事人不仅应当按照法律和合同的规定履行义务，而且应当按照诚信原则的要求，作出履行和接受履行。第四，在履行完毕以后，当事人也应当按照诚信原则履行后契约义务。

2. 在物权法领域中，诚信原则成为物权行使的一项重要规则。只有严格遵循诚信原则，物权人才能正当地行使物权并建立和谐的经济生活秩序，保障财产流转的正常进行。例如在相邻的不动产所有人和使用人之间，不得在自己的不动产之上存放向对方散发臭气的污物，从而损害邻人的利益。权利人应以善意的方式行使权利和履行义务，不得滥用权利损害他人利益。诚信原则也对所有权本身形成了一种限制。主要表现在：所有权人在行使所有权时，必须要符合社会的整体利益，不得损害他人利益和社会公共利益。

3. 在侵权法领域，诚信原则的适用范围也日益广泛。侵权法在许多领域也引用诚信原则，作为确定行为人是否对他人负有义务的依据。我国民法确定的安全保障义务，意味着侵权法从过去确立“无害他人”的普遍义务转变为在特定情况下要求行为人应“适当地关爱他人”，这实际上是依据诚信原则产生的义务。尤其是现代侵权法承认了商业侵权的概念，对商业领域中违反诚信原则的欺诈行为也认定为侵权，并且行为人要承担侵权责任，表明诚信原则的适用范围在侵权法领域得到了扩大。

（二）填补法律和合同漏洞的功能

首先，诚信原则可以运用于填补法律漏洞。其次，诚信原则也可以适用于填补合同漏洞。填补合同漏洞具体表现在：一是合同的内容存在遗漏，即对一些合同的条款，在合同中并没有作出规定，例如合同中缺少对质量条款的约定的，可以依诚信原则填补漏洞。二是合同中的约定不明确，或者约定前后矛盾，可以依诚信原则加以完善或协调。

（三）衡平的功能

诚信原则要求平衡当事人之间的各种利益冲突和矛盾。平等主体之间的交易关系，都是各个交易主体因追求各不相同的经济利益而产生的，而各方当事人之间的利益常常会发生冲突或矛盾，这就需要借助诚信原则加以平衡。

诚信原则不仅要平衡当事人之间的利益，而且要平衡当事人的利益和社会利益之间的冲突与矛盾，即要求当事人在从事民事活动过程中，要充分尊重他人和社会的利益，不得滥用权利，损害国家、集体和第三人的利益。

（四）解释的功能

诚信原则要求在法律与合同缺乏规定或规定不明确时，司法工作人员应依据诚信、公平的观念，准确解释法律和合同。具体来说，一方面，在适用法律方面，诚信原则要求司法工作人员能够依据诚信、公平

的观念正确解释法律、适用法律，弥补法律规定的不足。另一方面，诚信原则也是司法工作人员在解释合同时应当遵循的一项原则。

确定行为规则、衡平利益的冲突、为解释法律和合同确定准则以及填补法律与合同的漏洞，是诚信原则所具有的四项基本功能。这些功能都是因为诚信原则体现了伦理道德的观念或正义的现实要求，从而在适用中能产生特殊的作用。

诚信原则的上述功能，直接有助于维护交易安全。因此，只有强化人们诚实守信的观念，督促当事人认真履行合同，才能维护交易的秩序，也有利于降低交易费用，节约交易成本。

诚然，诚信原则是对伦理观念的法律确认，但这并不是说诚信原则只是一项道德原则。诚信原则将道德规范确认为法律原则以后，已成为法律上一项重要的原则。在法律上，诚信原则属于强行性规范，当事人不得以其协议加以排除和规避。

第七节 符合法律和公序良俗原则

一、合法原则

合法原则，是各国法律普遍确认的基本原则。从狭义上讲，合法是指所有民事法律行为都不得违反法律的强制性规定。而从广义上说，合法还包括民事法律行为不得违反公序良俗。因为《民法总则》就公序良俗作出了特别的规定，所以，此处所说的合法原则是从狭义上理解的。《民法总则》第8条规定：“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”该条将合法原则表述为“不得违反法律”，但其应当仅仅理解为不得违反法律的强制性规定。关于违反法律强制性规定的民事法律行为的效力，《民法总则》第153条规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。”当然，在评价民事法律行为的效力时，不仅要考虑私法中的强制性规定，还应当考虑公法中的强制性规定，这实际上为公法进入私法提供了通道，而且有利于保持公法评价和私法评价的一致性。例如，走私、贩毒行为在刑法上是犯罪行为，而当事人订立的走私、贩毒合同，也因为违反了刑法上的强制性规定而归于无效，这就可以使法秩序内部保持统一。

二、公序良俗原则

公序良俗，是由“公共秩序”和“善良风俗”两个概念构成的。《法国民法典》将两者统称为公序良俗。《法国民法典》第6条规定：“个人不得以特别约定违反有关公共秩序和善良风俗的法律。”日本民法也采纳了这种规定^[20]，而在《德国民法典》中，只有善良风俗而没有公共秩序的概念。^[21]我国《民法通则》没有采用“公序良俗”的概念，《民法通则》第7条规定：“民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益。”《合同法》第7条规定：“当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。”按照许多学者的理解，所谓社会公共利益和社会公德，就相当于国外民法中的公序良俗的概念。^[22]

依据我国《民法总则》第8条的规定，民事主体从事民事活动，不得违背公序良俗。如前所述，从广义上理解，违法也包括违背公序良俗。《民法总则》第153条第2款也规定：“违背公序良俗的民事法律行为无效。”因此，任何违背公序良俗的行为，都应当无效。例如，当事人订立的“包二奶”协议、斡旋行贿等合同，都应当认定为因违反公序良俗而无效。我国民法所规定的公序良俗原则，不仅适用于财产关系，也适用于人身关系。它是社会主义核心价值观的体现，与《民法总则》第1条所确立的“弘扬社会主义核心价值观”的目的是一致的，对于维护社会伦理，维护社会秩序，都具有重要意义。

第一，公共秩序。所谓公序就是指公共秩序，它主要包括社会公共秩序和生活秩序。公共秩序是指现存社会的秩序^[23]，或者说，是“社会之存在及其发展所必要之一般秩序”^[24]。对公共秩序的维护，在

法律上大都有明确的规定，因此，危害社会公共秩序的行为通常也就是违反法律的强制性规定的行为。如果合同内容损害社会公共秩序、违反现行法律规定，如走私军火、买卖枪支和毒品、以从事犯罪或帮助犯罪行为作为内容的合同等，应当以违反了法律或行政法规的强制性规定为由宣告合同无效。但有时法律规定并不可能涵盖无余，因此，需要借助公共秩序的概念实现对法律的有效补充。因此，凡是订立合同危害国家公共安全和秩序，即使没有现行的法律规定，也应当被宣告无效。例如，购买“洋垃圾”、规避课税的合同等，即使现行法律没有明确作出禁止性规定，也应当认为是无效的。可见，有关禁止危害公共秩序的规定，实际上有助于弥补法律的强制性规定的不足。但是，应该看到，当前我国正处于一个社会转型的阶段，各个主体为了追求利益的最大化，难免会与他人的利益或者社会利益发生冲突。这就需要借助民法规范协调社会公共利益和民事主体的利益，避免片面强调某一方面的利益而漠视另一方面的利益的现象。而通过“公共秩序”这一概念的引入，就可以妥当协调社会公共利益和民事主体的私人利益。

第二，善良风俗。它是指由社会全体成员所普遍认许、遵循的道德准则。善良风俗的含义又包含两个方面，一是指社会所普遍承认的伦理道德，例如救死扶伤、助人为乐、见义勇为等。二是指某个区域社会所普遍存在的风俗习惯，例如婚礼不得撞丧。善良风俗本身就是社会生活中的一些基本规矩，而且，许多地方将善良风俗转化为乡规民约，使之成为“软法”，构成社会自治的重要内容。在善良风俗中，有许多道德规则已经表现为法律的强行规定，如不得遗弃老人等。我国民法提倡家庭生活中互相帮助、和睦团结，禁止遗弃、虐待老人和未成年人，禁止订立违反道德的遗嘱，禁止有伤风化、违背伦理的行为，提倡尊重人的人格尊严，切实保护公民的人格权，等等。在财产关系中，我国民法要求人们本着“团结互助，公平合理”的精神建立睦邻关系，提倡拾金不昧的良风美俗，确认因维护他人利益而蒙受损失者，有权获得补偿，这些都是从正面倡导社会公德的。需要通过善良风俗这样一个条款，尽可能将其引入民法体系中来，以弥补法律规定的不足。因此《民法总则》第153条第2款规定：“违背公序良俗的民事法律行为无效。”

公序良俗原则具有调节性的功能，它可以协调个人利益与社会公共利益、国家利益之间的冲突，维护正常的社会经济和生活秩序。“公序良俗的调整机能由确保社会正义和伦理秩序向调节当事人之间的利益关系、确保市场交易的公正性转变，从而使法院不仅从行为本身、而且结合行为的有关情势综合判断其是否具有反公序良俗性。”[25]也就是说，这一原则实际上赋予了法官一定的自由裁量权，从而使其能够有效地调整各种利益冲突，具体表现在：一方面，如果民事主体因为追求利益的最大化所从事的行为和社会公共利益发生冲突和矛盾，法官应当借助于善良风俗条款维护社会公共利益。另一方面，一些法律法规所确定的强行法规则可能过于僵化，缺乏弹性，或者在适用中具有明显的不合理性，此时法官就应当考虑援用公序良俗原则解决个人利益与社会公共利益的冲突。

还应当看到，该原则可以弥补强行法规范的不足。公序良俗作为一个弹性条款，之所以要在法律上予以确认，根本原因在于，由于强行法不能穷尽社会生活的全部，其适用范围不能将各种民事活动都涵盖其中。民事活动纷繁复杂，强行法不可能对其一一作出规定，但是法律为了实现对秩序的控制，需要对民事活动进行规范，这种规范不仅要靠强行法来完成，还需要通过在法律上设立公序良俗条款，对民事行为提供更为全面的规则，并对其效力作出评价。例如，尽管民法中许多条款反映了很多道德规则，但民法也不可能将道德全部摄入其中，由于民事活动，无论是交易活动还是一般的社会生活，大都离不开道德的评价和规制，违反了社会所普遍接受的道德准则，不仅可能会给当事人造成损害，也会造成对社会秩序的妨害，这就需要采用公序良俗的原则，作为调整民事活动的重要方式。[26]公序良俗本身不是强行法，但它是沟通强行法与道德规范的桥梁，为道德规范引入法律提供了媒介。公序良俗原则也有利于避免法律的僵化，能够保护法律强行性规范与道德的有机协调，维护社会经济生活秩序的和谐稳定。

三、公序良俗原则与相关原则

（一）公序良俗原则与自愿原则

公序良俗原则与自愿原则关系密切。在现代社会，虽然私法自治原则可以成为社会治理的重要方式，但私法自治也可能被滥用，而对社会经济生活造成妨碍，因此，需要借助于公序良俗原则，对私法自治原则进行必要的限制，这尤其体现在伦理生活领域。例如，借助公序良俗原则否定当事人所订立的损害伦理道德、危害社会公共利益的合同的效力。[27]在我国，尽管为了促进市场经济的发展，需要借助自愿原则，不断扩大民事主体意思自治的范围，允许其在民事活动领域依法享有广泛的行为自由，但也需要借助公序良俗原则对民事主体的行为进行必要的限制。例如，为了保护个人的人格尊严，应当对有偿代孕行为进行必要的控制，以防止将人的身体作为商品进行交易的现象。公序良俗原则就是要强调民事主体进行民事活动时必须遵循社会所普遍认同的道德，从而建立稳定的社会秩序，使社会有序发展。因此，在一定程度上，公序良俗原则对自愿原则作出了限制和干预，从而保障人们依据自主自愿行为时能够符合法律的价值和目的。

（二）公序良俗原则与诚信原则

公序良俗原则与诚实信用原则一样，都要反映一个社会主流的价值观和道德观，并通过这一原则的引入以发挥填补法律漏洞、弥补法律不足的功能。但是，两者毕竟是不同的民法原则，其存在如下区别：

一是适用范围不同。诚信原则作为“帝王规则”，其适用范围更为宽泛。它不仅适用于债法领域，而且适用于民法的各个领域。特别是强调在交易活动中秉持诚实、恪守承诺，意义重大。而公序良俗原则主要适用于人身关系和债法领域，在物权法等领域适用情形相对较少。

二是功能不同。诚信原则经常用于填补法律漏洞和合同漏洞。正是因为这一原因，在诚信原则的基础上产生了许多新的规则，如合同正义原则、禁止暴利原则、禁止滥用权利原则、缔约过失责任规则、当事人应承担附随义务的原则等。而公序良俗原则的功能主要是认定法律行为的效力。依据《民法总则》的规定，违反公序良俗的后果将导致法律行为无效。但诚信原则主要不是用于判断法律行为效力的，违反诚实信用原则也不当然地导致法律行为无效。在司法实践中，法官也很少以公序良俗原则为基础解释出新的规则和制度。

三是调整民事行为的方式不同。诚信原则一般通过设定行为人积极行为义务（如附随义务）的方式，调整人们的行为；而公序良俗原则一般通过禁止行为人从事某种行为的方式，实现对个人行为的调整。

四是目的不同。诚实信用原则主要是为了保护对方当事人利益。因此，诚实信用原则往往赋予一方当事人要求另一方当事人为特定行为的权利，如合同当事人可以基于此原则要求对方履行附随义务。而公序良俗原则往往侧重于保护第三人的利益和一般社会大众的利益，从这一意义上说，公序良俗原则设定了私法自治的框架，消极地限制法律行为的效力，当事人通常并不能以此为基础要求对方当事人为特定行为。

第八节 绿色原则

一、绿色原则的概念和意义

所谓绿色原则，是指民事活动应当遵循节约资源、保护生态环境的原则。《民法总则》第9条规定：“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。”这就从基本原则的层面，提出了生态环境保护的要求。

从比较法上看，传统民法注重调整财产关系，而不注重对环境的保护。但《德国民法典》已经开始考虑对环境的保护，该法第906条第1项规定：“（1）土地所有人不得禁止煤气、蒸汽、臭气、烟、煤烟子、热、噪音、震动以及从另一块土地发出的类似干涉的侵入，但以该干涉不妨害或仅不显著地妨害其土地的

使用为限。在通常情况下，法律或法令所确定的极限值或标准值不被依这些规定算出和评价的干涉所超出的，即为存在不显著的妨害。依《联邦公害防止法》第48条颁布所反映技术水平的一般行政规定中的数值，亦同。”《瑞士民法典》第684条规定：“经管工业的方式：（一）任何人，在行使其所有权时，特别是在其土地上经管工业时，对邻人的所有权有不造成过度侵害的注意义务。（二）因煤、烟、不洁气体、音响或震动而造成的侵害，依土地的位置或性质，或依当地习惯属于为邻人所不能容忍的情况的，应严禁之。”可见，一些国家的民法典已经对环境保护问题作出了规定。

我国《民法通则》中并没有关于环境保护的原则和规则，保护环境主要是通过《环境保护法》等法律实现的。早在1989年，立法机关就颁布了《环境保护法》，在此之后，立法机关又相继颁布了《水污染防治法》《环境噪声污染防治法》《节约能源法》《大气污染防治法》《水法》《草原法》《固体废物污染环境防治法》等多部保护环境的法律，构建了我国环境保护法的完整体系。我国《民法通则》《侵权责任法》等民事立法虽然对环境侵权责任作出了规定，但其并不直接救济生态环境损害本身。《民法总则》对绿色原则作出规定，是我国民事立法的一大进步，而且《民法总则》将绿色原则作为一项民法基本原则进行规定，表明保护生态环境并不仅仅适用于侵权，其应当贯彻适用于整个民法，其将直接影响民法典各分编制度、规则的设计、理解与适用。《民法总则》第132条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”该条所规定的禁止权利滥用规则与绿色原则相配合，能够直接起到保障民事主体正当行使民事权利、维护生态和环境的作用。

绿色原则是我国民法典积极回应现代社会问题的体现，也是我国传统法律文化的传承。它既传承了天地人和、人与自然和谐共生的我国优秀传统文化理念，又体现了党的十八大以来的发展理念，与我国是人口大国、需要长期处理好人与资源生态的矛盾的国情是相适应的。[28]尤其是在我国，随着经济社会的快速发展，环境和生态日益成为严重的社会问题，关系到基本民生和人民群众的生命健康。现阶段，我国水资源严重短缺，污染严重，空气质量恶化，许多城市深受雾霾困扰，人们对于青山绿水、蓝天白云、清新空气的需求，比以往任何时候都更为强烈，它们成为人们生活的必需品，也是人们幸福生活的组成部分。虽然人类不能支配大自然的阴晴、风雨，但是我们可以支配我们的行为，可以通过法律来规范人们的行为，保护环境、维护生态。所以，民法以人中心，应当积极回应人民的关切，担当起节约资源、保护生态环境的使命。《民法总则》规定绿色原则，将其作为民法的基本原则，将对民法典分则各编的制度、规则产生重大影响，也会对人们的日常行为产生重要的引导作用。

绿色原则的提出，是我国民法典时代性的体现，反映出因为资源环境日益恶化而强化对生态环境保护的现实需要。21世纪是一个面临严重生态危机的时代，生态环境被严重破坏，人类生存与发展的环境不断受到严峻挑战。全球变暖、酸雨、水资源危机、海洋污染等已经对人类的生存构成了直接的威胁，并引起了全世界的广泛关注。如何有效率地利用资源并防止生态环境的破坏，已成为直接调整、规范物的归属和利用的民法典的重要使命。十八届五中全会提出了“五大发展理念”，即创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。坚持绿色发展，就是要求必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进人与自然和谐共生，推进美丽中国建设。绿色原则的提出，是五大发展理念的具体体现。它表明民法规则应当在尊重民法逻辑自洽的前提下，在基本精神和理念上顺应生态规律，为资源保护和生态文明建设预留充分的空间。[29]

二、绿色原则的内涵

第一，有效率地利用资源。现代社会，资源的有限性也与人类不断增长的需求和市场的发展形成尖锐的冲突和矛盾。由于人口增长，发展速度加快，现代社会的资源和环境对于发展的承受能力已临近极限。解决这种冲突和矛盾的有效办法就是有效率地利用资源。由于资源利用中冲突的加剧，民法典必须承担起引导资源合理和有效利用的功能，“以使互不相侵而保障物质之安全利用”[30]。而在我国资源严重紧缺

、生态严重恶化的情况下，更应当重视资源的有效利用。[31]绿色原则要求人们的生产、生活等活动要与资源、环境相协调，要实现人与自然的和谐相处，有效率地利用资源、节约资源。我国民法确认和保护产权本身，也是为了有效利用资源，因为只有产权界定明晰，才能更好地发挥资源的经济效用。我国民法上其他一些制度也都在一定程度上体现了节约资源、保护环境的理念。例如，《物权法》确认了物尽其用的原则，该原则贯穿于物权法各项制度和规则之中，尤其是物权法所确认的用益物权制度，就是为了更好地发挥资源的经济效用。再如，《物权法》第119条规定：“国家实行自然资源有偿使用制度，但法律另有规定的除外。”该条确立了自然资源有偿使用制度，对于有效防止资源滥用具有重要意义。

第二，保护和生态。保护和生态是环境保护法等法律的重要任务，我国立法机关早在1989年就颁布了《环境保护法》（2014年修订）。迄今为止，我国已经建立了一整套保护环境的法律制度。但是，这并不意味着民法就不应当承担环境保护的使命。实际上，现代民法发挥作用的一个重要发展趋势就是保护环境、维护生态。民法典必须反映资源环境逐渐恶化的社会的特点，因为在市场经济环境下，由于民法典具有保护主体权利、配置市场资源的作用，其基本理念及相关制度设计都将对资源环境产生重大影响。[32]一方面，我国环境保护法主要通过行政手段和行政责任，强制当事人保护环境，而在一定程度上忽视了通过侵权责任来保护环境，未能形成与侵权责任法的有效衔接。行政处罚并非以损害后果作为确定处罚数额的依据，甚至某些处罚与损害后果并无直接的关联。行政机关也会受其能力所限，难以对有关损害后果进行准确认定。因此，处罚的结果大多远远低于污染所造成的实际损失，实践中经常出现违法成本低、执法成本高的问题。事实上，《侵权责任法》专设“环境污染责任”一章，对污染环境造成损害时的污染者责任作出了规定，对于有效保护生态环境具有重要意义。另一方面，在世界范围内，传统的所有权绝对主义观念也在保护生态环境的大背景下出现松动，并在相当程度上融入了“预防原则”和“可持续发展原则”的要求。[33]为此，有必要结合保护生态环境的具体需要，对财产权的客体、权能、属性、用益物权、相邻关系以及征收等制度进行完善，强化不动产所有人、使用人保护环境、维护生态的义务。我国《民法总则》第132规定的禁止滥用权利，也要求所有人和使用人不得滥用民事权利，破坏环境和生态，损害社会公共利益。

我们要建设的国家，应当是山清水秀、空气清新、蓝天白云、绿树成荫的美丽家园。我们要建设的小康社会，应当是环境友好、人与自然充分和谐的社会。为了保护好环境生态，为子孙后代留下可持续发展的空间，必须要遵守民法的绿色原则，有效利用资源、保护好环境生态。

思考题

1. 如何理解民事权益受法律保护原则的内涵？
2. 平等原则包含哪些内容？
3. 如何理解意思自治原则在私法中的作用？
4. 如何理解公平原则与公平责任的关系？
5. 如何理解诚实信用原则在民法中的地位？
6. 如何理解公序良俗原则与诚信原则的关系？
7. 如何理解绿色原则的内涵？

[1] 维亚克尔. 近代私法史（下）. 陈爱娥译. 上海：上海三联书店，2006：496-510.

[2] 在“民法总则三审稿”中，该条被置于第9条，但在大会审议时，有代表提出，民事权利受法律保护是民法的基本精神，统领整个民法典和商事特别法，应当进一步突出该原则的地位，因此立法机关最后决定将该条置于第3条，作为民法基本原则之首加以规定。

[3]彼得·斯坦, 约翰·香德. 西方社会的法律价值. 王献平译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1989: 41.

[4]松尾弘. 民法的体系. 4版. 东京: 庆应义塾大学出版社, 2005: 15.

[5]大村敦志. 民法总论. 江溯, 张立艳译. 北京: 北京大学出版社, 2004: 34.

[6]张文显. 法治与国家治理现代化. 中国法学, 2014 (4) .

[7]陈卫佐译注. 德国民法典. 北京: 法律出版社, 2010: 5, 注4.

[8]魏振瀛, 钱强波. 市场经济与民法观念. 中外法学, 1994 (5) .

[9]郑成良. 法律之内的正义. 北京: 法律出版社, 2002: 40.

[10]博登海默. 法理学——法哲学及其方法. 邓正来译. 北京: 华夏出版社, 1987: 281.

[11]苏永钦. 走入新世纪的私法自治. 北京: 中国政法大学出版社, 2002: 1-54.

[12]江平. 市场经济和意思自治. 中国法学, 1993 (6) .

[13]陈苇, 李欣. 私法自治、国家义务与社会责任——成年监护制度的立法趋势与中国启示. 学术界, 2012 (1) .

[14]D. 50, 17, 206.

[15]《合同法司法解释二》第26条规定: “合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化, 继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的, 当事人请求人民法院变更或者解除合同的, 人民法院应当根据公平原则, 并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”

[16]王泽鉴. 民法学说与判例研究. 第1册. 台北: 自版, 1979: 330.

[17]1234年, 教皇格里高利九世发布了敕令, 其中一条敕令写道: “和平必得维持, 愿协议必得遵守 (pax servetur, pacta custodiantur)。”这一原则后来逐渐在世俗的法庭中得到适用。

[18]康拉德·茨威格特等. 略论《德国民法典》及其世界影响. 法学译丛, 1983 (1) .

[19]林诚二. 民法理论与问题研究. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 8-9.

[20]参见《日本民法典》第90条.

[21]参见《德国民法典》第138、826条.

[22]李双元, 温世扬主编. 比较民法学. 武汉: 武汉大学出版社, 1998: 67; 梁慧星主编. 民商法论丛. 第1卷. 北京: 法律出版社, 1994: 49.

[23]转引自卡尔·拉伦茨. 德国民法通论. 上册. 王晓晔等译. 北京: 法律出版社, 2003: 598.

[24]史尚宽. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 334.

[25]李双元, 温世扬主编. 比较民法学. 武汉: 武汉大学出版社, 1998: 70.

[26]梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 511.

[27]梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2000: 516.

[28]李建国. 关于《中华人民共和国民法总则(草案)》的说明(2017年3月8日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上的讲话) .

[29]王旭光. 环境权益的民法表达——基于民法典编纂“绿色化”的思考. 人民法治, 2016 (3) .

[30]史尚宽. 物权法论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 1.

[31]2006年6月5日，国务院新闻办公室发表了《中国的环境保护（1996—2005）》白皮书。《白皮书》指出，由于中国人均资源相对不足，地区差异较大，生态环境脆弱，生态环境恶化的趋势仍未得到有效遏制。

[32]吕忠梅.如何“绿化”民法典.法学,2003(9).

[33]石佳友.物权法中环境保护之考量.法学,2008(3).

第三章 民事法律关系概述

“打工案”：甲是一名农民工，外出打工临走前与邻居乙达成协议，委托乙代为收割地里的庄稼，并由乙将之运送到甲家里储存，甲向其支付一定的报酬。后来，乙发现甲的房屋因连降大雨而即将倾倒，就请人修缮该房屋。另一位邻居丙看到甲的房屋一直无人居住，就擅自进入该房屋居住，并利用房屋的临街部分开设小吃店，每年经营收入达到数万元。问：本案形成了哪几种民事法律关系？

简要评析：上述“打工案”中，当事人之间主要形成了以下四种债的关系：一是合同之债。其产生原因为甲与乙之间的委托合同，具体来说，就是委托人甲与受托人乙之间就甲的庄稼的收割以及储存达成了合意，成立了委托合同关系。基于该委托合同而在二人之间形成了一定的债权债务关系，即乙负有为甲收割庄稼并存储的义务，而甲负有支付报酬的义务。二是无因管理之债。当乙发现甲的房屋即将倾倒时，未经甲的同意就直接请人修缮并承担了修缮费，这属于无法定义务和约定义务管理他人事务的情形，因此在甲乙之间形成了无因管理之债的法律关系。三是侵权之债。丙未经房屋所有权人甲的同意，擅自进入甲的房屋居住，符合过错侵权的一般构成要件，该行为属于侵害甲房屋所有权的侵权行为。因此，在甲和丙之间形成了侵权损害赔偿之债的关系。四是不当得利之债。丙未经甲的同意，擅自利用甲的房屋开设小吃店，获得利益（如经营收入），该利益之获得并无法律上的原因且与甲的损失之间存在因果关系，因此在丙和甲之间形成了不当得利之债的关系。

第一节 民事法律关系的一般原理

一、民事法律关系的概念和特征

在社会生活中，“人非遗世而孤立，而是具有社会性，共营社会及经济生活”[1]。各类主体为了满足自身的需要，必须从事社会交往，相互之间要发生各种社会关系。同时，为了使社会关系形成安定、和平、有序的状态，人与人之间形成正常的交往关系，法律需要对各种社会关系进行规范。法律关系是法律规范在调整人们之间的社会关系过程中所形成的一种特殊的社会关系，即法律上的权利义务关系。[2]民事法律关系是由民法规范调整的社会关系，也就是由民法确认和保护的社会关系。民事法律关系不同于其他法律关系的特点在于：

1. 民事法律关系是民法所调整的社会关系在法律上的表现

人们在社会生活中会形成各种社会关系，各种社会关系分别由不同的法律部门调整，由此形成了不同的法律关系。而民法在调整平等主体之间的财产关系和人身关系的过程中，形成了民事法律关系，并使原来的社会关系的内容表现为法律上的权利义务关系。

民事法律关系是民法调整的结果。民事法律关系与现实生活中存在的由民法所调整的社会关系并不是两个关系，而是一个关系。法律调整社会关系只是赋予当事人权利和义务，使之成为权利义务关系。不能把民事法律关系理解为是一种独立于民法的调整对象以外的社会关系。[3]

2. 民事法律关系是人与人之间的权利义务关系

拉伦茨认为，法律关系是“人与人之间的法律纽带”[4]。民事法律关系也不例外。民事法律关系作为一种权利义务关系，实质上是发生在民事主体之间的社会关系。即使是人格权关系，也是人与人之间的关系，不是人对自身的关系。民事法律关系虽然在许多情况下要与物发生直接的联系，但是它并不是人与物、人与自然界的关系，而是通过物所发生的人与人之间的关系。[5]明确民事法律关系为人与人之间的关系，对于正确适用民法具有重要意义。

3. 民事法律关系具有平等性

民法调整社会关系的特点首先在于其平等性，民事法律关系就是平等主体之间的财产关系和人身关系在法律上的表现，因此，在这种关系中，不仅当事人在法律地位上是平等的，而且许多法律关系中当事人的权利、义务具有对等性和相应性，一方的权利即是另一方的义务，一方的义务即是另一方的权利。

4. 民事法律关系具有一定程度的任意性

民事主体参与的各种社会关系大都体现其私人利益，所以法律赋予民事主体较大的自治权，因此民事法律关系具有较强的任意性。表现在：第一，发生上的任意性，即许多民事法律关系由当事人意思自治的方法产生；第二，变更上的任意性，即许多民事法律关系允许当事人协商变更；第三，消灭上的任意性，即许多民事法律关系也允许当事人通过意思自治的方法消灭；第四，内容上的任意性，民事法律关系的内容大多系由当事人的意思决定，当事人的约定优先于法律规定，只要不违反国家强行性法律和公序良俗，当事人可以依法协商自由确定其权利义务内容。

在我国目前的情况下，强调民事法律关系的任意性具有特殊的意义。在市场经济条件下，交易的发展和财产的增长都要求市场主体在经济活动中保持高度的能动性和活力，法律应为市场主体提供广阔的自治空间，政府对经济活动的干预应限制在合理的范围内，市场经济对法律提出了尽可能赋予当事人行为自由的要求。这一点在民法中表现得最为突出和明显，这就决定了民事法律关系具有较强的任意性。所以我们在民事立法过程中，应当更多地运用任意性调整方法，赋予民事主体更多的自治权，不能沿袭旧有的国家过分干预经济生活的传统，否定当事人的意思自治。

二、民事法律关系在民法体系构建中的意义

民事法律关系在民法体系构建中具有如下意义：

第一，民事法律关系是整个民法逻辑体系展开与构建的基础。一般认为，萨维尼最早系统提出以法律关系构建整个民法的体系，其代表作《当代罗马法体系》就详细探讨了法律关系，在此基础上，依据五编制分别讨论具体的民法制度。[6]潘德克顿学派一个最伟大的贡献就在于，以法律关系的要素作为构建民法典总则体系的骨架。具体来说，在总则中根据法律关系的要素确立了主体、行为、客体制度，然后在分则中确立法律关系的内容，该内容主要是民事权利，具体包括债权、物权、亲属权、继承权，当总则中确立的主体、行为、客体与分则中的权利结合在一起时，就构成一个完整的法律关系。[7]例如，总则中的主体、行为、客体与物权制度结合在一起，就构成完整的物权法律关系。[8]由于法律关系的各种要素都已具备，从而形成完整的法律关系，这种构架模式体现了潘德克顿体系的严谨性和科学性。在我国民法典制定过程中，这种体系化的构建模式对我们具有重要的参考意义。我们需要以民事法律关系为民法典体系构建的骨架，整合现行的零散的民事法规，建立逻辑清晰、结构严密、体系完整的民事权利体系。

第二，民事法律关系理论对整个民法学的建立和发展具有重要意义。“法书万卷，法典千条，头绪纷繁，莫可究诂，然一言以蔽之，其所研究和所规定者，不外法律关系而已。”[9]民法学作为以民法为研究对象的学科，不是孤立地研究个别的民法规范，而是从整体着眼，将民法体系作为研究的对象，而法律关系正是贯穿始终的一根红线，它将民事主体、客体、行为、各种民事权利等诸要素整合为一体，形成清晰

的脉络。民法学作为具有自身特点与体系的独立学科，其研究体系与论述方式的展开，也是建立在民事法律关系各项要素的基础上的。民法学在一定意义上就是民事法律关系之学。

第三，从方法论上看，民事法律关系是指导理论研究人员与司法实务工作者解决实践问题的基本思维模式与思考方法。司法审判人员在处理民事纠纷时，都需要将当事人置放在具体的民事法律关系中，分析该具体法律关系的主体、客体以及当事人的权利义务关系，把握权利的产生、变更、消灭，这样才能公正裁判，正确地解决各种民事纠纷。例如，在解决某个纠纷时，先需要判断所涉及的是侵权法律关系还是违约法律关系，如果是合同关系，那么究竟是一个合同关系还是两个合同关系，该合同关系的内容、性质究竟为何。这就是正确审理民事案件所应当遵循的基本思路。

第二节 民事法律关系的要素

一、民事法律关系的要素概述

民事法律关系的要素是指构成民事法律关系的必要因素。任何民事法律关系都由几项要素构成，要素发生变化，具体的民事法律关系就随之而变化。

关于法律关系的要素，民法学界有三种观点：一是三要素说，即认为民事法律关系的要素包括主体、客体和内容；二是四要素说，认为民事法律关系的要素包括主体、客体、内容和责任；三是五要素说，认为民事法律关系的要素除了主体、客体和内容之外，还应当包括民事权利、义务的变动以及变动的原因。所谓变动的原因实际上就是法律事实，而变动本身就是指法律事实所产生的法律效果。

本书认为，民事法律关系要素仅限于三个要素，即主体、客体和内容，这是任何法律关系都应具备的，民事法律关系也不例外。而五要素说将法律事实包含在法律关系当中，这是值得商榷的。法律事实本身指的就是社会生活中的能引起法律关系产生、变更、消灭这一后果的事实。民事法律关系都是不断变动的，考察任何一种民事法律关系都应当了解其变动的原因及变动的效果，这就意味着必须查找一定的法律事实，但是法律事实毕竟是外在于法律关系的，它是将抽象的法律规范与具体的法律关系加以连接的中间点，是使客观的权利变为主观的权利的媒介，但它本身并不是法律关系的要素。只有在考察法律事实之后才能明确其引发了何种法律关系，而在明确了该种法律关系之后已经无须再考察法律事实了。

那么，民事责任能否作为法律关系的一个要素呢？本书认为，民事责任在性质上是违反民事义务的法律后果，因此责任是法律关系遭到破坏、违反而产生出来的新的法律关系。例如，合同法律关系被违反后就产生了违约责任，而违约责任本身就是一种法律关系，同理，因侵权行为而引发的侵权责任就是侵权法律关系。所以，民事责任本身就是法律关系的一种，是原有的法律关系的变异形态，而非法律关系的要素。

二、民事法律关系的具体要素

民事法律关系包括主体、内容和客体三个要素。

（一）民事法律关系的主体

民事法律关系的主体，简称民事主体，是指参加民事法律关系，享有民事权利并承担民事义务的人。在我国，民事主体包括公民、法人和非法人组织，国家在一些场合也是民事法律关系的特殊主体。任何个人和组织要成为民事主体，必须由法律赋予其主体资格。

在具体民事法律关系中，一般都要有双方或多方当事人参加。在参加民事法律关系的当事人中，享有权利的一方是权利主体，承担义务的一方是义务主体。在某些民事法律关系中，一方只享有权利，另一方只承担义务。而在大多数民事法律关系中，双方当事人既享有权利，又承担义务。

民事法律关系的每一方主体可以是单一的，也可以是多数的。例如，在债权债务关系中，债权人和债务人每一方都既可以是一个人，也可以是多个人。在相对法律关系中，每一方主体都是特定的，而在绝对法律关系中，则承担义务一方是不特定的任何人。

（二）民事法律关系的内容

民事法律关系的内容，是指民事主体所享有的权利和承担的义务。任何个人和组织作为民事主体，参与民事法律关系，必然要享有民事权利和承担民事义务。

民事权利，是指由国家强制力予以保障的类型化的民事主体所享有的利益，这种法律之力和特定利益的结合则构成权利。民法是权利法，各种民事权利的共同因素包括：权利主体、权利客体、权利变动的原因、权利的救济、权利的时间因素。[10]我国《民法总则》系统、全面地确认了民事主体所享有的各项民事权利，并规定了民事权利行使的原则与限制，以及因侵害民事权利所应当承担的民事责任等，从而确定了民事法律关系的基本内容。

民事义务，是指义务人为满足权利人的要求而为一定的行为或不为一定的行为的法律负担。它具体包括：（1）义务人必须依据法律的规定或合同的约定，为一定的行为或不为一定的行为，以便满足权利人的要求；（2）义务体现为一种负担，义务通常以满足权利人的需要为目的，而并非满足义务人自身的目的；（3）义务具有强制性。民事义务是一种受到国家强制力约束的法律义务，如果义务人不履行其义务，将依法承担法律责任。民事义务和民事权利一样，也是由国家法律确认的，它规定了义务主体的行为范围，即义务人必须这样做或那样做，违反义务将转化为法律上的责任。

在民事法律关系中，权利和义务是相互对立、相互联系在一起的。《民法总则》第131条规定：“民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。”该条对义务必须履行原则作出了规定。在通常情况下，权利和义务都是一致的，权利的内容要通过相应的义务表现，而义务的内容则由相应的权利限定，离开了民事义务就无所谓民事权利。当事人一方享有权利，必然有另一方负有相应的义务，并且权利和义务往往是同时产生、变更和消灭的。因此，民事权利和民事义务是从不同的角度表现民事法律关系的内容的。

（三）民事法律关系的客体

民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所指向的对象。如果没有客体，民事权利和民事义务就无法确定，更不能在当事人之间分配权利、义务。

关于民事法律关系的客体，理论界有不同的看法。有人认为客体是物，也有人认为客体是物和行为。本书认为，关于民事法律关系的客体，应当区分不同的民事法律关系确定：就物权法律关系而言，其客体应为物；就知识产权法律关系而言，其客体应为智力成果；就债权法律关系而言，单纯的物和行为一样，都不能作为债权法律关系的要素，只有把它们结合起来，即结合成“体现一定物质利益的行为”[11]，才能成为债权法律关系的客体，如买卖关系中的客体是交付买卖标的物的行为，运输关系中的客体是安全、及时送达运输标的物的行为。

第三节 民事法律事实

一、民事法律事实的概念和意义

民事法律事实，是指依法能够引起民事法律关系产生、变更或消灭的客观现象。法律可以根据统治阶级利益的需要，规定一些事实条件，在发生这些事实以后，就使民事法律关系产生、变更和消灭。这些由法律规定的、能够产生一定法律后果的事实，就是法律事实。法律事实是法律现象产生的原因，是依法能够引起民事法律关系产生、变更和消灭的客观现象。法律事实的特点在于：

1. 它是一种客观存在的社会生活中出现的事实，而不是当事人主观的内心意思。在法律事实中，有的与人的意志相关，有的则与人的意志无关，但不论当事人的意思如何，法律事实都是外在于主观意思而存在的客观事实[12]，如自然现象等，就行为而言，必须是表露于外的事实，单纯的内心意思无法产生法律效果。

2. 法律事实必须能够引起一定的法律后果。社会生活中出现的事实，并非都与法律规定有关，也并非都能产生一定的法律效果。例如，朋友亲戚相聚交谈、邻里之间相互串门等，不可能产生法律意义。法律事实不仅可能引起当事人预期的特定的法律效果，也可能引起当事人预期之外的其他法律后果。例如，当事人订立的合同符合法律的强行性规范且不违反社会公共利益时，就能够产生合同法律关系。如果该合同是无效合同，此时虽然不引起当事人预期的法律后果，但仍产生诸如返还财产、赔偿损失等法律后果。法律事实出现时，产生如下法律后果：

第一，引起民事法律关系的产生。只有通过法律事实，才能使民事法律所规定的权利、义务，转化为当事人实际享有的权利和承担的义务。

第二，引起民事法律关系的变更。因法律事实的出现而导致民事法律关系的变更通常包括：主体变更、内容变更和客体变更。

第三，引起民事法律关系消灭，使主体之间的权利、义务不再存在。例如，物质资料被消费使该物的所有权关系消灭，债务的清偿使债的关系消灭。

法律事实与法律后果之间，可能具有一定的因果联系，也可能不具有直接的因果联系，而某个法律后果的发生，可能是多种法律事实相互作用的结果，所以，法律事实与法律结果之间的联系是复杂的。我国台湾地区学者黄茂荣认为，法律事实与一定的法律后果间属于三段论的逻辑推论关系，因为二者间并不是一一对应关系。此观点可值赞同。[13]

3. 法律事实能否引起一定的法律后果或者引起何种特定的法律后果，最终都取决于法律的规定。社会生活中的各种事实，有的是由法律规范的，有的是由道德、宗教等规范的，只有为法律规范支配的事实，才是法律事实。

二、民事法律事实的分类

根据客观事实是否与人的意志有关，法律事实可以分为事件和行为两大类。

事件，又称为自然事实，是指与人的意志无关，能够引起民事法律后果的客观现象。例如，人的死亡使继承人取得继承遗产的权利，物的灭失引起所有权关系的消灭等。

行为，是指人的有意识的活动。行为可以分为以下几种类型：

1. 民事法律行为，是指行为人旨在确立、变更、终止民事权利义务关系的行为。有的民事法律行为符合法律的要求，能够达到当事人预期的目的，称为有效的民事法律行为；有的民事法律行为不符合法律的要求，不能达到当事人预期的目的，发生与当事人的意志相悖的法律后果，称为无效的民事法律行为。民事法律行为是最主要的民事法律事实。

2. 事实行为，是指行为人实施一定的行为时在主观上并没有产生、变更或消灭某一民事法律关系的意识，但由于法律的规定，同样会引起一定的民事法律后果的行为。事实行为有合法的，也有不合法的。从事智力创造活动，拾得遗失物、漂流物等属于合法的事实行为；侵害国家、集体的财产或他人的人身、财产则是不合法的事实行为。

民事法律关系的产生、变更和消灭，有时只以一个法律事实为根据，有时需要以两个或两个以上的法律事实的相互结合为根据。例如，遗嘱继承法律关系，就需要立遗嘱的行为和遗嘱人死亡这两个法律事实才能够发生。这种引起民事法律关系的产生、变更或消灭的两个以上的法律事实的总和，称为民事法律关

系的事实构成。要求事实构成的民事法律关系，只有在事实构成具备的情况下，才能引起民事法律关系的产生、变更和消灭。

思考题

1. 如何理解民事法律关系的概念和特征？
2. 如何理解民事法律关系在民法体系构建中的意义？
3. 如何理解民事法律关系的客体？
4. 简述民事法律关系的构成要素。
5. 简述民事法律事实的类型划分。

[1]王泽鉴. 民法总则. 北京：北京大学出版社，2009：37.

[2]郑玉波. 民法总则. 北京：中国政法大学出版社，2003：94.

[3]孙国华主编. 法理学教程. 北京：中国人民大学出版社，1994：463-466.

[4]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京：法律出版社，2001：122.

[5]彭万林主编. 民法学. 修订版. 北京：中国政法大学出版社，1997：224.

[6]Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, Bd. I, Berlin, 1840. I331 f. 7.

[7]罗伯特·霍恩等. 德国民商法导论. 楚建译. 北京：中国大百科全书出版社，1996：70-71.

[8][9]郑玉波. 民法总则. 北京：中国政法大学出版社，2003：95.

[10]杨代雄. 私权一般理论与民法典总则的体系构造. 法学研究，2007（1）.

[11]佟柔主编. 民法原理. 北京：法律出版社，1983：33.

[12]江平主编. 民法学. 北京：中国政法大学出版社，2007：142-143.

[13]黄茂荣. 法学方法与现代民法. 北京：中国政法大学出版社，2001：201.

第五章 自然人

甲今年16周岁，是某中学的一名学生，平时沉迷于网络游戏，在未经其父母同意的情形下，甲向乙借款2 000元用于购买游戏卡，乙向甲的父母追讨欠款时，甲的父母拒绝追认甲的借款行为，并拒绝偿还甲的借款。

简要评析：该案中，甲16周岁，在法律上属于限制民事行为能力人，仅能够从事与其年龄、心智状况相适应的法律行为，其从事的行为超出其年龄、心智状况的，该行为在效力上属于效力待定的民事法律行为，只有得到其法定代理人的追认才能发生法律效力，其法定代理人拒绝追认的，该行为无效。在该案中，甲向乙借款2 000元，显然已经超出了其年龄、心智状况，该借款行为在性质上属于效力待定的民事法律行为，甲的父母拒绝追认该行为时，该法律行为无效，甲的父母也无须向乙偿还该借款。

第一节 自然人的民事权利能力

一、自然人的概念

民事主体是一个特定的法律范畴，是指依照法律规定能够参与民事法律关系，享有民事权利和承担民事义务的人。民事主体是“私法上的权利和义务所归属之主体”[1]。民法上，“人”既包括自然人，也包括法人。所谓自然人，是指依自然规律产生，具有五官百骸，区别于其他动物的人。自然人既是一个生物学意义上的概念，又是一个法律概念。

我国《民法通则》第二章规定了自然人的法律地位，但该章标题为公民（自然人），而《民法总则》修改了这一规定，明确以“自然人”作为章名，并且将自然人的民事权利能力、民事行为能力、宣告失踪、宣告死亡等规则都规定在该章中，具有重要意义。本书认为，与《民法通则》的规定相比，《民法总则》采用“自然人”的表述更为科学，因为一方面，“自然人”概念更符合民法的私法特点。公民是公法领域中主体的称谓，它是指具有一国国籍的自然人。而在私法领域中，主体的范畴包括自然人。另一方面，“自然人”概念更有利于彰显民事权利能力平等的理念。采用“自然人”的概念，进一步强调了各个自然人，不分国籍，在权利能力上一律平等，从而为权利能力的平等奠定了基础。[2]自然人不仅包括本国公民，还包括外国公民和无国籍人。如果在民法中仍然使用公民的概念，则将使我国公民之外的自然人难以获得民法赋予的民事主体资格，从而不能保护这些自然人的民事权利。

二、自然人民事权利能力的概念和特征

（一）自然人民事权利能力的概念

自然人的民事权利能力是自然人依法享有民事权利和承担民事义务的资格，它是每个自然人平等地享有民事权利、承担民事义务的可能性。民事权利能力，在罗马法中称为“人格”，据学者考证，第一次在法律上使用近代意义上的权利能力概念，是学者泽勒（Franz von Zeiller）所起草的《奥地利民法典》。[3]19世纪中期，萨维尼在其名著《当代罗马法体系》中，区分了权利能力与行为能力的概念。[4]《德国民法典》也采纳了权利能力的概念，并将其视为法律意义上的人的本质属性。权利能力，首先是指人能成为权利的主体的能力。[5]任何社会组织要成为权利主体，必须在民法中被赋予承受法律关系的资格。唯具有主体资格者，才可以成为权利主体或法律关系的主体。

（二）自然人民事权利能力的特征

从总体上看，自然人民事权利能力主要具有如下特点：

1. 自然人权利能力具有平等性。自然人的权利能力最突出地表现了平等性的特点。我国《民法总则》第14条规定：“自然人的民事权利能力一律平等。”自然人的民事权利能力一律平等，这既是社会主义法治基本原则的具体体现，也是民法调整私法关系的本质要求。它意味着任何自然人，不分性别、民族、出身、职业、职务、文化程度、宗教信仰、政治面貌、财产状况，其民事法律地位一律平等，都可以享有法律所规定的民事权利和承担法律所规定的义务。《民法总则》第12条规定：“中华人民共和国领域内的民事活动，适用中华人民共和国法律。法律另有规定的，依照其规定。”因此，外国人和无国籍人在中国领域内从事民事活动，和中国公民一样，享有平等的民事权利能力。但是，给予外国人的这种待遇通常是以该外国人所属国家对等地给予我国公民国民待遇为前提的。

权利能力概念的产生最精确地表达了自然人之间的平等性，但这种平等只是一种抽象的地位或资格的平等，并非指在具体的法律关系当中，当事人之间的具体权利义务上的平等。在例外的情况下，某些主体的权利能力应有所限制，如受破产宣告的人、筹备中的法人、未经许可的外国法人等，有学者将其能力称为相对权利能力。

2. 自然人的民事权利能力具有普遍性。在近现代世界各国民法中，都承认外国人和无国籍人具有民事权利能力。因为如果不承认其具有民事权利能力，则可能影响国际上的民事往来关系。另外，如果外国人和无国籍人不具有民事权利能力，则这些人的生命、健康、身体、财产等基本人权就不能得到保护，这也

有违最基本的人权思想。

3. 权利能力具有不可剥夺性。自然人的权利能力始于出生，终于死亡。一个自然人可能因刑事犯罪而被限制自由，但不能因此而剥夺其民事权利能力。自然人的民事权利能力和民事行为能力除依法律规定并经法定程序加以限制和剥夺外，任何人不得限制或剥夺。

4. 权利能力不得转让和抛弃。权利能力既是主体的基础，也是主体的前提条件，它与主体资格是不可分离的，因此，无权利能力之人不可能成为权利主体，也不能从事任何社会经济活动，所以，权利能力是不能够被抛弃或者与主体相分离的。自然人民事权利能力具有与自然人的身份不可分离和不可转让的属性，个人也不得抛弃其权利能力。

5. 自然人的民事权利能力在内容上具有广泛性。自然人的民事权利能力的内容，是指自然人可以享有的各种民事权利的范围。在我国，自然人的民事权利能力不仅具有平等性，而且在内容上具有广泛性，因而其能够依法享有各种人身权利和财产权利。

民事权利能力的概念是私法文明发展的结晶。从罗马法上不平等的法律人格到近代权利能力一律平等，从法律人格可以被减损、剥夺到近代对权利能力的同等保护，是一个巨大的历史进步。我国确立权利能力制度本身就是对先进的私法文化的继受。我国由于存在几千年的封建专制主义传统，缺乏人格平等的基本理念，现实生活中特权观念、等级观念和大量的不尊重人格平等的现象依然存在，因而需要在法律上确认并宣示人格平等的理念。这也是法律面前人人平等原则的体现。此外，权利能力制度是主体制度的重要内容，没有该概念，主体制度从逻辑体系上将无法构建。权利能力和行为能力是民事主体制度的两大支柱，权利能力是主体参与社会活动的资格，行为能力是主体通过自己的行为取得权利的资格，而权利能力概念是各类民事主体享有权利和承担义务的逻辑起点与前提条件。

（三）民事权利能力与权利

民事权利能力是国家通过法律确认的民事主体享有民事权利和承担民事义务的资格，它是民事主体享有权利和承担义务的基础。权利能力和权利的概念经常容易混淆。应该看到，这两者之间存在密切联系：一方面，权利能力是权利享有的基础；另一方面，人格权如生命健康权的享有也是人格实现的保障。但是两者之间存在明显的区别，表现在：

第一，民事权利能力是享有权利、承担义务的资格，是一种法律上的可能性。只有具有这种资格的人，才能实际享有民事权利和承担民事义务，才能平等地参与民事法律关系。而民事权利是民事主体已经实际享有的现实权利，民事权利都是以一定的实际利益为内容的。

第二，民事权利能力，包括享有民事权利的能力以及承担民事义务的能力。民法中能够享有权利的人，也就是能够承担义务的人，现代民法中没有只能享有权利而不能承担义务的人，也没有只能承担义务而不能享有权利的人。民事权利涉及享有的权利，而不包括民事义务。

第三，民事权利能力是由国家通过法律直接赋予的，归根结底决定于社会的物质生活条件。在不同的社会，法律所规定的权利能力是不同的。而具体的权利，都是由民事主体参与具体的法律关系才能享有[6]，权利的范围不仅决定于社会经济生活条件和法律的规定，有时还取决于一个人的财产状况。

第四，在存续期间上，公民的权利能力始于出生、终于死亡，伴随民事主体的存续过程。权利是权利主体在其存续过程中介入具体的法律关系而取得的，其存续与否由特定法律事实决定。

第五，民事权利能力是享有权利、负担义务的前提，是作为主体资格的基本条件，所以，其与民事主体有着不可分割的联系，它既不能转让，也不得放弃，本人不得自行处分。而权利除了法律另有规定或依其性质或依当事人约定不得处分外，可以自行处分。

（四）民事权利能力与民事诉讼上的当事人能力

所谓当事人能力，又称诉讼权利能力，是指能够成为诉讼当事人的资格，只有具有当事人能力才能成为诉讼当事人。〔7〕此种能力是由民事诉讼法所确定的能力。《民事诉讼法》第48条第1款规定：“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。”这就确认了公民、法人和其他组织具有当事人能力。民事权利能力和诉讼权利能力，也具有密切的联系。

一般来说，具有民事权利能力一定具有诉讼权利能力，但不具有民事权利能力也未必就不具有诉讼权利能力，主要原因在于，实体法上的社团是否具有权利能力或主体资格，往往取决于其是否拥有独立的财产，能否独立承担责任，而对于一些不具有独立财产和独立责任的法人分支机构，在程序法上为了简化诉讼，可以赋予这些组织诉讼法上的主体资格。同时，在许多诉讼中，如确认之诉和形成之诉，本身和责任没有必然联系，所以不能承担独立责任的社会组织，完全可以具有诉讼上的权利能力，不具有民事上的权利能力。例如，法人的分支机构在民法上可能并不具有民事权利能力，却可能成为诉讼主体，即具有诉讼权利能力。至于其能否独立承担责任，则是执行中的问题，也可以在判决中确定。从这一意义上说，具有当事人能力或诉讼主体资格的范围更广。〔8〕

三、自然人民事权利能力的开始

（一）自然人的民事权利能力始于出生

自然人的民事权利能力是自然人享有民事权利、承担民事义务的资格，是自然人的法律人格的要素，它具有与自然人的人身不可分割和不可转让的属性，因此，自然人的民事权利能力是自然人终生享有的。人一旦出生，就应当成为一个民事权利主体，就必须享有民事权利能力，我国《民法总则》第13条规定：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”据此，自然人的民事权利能力应自出生时开始。

何谓出生？出生在性质上属于民事法律事实中的事件。根据郑玉波先生的观点，其应具备的要件为“出”与“生”，两者缺一不可。“所谓‘出’者，乃由母体分离是。所谓‘生’者，乃保持其生命而出是（否则谓之死产），至保持命之久暂，亦非所问。”〔9〕本书认为，出生应当具备如下条件：第一，必须与母体相分离。自然人的权利能力自出生开始，出生就是脱离母体成为独立的有生命的人。第二，必须活着出生。即使只有片刻的生命，也应当肯定其具有权利能力。医学上通常以胎儿出生时有呼吸行为作为生存的证明。如果胎儿出生时是死体的，则不能将其认定为法律意义上的出生。〔10〕

既然出生决定着民事权利能力的产生，是一个重要的法律事实，那么正确地确定出生的时间也就具有重要意义。关于出生的时间，学说主要有三种不同观点，即阵痛说、露出说（又分为一部露出说和全部露出说）与独立呼吸说。本书认为，应当以独立呼吸作为判断出生时间的标准。因为通常情况下，如果胎儿已经独立呼吸，就意味着其已经与母体相分离，成为一个独立的生命体。在某些情况下，即便没有全部露出，但也不可能独立呼吸，此时也应当承认其已经成为一个独立的生命体。《民法总则》第15条规定：“自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。”依据这一规定，自然人的出生时间一般以出生证明记载的时间为准，如果没有出生证明的，或者出生证明没有详细记载自然人出生时间的，则应以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间（如个人居民身份证件记载的时间）为准。

一般来说，自然人的民事权利能力与年龄和健康状况无关。但是，对于某些领域的权利能力，法律特别规定只有达到一定年龄才能具有或有某些疾病的人不能享有。如我国《婚姻法》第6条规定：结婚年龄，男不得早于22周岁，女不得早于20周岁，即是说公民只有达到这个年龄才有结婚的权利能力。《婚姻法》第7条还规定：患有医学上认为不应当结婚的疾病，禁止结婚。因此，患有此类疾病的公民结婚的权利能力自治愈之日起才能取得。这些达到一定年龄才能具有或有某些疾病不得享有的权利能力称为特殊的民事权利能力。

（二）关于胎儿利益的保护

自然人权利能力始于出生，由于胎儿的利益也是需要保护的，所以法律上需要有专门的制度对此作出规制。《民法总则》第16条规定：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”依据该条规定，胎儿并不是民事主体，但其利益仍然受到法律保护。

依据我国《民法总则》第13条的规定，民事权利能力始于出生，因此，胎儿不享有民事权利能力，并不是民事主体。胎儿本身不具有权利能力，法律不能为了保护胎儿的某种特殊的利益，而改变权利能力制度，赋予胎儿权利主体的资格。主要理由是：第一，权利能力的取得必须始于出生，没有出生就不可能作为一个独立存在的生物体享有权利能力，而胎儿在没有出生之前，完全依附于母体，不可能作为区别于母体的一个独立的生物体而存在，所以不能成为具有民事权利能力的主体。第二，享有权利能力必须是一个活着的主体。胎儿在出生以前，不是一个完整的自然人，其是否存活还是一个疑问，也就不能确定其作为权利主体存在。第三，如果胎儿真的具有权利能力，那么胎儿的权利能力的起始期限也难以确定。

2. 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力

胎儿虽然不是民事主体，但其利益仍然应当受到法律保护。比较法上关于胎儿利益保护。有采取具体列举方式和概括规定方式，前者是指法律具体列举胎儿所享有的权益的范围，而后者则概括规定胎儿所享有的一切权益。[11]我国《民法总则》第16条兼采上述两种方式，即一方面具体规定了遗产继承、接受赠与；另一方面又用“等”字概括规定了胎儿所享有的各项权益。依据《民法总则》第16条的规定，胎儿受到法律保护的利益范围如下：一是遗产继承利益。我国《继承法》第28条对胎儿继承时的特留份利益作出了规定，当然，从《民法总则》第16条规定来看，在涉及遗产继承时，胎儿视为具有民事权利能力，这实际上在《继承法》第28条的基础上，扩大了胎儿在遗产继承中的利益范围，其不再限于特留份利益。二是接受赠与。这就是说，在胎儿出生前，如果有人对其作出赠与时，该项赠与有效，胎儿可以保有该赠与利益。此外，《民法总则》第16条在规定胎儿所享有的民事权利的范围时，采用了“涉及遗产继承、接受赠与等”这一表述，表明胎儿所享有的利益并不限于上述两项。例如，在胎儿未出生之前，其健康遭受侵害，也可以在其出生后独立提出损害赔偿的请求。当然，从《民法总则》第16条的规定来看，在涉及胎儿利益保护时，法律将胎儿“视为”具有民事权利能力，这就是说，胎儿本身并不是民事主体，只是在需要受到法律保护的情形下，可以适用民事主体的相关规则对其进行保护。

需要指出的是，该条也可以为胚胎的保护提供法律依据。在现代社会，生命科学、医学的发展，都对人类提出了新的挑战。试管婴儿技术发展以后，美国威斯康星大学的詹姆斯·汤姆森教授（James Thomson）从人类早期胚胎的内层细胞团中分离培养出第一例人体胚胎干细胞系，给人类带来了福音。1978年，第一个试管婴儿在英国诞生，人工生殖技术迅速发展，生命科学的发展也日新月异。如今，人体胚胎技术已经日渐成熟。人体胚胎是一个医学上的词汇，它主要是指受精后的生殖细胞，属于胎儿的前阶段。胚胎不同于胎儿，在医学上，只有在胚胎发育到具有初步的人形后，才能称为胎儿，在此之前的阶段即属于胚胎。胚胎又分为体内胚胎和体外胚胎。前者是在母体内发育的胚胎，其可由自然方式受孕，也可能通过人工授精实现；而后者则是在母体外发育的胚胎，其一般不是通过自然方式受孕的。从我国司法实践来看，有关胚胎的纠纷也开始出现，如著名的“无锡冷冻胚胎案”[12]，《民法总则》对胎儿的利益保护作出规定，也可以为胚胎的保护提供法律依据。

3. 胎儿利益保护的条件是娩出时为活体

关于胎儿视为具有民事权利能力应从何时开始计算，存在两种观点：一种观点认为，胎儿在出生前即具有民事权利能力。如果胎儿娩出时为死体，则溯及地丧失民事权利能力。另一种观点认为，胎儿在出生前并未取得民事权利能力，如果胎儿娩出时为活体，则溯及地享有民事权利能力。[13]依据《民法总则》第16条的规定，“胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在”。该条更接近于前一种观点，也就

是说，在胎儿出生前，可以通过民事权利能力的相关规则对其进行保护。该条所规定的“娩出”是指胎儿从母体内产出，与“出生”这一表述相比，娩出这一表述更符合医学标准，也更加规范。这就是说，如果胎儿娩出时是死体的，则视为胎儿自始不具有民事权利能力。因此，胎儿在娩出前因继承、接受赠与等原因所取得的利益，也自始不享有。例如，胎儿在接受赠与后，如果娩出时为死体的，则该赠与无效，应当将该财产返还赠与人。

三、自然人民事权利能力的终止

（一）自然人的权利能力终于死亡

自然人死亡以后，自然不能继续成为权利、义务的承担者，其权利能力当然消灭。我国《民法总则》第13条规定：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。”据此，自然人的权利能力因死亡而终止。也就是说，死亡之后，自然人不能再作为民事主体享有民事权利、承担民事义务。

死亡是一种自然事件，也是引起法律关系变动的重要的法律事实，与民事权利能力的终止联系在一起。自然人的民事权利能力既然为自然人终生享有，那么，它就只能在自然人死亡时终止。死亡包括生理死亡和宣告死亡。生理死亡也称为自然死亡，是指自然人生命的自然终结。自然人死亡以后应当由医院和有关部门开具死亡证明书，自然死亡的时间一般应以死亡证明书上记载的时间为准。

自然人死亡以后，不当再作为民事主体享有权利并承担义务，但是法律在例外情况下需要对公民死亡后的某些利益进行保护。不过，关于死者利益保护的原因，应当区分各种具体情况而分别考察。民事权利以利益为内容，这种利益是社会利益和个人利益的结合，一个人死亡后，其已不可能再享有实际权利中包含的个人利益，但某些权益中可能包含了公共利益的因素，因此在自然人死亡后，仍需要对这种利益进行保护。而且，损害这些利益，将直接影响到曾经作为民事主体存在的该自然人的人格尊严。法律保护这些利益，体现了法律对民事主体权益保护的完整性，也有利于引导人们重视个人生前死后的声誉，维护社会公共道德和秩序。[14]

（二）生理死亡的时间认定

生理死亡的时间直接关系到民事主体是否存在、原权利义务是否变更、继承是否开始等，这就需要准确判断生理死亡的时间，因此，其在民法上具有一定的法律意义。关于自然死亡的时间，主要有三种学说，即心脏跳动停止说、呼吸停止说、脑电波消失说。本书认为，关于死亡时间的认定，应当按照医学标准来确定，目前大多数医学专家主张，脑电波消失说比较科学，也在临床中逐渐被采纳，因此，采纳这一观点认定死亡时间有一定的道理。

如何具体确定生理死亡的时间，需要有一定的证据证明。我国《民法总则》第15条对生理死亡时间的证明规则作出了规定，该条规定：“自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。”依据该条规定，首先，按照死亡证明所记载的时间确定自然人的生理死亡时间；其次，如果没有死亡证明，则以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为自然人的生理死亡时间。当然，死亡毕竟是一个事实问题，因此，如果死亡证书中记载的时间与公民死亡的真实时间有出入，则应以事实为准。

在特殊情形下，如果数人在同一事件中死亡的，可能难以确定每个人的死亡时间顺序，这可能带来继承法上的难题。对此，1985年最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国继承法〉若干问题的意见》第2条规定：“相互有继承关系的几个人在同一事件中死亡，如不能确定死亡先后时间的，推定没有继承人的人先死亡。死亡人各自都有继承人的，如几个死亡人辈份不同，推定长辈先死亡；几个死亡人辈份相同，

推定同时死亡，彼此不发生继承，由他们各自的继承人分别继承。”

第二节 自然人的民事行为能力

一、自然人的民事行为能力的概念和特点

自然人的民事行为能力，是指自然人能够以自己的行为行使民事权利和设定民事义务，并且能够对于自己的违法行为承担民事责任，简言之，是自然人可以独立进行民事活动的能力或资格。其特点在于：

1. 独立进行民事活动的能力。人们对自己的行为后果并不是都能认识清楚的，如果许可一切人都可独立地进行活动，势必会对一些缺乏判断能力的人不利，也不能进行公平的交易。因此，法律规定，不具备认识能力的人的行为是无效的，不能发生法律后果。

2. 以意思能力为基础。自然人的民事行为能力是公民对自己的行为后果承担责任，使自己的行为发生法律效力。因此，一个人要具备承担自己行为后果的能力，首先应具备认识这种行为的能力，即要以意思能力为基础。

3. 法定性。自然人的民事行为能力与人的认识能力有关，但它不是以自然人个人的意思为标准的，也不是“天赋”的，而是由国家法律赋予的。所以除法律规定的情况和依法定程序外，任何人不得剥夺和限制公民的民事行为能力。

法律上规定自然人的民事行为能力，其根本原因在于：一是保护无行为能力和限制行为能力人的利益。行为能力欠缺，意味着欠缺独立行为的能力，因此其在交易中容易受到损害。所以，法律有必要规定一个标准，使那些不具有或欠缺意思能力的人不能自由行为，即不能通过自己的积极活动，去设定权利义务关系，行使权利、履行义务，从而保护这些行为能力欠缺的人的利益。二是保护交易的安全和秩序。如果任何人可以其无行为能力而主张交易无效，这对交易安全的保护是不利的，所以，对行为能力应规定严格、明确的标准。总之，法律正是根据公民的个人利益和社会利益的需要来规定自然人的民事行为能力的。有民事行为能力必然有民事权利能力，而有民事权利能力并不一定就具备民事行为能力。

二、民事行为能力与民事权利能力

具备了民事主体资格，要实际地参与民事活动，还必须要有民事行为能力。民事行为能力，就是法律所认定的形成意思的能力^[15]，即主体能够独立地以自己的行为取得权利、承担义务的资格。主体能否独立认识和判断自己行为的性质和后果并对自己的行为作出选择，从而具备形成意思的能力，通常是由法律确认的。

民事权利能力和民事行为能力是主体制度中的两项重要内容。没有民事权利能力，就失去了主体资格，也就不可能具有行为能力。但是仅有权利能力，而没有行为能力，也不能通过自己的行为去享有权利和承担义务。具体来说，二者的区别表现在：

第一，民事权利能力是成为民事主体的资格，而民事行为能力是能够以自己的行为从事民事活动的资格^[16]，换言之，它是法律认定的意思能力。有权利能力的人，如果不具备法定的意思能力，就没有行为能力。但反过来说，任何具备行为能力的人，都具有权利能力。

第二，民事权利能力具有普遍性，而行为能力不具有普遍性。任何人都具有权利能力，权利能力也不需要特别认定，更不需要通过某种程序来认定。而对自然人来说，在何种情况下具有行为能力，首先要达到一定的标准。其次，对于一些因健康等原因欠缺足够的意识能力的人认定其行为能力，要经过特殊的程序。对于自然人来说，权利能力都是平等的，但行为能力却可能因人而异。

第三，民事权利能力是不受限制和剥夺的，而民事行为能力却可以依据法律规定的原因和程序作出限制。例如，精神病人可以被认定为限制民事行为能力人或无民事行为能力人。

第四，民事行为能力以意思能力的存在为基础，而民事权利能力不以意思能力的存在为基础，不受年龄、精神状况和身体条件的限制。

三、自然人的行为能力和责任能力

所谓责任能力，又称为不法行为能力或过失责任能力，是指对自己的过失行为能够承担责任的能力。[17]需要指出的是，也有学者认为，责任能力，是指“以自身违法行为负损害赔偿义务的能力”[18]。责任能力包括侵权责任能力、违约责任能力和其他责任能力。[19]但由于责任能力在侵权法中最为重要，所以各国对侵权责任能力都有明确规定[20]，而对于违约责任能力则规定准用侵权责任能力之规定。[21]我国《民法通则》第133条第1款规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担民事责任。监护人尽了监护责任的，可以适当减轻他的民事责任。”该条规定在第六章第三节“侵权的民事责任”名下，可见，我国对于责任能力的规定仅仅限于侵权责任能力。

本书认为，责任能力与行为能力有着密切的联系，但也不完全等同于行为能力。凡是具有民事行为能力者，均具有民事责任能力。[22]从意思能力的角度来看，责任能力也要求有意思能力。但是民事行为能力和责任能力又有区别，主要表现在：第一，就侵权责任而言，现代民法为了对受害人遭受的损害给予充分的补救，在分配责任的时候，不仅仅要考虑过错，还要考虑如何对受害人的损害予以充分救济，这就要突破意思能力的局限，使行为能力和责任能力分开。因此，无行为能力人致人损害，其监护人应当负责。侵权责任中的公平原则，更是注重行为人是否具有责任财产，所以财产也称为责任能力的基础。第二，行为能力实际上是以理性的判断能力为基础的，而责任能力是以对不法行为的识别能力为基础的，因此，行为能力的判断标准显然要高于责任能力的判断标准。第三，行为能力的判断标准是由法律统一规定的，即由年龄和智力状况来进行判断。而对责任能力的判断，则要根据每个具体不法行为人的意思能力和财产等分别进行判断。[23]

四、民事行为能力的划分

（一）完全民事行为能力

所谓完全民事行为能力，是指自然人能以其自己的行为独立享有民事权利，承担民事义务的资格。《民法总则》第17条规定：“十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。”第18条第1款规定：“成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。”依据上述规定，18周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，《民法总则》作出此种规定是合理的，因为一方面，根据我国宪法规定，年满18周岁的公民享有选举权和被选举权，且在社会生活交往中，一般认为18周岁的人为成年人，已经具有相当的社会经验和知识，能够独立地生活和就业，因此，年满18周岁的人应为完全民事行为能力人。另一方面，对18周岁以上的自然人而言，其已经成年，对外界各种情况已经有了自己独立的判断能力，可以独立实施各种民事法律行为，有必要规定其为完全民事行为能力人。

《民法总则》第18条第2款规定：“十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。”所谓“以自己的劳动收入为主要生活来源”，包括两个方面：第一，具有一定的劳动收入，即依靠自己的劳动获得了一定的收入，如工资、奖金等。这种收入应当是固定的，而不是临时的、不确定的。第二，其劳动收入构成其主要生活来源。也就是说，其劳动收入能够维持其生活，不需要借助其他人的经济上的资助，也可以维持当地群众的一般生活水平。[24]此处所说的“视为”属于法律上不可推翻的推定。“视为”完全民事行为能力人，亦即“即是”。我国《民法总则》作出上述规定的主要原因在于，法律上对于自然人是否具有行为能力的规定，是对所有的自然人的民事行为能力的一般规

定，但每个自然人的情况并非完全相同，是否具有完全民事行为能力，其情况也可能是有差别的，因此法律上有必要设定例外规定。《劳动法》第15条规定，16周岁以上的自然人就享有劳动权。因此，16周岁以上的公民能够参加劳动，并可能有一定的收入，完全否定其具有完全的行为能力，也不一定妥当。所以，我国《民法总则》第18条规定，以自己的劳动收入为主要生活来源的，可以视为完全民事行为能力人。

（二）限制民事行为能力

限制民事行为能力，又称为不完全民事行为能力，是指自然人部分独立地，或者说在一定范围内具有民事行为能力。根据《民法总则》的规定，限制民事行为能力人有两种：一是8周岁以上的未成年人，《民法总则》第19条规定：“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。”该条将限制民事行为能力人的年龄下限从《民法通则》规定的10周岁降低为8周岁，降低的主要原因在于，随着经济社会的发展和受教育水平的提高，未成年人的生理心理成熟程度和认知能力较以往有了一定的提高，适当降低限制民事行为能力人的年龄下限，有利于其从事与其年龄、智力状况相适应的民事活动，这也是尊重未成年人自主意识的体现，有利于保护其合法权益。[25]

二是不能完全辨认自己行为的成年人。一些成年人（如精神病人）也可能因精神、智力障碍而不能完全辨认自己行为的内容与法律后果，不能独立实施一些民事活动，其也应当属于限制民事行为能力人。对此，《民法总则》第22条规定：“不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。”

对于限制民事行为能力人来说，法律只允许其独立从事纯获利益的民事法律行为及与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，具体而言：

第一，纯获利益的民事法律行为。有的国家立法在限制民事行为能力人可以实施的法律行为时，采用了纯获法律上利益的表述。例如，《德国民法典》第107条规定：“[法定代理人的允许]对于未成年人并不因之而纯获法律上的利益的意思表示，未成年人必须得到其法定代理人的允许。”依据这一规定，凡是双务合同，实际上都会使未成年人负担一定的义务，都不属于该条所规定的纯获法律上利益的民事行为。[26]我国《民法总则》第19条并没有采用《德国民法典》的表述，而是采用了“纯获利益的民事法律行为”这一表述，所谓纯获利益的民事法律行为，是指限制民事行为能力人从某项民事法律行为中纯粹获得利益而不负有负担，或者虽然负有负担，但所获得的利益明显高于负担的民事法律行为。这就是说，一方面，限制民事行为能力人如果仅从某项民事法律行为中纯粹获得利益，则该民事法律行为应当属于纯获利益的民事法律行为。此类民事法律行为类似于比较法上的纯获法律上利益的民事法律行为。二是在某项民事法律行为中，限制民事行为能力人虽然有一定的负担，但该负担明显小于其所获得的利益，则也应当将该民事法律行为认定为纯获利益的民事法律行为。例如，如果未成年人获得的利益远远高于其承受负担所遭受的不利益，那么这种合同也可以认为是纯获利益的合同。此外，就附负担的赠与而言，如果限制民事行为能力人所负担的明显小于其因赠与而获得的利益，则也应当将该附负担的赠与认定为纯获利益的民事法律行为。

第二，与其年龄、智力及精神健康状况相适应的民事法律行为。依据《民法总则》第19条与第22条的规定，限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄、智力及精神状况相适应的民事法律行为。具体而言，对未成年人而言，其可以独立实施与其年龄、智力状况相适应的民事法律行为。因为从8周岁至18周岁跨度有10年，17周岁的未成年人与8周岁的未成年人的认知状况是不同的，应当区别对待。还应当看到，即便是同一年龄的未成年人，其智力状况也有一定的差别。例如，虽然都是8周岁，但有的未成年人心智发育较早，有的未成年人心智发育较晚，因此，应当区别对待。对不能完全辨认其行为的成年人来说，其可以独立实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。与限制民事行为能力人年龄、智力及精神健康状况

相适应的民事法律行为主要是指日常生活必需的行为。限制行为能力人应当可以从事一些日常生活所必需的交易，否则会不当限制其行为的自由，也会给其生活造成不便。在王泽鉴教授看来，此类行为如理发、购买零食、学生购买文具用品、少女购买脂粉等，固不待言；就现代社会生活而言，它尚应包括看电影、适当玩玩电动玩具、去儿童乐园坐云霄飞车等在内。〔27〕

限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事法律行为，则应当由其法定代理人代理实施。对此，《民法总则》第23条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。”依据该条规定，限制民事行为能力人的监护人为其法定代理人，限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事法律行为，应当由其监护人代理实施，否则应当属于效力待定的民事法律行为。

依据《民法总则》第19条与第22条的规定，在经法定代理人允许的情形下，限制民事行为能力人可以独立实施各类民事法律行为。法定代理人的允许既可以是事先的同意，也可以是事后的追认。具体包括两种：一是事先同意。也就是说，限制民事行为能力人的法定代理人可以事先同意或者授权该限制民事行为能力人实施民事法律行为，在此情形下，即便该民事法律行为超出了该限制民事行为能力人的年龄、智力发展状况，其也是有效的。例如，父母授权子女在300元范围内购买一辆自行车，只要其子女是在300元内购买自行车，就应认为已得到父母的允许。当然，该限制民事行为能力人应当在其法定代理人允许的权限范围内行为。二是事后追认。追认就是事后表示同意。从这一规定可以看出，此类行为并不是一概被认定为无效，而是将其作为效力待定的民事法律行为。这就是说，对限制行为能力人实施的依法不能独立实施的行为，在法律上既不是当然无效，也不是当然有效，其是否有效，要取决于其法定代理人是否追认。限制民事行为能力人有权实施一些与其年龄、智力状况相适应的民事行为，除此以外的其他比较复杂及重大的民事法律行为，则应当由其法定代理人代理或征得其法定代理人同意后进行。

（三）无民事行为能力

所谓无民事行为能力，是指自然人无独立从事民事活动的资格，也就是说，不具有以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的资格。在我国，无民事行为能力人包括两类：一是不满8周岁的未成年人，对此，《民法总则》第20条规定：“不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”二是不能辨认自己行为的人。对此，《民法总则》第21条第1款规定：“不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。”依据该条规定，如果成年人因为智力、精神状况等原因而无法辨认自己的行为，则应当属于无民事行为能力人。《民法总则》第21条第2款规定：“八周岁以上的未成年人不能辨认自己行为的，适用前款规定。”依据《民法总则》第19条的规定，年满8周岁的未成年人属于限制民事行为能力人，但如果其不能辨认自己的行为，则也应当属于无民事行为能力人。对于不能辨认自己行为的自然人而言，从保护其利益出发，法律规定其为无民事行为能力人是十分必要的。

依据《民法总则》第20条与第21条的规定，对无民事行为能力人而言，其不能独立实施任何民事法律行为，而必须由其法定代理人代理实施。因此，无民事行为能力人所实施的民事法律行为都是无效的。但根据《民法通则意见》第6条的规定，“无民事行为能力人、限制民事行为能力人接受奖励、赠与、报酬，他人不得以行为人无民事行为能力、限制民事行为能力为由，主张以上行为无效”。本书认为，无民事行为能力人通常不能辨认和理解自己的行为，因此不能独立实施民事法律行为。但在特殊情形下，无民事行为能力人可以实施如下两类行为：一是纯获利益的行为，例如，接受赠与、奖励等。对此类行为，也必须从严解释，即只能对未成年人有利，而不能给其增加任何负担，这些行为应当予以允许。二是日常生活必需的细小的行为。无行为能力人也可能会从事一些日常生活所必需的行为，例如乘坐公交车和地铁、购买早点或零食。如果这些行为所涉金钱数额不大，且与其年龄和智力相符合的，其可以实施。允许无民事行为能力人实施上述行为，有利于保护无民事行为能力人的利益，同时，也有利于保护交易安全。

五、自然人民事行为能力的宣告

（一）申请认定自然人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人

在自然人因智力、精神健康状况等原因而不能辨识或者不能完全辨识自己的行为时，相关主体有权申请人民法院认定该自然人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。《民法总则》第24条第1款规定：“不能辨识或者不能完全辨识自己行为的成年人，其利害关系人或者有关组织，可以向人民法院申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。”依据该条规定，申请认定自然人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人需要具备如下条件：

第一，被认定人为不能辨识或者不能完全辨识自己行为的成年人。从该条规定来看，其仅适用于成年人，未成年人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人不需要人民法院的认定，而可以直接依据其年龄来判断。同时，被认定人应当是不能辨识或者不能完全辨识其行为的自然人，即该自然人因为智力发育不成熟，或者因为精神健康状况方面的原因，导致其辨识能力不足。从比较法上看，有的国家设置了禁治产制度，适用于因醉酒、服用麻醉品等人，但我国并不存在禁治产制度，无民事行为能力人或限制民事行为能力人的认定仅适用于不能辨识或者不能完全辨识自己行为的人。

第二，必须经利害关系人或者有关组织申请。认定自然人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人必须依据利害关系人或者有关组织申请，法院不能依职权主动认定。所谓利害关系人，是指与被申请宣告的人有利害关系的人，如精神病人的配偶、父母、成年子女以及其他亲属等。法院不得主动进行宣告。所谓有关组织，依据《民法总则》第24条第3款规定，具体包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、民政部门等。只有利害关系人或有关组织才能提出申请。

第三，须经人民法院认定。行为能力的认定涉及个人的行为自由，也涉及交易安全，因此，任何人不得单方认定他人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人，而必须由人民法院予以认定。人民法院在认定某一自然人为无民事行为能力或限制民事行为能力人时，必须确定其辨识能力的状况，具体进行认定。

（二）民事行为能力的全部和部分恢复

《民法总则》第24条第2款规定：“被人民法院认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，经本人、利害关系人或者有关组织申请，人民法院可以根据其智力、精神健康恢复的状况，认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或完全民事行为能力人。”该条对民事行为能力的全部或者部分恢复作出了规定，依据该条规定，民事行为能力的全部和部分恢复应当具备如下条件：

第一，必须针对被人民法院认定为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的成年人。一方面，如果不是被人民法院认定为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，则不能适用该条所规定的民事行为能力的恢复规则。另一方面，从该条规定来看，其仅适用于成年人民事行为能力的恢复，如果未成年人因为年龄增长而取得限制民事行为能力或完全民事行为能力，则不需要通过该条所规定的程序取得相应的民事行为能力。

第二，必须经本人、利害关系人或者有关组织申请。依据该条规定，人民法院不能依职权主动宣告某自然人恢复相应的民事行为能力，其必须经申请才能作出相应的认定。请求恢复民事行为能力的申请人包括本人、利害关系人或者有关组织。具体来说，一是本人。民事行为能力的恢复关系本人的切身利益，因此，与认定自然人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的申请不同，被认定恢复相应民事行为能力的自然人本人也可以提出相应的申请。二是利害关系人。此处的利害关系人主要是指该自然人的近亲属、债权人等。[28]三是有关组织。依据《民法总则》第24条第3款规定，可以提出申请的“有关组织”具体包括：居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、依法设立的老年人组织、

民政部门等。

第三，根据成年人的智力、精神健康恢复的状况决定是否恢复。人民法院在认定是否有必要全部或者部分恢复某人的民事行为能力时，主要是考虑其智力、精神健康恢复状况。如果法院在考虑其智力、精神健康状况后认为其已经能够完全辨识自己的行为，则应当认定其已恢复完全民事行为能力；如果该自然人只恢复到部分辨识自己的行为，则应当认定其恢复为限制民事行为能力人。在必要时，可能需要医院提供相关的诊断证明，以确定其智力、精神健康恢复状况。

需要指出的是，该条所规定的民事行为能力的恢复包括两种情形，即恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。这就是说，民事行为能力的恢复并不意味着一概恢复为完全民事行为能力人，而是由人民法院根据该自然人的智力、精神健康恢复的情况，具体认定其恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。

六、自然人民事行为能力的终止

自然人民事行为能力的终止是指民事行为能力的消灭。自然人的民事行为能力因一定的法律事实而取得，也因一定法律事实而终止。《民法总则》第13条规定：“自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力。”因此，自然人的主体资格因死亡而终止，自然人死亡后，其民事行为能力也因此终止。死亡是自然人民事行为能力终止的法律事实。因为自然人一旦死亡，其民事权利能力终止，其就不再是民事权利主体，因而也就不可能再从事民事活动。当然，自然人民事行为能力的终止应当是基于自然死亡，在宣告死亡的情形下，如果某自然人仍然处于生存状态，则其民事行为能力并不因此终止。

自然人因智力、精神健康状况而被宣告为无民事行为能力，并非意味着其民事行为能力终止。在此应当区分民事行为能力的终止与民事行为能力的中止的概念：民事行为能力的中止是自然人民事行为能力的一时丧失，而终止则是永远的消灭。自然人因智力、精神健康状况被宣告为无民事行为能力人时，其民事行为能力一时丧失，在他恢复健康时，可以重新获得行为能力。

第三节 监护

一、监护的概念与特征

所谓监护，是指民法上所规定的对于无民事行为能力人和限制民事行为能力人的人身、财产及其他合法权益进行监督、保护的一项制度。[29]履行监督、保护义务的人，称为监护人，而被监督、保护的人，称为被监护人。从各国立法来看，为对未成年人及无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人进行监督和保护，设立亲权、监护、保护、保佐、辅保等制度，这些制度在内容上各有侧重，不尽相同。我国立法没有作此种区分，而对于无行为能力人和限制行为能力人的监督和保护统一采用监护制度。不过，在我国《民法总则》中，监护包括两个方面：一是未成年人的监护制度，即专门针对未达到法定成年年龄的人所设立的监督和保护制度；二是成年人的监护制度。其中包括了对无民事行为能力、限制民事行为能力的成年人的法定监护与成年意定监护。这两种监护是根据被监护对象的不同而作出的区分，表明两者在监护人的确定等方面存在一定的区别。

监护制度的设立，主要是为了保护无行为能力人和限制行为能力人的合法权益，同时也为了保护交易第三人的合法权益，从而维护社会秩序的稳定、保护交易的安全。关于监护制度究竟应该规定在民法典总则中的自然人部分，还是规定在民法典分则中的亲属法中，之前一直存在争议。《民法总则》选择将其规定在自然人中，不无道理。因为监护制度主要是对自然人民事行为能力的一种补充，应该成为民事行为能力制度的组成部分，而且监护本身并不一定涉及亲属关系，将其规定在亲属法中，难以涵盖所有类型的监护，会人为地割裂监护制度的内容。

监护从其本质上讲，就是对缺乏行为能力人的监督、照顾和辅助制度。法律设立监护制度，一是对被监护人的行为能力予以弥补，因为不具有完全民事行为能力的自然人，不能进行或不能独立进行民事活动，这就难以满足其物质和精神生活的需要，而通过监护制度，由监护人代为或协助其进行民事活动，就能够满足被监护人的物质和精神需求，有效地保护其合法权益；二是通过监护人的设立，可以对其财产和人身等合法利益予以保护和照顾，避免其受到其他人的侵害；三是对被监护人进行监督和管束，防止其实施违法行为，对他人和社会造成损害；四是由监护人作为法定代理人代理被监护人从事民事法律行为，从而保护相对人的合法权益，维护交易安全。

二、监护的性质

关于监护的法律性质，学者历来有不同的观点，主要分为如下几种学说：

1. 权利说。此种观点认为，监护是一种权利。持此种观点的学者把监护统称为监护权，但这种权利主要是身份权[30]，并认为只有从性质上把监护权视为权利，才能使监护人正确、主动地行使权利，并实现监护的目的。也有学者认为，我国《民法通则》第18条第2款规定：“监护人依法履行监护的权利，受法律保护。”这就含有将监护视为权利的意思。

2. 权利义务一体说。此种观点认为，首先，监护在本质上仍然是一种权利，但是要以履行一定的义务为前提和目的，监护是指“对于那些由于年龄或者精神健康原因而不能自我保护的人给予监护和保护、由民法所赋予的必要的权利和义务”[31]。其次，按照法律规定，监护关系的设立不应附带任何条件，监护人不能基于自身利益考虑而决定是否履行其监护之责，只要监护人不履行其监护之责，就要承担相应的责任。

3. 职责说。此种观点认为，监护并不是一种权利，而是一种职责，监护的内容在于保护被监护人的身体和财产，而不是对人的支配的权利。罗马法中就把监护视为一种公职，而不是权利。我国民法设立监护制度，纯粹是为保护被监护人的利益，绝对不允许监护人借监护谋取自身利益。[32]

上述各种观点，都不无道理，但本书认为，监护在性质上不是一种权利，《民法总则》第34条第2款也规定：“监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。”虽然此处使用了“权利”这一表述，但其并不是权利。一方面，任何权利都以一定的实有利益为基础，权利都要体现权利人的利益，而监护制度的着眼点在于保护被监护人的合法权益，由于监护人并不是从监护中获得利益，其主要是为了对被监护人进行照顾和保护，主要体现为义务，因而，一般认为，其属于职责，而非权利。另一方面，如果说监护是一种权利，那么监护人就可以因监护而取得相应的利益，甚至借监护而谋求自身利益（如为了自己的利益不正当地处分被监护人的财产），这显然违背了监护制度的目的。由于监护在性质上并不是权利，因而也不能认为监护是权利义务一体的产物。

从性质上看，监护是一种职责。《民法总则》第34条规定：“监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。”从该条规定来看，监护的主要内容是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的权益，可见，《民法总则》采纳了职责说。因为监护在本质上并不是一种权利，而是一种职责，监护人既享有职权（权利），又负有一定的义务。从整体上看，我国监护制度注重监护人所负有的职责以及对职责的正确履行。任何人作为监护人首先应意识到其对社会和国家负有的责任，而不能根据自己的意志和利益而推卸或不适当地履行此种职责。

监护权与亲权是不同的。所谓亲权，是父母对未成年子女以教养保护为目的，在人身和财产方面所享有的各种权利。其中，人身方面的亲权可分为保护权、教育权和惩戒权，财产方面的亲权可分为财产管理权、使用收益权、处分权和财产上的代理权、同意权。[33]我国现行立法中没有对亲权的概念作出明确规定，所以，有关亲权的一些内容都已经包括在监护权之中。例如，《民法总则》第26条就规定：“父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。”

三、监护的分类

依据被监护人的不同，监护可以分为未成年人监护和成年监护。

（一）未成年人监护

所谓未成年人监护，是指以未成年人为被监护人的监护。依据《民法总则》第27条的规定，未成年人监护的监护人首先是该未成年人的父母，父母对未成年子女的监护因子女出生的法律事实而发生，除因死亡或按法定程序予以剥夺外，任何人不得加以剥夺或限制。父母作为未成年子女的法定监护人，以子女出生这一法律事实为发生原因，一直延续到子女年满18周岁。按照《婚姻法》的规定，养子女和生父母间的权利与义务，因收养关系的成立而解除。因此，未成年人被他人收养后，收养人即应为其法定监护人。在父母离婚后，抚养子女的一方应是未成年子女的监护人。在抚养子女的一方不履行监护职责时，另一方可以请求法院撤销原来的裁决，由自己来担任监护人。

依据《民法总则》第27条第2款的规定，在未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的情形下，可以由其他人或者组织担任监护人。也就是说，在未成年人父母可以担任监护人的情形下，应当由其父母担任监护人，因为由父母担任监护人，最有利于保护未成年人的利益，而且父母一般也会以最有利于子女的方式履行监护职责。此外，由父母担任监护人，也有利于未成年人的成长，因为父母与子女往往具有最亲密的联系。但如果该未成年人的父母已经死亡，或者没有监护能力（如丧失民事行为能力，或者被撤销监护人资格），则应当按照如下顺序确定未成年人的监护人：一是祖父母、外祖父母，二是成年的兄、姐，三是其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。上述主体担任未成年人的监护人时，应当按照先后顺序确定，而且已确定的监护人应当具有监护能力。可以说，此种规定符合我国的社会习惯。在法律上规定监护的顺序有利于解决实践中存在的因监护权发生的各种纠纷，并且有利于明确监护人。

此外，依据《民法总则》第32条的规定，如果没有依法具有监护资格的人，则由民政部门担任监护人，当然，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任监护人。这实际上是对《民法总则》第27条规定的补充，也体现了“以家庭监护为基础，社会监护为保障，国家监护为补充”的理念。对未成年人的监护人，也可以通过法院指定来确定。《民法总则》第31条规定：对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。

《民法总则》在未成年人监护中并没有继续规定《民法通则意见》中的委托监护制度，但《民法通则意见》第22条规定：“监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人。因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，应当由监护人承担，但另有约定的除外；被委托人确有过错的，负连带责任。”一般认为，该条对委托监护制度作出了规定。有观点认为，法律上有必要设置委托监护，这有利于保护未成年人的利益，特别是农村广大留守儿童无人照看，规定委托监护制度有利于保护未成年人的利益。本书认为，《民法总则》未对委托监护制度作出规定是合理的，虽然委托他人承担一定的监护职责在实践中也是常见的，但受托人只是基于委托合同帮助监护人履行一定的监护职责，这并不意味着一定要设置委托监护制度。监护人资格具有人身专属性，不得随意移转，如果允许监护人通过合同移转监护人资格，将不利于保护被监护人的利益，监护制度的目的也难以实现。因此，虽然监护人可以委托他人履行监护职责，但监护人的资格并没有因此移转，监护人与受托人之间的法律关系在性质上应当是委托合同关系，在被监护人造成他人损害时，监护人仍然应当依法承担监护人责任。

（二）成年监护

成年监护，是指依据法律规定和约定对无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人所实施的监护。从《民法总则》的规定来看，成年监护包括两种：一是法定监护，即依据法律规定对无民事行为能力或

限制民事行为能力的成年人所进行的监护，监护人的范围、顺序以及监护人的设定等都是依法进行的。《民法总则》第28条对成年监护的法定监护人作出了规定，即成年监护第一顺序监护人为配偶，第二顺序监护人是父母、子女，第三顺序监护人是其他近亲属，第四顺序的监护人为其他愿意担任监护人的人。二是意定监护，即按照具有完全民事行为能力的成年人与有关个人或组织之间的约定所形成的成年监护。关于意定成年监护，《民法总则》第33条规定：“具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，履行监护职责。”

我国《民法总则》使用多个条款对成年监护制度作出了规定，并强化了对被监护人的成年人权益的保护，突出了对其个人意愿的尊重。规定成年监护具有重要意义：第一，有利于保护老年人的合法权益，适应了老龄社会的发展需要。[34]通常，老年人对外界情况的判断能力和认知能力下降，对外界的风险常常难以作出清晰的判断，这也使其人身权益和财产权益极易遭受侵害，例如，在实践中，老年人常常成为电信诈骗的受害人。第二，符合国际上的发展趋势。随着老龄社会的到来，各国开始重视老年监护制度，即为不能完全处理自身事务的老年人设置监护人，从而对其进行照料和管理的一项民事法律制度。[35]从比较法上看，各国目前主要依靠老年康复协议和老年监护协议等方式推进老年监护制度。一些国家已经开始对老年监护制度作出规定，如一些国家判例要求疗养院应当尽量对老年人进行精神关爱，不得歧视老年人，凸显了维护老年人人格尊严的价值理念。[36]“因高龄化社会来临及社会因素的增加，精神障碍轻重程度有别，应创设较有弹性且周全的新监护制度，以保障精神障碍者的人格尊严，并促进社会安全”[37]。我国成年监护立法的重构需要以法律发展趋势为背景，贯彻尊重自我决定权理念，增设意定监护制度[38]，成年监护应当尽量保障其正常生活，监护人的作用主要是一种辅助作用，而不是纯粹地对被监护人的人身、财产权益进行管理。我国《民法总则》成年监护制度也反映了这一比较法上监护制度的发展趋势。第三，弥补了现行立法的不足。我国《民法通则》仅对未成年人监护作出了规定，而没有对成年监护制度作出一般规定，只是对患有精神病的成年人的监护问题作出了规定，《民法总则》适应老龄社会的发展需要，对成年监护制度作出规定，弥补了《民法通则》规定的不足，完善了我国的监护制度体系。

未成年人监护和成年监护构成了我国民法总则上的监护制度，但二者也存在一定区别，主要在于：第一，被监护人不同。未成年人监护的被监护人是未成年人，而成年监护的被监护人是成年人。第二，监护职责不同。关于未成年人监护中监护人的监护职责，《民法总则》第35条第2款规定：“未成年人的监护人履行监护职责，在作出与被监护人利益有关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监护人的真实意愿。”关于成年监护中监护人的监护职责，《民法总则》第35条第3款规定：“成年人的监护人履行监护职责，应当最大程度地尊重被监护人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。”从上述规定可以看出，在未成年人监护中，监护人对被监护人能够独立处理的事务，应当尊重被监护人的真实意愿。而在成年监护中，监护人应当最大限度地尊重被监护人的真实意愿，并且监护人应当协助被监护人实施与其年龄、精神健康状况相适应的民事法律行为，在被监护人处理其有能力独立处理的事务时，监护人不得干涉。第三，在成年监护中，监护人的职责主要是协助被监护人处理事务，而在未成年人监护中，监护人的职责则更多地体现为监督和照管。第四，法定监护人的顺序不同。关于未成年人监护中监护人的顺序，《民法总则》第27条规定：“父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”关于成年法定监护中监护人的范围，《民法总则》第28条规定：“无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）配偶；（二）父母、子女；（三）其他近亲属；（四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”可见，两种监护中法定监护人的顺序存在一定差别。第五，是否允许意定监护不同。对未成

年人监护而言，为保护未成年人的利益，不允许当事人进行意定监护，而依据《民法总则》第33条的规定，成年监护可以进行意定监护。

四、监护的设定

我国《民法总则》构建监护制度的基本思路，是要构建以家庭监护为基础，以社会监护为补充，以国家监护为保障的监护制度。从《民法总则》第32条规定来看，“没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任”。可见，在没有监护人的情形下，由民政部门或者具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任监护人，这就形成了国家治理和社会治理的良性互动。关于监护的设立，从我国《民法总则》的规定来看，其主要规定了法定监护、意定监护、遗嘱监护和指定监护几种方式。

（一）法定监护

1. 法定监护的概念和特征

所谓法定监护，是指监护人由法律直接规定的监护。关于法定监护的类型，我国《民法通则》仅规定了未成年人的法定监护，《民法总则》在此基础上对成年人的法定监护作出了规定。法定监护具有如下特征：

一是监护人范围具有法定性。《民法总则》第27、28条分别对未成年人和成年人的法定监护人作出了规定，可以看出，不论是未成年人的法定监护，还是成年人的法定监护，监护人的范围都是法定的。

二是监护人具有法定的顺序。与其他类型的监护不同，在法定监护中，各个具有监护资格的人在担任监护人时，存在一定的顺序限制，即只有顺序在前的人无法担任监护人时，顺序在后的人才能担任监护人。在实践中，确实存在不少监护争议，如争当监护人或者相互推诿，如果没有法定的顺序，则法院对此类纠纷就缺乏解决的依据。

三是监护的对象具有特定性。从《民法总则》的规定来看，法定监护的被监护人具有特定性，即限于未成年人、无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人。由于未成年人、无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人的认知能力较弱，因而，在法定监护中，监护人的监护职责主要是对被监护人进行监管和照顾；而在成年意定监护中，监护人的职责更多地是对被监护人从事民事活动进行协助。

2. 法定监护的监护人范围

（1）未成年人法定监护人的范围

《民法总则》第27条规定：“父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”该条对未成年人的法定监护人范围作出了规定，依据该条规定，未成年人的法定监护人包括：

第一，未成年人的父母。在未成年人父母能够担任监护人的情形下，首先由父母担任未成年人的法定监护人。因为一般情况下，父母能够在最大限度内实现子女的利益，由其作为第一顺序的法定监护人，有利于保护未成年人的利益；同时，由父母担任第一顺序的监护人，也能够为未成年人提供更好的成长环境，更能够实现监护制度的目的。父母作为未成年子女的法定监护人，以子女出生这一法律事实为发生原因，一直延续到子女年满18周岁。亲子血缘关系和子女未成年状态是这一监护关系设立和存在的自然基础。在此意义上，可以说父母是未成年子女与生俱来的、当然的监护人，法律只不过加以确认而已。父母是子女的第一顺序监护人，父母对未成年子女的监护因子女出生的法律事实而发生，除因死亡或按法定程序予以剥夺外，任何人不得加以剥夺或限制。关于担任未成年人监护人的父母的范围，我国《婚姻法》第26条规定：“养父母和养子女间的权利和义务，适用本法对父母子女关系的有关规定。养子女和生父母间的权

利和义务，因收养关系的成立而消除。”第27条规定：“继父或继母和受其抚养教育的继子女间的权利和义务，适用本法对父母子女关系的有关规定。”因此，作为未成年人监护人的“父母”除该未成年人的生父母外，还包括养父母和有抚养关系的继父母。同时，应当指出的是，在收养关系成立的情形下，应当由养父母担任未成年人的监护人，与养父母相比，生父母并不享有担任未成年人监护人的优先权。

第二，其他近亲属及个人或组织。如果未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力，则依据《民法总则》第27条，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：第一，祖父母、外祖父母；第二，兄、姐；第三，其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。从《民法总则》第27条的规定来看，上述主体在担任未成年人的监护人时，应当按照法律规定的顺序进行。如果未成年人祖父母、外祖父母、兄、姐以外的愿意担任未成年人的监护人，其在担任监护人时应当经该未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意，以避免上述人担任监护人不适当造成未成年人的损害。此外，在未成年人法定监护中，《民法总则》改变了《民法通则》的规定，不再将单位作为未成年人的监护人，因为在社会主义市场经济条件下，单位与职工之间是劳动合同关系，就业人员具有很强的流动性，单位缺乏履行监护职责的意愿，也不具有担任监护人的能力。《民法总则》第27条所规定的“组织”主要是指社会公益组织，因为随着我国公益事业的发展，有监护意愿和能力的社会组织增多，由公益组织担任未成年人的监护人，可以作为家庭监护的有益补充。

（2）成年人法定监护人的范围

《民法总则》第28条规定：“无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）配偶；（二）父母、子女；（三）其他近亲属；（四）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”因此，成年人法定监护的范围如下：

一是配偶。与未成年人法定监护不同，在成年人法定监护中，第一顺序的监护人是被监护人的配偶，而不是其父母。法律之所以作出此种规定，主要是因为配偶与被监护人长期生活在一起，与其关系更为密切，相互之间更为熟悉，而且被监护人的配偶对其生活习惯也更为熟悉，由其作为第一顺序的监护人更为合理，更有利于被监护人的权益保护。配偶关系因婚姻的合法成立而生效。我国以夫妻进行结婚登记、取得结婚证的时间为配偶关系开始时间。当然，一旦一方死亡或者双方离婚，则配偶关系也随之终止。

二是父母、子女。在成年人的配偶无法担任监护人时，由成年人的父母或者子女担任。成年人的父母或者子女具有监护能力的，则在成年人配偶不能担任监护人时，应当担任监护人，履行监护职责。

三是其他近亲属。依据《民法通则意见》第12条的规定，近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。但《民法总则》第28条所规定的“其他近亲属”应当是除被监护人的配偶和父母、子女以外的近亲属。

四是其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。从该条规定来看，其并没有对能够担任成年人法定监护人的范围进行严格限制，任何个人和组织都可以担任成年人的法定监护人，但其担任成年人的法定监护人应当具备如下条件：一是其他个人或者组织愿意担任。二是应当取得被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。防止因为监护人设置不当，侵害被监护人的利益。三是其他个人或者组织具有担任监护人的能力。

《民法总则》第30条规定，依法具有监护资格的人之间，可以协议确定监护人，协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。《民法总则》第30条规定了协议监护，但必须符合几个条件：第一，必须是在依法具有监护资格的人之间进行协商，但要尊重监护人的法定顺序。例如，在父母有多个子女，或者未成年人有多个兄弟姐妹时，究竟由何人担任监护人，可以协商确定。第二，协议监护必须是父母以外的人，不能通过协议将父母排除在监护人的范围之外。第三，要尊重被监护人的真实意愿。具有监护资格的数人在进

行协商确定时，要考虑被监护人的真实意愿。也就是说，通常在协商时应当征求被监护人的意见。[39]需要指出的是，该条规定的依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人，仍然属于法定监护的一种，而非意定监护。虽然协议确定监护人也可以适用于未成年人监护，但该协议只能在依法具有监护资格的人之间订立，因此，其应当属于法定监护的范畴。

（二）意定监护

所谓意定监护，依据《民法总则》第33条的规定，是指具有完全民事行为能力的成年人与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定，在其丧失或者部分丧失民事行为能力时由该监护人履行监护职责的监护。《民法总则》第33条关于意定监护的规定源自《老年人权益保障法》，该法第26条第1款规定：“具备完全民事行为能力的老年人，可以在近亲属或者其他与自己关系密切、愿意承担监护责任的个人、组织中协商确定自己的监护人。监护人在老年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，依法承担监护责任。”当然，《民法总则》也在《老年人权益保障法》的基础上，对其做了进一步完善，如强调书面形式等，以防止发生争议。

从《民法总则》的第33条规定来看，意定监护具有如下特征：

第一，仅适用于具有完全民事行为能力的成年人。从该条规定来看，只有成年人才能通过协议确定自己的监护人。同时，只有具有完全民事行为能力的成年人才能通过协议确定自己的监护人，因为完全民事行为能力人具有辨认自己行为后果的能力，所以，法律上允许其可以通过协议确定监护人，安排自己的事务，规划好自己的生活。如果成年人是无民事行为能力人或限制民事行为能力人，则无法通过协议确定自己的监护人。[40]

第二，监护人的范围较为广泛，不限于法定监护人，也不受法定监护人顺序的限制。从《民法总则》第33条的规定来看，意定监护的监护人范围并不限于法定监护人，设定意定监护的成年人的近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织都可以成为其监护人，这也赋予成年人较大的选择监护人的自由。

第三，需要采用书面形式。《民法总则》第33条要求当事人设定意定监护必须采用书面形式。由于意定监护的内容直接关系到被监护人的重大权益，而且在设定监护的成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，监护人才开始履行监护职责，此时可能因为距离协议订立时间较为久远，或者因为设定监护的成年人民事行为能力欠缺等原因，使准确确定协议的内容较为困难，因此，为准确确定意定监护协议的内容，减少可能发生的争议，《民法总则》要求设定意定监护必须采用书面形式。

第四，在设定意定监护的成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，监护人才开始履行监护职责。也就是说，当事人订立协议与监护人履行监护职责之间有一定的时间间隔，当事人在订立意定监护协议时，设定意定监护的成年人仍属于完全民事行为能力人，并不需要他人的监护，只有在其丧失或者部分丧失民事行为能力时，协议所设定的监护人才开始履行监护职责。这就是说，只有在监护设定人丧失或者部分丧失民事行为能力时，监护人才开始履行监护职责，因为在其未完全或者部分丧失民事行为能力时，在客观上并不需要被监护。[41]

还应当看到，意定监护制度能够更好地尊重当事人的意愿：一方面，成年监护中的法定监护主要是对精神病人的监护，而成年人在其丧失行为能力之前，可以根据自己的意愿，选择适当的人作为其未来的监护人，这也是私法自治原则的重要体现。而且与指定监护相比，允许成年人通过协议设定监护人，也能够更好地尊重其意愿。另一方面，在意定监护中，当事人在选择监护人时，既不受法定监护人范围的限制，也不受监护顺序的限制，更不需要其住所地的居民委员会、村民委员会的同意，这就能够最大限度地尊重当事人的意愿。

（三）遗嘱监护

遗嘱监护是指被监护人的父母在担任监护人期间，通过遗嘱的方式为被监护人指定监护人的监护制度。我国《民法总则》第29条规定：“被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。”该条对遗嘱监护制度作出了规定。《民法总则》增加了遗嘱监护，规定未成年人的父母在死亡前指定对子女对有利的监护人，这借鉴了比较法上的经验，同时也有利于贯彻我国监护制度中的被监护人利益最大化原则。依据该条规定，遗嘱监护具有如下特征：

第一，能够设定遗嘱监护的是被监护人的父母。我国监护制度的基本原则之一，是要实现未成年人利益的最大化，而父母在设定遗嘱监护时，能够从最有利于保护子女利益的角度出发，实现子女利益的最大化。从比较法上来看，各国也都只允许父母通过遗嘱指定监护人。当然，如果被监护人的父母都是监护人的，则父母一方不得通过设定遗嘱的方式排除另一方的监护人资格，因为父母都是第一顺位的法定监护人，任何一方不得通过设定遗嘱的方式排除另一方的监护人资格。

第二，遗嘱监护既适用于未成年人监护，也适用于成年监护。遗嘱的方式通常适用于在父母去世前，因担忧被监护人没有合适的监护人会遭受人身财产损害，所以，通过遗嘱的方式，为被监护人指定监护人。这一制度主要适用于未成年人监护，但也可以适用于成年人监护。

第三，被监护人父母在设定遗嘱监护时必须具有监护人资格。如果其父母已经被取消监护资格，则不能通过遗嘱指定监护人。尽管该条并没有提到，在设定遗嘱监护时需要实现被监护人利益的最大化，但此处实际推定，由父母通过遗嘱指定监护人，最有利于实现被监护人利益的最大化。

第四，在遗嘱监护的情形下，所指定的监护人不受《民法总则》第27条、第28条关于监护人范围以及顺序的限制。从《民法总则》第29条的规定来看，其只是规范被监护人的父母可以通过遗嘱为被监护人指定监护人，而没有对被指定的监护人的范围作出限制，可见，被指定的监护人的范围并不受法定监护顺序的限制。

第五，遗嘱监护的生效需要被指定的人同意担任监护人。通过遗嘱指定监护人，是否需要被指定人接受？从《民法总则》第30条关于协议确定监护人的规定来看，监护人之间可以协商确定由谁担任监护人。但《民法总则》第29条规定的遗嘱监护中并没有提及是否需要尊重被指定人意愿。本书认为，如果被指定人必须无条件接受，则在性质上就不属于遗嘱监护；如果遗嘱所指定的人拒绝担任监护人，则该指定不发生效力，因此必须被指定人接受担任监护人的指定。此外，遗嘱监护仍然应当考虑被监护人的真实意愿，因为立遗嘱人都是被监护人的父母，通常其指定的人都是符合被监护人的意愿的。如果确实不利于被监护人，也可以通过法律程序变更监护人。

第六，遗嘱监护以遗嘱人的死亡作为生效要件。遗嘱作为一种死因法律行为，其生效应以遗嘱人死亡为条件，也就是说，只有设定遗嘱的人死亡后，遗嘱监护才能生效。

（四）指定监护

《民法总则》第31条第1款规定：“对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。”该条规定了指定监护制度，依据这一规定，指定监护包括两种类型：

1. 由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人。《民法总则》第27、28条虽然规定了监护人的顺序，但同一顺序的当事人可能会对监护人资格产生争议，如对当事人担任监护人的资格等发生争议，或者相关当事人因不愿担任监护人而发生争议。依据《民法总则》第31条第1款的规定，当事人就监护人的确定发生争议的，则由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，如果当事人对该指定不服，则可以向人民法院申请指定监护人。

2. 由人民法院指定监护人。从该条规定来看，由人民法院指定监护人包括两种情形：一是当事人对被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定的监护人不服的，可以由人民法院指定监护人；二是人民法院也可以直接依据有关当事人的申请指定监护人，而不需要经过被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人这一阶段。可见，与《民法通则》规定相比，《民法总则》实际上是扩大了法院在指定监护人方面的权力。

关于监护人的指定，《民法总则》第31条第2款规定：“居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。”依据这一规定，居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院在指定监护人时，应当遵循如下规则：一是按照被监护人利益最大化的原则和尊重其意愿的原则指定。也就是说，如果被监护人有一定的识别能力，在指定监护人时应当征求被监护人的意见，同时，也要充分考虑具有监护资格的人的品行、身体状况、经济条件以及能够为被监护人提供的教育水平或者生活照料措施等，综合进行判断。[42]二是应从有监护人资格的人中指定。《民法总则》第27条、第28条对未成年人监护和成年人监护的监护人范围作出了规定，居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院在指定监护人时，应当在上述规定所确定的监护人范围中指定。不过，虽然《民法总则》第27条、第28条在指定监护人范围时，设定了一定的顺序限制，但居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院在指定监护人时，并不需要严格按照这一顺序指定，而只需要在尊重被监护人意愿的情况下，按照被监护人利益最大化原则指定即可。指定监护人时，被指定的监护人既可以是一个，也可以是数个。

在指定监护人之前，被监护人的人身、财产等权益可能处于无人照管的状态，例如，某个老人因为没有子女，其配偶也无法担任监护人，在申请居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院指定监护人之前，该老人处于无监护人的状态，其人身、财产权益随时可能遭受他人侵害，此时，就有必要相关主体担任临时监护人。《民法总则》第31条第3款规定：“依照本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。”这就是说，出现上述情形时，可以由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人，这些主体也应当履行监护职责。

在指定监护人的情形下，监护人一旦确定，就不得随意变更，对此，《民法总则》第31条第4款规定：“监护人被指定后，不得擅自变更；擅自变更的，不免除被指定的监护人的责任。”依据该条规定，在指定监护人后，因相关主体擅自变更监护人而使被监护人遭受损害的，则监护人应当承担不履行监护职责的责任。

五、监护人的职责及其履行

（一）监护人监护职责的内容

《民法总则》第34条采用的是“监护人的职责”这一表述，因此，在监护关系中，监护人负担的是监护职责，其应当是权利与义务的结合。《民法总则》第26条规定：“父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。”第34条规定：“监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。”依据上述规定，监护人的监护职责包括如下内容：

一是代理被监护人实施民事法律行为。《民法总则》第23条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。”依据该条规定，在法定监护中，监护人是被监护人的法定代理人，代理被监护人实施民事法律行为。在指定监护中，监护人是在被监护人丧失或者部分丧失民事行为能力时

才开始履行监护职责，监护人也需要代理被监护人实施部分民事法律行为。监护制度的首要目的在于弥补被监护人行为能力的不足，监护人作为被监护人的法定代理人，可以以被监护人的名义进行民事活动，为被监护人取得和行使权利、设定和履行义务。

二是保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益。监护制度的重要目的是对被监护人进行照管，因此，保护被监护人的人身、财产及其他合法权益也是监护人监护职责的重要内容。《民法总则》第34条规定：“监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。”该条所规定的“法律责任”一般是侵权责任，但在意定监护中，监护人不履行监护职责也可能构成违约。

（二）监护人监护职责的履行

《民法总则》第34条规定，监护人依法履行监护产生的权利受法律保护。也就是说，监护人在依据法律规定或者约定履行监护职责时，任何个人或组织不得进行非法干涉。依据《民法总则》第35条的规定，监护人履行监护职责应当遵循如下原则：

1. 按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护制度设立的主要目的是对被监护人进行保护和照顾，因此，监护人在履行监护职责时，应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。比较法上普遍采纳了这一原则。[43]所谓最有利于被监护人，就是说，监护人要根据被监护人的实际情况来行使监护职责，充分地保护被监护人的财产、人身和其他利益。[44]例如，被监护人有财产的，监护人应努力使被监护人的财产保值、增值，而不能浪费；如果被监护人生病的，则监护人应当及时将其送医救治；如果被监护人处于受教育阶段的，则监护人应当使被监护人尽量获得好的教育。在判断监护人履行监护职责是否最有利于被监护人时，应当结合监护事项的特点、对被监护人利益的影响、监护人的监护能力等多种因素加以判断。

2. 不得擅自处分被监护人的财产。监护制度的目的在于对被监护人进行管理和照顾，其既包括对被监护人的人身权益进行照顾，也包括对被监护人的财产进行照管，这尤其体现在成年监护中。监护人在履行监护职责时，一般只是对被监护人的财产进行管理，而不能通过被监护人的财产为自己谋利。依据《民法总则》第35条的规定，除为维护被监护人利益的情形外，监护人不得处分被监护人的财产。

3. 尊重被监护人的意愿。我国《民法总则》秉持人文关怀的理念，从关爱、保护被监护人考虑，要求监护人在履行监护职责时，应当尽可能尊重被监护人的意愿。《民法总则》在尊重被监护人的意愿方面，又区分未成年人监护和成年人监护，分别作出了规定，具体来说，应从两方面考虑：

第一，在未成年人监护中，依据《民法总则》第35条第2款的规定，监护人在作出与被监护人利益有关的决定时，应当根据被监护人的年龄和智力状况，尊重被监护人的真实意愿。在未成年人监护中，未成年人毕竟心智发育不全，判断能力不足，其所作出的判断可能并不是最佳判断，监护人不能完全按照未成年人的意愿行为。

第二，依据《民法总则》第35条第3款的规定，成年人的监护人履行监护职责，应当最大限度地尊重被监护人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。由于成年人相对于未成年人而言，其认知能力和判断能力更强，因而，《民法总则》要求监护人必须最大限度地尊重被监护人的真实意愿。所谓最大限度，就是指监护人应当尽可能地尊重被监护人的意愿，由被监护人作出决定，在作出决定时，监护人只是起到一种保障并协助的作用。[45]例如，城市中许多老人都有自己的房屋，但老年人愿意以房养老，或者愿意将房屋以多少价格出售，或者将房屋长期出租等，这些事务究竟应当如何处置，监护人应当尽可能听取老年人的意愿，如果老年人有能力独立处理这些事务，就应当由其独立决定，监护人主要起到一种保障与协助的作用。在处分被监护人的财产时，监护人不能决定在房价涨到最高时，就代其出卖房屋。如果被监护人能够独立作出决定，则监护人只是提供意见供被监护人参考，最终还是由被监护人独立作出决定。

六、监护的终止

监护因一定的事实而发生，也因一定的法律事实而终止。监护设立的根据不同，终止的原因也不相同。《民法总则》第39条规定：“有下列情形之一的，监护关系终止：（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力；（二）监护人丧失监护能力；（三）被监护人或者监护人死亡；（四）人民法院认定监护关系终止的其他情形。”依据这一规定，监护主要因下列原因而终止：

（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力

对于未成年人的监护，自被监护人成年之日起，监护即终止。成年是一个法律事实，受监护的未成年人一旦年满18周岁，就成为成年人，具有完全民事行为能力，可以独立地进行民事活动。此时，监护当然终止。如果被监护人是精神病人，当其痊愈以后，经利害关系人申请，由人民法院撤销对其作出的监护的裁决，才能导致监护关系终止。如果被监护人是因其他原因导致失去全部或部分民事行为能力的成年人，则当其恢复完全民事行为能力时，监护关系终止。

（二）监护人丧失监护能力

监护关系的成立以监护人具有行为能力为条件。监护人如果在履行职责过程中，丧失民事行为能力，也就根本不可能履行监护职责，从而自然应当导致监护关系终止。例如，监护人在履行职责过程中，突然患病陷入昏迷而丧失民事行为能力，就无法继续担任监护人。

（三）被监护人或者监护人死亡

监护关系是由双方当事人即监护人与被监护人共同构成的，任何一方的死亡，都将导致监护关系的终止。如果被监护人死亡，则监护关系就不必存在，而监护人死亡，则无人履行监护职责，监护关系自然也应当终止。

（四）人民法院认定监护关系终止的其他情形

如果存在人民法院认定监护关系终止的其他情形，则监护关系也应当终止。例如，在监护人不依法履行其监护职责，或者滥用监护人资格损害被监护人利益时，人民法院可以根据有关人员或者单位的申请，在查明事实后，撤销监护人的监护资格，从而导致监护关系终止。此外，如果有关当事人有正当理由，也可以向法院申请变更监护人，该申请若得到法院许可，也可导致原监护关系终止。

监护人在一般情况下，不得抛弃其监护资格，也不得要求辞去监护，但如果确有正当理由使其不能履行监护职责，可以向指定机关提出申请，请求辞去监护资格。一般来说，辞去监护仅适用于指定监护的情况，而不能适用于法定监护。

《民法总则》第39条第2款规定：“监护关系终止后，被监护人仍然需要监护的，应当依法另行确定监护人。”虽然出现了上述原因导致监护关系终止，但在某些情况下，被监护人仍然需要监护。例如，监护人死亡后，被监护人仍未成年，仍然需要监护人，此时就应当依照《民法总则》的相关规定，重新确定监护人。如果由人民法院撤销监护人资格的，在撤销的同时，法院也应当依法重新指定监护人。

七、监护人资格的撤销

（一）撤销条件

所谓撤销监护资格，是指监护人在履行职责期间，从事了严重侵害被监护人权益的行为，被取消其监护资格的行为。法律之所以规定撤销监护人资格制度，主要是为了保护被监护人的合法权益，对监护人进行监督。在监护关系设定后，监护人因各种原因已经无法或者未能履行职责，从保护被监护人利益角度考虑，有必要规定监护资格撤销制度。《民法总则》第36条第1款规定：“监护人有下列情形之一的，人民法

院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：（一）实施严重损害被监护人身心健康行为的；（二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的；（三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为的。”这就对撤销监护人资格的原因和条件等作了明确规定。依据这一规定，撤销监护人资格的条件，包括如下几种：

第一，实施严重损害被监护人身心健康行为。监护制度的本意，是实现对被监护人的照管、保护，如果监护人对被监护人实施了严重损害其身心健康的行为就构成撤销的事由，例如监护人对被监护人实施性侵害，对被监护人进行暴力殴打、虐待等行为，都会严重损害被监护人的身心健康。此处所说的严重侵害，是针对被监护人的人身权益，而不是针对财产的伤害，而且侵害行为必须达到造成严重损害的后果的程度。

第二，怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态。具体而言，又可分为如下几种：一是怠于履行监护职责，导致被监护人处于危困状态的。监护人本应尽到对被监护人利益最大化的保护，但监护人不作为，怠于履行监护职责。〔46〕例如，监护人明知被监护人挨饿受冻，而拒绝提供食物和衣物，使被监护人处于可能冻死饿死的危急状态，则可能导致其监护资格的撤销。二是无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态的。如果监护人因各种原因而无法履行监护职责，例如监护人因吸毒、赌博、身患重病等原因而无法履行监护职责，在此情形下，监护人应当尽快将监护职责委托给他人行使。如果监护人及时将监护职责委托给他人行使，则并不会导致自身的监护资格被撤销。只有当监护人自己无法履行监护职责，并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人时，才应导致监护资格的撤销。在上述两种情形下，如果导致被监护人的权益受到重大损害、被监护人处于危困状态的，则将会发生监护人监护资格被撤销的情形。此处所说的被监护人处于危困状态，是指被监护人的人身权益受到重大威胁或侵害，例如被监护人处于挨饿、受冻状态，或者居住在危楼之中，极不安全。在此情形下，就会导致监护人监护资格的撤销。

第三，实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。该条是一个兜底条款，只要出现了其他严重侵害被监护人合法权益的行为，都可能导致监护人监护资格的撤销。例如，监护人恶意侵占被监护人的财产，导致被监护人合法的财产权益受损。

（二）指定临时监护人

监护人资格被撤销之后，如果没有及时指定新的监护人，则被监护人就处于无人监护的状态，对其十分不利。如被监护人的人身、财产都处于无人监护的状态，极易遭受第三人的侵害。因此，依据《民法总则》第36条第1款，人民法院根据有关个人或者组织的申请，在撤销监护人资格以后，应当为被监护人安排必要的临时监护措施。所谓临时监护措施。就是为了在短期内起到保护被监护人权益的作用而采取的一些监护措施。例如，将被监护人安置在医院、看守所等场所，委托医院负责看护等。在采取这些措施的同时，人民法院也应当按照最有利于被监护人的原则依法指定临时监护人。

（三）申请撤销的主体

并非任何人都有权申请撤销监护人的监护资格。只有了解被监护人的情形、能够为其提供照顾、保护等措施的人，或者与被监护人有一定利害关系的人，才能作为主体申请撤销监护资格。关于申请撤销监护资格的主体，《民法总则》第36条第2款规定：“本条规定的有关个人和组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。”在这些机构中，居民委员会、村民委员会都是群众性的自治组织，有义务办理一些公益性的事业，防止被监护人的利益受到侵害。至于学校、医疗机构、妇女联合会、残疾

人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等机构，也都与被监护人的成长、生活相关，对被监护人负有照顾、保护等义务。而且该条还使用了“等”字，就表明列举的这些机构并不是完全列举，并不局限于这些机构。这一规定作为兜底性的规定，尽量扩大了有权申请撤销监护资格的主体范围。

此外，《民法总则》第36条第3款还规定：“前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。”这就规定了民政部门在其他个人或组织均未及时提起撤销申请时的申请义务。民政部门作为政府的职能部门，负有保护未成年人的义务，其本身就应当承担一定的社会救助义务，这样规定，可以防止出现无人申请的情况。我国的监护制度是以家庭监护为基础，以社会监护为补充，以国家监护作为保障的监护制度，这一规定实际上也强化了国家在监护中的义务，因此，在相关主体未向人民法院申请撤销监护人的，民政部门负有提出申请的义务。

（四）抚养费、赡养费、扶养费的支付

《民法总则》第37条规定：“依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。”监护资格与扶养义务是区分的。抚养、赡养、扶养是法定的义务，是基于血缘等关系而确立的，这些义务不因监护关系的终止而终止。依《婚姻法》规定，法定扶养关系有如下几种：一是父母对未成年子女有抚养的义务。二是夫妻之间的相互扶养义务，这就是说，依据《婚姻法》第20条的规定，夫妻之间有相互扶养的义务。三是依据《婚姻法》第21条的规定，成年子女对父母负有赡养的义务。上述义务都是法定的义务，不因监护关系的撤销而终止，即便监护资格被撤销，上述义务仍然应当履行。

（五）监护资格的恢复

某人的监护资格被撤销后，并不意味着其永远丧失监护资格，在一定条件下也可以恢复。《民法总则》第38条规定：“被监护人的父母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。”依据这一规定，监护资格的恢复必须具备如下几个条件：

第一，被撤销监护资格的人确有悔改表现。该条规定仅适用于被撤销监护资格的自然人，主要包括两类人：一是被监护人的父母；二是被监护人的子女。如果这些人确有悔改的表现，则人民法院可以考虑恢复监护人的监护资格。当然，监护人不能仅有悔改意愿，而且必须有悔改的行为。监护人是否有悔改的表现，应当由人民法院根据具体情形予以判断。〔47〕

第二，提出申请，愿意继续担任监护人。监护资格的恢复应当按照法定程序进行，监护人监护资格的恢复应当由监护人提出申请，愿意继续担任监护人。因此，即便监护人有悔改表现，且被监护人愿意恢复监护关系，该监护关系也不能当然恢复，而必须由人民法院依据法定程序予以恢复。

第三，被监护人愿意恢复。监护人监护资格的恢复应当尊重被监护人的意愿，这也有利于保障被监护人的健康成长。因此，在监护资格被撤销后，即便其确有悔改表现，但如果被监护人不愿意恢复其监护人资格，则人民法院仍然不能恢复其监护资格。

第四，不存在监护人实施故意犯罪的情形。根据2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为若干问题的意见》第40条的规定，监护人具有下列情形之一的，一般不得判决恢复其监护人资格：（1）性侵害、出卖未成年人的；（2）虐待、遗弃未成年人6个月以上、多次遗弃未成年人，并且造成重伤以上严重后果的；（3）因监护侵害行为被判处5年有期徒刑以上刑罚的。

第三节 宣告失踪

一、宣告失踪的概念

所谓宣告失踪，是指自然人离开自己的住所下落不明达到法定的期限，经利害关系人申请，人民法院依照法定程序宣告其为失踪人的一项制度。在自然人下落不明的情形下，其财产将处于无人照管的状态，而且其债权人和债务人也难以主张权利或者履行义务，这可能影响经济秩序的稳定，对多方当事人的利益产生影响。这就有必要在法律上设置宣告失踪制度，并通过设置财产代管人的方式，对失踪人的财产进行管理，从而保护失踪人的利益，及时了结相关的债权债务关系。

宣告失踪的目的是通过人民法院确认自然人失踪的事实，并通过设置财产代管人管理失踪人的财产，并及时了结其债权债务关系，以保护失踪人和利害关系人的利益，从而维护社会经济秩序的稳定。从比较法上看，许多国家的立法都对宣告失踪制度作出了规定。例如，《法国民法典》第112条规定：“一人停止出现在其住所地或居所地且他人无其音讯时，监护法官得应有利益关系的当事人或检察院的请求，确认失踪推定。”《意大利民法典》第49条规定：“自获得失踪人最后消息之日起经过两年，推定的法定继承人以及任何一个有理由认为由于失踪人的死亡能够取得失踪人财产的人都可以向有管辖权的法院按照前款的规定提出宣告失踪的申请。”我国《民法总则》也在《民法通则》规定的基础上，对宣告失踪制度作出了规定，该法第40条规定：“自然人下落不明满二年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。”

二、宣告失踪的条件

宣告失踪应当符合法定的条件，依据《民法总则》第40条、第41条的规定，宣告失踪应当具备如下条件：

第一，必须有自然人下落不明满2年的事实。依据《民法总则》第40条的规定，宣告失踪要求自然人必须下落不明满2年。依据《民法通则意见》第26条的规定，所谓下落不明，是指自然人离开最后居所和住所后没有音讯的状况，这种状况须持续、不间断地存在。[48]如果自然人离开住所和居所后仍然有音讯，只是因为通信等方面的原因无法联系到，并不属于下落不明。

关于下落不明的起算点，《民法总则》第41条规定：“自然人下落不明的时间从其失去音讯之日起计算。战争期间下落不明的，下落不明的时间自战争结束之日或者有关机关确定的下落不明之日起计算。”依据该条规定，自然人下落不明的时间起算点并不是其离开住所或者居所的时间，而是其失去音讯的时间。如果自然人是在战争期间下落不明的，则其下落不明的时间应自战争结束之日起计算，如果有关机关确定了自然人下落不明的时间，则其下落不明的时间自该机关确定的时间起算。

第二，必须由利害关系人向人民法院提出申请。依据《民法总则》第40条的规定，宣告失踪需要利害关系人的申请。由于宣告失踪仅涉及当事人之间的私人事务，一般不涉及社会公共利益，因而，法院不能依据职权进行失踪宣告，宣告失踪必须由失踪人的利害关系人提出申请。关于利害关系人的范围，《民法总则》并没有作出规定，《民法通则意见》第24条规定：“申请宣告失踪的利害关系人，包括被申请宣告失踪人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女以及其他与被申请人有民事权利义务关系的人。”从该条规定来看，其既没有对申请宣告失踪的利害关系人的人数作出规定，也没有对其申请顺序作出规定，因此，上述利害关系人可以单独申请，也可以同时申请，而且其申请并没有顺序限制，即便这些利害关系人就是否宣告失踪发生冲突，只要符合受理的条件，法院就应当受理。[49]

第三，必须经过法院依据法定程序宣告。宣告失踪只能由人民法院作出，其他任何机关和个人无权作出宣告失踪的决定。人民法院在收到宣告失踪的申请以后，应当依据《民事诉讼法》规定的特别审理程序，发出寻找失踪人的公告，公告期满以后，仍没有该公民的音讯时，人民法院才能宣告该公民为失踪人。

三、宣告失踪的法律后果

在自然人被宣告失踪后，其民事主体资格仍然存在，其仍然可以实施各种民事行为。因此，宣告失踪并不产生消灭婚姻关系的效力，也不会导致失踪人的财产被他人继承。依据《民法总则》的规定，宣告失踪的法律后果是为失踪人设置财产代管人。

（一）财产代管人的设置

财产代管人是为失踪人管理财产的人。自然人在被宣告失踪后，有必要为其设置财产代管人，因为在自然人下落不明的情形下，其财产无人照管，可能遭受毁损、灭失，这就有必要设置财产代管人为其管理财产。同时，设置财产代管人也有利于及时了解失踪人的相关权利义务关系，从而维护社会经济秩序的稳定。[50]

关于财产代管人的设置，《民法总则》第42条规定：“失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前款规定的人，或者前款规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。”依据该条规定，在自然人被宣告失踪后，首先应当由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。该条并没有对上述主体担任财产代管人的人数和顺序作出规定，因此，可以由上述人中的一人或者数人担任失踪人的财产代管人，而且上述主体在担任财产代管人方面并没有顺序上的限制。当然，在特殊情况下，上述主体可能对担任失踪人的财产代管人有一定的争议，或者失踪人没有上述人等担任财产代管人，或者虽然有上述主体，但上述主体均无代管能力，此时，依据该条规定，由人民法院指定财产代管人。从该条规定来看，其并没有对法院指定的财产代管人的范围进行限定，因此，人民法院可依具体情况确定合适的财产代管人。

（二）财产代管人的职责

依据《民法总则》第43条的规定，财产代管人的职责包括如下内容：

1. 妥善管理失踪人的财产。《民法总则》第43条第1款规定：“财产代管人应当妥善管理失踪人的财产，维护其财产权益。”财产代管人管理失踪人财产的行为主要体现为一种消极的管理行为，如履行失踪人的债务，接受失踪人债务人的履行等，其一般不得积极利用失踪人的财产。当然，在特殊情形下，为了保护失踪人的利益，财产代管人也需要对失踪人的财产进行积极处分，如为防止失踪人的房屋倒塌，应当允许财产代管人请人代为修缮。同时，依据该条规定，财产代管人应当妥善管理失踪人的财产，而且财产代管人在管理失踪人的财产时应当尽到善良管理人的管理义务。当然，依据《民法总则》第43条第3款的规定，财产代管人只有因故意或者重大过失造成失踪人财产损失时，才需要承担赔偿责任，财产代管人在因一般过失造成失踪人财产损失时，并不需要承担赔偿责任。

2. 清偿失踪人的债务，并追索其债权。代管人的另一项主要职责是代理失踪人履行债务和接受履行。一是代管人有权从失踪人的财产中支付税款、债务和其他应当支付的费用（如赡养费、抚养费等）。关于财产代管人履行管理职责的费用，《民法总则》第43条第2款规定：“失踪人所欠税款、债务和应付的其他费用，由财产代管人从失踪人的财产中支付。”依据该条规定，财产代管人缴纳失踪人所欠税款、清偿债务以及所支出的其他费用，应当从失踪人的财产中支付。二是代管人应当尽力追索失踪人的债权，代理失踪人接受债权。如果财产代管人怠于主张债权或者怠于接受履行造成失踪人损失的，财产代管人应当承担赔偿责任。

当然，该条并没有对财产代管人的报酬请求权作出规定，因此，财产代管人原则上只能请求失踪人偿还履行财产代管职责所支出的必要费用，而不能请求失踪人支付管理报酬。

（三）财产代管人的变更

在自然人失踪期间，财产代管人可能因为丧失民事行为能力等原因而无法履行财产代管职责，此时，就有必要变更财产代管人。依据《民法总则》第44条的规定，财产代管人的变更主要包括如下情形：

一是失踪人的利害关系人申请变更财产代管人。《民法总则》第44条第1款规定：“财产代管人不履行代管职责、侵害失踪人财产权益或者丧失代管能力的，失踪人的利害关系人可以向人民法院申请变更财产代管人。”依据该规定，在财产代管人不履行代管职责、侵害失踪人财产权益或者丧失代管能力的情形下，为失踪人设置财产代管人的目的将难以实现，此时，失踪人的利害关系人有权向人民法院申请变更财产代管人。

二是财产代管人申请变更财产代管人。《民法总则》第44条第2款规定：“财产代管人有正当理由的，可以向人民法院申请变更财产代管人。”依据该规定，如果财产代管人有正当理由，其也可以申请变更财产代管人。例如，财产代管人因为年龄、健康状况等原因难以有效履行财产代管职责，可能导致失踪人遭受损失的，此时，应当允许其向人民法院申请变更财产代管人。

在人民法院变更失踪人的财产代管人后，为保障新的财产代管人有效履行代管职责，同时为了明确当事人之间的权利义务关系，减少纠纷，原财产代管人应当及时将失踪人的有关财产移转给新的财产代管人，并且及时向新的财产代管人报告其担任财产代管人期间的代管情况。对此，《民法总则》第44条第3款规定：“人民法院变更财产代管人的，变更后的财产代管人有权要求原财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。”

四、失踪宣告的撤销

（一）撤销失踪宣告的条件

自然人在被宣告失踪后，如果又重新出现，则其有权申请撤销失踪宣告，也可由利害关系人申请撤销。关于失踪宣告的撤销，《民法总则》第45条第1款规定：“失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。”依据该规定，撤销失踪宣告应当符合如下条件：

1. 失踪人重新出现。依据该条规定，失踪人重新出现是撤销失踪宣告的必要条件，当然，失踪人重新出现并不限于失踪人回到住所或者居住地，如果确知其下落，也应当属于“失踪人重新出现”。

2. 经本人或者利害关系人申请。撤销失踪宣告需要被宣告失踪人本人或者其利害关系人向人民法院提出申请。从该条规定来看，失踪人本人或者其利害关系人在申请撤销失踪宣告方面并没有顺序限制，在失踪人重新出现后，利害关系人中的一人或者数人都可向人民法院申请撤销失踪宣告。

3. 由人民法院撤销。失踪宣告的撤销应当由人民法院作出，申言之，撤销失踪宣告的申请应当向作出失踪宣告的人民法院提出。关于撤销失踪宣告的程序，《民事诉讼法》第186条进一步详细规定了撤销失踪宣告的法定程序：“被宣告失踪、宣告死亡的公民重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当作出新判决，撤销原判决。”

（二）撤销失踪宣告的法律后果

失踪宣告一旦撤销，即产生如下法律效力：

一是财产代管关系终止。财产代管人是在自然人失踪期间代其管理财产，一旦失踪宣告被撤销，相应的财产代管关系也应当终止。当然，依据《民法总则》第45条第2款的规定，在失踪人重新出现的情形下，财产代管人即应当负有相应的移转财产和报告义务，此时，即应当认定财产代管关系已经终止。

二是财产代管人的移交财产和报告义务。《民法总则》第45条第2款规定：“失踪人重新出现，有权要求财产代管人及时移交有关财产并报告财产代管情况。”依据该条规定，一旦失踪人重新出现，则其就有权请求财产代管人移交有关财产，并有权请求财产代管人报告代管其财产期间的相关情况。

第四节 宣告死亡

一、宣告死亡的概念

所谓宣告死亡，是指自然人下落不明达到法定期限，经利害关系人申请，人民法院经过法定程序在法律上推定失踪人死亡的一项制度。自然人长期下落不明可能导致相关的财产关系和人身关系长期处于不确定状态，这有可能影响经济秩序和社会秩序。通过宣告死亡制度，可以及时了结下落不明人与他人的财产关系和人身关系，从而维护正常的社会秩序。宣告死亡虽然可以了结相关的财产关系和人身关系，但其毕竟属于对下落不明人死亡的一种推定，在该自然人仍然生存的情形下，其民事权利能力并不受影响。[51]

宣告死亡和宣告失踪的联系十分密切。在多数情况下，应先宣告失踪，而后宣告死亡，使宣告失踪成为宣告死亡的一个步骤。但从法律上看，宣告失踪并不是宣告死亡的必经程序，只要符合申请宣告死亡的条件，不论利害关系人是否曾经申请宣告失踪，都可以直接到法院申请宣告死亡。[52]

二、宣告死亡的条件

《民法总则》第46条规定：“自然人有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡：（一）下落不明满四年；（二）因意外事件，下落不明满二年。因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。”该条对宣告死亡的条件作出了规定，依据该条规定，宣告死亡必须具备以下条件：

第一，自然人下落不明达到法定期限。如前所述，下落不明是指自然人离开最后居所和住所后没有音讯的状况。在宣告死亡的情形下，自然人的下落不明主要是指生死不明，如果确知某人仍然活着，只是没有和家人联系或者不知道其确切地址，不能认为其生死不明。

依据《民法总则》第46条的规定，在申请宣告死亡的情形下，自然人下落不明达到法定期限可以分为如下两种情形：一是一般情形下，下落不明满4年。可见，与宣告失踪相比，在宣告死亡的情形下，自然人下落不明的时间应当更长，因为在宣告失踪的情况下，只是发生了被宣告失踪人的财产代管和债权债务了结的后果，但宣告死亡以后，还会发生继承的开始、身份关系解除等，因此，宣告死亡的条件应当比宣告失踪严格，下落不明的时间应当比宣告失踪时所要求的时间长。[53]二是在自然人因意外事件下落不明时，其下落不明需要满2年。由于自然人在因意外事件下落不明的情形下，其生存的可能性相对较小，因而，宣告其死亡时对其下落不明的时间要求也相对较短。此外，依据《民法总则》第46条的规定，在自然人因意外事件下落不明的情形下，如果有关机关证明该自然人不可能生存的，此时，申请宣告该自然人死亡不受2年时间的限制，即在此情形下，其利害关系人可随即申请宣告该自然人死亡。例如，发生沉船事故后，相关部门进行了紧急搜救，证实乘客已不可能生存，此时，其利害关系人可以立即申请宣告该人死亡，而不受2年期限的限制。

第二，必须要由利害关系人提出申请。依据《民法总则》第46条的规定，宣告死亡需要由利害关系人向人民法院提出申请，此处所说的利害关系人，是与被宣告死亡法律后果具有利害关系的人。关于各利害关系人在申请死亡宣告时是否有顺序的先后，存在不同观点：一种观点认为，宣告死亡的利害关系人包含的范围很广，如果没有顺序的限制，就会导致父母要求宣告死亡，但配偶并不希望宣告死亡，如果满足父母的请求，就会干涉配偶的婚姻自主。另一种观点认为，我国法律不应当规定申请宣告死亡的顺序，因为如果顺序在前的当事人不申请，则失踪人长期不能被宣告死亡，造成财产关系长期不能稳定。《民法总则》没有对各利害关系人申请宣告死亡的顺序作出规定，但《民法通则意见》第25条规定：“申请宣告死亡的利害关系人的顺序是：（一）配偶；（二）父母、子女；（三）兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女；（四）其他有民事权利义务关系的人。申请撤销死亡宣告不受上列顺序限制。”该司法解释确立了宣告死亡申请人的顺序。这就意味着，居于优先次序的利害关系人对失踪人不申请宣告死亡的，后

一顺序的利害关系人不得提出死亡宣告的申请。当然，同一顺序的利害关系人之间则无优先次序，如果部分申请宣告死亡而部分不同意宣告死亡的，则可以宣告死亡。

《民法总则》第47条规定：“对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合本法规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。”依据该条规定，如果对同一自然人，有的利害关系人申请宣告其死亡，有的申请宣告其失踪，如果该自然人符合宣告死亡的条件，则人民法院应当宣告该自然人死亡。法律之所以作出此种规定，是因为宣告死亡的法律效力范围要强于宣告失踪，在不同利害关系人同时申请宣告失踪与宣告死亡的情形下，如果符合宣告死亡的条件，人民法院作出死亡宣告有利于更好地解决当事人之间的纠纷。[54]

第三，必须要由人民法院作出宣告。依据《民法总则》第46条的规定，死亡宣告应当由人民法院作出。人民法院在受理死亡宣告的申请后，应当按照《民事诉讼法》规定的特别审理程序发出寻找下落不明人的公告，公告期届满，没有其音讯的，人民法院才能作出死亡宣告。

三、宣告死亡时间的认定

在宣告死亡的情形下，自然人死亡时间的认定对于确定相关的权利义务关系具有重要意义。被宣告死亡是人民法院基于利害关系人的申请，依据法定程序推定下落不明的公民死亡的一种法律制度。作出这种推定首先就是要确定死亡的具体时间，如果死亡的时间不确定，则不利于准确认定相关的权利义务关系。例如，自然人死亡时间的认定，对于死亡赔偿金的计算、养老金的领取、抚恤金的领取、继承开始时间的确定，甚至婚姻关系的终止时间等，均具有重要意义。

关于宣告死亡情形下自然人死亡时间的认定，《民法总则》第48条规定：“被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。”该条将宣告死亡情形下自然人的死亡时间区分为两种情形：

一是一般情形下被宣告死亡时死亡时间的认定。依据该条规定，一般情形下，在自然人被宣告死亡时，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡时间。该规则基本沿袭了《民法通则意见》的规则，该司法解释第36条第1款规定：“被宣告死亡的人，判决宣告之日为其死亡的日期。判决书除发给申请人外，还应当在被宣告死亡的人住所地和人民法院所在地公告。”该规则被实践证明是行之有效的。因此，《民法总则》继受了这一经验，将人民法院宣告死亡的判决作出之日视为自然人的死亡时间。

二是因意外事件被宣告死亡时死亡时间的认定。依据该条规定，在因意外事件导致自然人下落不明，该自然人被宣告死亡的，该意外事件发生的日期将视为该自然人的死亡日期。例如，马航MH370航班事故属于众所周知的意外事故，该事故发生后，相关人员生死未卜，此时，如果依法作出死亡宣告，则相关人员的宣告死亡时间应当是该事故发生的日期。

四、宣告死亡的法律后果

（一）宣告死亡的效力及于一切人

自然人一旦被宣告死亡，将产生消灭其既有财产关系和人身关系的效力，该效力不仅及于申请人，而且及于其他任何人。[55]

（二）宣告死亡并不当然消灭被宣告死亡人的民事主体资格

由于宣告死亡的目的在于终结被宣告死亡人原有的财产关系和人身关系，但其不同于自然死亡，其只是对下落不明的自然人死亡的一种拟制，不能完全等同于自然死亡。因而，宣告死亡并非为了绝对地消灭或剥夺被宣告死亡人的主体资格，而在于结束以被宣告死亡人住所地为中心的民事法律关系。[56]自然人在被宣告死亡后仍然可能生存，并且也必然会从事一些民事活动，产生一些新的民事法律关系。如果被

宣告死亡的失踪人被认为完全没有权利能力，则其从事任何行为都是无效的，这显然不符合法理。假如被宣告死亡的自然人完全没有权利能力还可以自行向法院申请撤销对他的死亡宣告，即实施有效的诉讼行为，这在民法上是无法解释的。[57]因此，《民法总则》第49条规定：“自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。”依据该条规定，在被宣告死亡后，如果自然人仍然生存的，则其主体资格并不受影响，其在被宣告死亡后所实施的民事法律行为的效力也不受影响。

（三）财产关系的变动

自然人被宣告死亡后，将对其财产关系产生一定的影响。如前所述，宣告死亡将产生消灭自然人原有的人身关系和财产关系的效力，因此，自然人一旦被宣告死亡，其财产将作为遗产由其继承人继承。同时，被宣告死亡的自然人的债权人也有权请求该自然人的继承人清偿债务。

自然人一旦被宣告死亡，其婚姻关系将消灭。对此，《民法总则》第51条规定：“被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭。”依据该条规定，自然人一旦被宣告死亡，其婚姻关系将自死亡宣告之日起消灭。宣告死亡制度的主要功能是为了结被宣告死亡人原有的人身和财产关系，因此，死亡宣告一旦作出，被宣告死亡人的婚姻关系即应当消灭。

五、死亡宣告的撤销

（一）死亡宣告撤销的条件

宣告死亡毕竟是一种法律上的死亡推定，该推定是可以被推翻的[58]，自然人被宣告死亡后，其客观上仍然可能处于生存状态，在确知该自然人仍然生存时，其本人或者利害关系人即有权撤销之前的死亡宣告。对此，《民法总则》第50条规定：“被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。”依据该条规定，死亡宣告的撤销应当具备如下条件：

一是被宣告死亡的人重新出现。被宣告死亡的人重新出现包括的情形很多，例如，该自然人回到住所或者居住地，或者有人确知其下落，或者虽然难以确定其下落，但确定其仍然处于生存状态。只要出现了能够确定被宣告死亡人仍然生存、否定其已经死亡的情形，就可以认定属于该条所规定的“重新出现”。

二是必须经本人或者利害关系人申请。被宣告死亡人重新出现，并不意味着其原有的人身、财产关系就当然恢复，而必须要经过本人和利害关系人申请，由人民法院作出新的判决，撤销原有的死亡宣告。毕竟，死亡宣告的判决具有既判力，而且已经产生了相应的法律后果，所以，要推翻该判决，也必须经过法定的程序。[59]这就是说，撤销死亡宣告需要被宣告死亡人或者利害关系人提出申请，当然，从《民法总则》第50条的规定来看，其并没有对申请撤销死亡宣告的利害关系人的顺序和人数进行限制，因此，只要被宣告死亡的人重新出现，任何一个利害关系人都可以申请撤销死亡宣告。

三是由人民法院作出撤销宣告。《民事诉讼法》在特别程序中对撤销死亡宣告作出了规定，该法第186条规定：“被宣告失踪、宣告死亡的公民重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当作出新判决，撤销原判决。”

（二）死亡宣告撤销的法律后果

死亡宣告的撤销将产生财产关系恢复的效果，对此，《民法总则》第53条第1款规定：“被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承法取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。”依据该条规定，一旦自然人的死亡宣告被撤销，其继承人应当向其返还自己依照继承法所取得的财产，原则上应当返还原物。由于宣告死亡只是对死亡的一种拟制，被宣告死亡的自然人仍然可能生存，在被宣告死亡的

自然人重新出现后，对其死亡的拟制将被推翻，相关当事人通过继承所取得的财产应当返还给被宣告死亡的人。同时，继承人取得遗产是无偿的，课以其返还义务也不会不当加重其负担。

当然，由于继承人对宣告死亡的发生并无过错，且属于合法取得财产，在其取得财产后，有权将财产使用、消费，因而，在死亡宣告被撤销后，如果其所继承的财产无法返还，如财产已经毁损、灭失，其并不需要承担赔偿责任，而只需要给予适当补偿。[60]所谓适当的补偿，主要是考虑返还义务人取得的财产价值、返还能力以及获得的利益。

如果被宣告死亡人的利害关系人隐瞒真实情况，导致他人被宣告死亡的，则在死亡宣告被撤销后，其除了应返还因此所取得的财产外，如果被宣告死亡人还有其他损失，则该利害关系人仍然应当予以赔偿。利害关系人隐瞒真实情况，是指利害关系人明知被宣告死亡人未死亡，却故意告知其下落不明，或者在被询问时，未告知被宣告死亡人未死亡的信息。在利害关系人隐瞒真实情况的情形下，其取得相关财产具有一定的过错，因此，其既需要向被宣告死亡人返还因此所取得的全部财产，还应当赔偿损失。返还原则上应当返还原物，如果原物不存在，应当作出适当的补偿。如果因此还导致被宣告死亡人的其他损失，该利害关系人应当予以赔偿。

《民法总则》第51条规定：“死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。”依据该条规定，被宣告死亡人的婚姻关系原则上应当自行恢复，但在例外情形下，其婚姻关系则不能自行恢复。依据该条规定，该例外情形包括如下两种：一是其配偶已经再婚。因为在死亡宣告后，被宣告死亡人的婚姻关系已经消灭，其配偶可以再婚，该婚姻也受到法律保护，在此情形下，即便死亡宣告被撤销，被宣告死亡人的婚姻关系也不能当然恢复，这也有利于维持婚姻家庭关系的稳定。如果配偶再婚，即使再婚后又离婚或再婚后新配偶死亡，其与被宣告死亡的配偶之间的婚姻关系也不得自动恢复。二是其配偶向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复。也就是说，如果被宣告死亡人的配偶不愿意恢复婚姻关系的，则其有权向婚姻登记机关声明不愿恢复婚姻关系。该条要求当事人必须作出书面声明，主要是为了避免发生争议。法律作出此种规定，有利于保护当事人的婚姻自由。[61]从该条规定来看，其并没有对被宣告死亡人的配偶作出书面声明的时间作出限定，因此，被宣告死亡人的配偶作出书面声明既可以在死亡宣告被撤销前作出，也可以在死亡宣告被撤销后作出。

《民法总则》第52条规定：“被宣告死亡的人在宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。”宣告死亡具有消灭自然人既有人身关系的效力，因此，自然人一旦被宣告死亡，如果符合收养的条件，其子女就可以被他人收养，依法产生的收养关系受法律保护，非因法律规定的原因，不得擅自解除或者被宣告无效。为了维护合法收养关系的效力，保持收养关系的稳定性，即便死亡宣告被撤销，被宣告死亡人也不得以其未同意收养为由主张收养关系无效。

第五节 个体工商户和农村承包经营户

一、两户制度

在我国，“两户”是个体工商户和农村承包经营户的简称。在改革开放之前，自然人从事经营活动受到严格限制。为了扩大自然人从事经营（包括工商业经营和农业经营）的自由，我国《民法通则》设立了个体工商户和农村承包经营户。可以说，“两户”是改革成果的制度化。

个体工商户是自然人从事工商业经营的法律形式，是自然人成为市场经济主体、参与工商业经营活动的重要途径。这一制度设计推动了市场经济的发展。截至2016年年底，我国已登记的个体工商户数量，达到5 929多万户，其在经济生活中发挥着十分重要的作用。[62]在法律上规定个体工商户的法律地位，不仅有助于解决就业问题，而且，也有利于推动“大众创业、万众创新”的主要主体。农村承包经营户有两亿

三千多户，并且成为我国家庭承包经营为基础、统分结合的农村经济制度的重要载体[63]。《民法总则》要巩固改革成果，并且要进一步推进改革，因此，继续规定了两户制度。

二、个体工商户

（一）个体工商户的概念和特征

《民法总则》第54条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。”由此可见，个体工商户，是指经过依法登记，从事工商业经营的自然人。关于个体工商户的性质，理论上存在不同观点。从《民法总则》的规定来看，其将个体工商户规定在“自然人”一章中，表明其在性质上仍然属于从事工商业经营活动的自然人，而不应当属于非法人组织。当然，自然人一旦以个体工商户的名义从事工商业经营活动，就成为商事主体。个体工商户的特征主要在于：

第一，它是商事主体的一种类型。虽然个体工商户是在“自然人”部分规定的，但是，它与自然人不完全相同。个体工商户可以是一个自然人，也可以是数个自然人。根据《个体工商户条例》第2条的规定，“有经营能力”的自然人可以申请成为个体工商户，因而作为个体工商户的自然人，应当具备经营能力，参与市场经济活动。但个体工商户又不是一个组织体，即使是家庭经营，家庭也并非组织。

第二，它有自己的经营范围。在我国，《个体工商户条例》等要求个体工商户明确其经营范围。该经营范围也决定了个体工商户的权利能力和行为能力范围。

第三，它必须依法办理登记。自然人要成为个体工商户，不需要出资，但必须依法进行登记。在这一点上，它和法人和非法人组织的设立是不同的。法律要求个体工商户必须依法登记，是为了有效规范和监管个体工商户的经营活动，保障其正常合法经营。法律也不要求其必须具有字号和名称。依据《民法总则》第54条的规定，个体工商户可以起字号，这是个体工商户依法享有的权利。

依据《个体工商户条例》第4条的规定，自然人在办理个体工商户登记时，并不需要登记机关的批准，只要不属于法律、行政法规禁止进入的行业，登记机关都应当办理登记，这就极大地保障了个人的经营自由。[64]依据《民法通则》第26条的规定，公民只有在法律允许的范围内经核准登记从事工商业经营的，才属于个体工商户，而从《民法总则》第54条规定来看，其删除了《民法通则》中“在法律允许的范围内”的表述，体现了对当事人私法自治的尊重，[65]也体现了对自然人经营自由的保障。

（二）个体工商户的债务承担

依据《民法总则》第56条第1款的规定，其采取区别处理的模式：

一是个人经营的个体工商户。个人经营个体工商户的，其债务以个人财产承担。从登记的角度来看，这些个体工商户会明确登记为“个人经营”。因为在个人经营的情况下，个体工商户和经营者是同一个主体，而且，个体工商户并没有独立的财产，因此，应当以经营者个人财产承担债务。

二是家庭经营的个体工商户。家庭经营个体工商户的，以家庭财产承担。在办理登记时，个体工商户可以被明确地登记为“家庭经营”。不过，从实践来看，有些个体工商户虽然登记为“个人经营”，但其其他家庭成员也参与到经营之中，从而形成事实上的家庭经营。这里所说的家庭财产，包括了从事经营的各个家庭成员的个人财产和共同财产。因为在家庭经营的情况下，家庭成员的个人财产也要投入到家庭经营之中，因而个体工商户的财产无法与家庭财产区分开来。如此规定有利于强化对债权人的保护。但是，在有些情况下，个体工商户究竟是个人经营还是家庭经营难以区分。例如，虽然登记为“个人经营”，但是其家庭成员也参与了经营活动。为了解决此时的债务承担问题，也为了强化对债权人的保护，我国《民法总则》第56条第1款规定：“无法区分的，以家庭财产承担。”

《个体工商户条例》第12条规定：“个体工商户不再从事经营活动的，应当到登记机关办理注销登记。”但是，法律上并没有要求其注销登记之前要进行清算，这是因为个体工商户的财产与经营者的财产并没有区分开来，而且，经营者要承担无限责任，因此，并无清算的必要。

三、农村承包经营户

（一）农村承包经营户的概念

《民法总则》第55条规定：“农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。”据此，所谓农村承包经营户，是指依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的农户。农村承包经营户的出现是我国20世纪70年代末农村经济体制改革的产物，至今仍然是最为重要的农村集体经济的经营形式。[66]我国《宪法》第8条规定：“农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。”因此，明确农村承包经营户的法律地位，保障其合法权益，是落实宪法确立的基本经济制度的要求。

比较而言，农村承包经营户与个体工商户的区别在于：

第一，农村承包经营户是以“户”为单位从事家庭承包经营的。户本身不是组织体，而是基于血缘、婚姻等而组成的。而个体工商户并非都是以“户”为单位从事经营，其可以是个人经营，也可以是家庭经营，在经营方式上是比较灵活的。

第二，农村承包经营户需要依法取得农村土地承包经营权。依据《民法总则》第55条的规定，农村承包经营户可以取得农村土地承包经营权，土地承包经营权是指权利人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利，依据《物权法》的规定，该权利在性质上属于独立的用益物权。[67]农村承包经营户可以将该权利流转，也可以利用该权利进行融资，而且在该权利被征收的情况下，农村承包经营权还有权获得征收补偿，这就更有利于保护农村承包经营户的权利。

第三，农村承包经营户从事的是土地承包经营。与个体工商户不同，农村承包经营户主要从事的是农业生产，而非工商业活动，并没有明确的经营范围。而个体工商户从事的是工商业经营，还必须经过登记取得营业执照。

第四，农村承包经营户并不以登记为前提，只要依法取得了农村土地承包经营权，就应当认定其主体资格。而个体工商户必须依法办理登记。此外，个体工商户可以起字号，该字号可作为名称权予以保护，而农村承包经营户并不享有起字号的权利。

（二）农村承包经营户的债务承担

考虑到农村承包经营户是以“户”为单位进行农业经营活动的，因此，其债务也应当由“户”来承担。《民法总则》第56条第2款规定：“农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担。”这里所说的“农户财产”包括该户内成员的个人财产和共同财产。例如，夫妻二人组成农村承包经营户，在债务承担时，责任财产既包括其夫妻的个人财产，也包括其夫妻的共同财产。

另外，在有些情况下，农户仅由部分成员经营。此时，应当由参与经营的成员承担债务。对此，《民法总则》第56条第2款规定：“事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。”这也体现了权利义务一致的原则。例如，因考上大学、参军等原因，农户中的一些成员已经不再从事农业经营，要求这些成员也对农户的债务负责，是不合理的。

第六节 自然人的身份证明和住所

一、自然人的身份证明

在我国，自然人的身份证明是居民身份证。根据《居民身份证法》的规定，身份证是证明公民真实身份的凭证，每个公民都有一个身份号码，身份号码是国家为每个公民编制的唯一的、终身不变的身份代码，由公安机关按照公民身份号码国家标准编制。[68]公民自年满16周岁之日起3个月内，应当向常住户口所在地申请；未满16周岁的公民，可自愿申请领取居民身份证。公民从事有关活动，需要证明身份的，有权使用居民身份证，有关单位及其工作人员不得拒绝。但是在特殊情况下，公民有义务出示身份证以证明自己的身份，例如人民警察依法执行公务，需要查验居民的身份证的，我国公民有义务配合。根据《居民身份证法》，任何组织和个人不得扣押居民身份证，公安机关和人民警察对因制作、发放、查验、扣押居民身份证而知悉的个人信息，应当予以保密。

二、自然人的住所

（一）自然人的住所概述

住所是指公民长期居住生活的地点。在社会生活中，每个人的活动总是存在于一定的空间的，其从事一定的民事活动和开展社会生活，总是在一定的场所内活动，例如，工作场所、营业活动的场所、居住的场所、财产所在地等，这些场所可能各不相同。住所是自然人参与的各种法律关系集中发生的中心地域，这就需要在法律上确定自然人的住所。[69]《民法总则》第25条规定：“自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。”该条对自然人的住所确定规则作出了规定。法律上确定住所的意义主要在于：

1. 确定自然人的民事主体状态。如宣告失踪、宣告死亡，都以自然人离开住所地下落不明为前提。

2. 决定债务的清偿地。《合同法》第62条规定：当事人履行地点约定不明确，依照本法第61条的规定仍不能确定的，适用下列规定：给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

3. 决定婚姻登记的管辖地点。如我国《婚姻登记条例》规定，依申请人住所管辖婚姻登记。再如，《民法总则》第31条规定，“对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人”。

4. 在涉外民事关系中确定法律适用的准据法。如《民法通则》第149条规定：“遗产的法定继承，动产适用被继承人死亡时住所地法律，不动产适用不动产所在地法律。”

5. 决定诉讼管辖法院和司法文书送达地。

在民法上，住所分为三类：一是法定住所。所谓法定住所是指由法律直接规定的住所。我国现行立法对于法定住所没有明确规定，但一般认为，如果无行为能力人及限制行为能力人与监护人共同生活，应当以其监护人的住所为住所。[70]夫妻在尚未离婚以前，夫妻一方可以以另一方的住所为其住所，但当事人另外选定住所的除外。二是意定住所，也称为任意住所，对于是否允许当事人根据自己的意志确定住所，我国现行立法没有规定，本书认为，对此应当允许当事人选择。三是拟制住所，法律规定在特殊情况下将居所推定为住所。所谓居所，即自然人居住的住处。如果自然人离开住所后长期在某居所居住，则可能将该居所推定为其住所。

（二）自然人住所的认定规则

1. 自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所

户籍登记是公安机关按照国家户籍管理的相关规定，对公民的身份信息进行记载的制度。依据相关法律法规的规定，公民应当在经常居住地的公安机关进行户籍登记。“其他有效身份登记”主要是指身份证、居住证和外国人的有效居留证件。[71]因为在我国，随着城镇化的发展，农村进城打工或从事各种经商

等活动的人越来越多，这些人可能并没有取得当地的户籍，但是取得了相关的居住资格；另外，随着我国对外交往的增多，外国人来华工作、居住的现象也越来越普遍，这些外国人并没有在我国进行户籍登记，其有效的居留证件也可以作为认定其住所的依据。

2. 经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所

《民法总则》第25条规定：“经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。”最高人民法院《民法通则意见》第9条规定：“公民离开住所地最后连续居住一年以上的地方，为经常居住地。但住医院治疗的除外。公民由其户籍所在地迁出后至迁入另一地之前，无经常居住地的，仍以其原户籍所在地为住所。”因此，如果自然人的经常居所与住所不一致的，则将其经常居所视为住所，法律之所以作出此种规定，是因为法律规定住所的主要目的是确定与自然人具有最密切联系的法律关系发生地和纠纷解决地[72]，在自然人在住所以外的居所经常居住的情况下，将该居所视为其住所，更有利于实现住所法律规则的目的。

思考题

1. 试述自然人的民事权利能力的概念和特点。
2. 试析权利能力和权利的区别。
3. 简要分析民事权利能力和民事行为能力的关系。
4. 试述民事行为能力的划分。
5. 请简要区分自然人的行为能力和责任能力。
7. 监护的设立方式有哪些？
8. 如何理解成年监护的制度功能？
9. 简述宣告失踪、宣告死亡的条件及法律后果。

[1] 星野英一. 私法上的人. 王闯译. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第8卷. 北京：法律出版社，1997：155.

[2] 杨震. 民法总则“自然人”立法研究. 法学家，2016（5）.

[3] 梁慧星. 民法总论. 北京：法律出版社，2011：56.

[4] 张俊浩主编. 民法学原理. 北京：中国政法大学出版社，2000：77.

[5] 卡尔·拉伦茨. 德国民法通论. 上册. 王晓晔等译. 北京：法律出版社，2003：36.

[6] 佟柔主编. 中国民法. 北京：法律出版社，1990：67.

[7] 江伟主编. 民事诉讼法学. 上海：复旦大学出版社，2002：176.

[8] 按照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第52条的规定，《民事诉讼法》第48条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，包括：（1）依法登记领取营业执照的个人独资企业；（2）依法登记领取营业执照的合伙企业；（3）依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业；（4）依法成立的社会团体的分支机构、代表机构；（5）依法设立并领取营业执照的法人的分支机构；（6）依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构；（7）经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业；（8）其他符合本条规定条件的组织。

[9] 郑玉波. 民法总则. 北京：中国政法大学出版社，2003：101.

[10] 黄立. 民法总则. 台北：三民书局，1994：71.

[11] 郑玉波. 民法总则. 北京：中国政法大学出版社，2003：104.

- [12]江苏省无锡市中级人民法院(2014)锡民终字第1235号民事判决书。
- [13]王泽鉴.民法总则.北京:北京大学出版社,2009:113.
- [14]最高人民法院民事审判第一庭编著.最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的理解与适用.北京:人民法院出版社,2001:43.
- [15]迪特尔·梅迪库斯.德国民法总论.邵建东译.北京:法律出版社,2001:409.
- [16]余能斌,马俊驹主编.现代民法学.武汉:武汉大学出版社,1995:83.
- [17]卡尔·拉伦茨.德国民法通论.上册.王晓晔等译.北京:法律出版社,2003:156.
- [18]黄立.民法总则.北京:中国政法大学出版社,2002:77.
- [19]龙卫球.民法总论.北京:中国法制出版社,2002:266.
- [20]参见《德国民法典》第827、828、829、832条;《日本民法典》第712、713条;我国台湾地区“民法”第187条.
- [21]参见《德国民法典》第276条;我国台湾地区“民法”第221条.
- [22]梁慧星.民法总论.北京:法律出版社,2011:74.
- [23]郑玉波.民法总则.台北:三民书局,1998:89.
- [24]柳经纬.民法总论.厦门:厦门大学出版社,2000:85.
- [25]李适时主编.中华人民共和国民法总则释义.北京:法律出版社,2017:57.
- [26]于程远.论限制民事行为能力人之中性行为.清华法学,2017(1).
- [27]王泽鉴.民法学说与判例研究.第4册.北京:中国政法大学出版社,1998:40.
- [28]石宏主编.中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定.北京:北京大学出版社,2017:53.
- [29]佟柔主编.中国民法.北京:法律出版社,1990:75.
- [30]李由义主编.民法学.北京:北京大学出版社,1988:573-574.
- [31]龙卫球.民法总论.北京:中国法制出版社,2002:276.
- [32]梁慧星.民法总论.北京:法律出版社,2011:84.
- [33]史尚宽.亲属法论.台北:自版,1980:622.
- [34]从国务院发布的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》来看,预计到2020年,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右;高龄老年人将增加到2900万人左右,独居和空巢老年人将增加到1.18亿人左右,老年抚养比将提高到28%左右。
- [35]龚梅.试论我国老年监护制度的构建.法制与社会,2009(12).
- [36]宇田川幸则.浅论日本关于成年人监护制度的修改.载渠涛主编.中日民商法研究.第1卷.北京:法律出版社,2003:387.
- [37]王泽鉴.民法总则.北京:北京大学出版社,2009:126.
- [38]陈苇,李欣.私法自治、国家义务与社会责任——成年监护制度的立法趋势与中国启示.学术界,2012(1).
- [39]王利明主编.《中华人民共和国民法总则》条文释义.北京:人民法院出版社,2017:74.

[40]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 74.

[41]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 69.

[42]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 69.

[43]陈苇, 李欣. 私法自治、国家义务与社会责任——成年监护制度的立法趋势与中国启示. 学术界, 2012 (1) .

[44]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 77.

[45]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 76.

[46]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 108.

[47]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 113.

[48]柳经纬. 民法总论. 厦门: 厦门大学出版社, 2000: 94-95.

[49]柳经纬. 民法总论. 厦门: 厦门大学出版社, 2000: 95.

[50]李浩. 民事诉讼法学. 北京: 法律出版社, 2011: 432-433.

[51]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 118.

[52]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 132.

[53]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 129.

[54]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 132.

[55]施启扬. 民法总则. 修订8版. 北京: 中国法制出版社, 2010: 79.

[56]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 111.

[57]柳经纬. 民法总论. 厦门: 厦门大学出版社, 2000: 97.

[58]史尚宽. 民法总论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 97.

[59]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 137.

[60]李适时主编. 中华人民共和国民法总则释义. 北京: 法律出版社, 2017: 141.

[61]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 106-107.

[62][63]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 111.

[64]《个体工商户条例》第4条规定: “国家对个体工商户实行市场平等准入、公平待遇的原则。申请办理个体工商户登记, 申请登记的经营范围不属于法律、行政法规禁止进入的行业的, 登记机关应当依法予以登记。”

[65]杨震. 民法总则“自然人”立法研究. 法学家, 2016 (5) .

[66]苏号朋. 民法总论. 北京: 法律出版社, 2006: 131.

[67]杨震.民法总则“自然人”立法研究.法学家,2016(5).

[68]参见《居民身份证法》第3条.

[69]王泽鉴.民法总则.北京:北京大学出版社,2009:144.

[70]魏振瀛主编.民法.4版.北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2010:69.

[71]李适时主编.中华人民共和国民法总则释义.北京:法律出版社,2017:74.

[72]石宏主编.中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定.北京:北京大学出版社,2017:56-57.

第十一章 民事权利

甲、乙是邻居,甲、乙两家的围墙相隔只有4厘米,甲在半年前建起了一栋三间三层的楼房,后乙经当地相关部门审批,也在自家的宅基地上修建楼房,但由于两家楼房地基相隔太近,乙在打造地基时造成甲的房屋地基出现裂缝,房屋出现了开裂、下沉,甲请求乙承担损害赔偿责任,而乙则主张,其建造房屋已经得到了相关部门的批准,不应当赔偿甲的损失。

简要评析:在该案中,乙虽然是在自己的宅基地上建造房屋,但其权利行使不得造成他人权益的损害,否则可能构成权利滥用。在该案中,由于甲、乙的宅基地相隔较近,乙虽然在自己的宅基地上建造房屋,但不顾甲的房屋的安全而打造地基,造成甲房屋出现裂缝、下沉,构成权利的滥用,应当对甲的损害承担赔偿责任。

第一节 民事权利概述

一、民事权利的概念

权利是指权利人对义务人提出的与自己的利益和意愿有关的、必须作为或不作为的要求。[1]中国古代虽有民本思想,但始终不存在西方法制中的“权利”概念,直到19世纪中叶,美国学者丁甦良(W. A. P. Martin)和他的中国助手们翻译惠顿(Wheaton)的《万国律例》(Elements of International Law)时,才选择“权利”一词作为英文“rights”一词的对应词语,并说服朝廷接受这一翻译。[2]

民事权利本质上是指法律为了保障民事主体的特定利益而提供法律之力的保护,是法律之力和特定利益的结合,是类型化了的利益。民法的中心问题就是民事权利问题。正如德国学者冯·图尔所言:“权利是私法的核心概念,同时也是对法律生活多样性的最后抽象。”[3]民法典之所以被称为“民事权利宣言书”,就是因为民法以确认和保护民事权利为首要任务,民事权利构成了民法的核心内容,整个民法就是以权利为中心而构建的体系。

权利的本质在法理上一直存在争议,主要有如下几种观点:

(1)意志说。又称为意思说,此说以德国历史法学派的萨维尼为代表。这派学者主张权利的本质就是意志,是个人意志所支配的范围。意志说解释了权利的本质是个人的意志。权利作为法律赋予权利人享有的行为自由,体现了权利人的自由意志。自由意志是权利存在的内在力量,某个主体选择何种权利通常都是基于其自由意志。

(2)利益说。利益说的代表人物为德国利益法学派的学者耶林。这种学说认为,“权利是受法律保护的利益”[4]。按照这种观点,凡依法律规定归属个人生活的利益即为权利,权利主体与受益主体同一。[5]任何权利的设定最终都是为了实现权利人的利益。

(3) 法力说。又称为法律力量说，由德国学者梅开尔（Merkel）所倡导，在欧洲许多国家和我国台湾地区，法律力量说正成为通说。这种学说认为，权利的本质表现为法律上之力，权利是由特定的利益和法律上之力两种因素构成的：特定利益为权利的内容，法律上之力为权利的外形。法律为保护或充实个人的特定利益，才给人以特定的法律上的力，使其借以享受特定的利益。[6]

本书认为，上述各种观点不无道理，但民事权利应该是利益和法力的结合，正如一些德国学者指出的，权利是“一种由法律赋予个人的权利力量，其目的旨在满足人的利益”[7]。利益说和法力说是从不同角度对民事权利所作的说明，但是仅仅从一个方面不能对权利的本质属性作出完全的概括。利益说揭示了民事权利的内容和目的，但没有解释此种内容实现的手段和方式。而法力说则解释了权利所具有的作用，权利赋予主体一定的自由等，但并没有表达出权利的内容和目的。所以，只有将两者结合起来才较为妥当。本书基本赞同第三种观点。

二、民事权利的特征

（一）民事权利是由民法所确认的一种权利

民事权利是由民法所确认的权利，这表明民事权利不同于任何个人在公法上的权利。公法上的权利主要是指宪法和行政法所确认的公民所享有的各种权利，例如宪法规定的公民所享有的选举权和被选举权、劳动权、休息权等。这里所说的民事权利是指由民法所规定的民事权利，又称为私权。私权与公权之间的区别在于：

第一，法律依据不同。公权一般由公法所规定，而私权则由私法所规定。[8]

第二，义务主体不同。私权无论为绝对权还是相对权，其义务主体都只是特定或不特定的民事主体。而大多数公权利从形式上看是一种权利，但实际上是为国家规定的一种职责，如公民享有劳动权，则国家应承担为公民提供就业机会的义务。

第三，权利的内容和目的不同。公民在公法上的权利通常要求公权力机关为一定行为或者不为一定行为，是政治国家的一个范畴。而公民的民事权利是市民社会中的权利，是用于对抗他人侵犯的权利。这两种权利的内容是不同的，并分别受到不同法律的保护。[9]

第四，救济途径不同。民事权利是私法上的权利，对该权利的侵犯一般通过民事诉讼的方式，适用民事诉讼程序提供救济。而针对侵害公法上权利的救济，则一般通过行政复议、行政诉讼的方式进行，甚至运用违宪审查的方式。

（二）民事权利是由民事主体所享有的利益

民事权利的设定大多体现了主体一定的利益目的，即主体为了追求一定的利益而从事一定的民事活动而取得权利。没有利益，民事权利的设定就失去了意义。[10]同时，民事权利的内容体现了权利人的利益。民事权利分为财产权利和人身权利，分别体现为财产利益和人身利益。权利的本质就在于对个人利益的确认。民事权利的客体也体现了主体的一定利益。如果没有主体的利益需要，就不能构成民法上的客体。还应当看到，民事权利的行使也体现了民事主体的利益。当事人行使或不行使权利，以及行使权利的方式等，都与权利人的利益直接相关。

应当指出，主体享有、行使、支配某种权利都是为了满足其特定利益需要。但是权利内容并不完全是一种个人利益的产物。因为权利本身要符合国家意志，权利需要体现一定社会目的和价值，所以国家就有必要协调个人利益和社会利益之间的冲突，从维护社会整体利益出发对民事权利的内容作出某种必要的限制，从而在一定程度上使权利的内容体现社会利益的要求。所以，权利内容本身是个人利益和社会利益的产物。在利益中，不仅包括民事主体的个人利益，而且在特定情况下可能还包括社会公共利益。

利益虽然是权利的主要内容，但并不是说，所有的利益都能够表现为权利。我国《民法总则》第3条规定：“民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。”该条规定合法权益也受法律保护，表明在权利之外仍然有一些合法的利益存在，但它们没有被确认为权利。例如，占有的利益、死者的人格利益等。所以，完全以利益来概括权利也不十分准确。

（三）民事权利体现为民事主体一定范围内的行为自由

因为权利的存在，就为民事主体的行为提供了一定的自由空间。“权利是个人自治权的外显及行为手段”[11]，民事主体可以在权利范围内自由地行为。权利人享有的自由包括：第一，权利人是否行使权利的自由。第二，权利人处分非专属性权利的自由。第三，权利人选择权利行使方式的自由。第四，权利人选择权利救济方式的自由。

权利中的自由和利益是密切联系在一起的。正因给予了民事主体一定的自由，主体才有可能去实现其利益，有时自由本身就意味着一定的利益。例如，只有享有处分的自由，才可能使权利人真正实现其所有权。反之，限制了民事主体的自由，实际上就减损了其利益。例如，在物上设定用益物权或担保物权，则所有权的价值将受到减损。

（四）民事权利都受到国家强制力的保障

权利在性质上是一种法律上之力。权利人依法可以请求义务人为一定行为或不为一行为，以保证其享有或实现某种利益。但是，单纯从利益角度还不能完全揭示权利的本质。权利人因他人的行为而使其利益受到侵害时，还可以请求有关国家机关采取强制措施予以保护。[12]例如，民事权利的实现大多需要赋予权利人一种请求权，即请求义务人履行义务。要使权利人的权利得以实现，最有效的手段是赋予其享有一项相应的请求权。这种请求的权利实际上是法律赋予其一定的力量。所以把利益说和法力说结合起来才能够解释权利的本质。总之，任何民事权利都能够获得民法上的救济，无救济则无权利。反之，某种权利能否获得民法上的救济，也是区分民事权利和公法权利的重要标准。

（五）权利是类型化了的利益

原则上，民事权利应当由成文法所确认，但现代社会习惯法和判例法也可以发挥创设民事权利的功能。例如，德国法上的营业权就是由判例法所确认的；我国司法解释还创设了一般人格权等成文法没有确认的权利。[13]这就表明，民事权利本身是一个开放的体系，完全由法律全面确认是很困难的。立法者的理性有限，而社会生活变动不居，随着社会的发展，会出现一些新型的民事权益类型，如比较法上出现的采光权、日照权等。而且随着社会的发展，一些民事利益也可能上升为民事权利。例如，从我国立法来看，隐私早期体现为一种民事利益，通过名誉权保护，后来被我国立法确认为独立的隐私权。因此，民事权利是一个动态的、变动的体系。正因如此，我国《民法总则》第126条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”，从而保持了保护民事权益范围的开放性。

三、民法总则关于民事权利规定的特色和意义

民法典被称为“民事权利的宣言书”。《民法总则》继续采纳《民法通则》的经验，专设“民事权利”一章，集中地确认和宣示自然人、法人所享有的各项民事权利，充分地彰显民法对私权保障的功能。《民法总则》在全面保障私权方面呈现出许多亮点，主要表现在：一是时代性，即体现了当代中国的时代特征，回应了当今社会的现实需求。例如，该法首次正式确认隐私权，有利于强化对隐私的保护。再如，针对互联网和大数据等技术发展带来的侵害个人信息现象，《民法总则》规定了个人信息的保护规则，维护了个人的人格尊严，并将有力遏制各种“人肉搜索”、非法侵入他人网络账户、贩卖个人信息、网络电信诈骗等现象。二是全面性，《民法总则》广泛确认公民享有的各项人格权、物权、债权、知识产权、亲属权、继承权等权利，从保护公民财产权利的角度来看，《民法总则》首次在法律上使用了“平等”保护民

事主体物权的表述，这是对《物权法》的重大完善。该法对知识产权的客体进行了详尽的列举，扩张了知识产权的保护范围，进一步强化了对知识产权的保护。该法强化了对英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉的保护，有助于弘扬公共道德，维护良好的社会风尚。三是开放性，《民法总则》第126条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。”依据该条规定，不论是权利还是利益，都受到法律保护。这不仅与保护民事权益的基本原则相对应，而且为将来对新型民事权益的保护预留了空间，保持了私权保护的开放性。

众所周知，现代法治的核心在于“规范公权、保障私权”，法律的功能主要是确认权利、分配权利、保障权利、救济权利，《民法总则》全面确认和保护民事权利，使其真正成为“民事权利的宣言书”，并奠定了现代法治的坚实基础。保障私权就是为了更好地保障最广大人民群众的根本利益，保护人民群众对美好生活的向往。此外，由于私权的保护在一定程度上界定了公权行使的范围，因而也将起到规范公权的作用。

第二节 民事权利的基本分类

一、财产权、人身权和综合性的权利

根据权利的内容和性质，民事权利可分为财产权、人身权和综合性的权利。这是民事权利最基本的分类。作出此种区分的重要意义在于：第一，权利的内容不同。第二，在是否可以转让方面具有区别。第三，保护方法不同。下面对这三种权利分别阐述。

1. 财产权。财产权是指以财产利益为直接内容的权利，其主体限于现实地享有或可以取得财产的人，而不像人格权那样可以为一切人普遍地享有。[14]财产权不具有专属性，可以由主体转让、抛弃，也可以继承。财产权利主要包括两大类，物权和债权。所谓物权，是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。所谓债权，是指特定的债权人一方请求债务人为一定行为或者不为一定行为的权利。债权在内容上是一种请求关系，而且只能发生在特定的当事人之间。

2. 人身权。人身权是指以人身所体现的利益为内容的、与权利人的身份不可分的民事权利，包括人格权和身份权。人格权是指以生命、健康、名誉等人格利益为内容，并排斥他人侵害的权利。它主要包括生命健康权、姓名权、名誉权、肖像权、荣誉权、隐私权、性自主权等。身份权是指基于权利人的特定身份产生的权利，包括亲属权、抚养权等。身份权须有一定的身份或资格等才能产生，如具有夫妻身份，才能享有配偶权。人身权的主要特点在于：其内容主要体现为人格和身份等精神利益。人身权一般具有专属性，尽管个别人格权的权能，如肖像权的权能可以转让，但人身权作为整体是不能转让的，也不能抛弃和继承。

3. 综合性的权利。所谓综合性的权利，是指由财产权和人身权结合所产生的一类权利。这些权利的特点表现在，其内容既包括人身利益又包括财产利益，其专属性并不十分强烈。[15]典型的综合性权利主要包括如下几类：一是知识产权，所谓知识产权，就是指以对人的智力成果和工商业标志的独占排他的利用为内容的权利，它包括著作权、专利权、商标权等。知识产权包括财产权和人身权两方面的内容。二是社员权。所谓社员权，是指在某个团体中的成员依据法律规定和团体的章程而对团体享有的各种权利的总称。例如，对团体的收入分配请求权、投票权、管理权、监督权等。其既有身份属性，又包含了财产利益。三是继承权。所谓继承权，是指继承人依法继承被继承人遗产的权利。继承权以继承人的特定身份为基础，以财产利益为内容。

当然，关于上述分类的标准本身也存在争议。如有人认为，知识产权和继承权应当属于财产权的范围；也有人认为，在财产权和人身权之外不存在一种综合性的权利，财产权不一定具有价格，只要体现了一定的经济价值就可以称为财产权。德国学者通常也将财产权称为具有经济价值之权利[16]，而非财产权通

常是指人身权，即不具有一定财产内容而以身份和人格为内容的权利。按照此种分类，财产权可以包括物权、债权、知识产权、有价证券等权利。[17]

二、支配权、请求权、抗辩权、形成权

根据权利的作用，民事权利可分为支配权、请求权、抗辩权和形成权。

（一）支配权

1. 支配权的概念和特征

支配权是指直接支配客体，并享有一定利益的权利。物权是典型的支配权，并且以支配作为其主要的功能。除物权以外，知识产权、人格权、身份权在性质上也可以称为支配权，但是身份权只是对身份利益的支配，而不是对他人人身的直接支配。支配权的特点表现在：

第一，支配权的客体是特定的，即特定化的财产和人身利益。尤其是就财产利益而言，支配权的客体必须特定化，才能对特定的财产产生排他的效力。

第二，支配权的权利主体是特定的，而义务主体是不特定的。[18]在涉及财产为客体的支配权时，“权利人可以长久地或暂时地使用其支配的财产。同时其他人被排除在使用权之外，以确保第三人无法对权利人的支配可能性造成损害”[19]，而除权利人之外的任何人都负有不侵害支配权的义务。

第三，支配权的实现不需要义务人的积极作为。支配权不需要义务人的介入，即可使权利人的权利实现，但义务人不得实施妨碍支配权实现的行为。

第四，支配权因支配而产生排他性等效力。支配权所产生的各种效力，因支配权的类型不同而有异。例如，物权人对物的支配可以产生排他性、优先性、追及性等。

根据所支配的客体不同，支配权可以分为如下几种类型：

（1）对物的支配权。物权人能够依据自己的意志依法直接占有、使用其物，或采取其他的支配方式。物权人的支配包括对特定的动产和不动产的实物的支配，也包括对物的价值的支配。当然，实物的支配与价值的支配是不能完全分开的。例如，恢复用益物权人对土地和房产的支配，也就保护了用益物权人对不动产的使用价值的支配。保护担保物权人对实物的支配，实际上也就保护了对交换价值的支配。当然，物权人对物的支配范围不仅受物本身的性质和效用等的限制，而且要受到物权本身的内容的限制。物权人直接支配一定的标的物，必然从支配中享有一定的利益。

（2）对人身利益的支配权。人身利益包括人格利益和身份利益，对人身利益的支配主要是通过人格权和身份权实现的。

（3）对无形财产的支配权。无形财产是与有形财产相对应的概念，一般是指基于创造性的智力成果所获得的权利。但对于无形财产的概念，仍然存在不同的理解。例如，许多日本学者认为，无形财产主要是指智力创造性成果。而法国一般认为，无形财产是指特定的财产权利，是一种非物质财富，主要包括知识产权以及对现代社会的商业信息所享有的权利。[20]对于无形财产的支配主要表现为知识产权。[21]

（二）请求权

所谓请求权（Anspruch），是指请求他人为一定行为或不为一定行为的权利。[22]请求权人自己不能直接取得作为该权利的内容的利益，必须通过他人的特定行为间接取得。请求权的概念是由德国学者温德夏特提出的[23]，并为许多大陆法系国家的立法所采纳。请求权包括债权的请求权、物权的请求权、人格权上的请求权、继承法上的请求权、亲属法上的请求权等。可见，请求权的适用领域十分广泛，有学者甚至认为，请求权在权利体系中居于枢纽地位。[24]请求权的特点是：

第一，具有相对性。请求权都是发生在特定的相对人之间的一种权利，不论是基于债权产生的请求权，还是基于物权或其他绝对权利产生的请求权，都要转化为相对人之间的关系。也就是说，请求权只能向特定的义务人提出，要求其履行义务。请求权作为相对权，产生于具有特定请求内容关系的特定当事人之间。

第二，依附于基础权利。请求权是由基础权利（如物权、债权）所发生的，如果没有基础权利，则当事人也难以享有请求权。[25]

第三，请求权作为独立的实体权利，连接了实体法和程序法的权利。因为民事诉讼可以分为三种，即确认、给付和变更之诉，这三种诉讼中给付之诉是民事诉讼的核心，而给付之诉的基础就是请求权。只有理解了请求权，才能理解给付之诉的基础。请求权不同于诉权，诉权是程序法上的权利，请求权是实体法上的权利。请求权可诉诸法院，请求保护，此时，它表现为诉权。

第四，请求权既可以作为独立的权利，也可以作为实体权利的内容。请求权大多表现为实体权利，如物权请求权、人格权请求权等。正是因为请求权可以采取独立的形态，故权利人可以转让、抵销、准许延迟或免除请求权的具体内容。但请求权也可以只是某项权利的内容。比较典型的是，债权的请求权只是债权的内容，或者说是债权的主要内容。但债权又不限于请求权，债权除请求权以外，还包括“选择、解除、终止等权能，且债权请求权因时效而消灭时，债权虽减损其力量，但仍然存在，债务人仍为履行之给付者，不得以不知时效为理由，请求返还”[26]。可见，请求权只是债权的一项权能。

根据产生的基础关系，请求权可以分为如下几类：

（1）债权的请求权，包括合同履行的请求权、违约损害赔偿请求权、缔约过失请求权、无因管理请求权、侵权的请求权、不当得利所产生的返还请求权。但是，赔礼道歉、恢复名誉等责任方式，因本质上不是一种给付关系，不当包括在债权的请求权中。

（2）物权请求权，具体包括返还原物请求权、停止侵害请求权、排除妨碍请求权、妨碍预防请求权。

（3）占有保护请求权，主要包括在占有受到侵害的情况下，而使占有人享有的占有返还请求权、妨碍排除请求权、消除危险请求权。

（4）人格权和身份权法上的请求权。人格权上的请求权，主要是指在人格权受到侵害的情况下，产生的停止侵害、排除妨碍、消除危险的请求权。身份权上的请求权主要包括抚养请求权、赡养请求权等。

（5）知识产权法上的请求权，主要是指知识产权受到侵害的情况下，产生的停止侵害、排除妨碍、消除危险请求权等。

根据请求权的独立性和派生性，请求权可以分为两类：一是其作为权利本身的内容而存在，如债权中的请求权，此种请求权以一定的实体法为依据，其存在不受是否有人提出主张的影响，也不受债权人是否知悉其请求权的影响。[27]二是在权利受到侵害的情况下，权利人针对义务人所提出的一种请求的权利，有学者将之称为“保护请求力”。在权利未受到侵害以前，此种权利是隐而不现的，一旦权利受到侵害，这种权利就表现出其作用，所以，它是实体权利的一种派生的产物，是以权利救济的手段出现的。学说上通常所说的物权请求权、侵权请求权、违约请求权等都属于这种权利，它是民法上请求权研究的主要对象。

民法上的请求权是由一系列请求权所组成的体系。这些请求权包括合同上的请求权、侵权上的请求权、不当得利请求权、无因管理请求权、缔约上过失的请求权等。这些请求权组成了一个有机的整体，形成一个请求权的完整体系。本书认为，分析任何一个民事案件，必须要先分析请求权的体系。原则上，请求权的体系应当按照如下顺序来确定：

第一，应将合同上的请求权作为第一顺序的请求权加以考虑。合同作为特定人之间的事先约定的关系，确定了当事人之间的权利、义务，只有先从合同关系着手，才能向其他关系展开，即合同上的请求权与其他的请求权发生密切联系时，应先考虑运用合同上的请求权。[28]

第二，缔约过失请求权。按照梅迪库斯的看法，缔约过失的请求权与合同的请求权是不可分割的，甚至可以包含在合同的请求权之中，因为无论是在合同的缔结过程中还是在合同终止以后，都会涉及缔约过失的请求权。[29]本书认为，这两项请求权应当分开。缔约过失的请求权适用于双方无合同关系的情况，而基于违约的请求权乃是以有效合同的存在为前提的。如果当事人之间存在合同关系，则属于合同责任；若不存在合同关系，则可以考虑缔约过失责任。缔约过失请求权仅次于合同请求权而适用，优先于其他请求权。

第三，无因管理请求权。无因管理的请求权与合同关系极为类似，它们都是产生合法占有权的依据，无因管理也常常与合同有密切的联系。但合同上的请求权应优先于无因管理上的请求权加以考虑，因为无因管理之所谓“无因”，是指无法律上的原因，包括无法定的义务或约定的义务为他人管理事务。如果管理人和本人之间事先存在合同关系，管理人是依照约定管理他人的事务，则管理人负有管理的义务，不构成无因管理。所以，合同请求权与缔约过失请求权应当优先于无因管理请求权。但由于无因管理本质上是一种合法行为，一旦无因管理请求权能够成立，则不应适用其他请求权，所以无因管理请求权应当优先于合同和缔约过失请求权之外的其他请求权。

第四，物权请求权。物权的请求权是指基于物权而产生的请求权，也就是说，当物权人在其物被侵害或有可能遭受侵害时，有权请求恢复物权的圆满状态或防止侵害；在物权受到侵害的情况下，首先应当采用物权的请求权对物权进行保护，这是因为物权的请求权具有优先于债权的效力。如在破产程序中，所有人对其物享有取回权，此种取回权实际上是由所有物返还请求权派生的，当然应优先于一般债权而受到保护。再如，所有物返还请求权一般不受诉讼时效的限制，所以物权请求权较侵权请求权更有利于保护受害人，因此，原则上，物权请求权应当优先于侵权请求权而适用。

第五，不当得利和侵权的请求权。不当得利和侵权行为都是法律禁止和限制的行为，广义上都属于不合法的行为。按照合法行为成立则排除非法的逻辑，先应当考虑有无其他以合法行为为基础的请求权存在，如果其他请求权不能适用，最后才能适用不当得利和侵权的请求权。因此，不当得利和侵权的请求权应当置于请求权体系的最后顺位考虑。

正确了解民法的请求权体系对于培养分析和运用法律的体系观念，从体系上把握整个民法的知识、制度和规范，从而正确适用民法规则具有十分重要的意义。

（三）抗辩权

1. 抗辩权的概念与特点

抗辩权又称为异议权，它是指对抗对方的请求或否认对方的权利主张的权利。[30]抗辩权是和请求权相对应的概念，如果将请求权比作矛，抗辩权就是盾。抗辩权的功能就是对抗或延缓请求权的行使，或使请求权归于消灭。[31]所以，抗辩和请求是相辅相成的。例如，《合同法》规定的同时履行抗辩权、不安抗辩权等都是针对履行请求权的权利。抗辩权具有如下特点：

第一，抗辩权是由法律明确规定的权利。抗辩权必须基于法律规定而产生，如果是约定的抗辩事由，仅产生合同的权利，一方行使基于约定的抗辩事由所产生的权利，仍然是行使合同权利。抗辩权本质上是一种私权，关系到当事人自身的利益，而与社会公共利益无关，因而当事人是否行使抗辩权完全由当事人自己决定。如果当事人不主动援引抗辩权，则法院一般不能依其职权审查是否存在抗辩事由。当然，在当事人提出抗辩时，法院仍应当审查抗辩事由是否成立。[32]

第二，抗辩权是對抗或否認對方的請求權的權利。抗辯權行使的主要目的就是對抗對方所提出的請求權。從抗辯權的效力來看，它可以包括如下兩種，一是延緩對方的請求，如債務履行期限未屆至的抗辯；二是排除對方請求權的抗辯，如當事人主張合同關係無效，從而排除對方依據合同請求履行的權利。抗辯不同於反請求，反請求是指被告依法向原告提出的獨立的請求，原告提出的訴訟成為本訴，被告提出的反請求成為反訴。由於反訴與本訴基於同一個法律關係而發生或者以同一事實為根據，且反訴的請求具有對抗性，這就使反訴與抗辯常常發生混淆。本書認為，區分二者的根本標準在於：如果僅僅是否認對方的請求，只是證明對方的請求存在或者不存在，則屬於抗辯而不屬於反請求。而在反請求和反訴中，反請求權提出了獨立的請求，而不僅僅是否認對方的請求。

第三，抗辯權的行使必須要以請求權的行使為前提。抗辯權是針對請求權而發揮作用的，只有在一方提出請求之後，另一方才能行使抗辯權。

關於抗辯權是否有一定的期限限制的問題，學理上有兩種不同的觀點：一是抗辯權有期限說。此種觀點認為，除了一些法定的權利如所有權等以外，任何民事權利的行使都應當有一定的期限限制，抗辯權也不例外。二是抗辯權無期限說。此種觀點認為，抗辯權是一種對他人的請求，提出一種對抗，主張維持既有的消極現狀，因此不應當受行使期限的限制，這在學理上也稱為抗辯權之永久性理論。^[33]本書贊成第一種觀點，抗辯權大多應有期限限制。例如，《合同法》規定的履行抗辯權原則上應當在履行期限內提出。因為請求權是有時效限制的，因而作為其反面的抗辯權也應當有期限限制，否則會使已經形成的法律關係處於不確定狀態。該期限可能是法定的，也可能法律並沒有作出規定，即使法律未作規定，抗辯權也要求抗辯權必須在合理的期限內行使，超過了合理期限，權利將有可能喪失。例如，一方提出請求以後，對方在很長時期內沒有提出抗辯，應當視為抗辯權已經消滅。

（1）實體法上的抗辯權和程序法上的抗辯權

實體法上的抗辯權就是實體法所規定的抗辯權，如《合同法》規定的同時履行抗辯權、後履行抗辯權、不安抗辯權，時效制度中規定的時效屆滿後的抗辯權等，從實體角度來看，抗辯和抗辯權並不是同一概念。抗辯所包括的事由極為廣泛，而抗辯權則是由法律明確規定由一方享有的對抗另一方請求權行使的權利。

程序法上的抗辯權是指被告針對原告的訴訟請求從程序上提出異議，例如，對管轄提出異議、對訴訟請求提出異議等。民事訴訟上的抗辯如果以主張實體法的事項為內容，則應以實體法上的權利為基礎，但它又不完全等同於實體法上的抗辯權，因為實體法上的抗辯權畢竟是針對請求權而行使的，它並不限於在訴訟中行使，在訴訟之外也可以行使。

這種分類的實際意義在於，程序法上的抗辯權可以由法官依職權審查，而實體法上的抗辯權由當事人自行決定行使與否，法官不得干預。

（2）消滅的抗辯權和延緩的抗辯權

消滅的抗辯權，是指抗辯具有消滅或否定請求權的效力。如存在合同請求權時，合同履行、代物清償、提存、抵銷、免除、撤銷合同、解除合同等構成消滅的抗辯。如果請求權應當在一定的期限行使而不行使，抗辯權人提出此種抗辯，也將導致請求權消滅。由於此種抗辯權可以使請求權的行使永遠被排除，故又稱為永久的抗辯權。

延緩的抗辯權，是指僅能使對方的請求權在一定期限內不能行使，所以，又稱為一時的抗辯權。此種抗辯權的行使，只是使請求權的行使發生障礙，一般並不能導致請求權本身消滅。^[34]例如，同時履行抗辯權和不安抗辯權的行使只是使履行的請求權發生障礙，但由於合同本身並沒有終止，所以請求權仍然存在，並沒有消滅。當請求權的障礙消除或消滅以後，請求權人可以繼續行使請求權。

抗辩权的行使是正当行使法定权利的表现，抗辩一旦成立将会导致对方的请求权消灭或使其效力延期发生。当然，抗辩权的行使必须严格遵循法律规定的抗辩权行使的条件和程序，不能违反法律规定而行使权利，或滥用抗辩权，否则，不仅不能发生抗辩的效果，而且行为人还可能承担相应的民事责任。

（四）形成权

1. 形成权的概念与特征

形成权是指当事人一方可以以自己单方的意思表示，使法律关系发生变动的权利。换言之，是指不需要他方相应地作出某种行为，即可以通过行使此种权利，使法律关系产生变动和消灭。学理上也称之为能为权、变动权等。[35]形成权的主要特征在于：

（1）它是指权利人根据自己的意思表示，就能够使既存的法律关系发生、变更或消灭的权利。一是使法律关系发生。例如，无权代理中本人的追认使无权代理行为有效。二是使法律关系发生变更，例如，受欺诈方主张变更合同的权利。三是使法律关系消灭。例如，当事人行使抵销权，使债权债务关系消灭。[36]行使形成权在绝大多数情况下，并不需要向法院提出请求。但是在特殊情况下，形成权的行使需要以向法院提起诉讼的方式进行。因形成权本身发生争议而提起诉讼，或者基于形成权提起诉讼，此种诉讼称为形成之诉。

（2）它的效力的产生不需要另一方作出某种辅助的行为或共同的行为。按照梅迪库斯的看法，形成权是“法律允许权利主体对某项法律关系采取单方面的行动”[37]。在一般情况下，形成权的实现不需要相对人的介入，只需要他人不妨碍其权利的行使即可。对形成权而言，仅需权利人一方的意思表示，就可以使民事法律关系产生、变更或消灭，因此，为保护当事人的合理信赖，维持法律关系的稳定，当事人在行使形成权时不得附条件或者附期限。

（3）它的行使所发生的效力很难因相对人的行为而受到影响。形成权在未行使前，对原来的法律关系没有任何影响。一旦行使，就可以使具体的法律权利和义务发生、变更或消灭。[38]一旦行使形成权的意思表示发出并到达相对人，就可以使法律关系发生、变更或者消灭。这种特殊的行使方式，使形成权的行使所发生的效力很难因相对人的行为而受到影响。

（4）它不能与其所依附的法律关系相分离。形成权本身是一种独立的权利，但是形成权大多是依据某种实体的权利（如债权等）而产生的，并可能作为该权利的一项权能而存在。例如，抵销权和撤销权就是作为债权的一项权能而发生的。所以，形成权大多依附于一定的法律关系才能发挥其作用，不得与原权利分割而单独转让。[39]

（5）它通常都具有一定的存续期间。形成权的存续期间在学说上称为除斥期间。权利人应当在该期限内行使权利，超过了该期限，将导致形成权的消灭。而且，除斥期间在性质上属于不变期间，不能发生中止、中断和延长。

形成权和抗辩权都有使法律关系发生变化的作用，但二者存在明显的区别，表现在：一方面，形成权的行使并不针对请求而主张，即使没有一方提出请求，权利人也仍然可以行使，但是抗辩权是针对一方提出的请求而行使的；另一方面，形成权的作用主要在于改变法律关系的效力，而抗辩权的作用则主要在于对抗权利的主张。此外，形成权的行使适用除斥期间，该期间为不变期间，而抗辩权的行使适用诉讼时效，可因一定的事由而中断、中止、延长。

（1）财产法上的形成权和身份法上的形成权

财产法上的形成权，是指依附于物权、债权等财产而产生的形成权。例如，债权的撤销权、变更权等。身份法上的形成权，主要是指基于身份关系而产生的形成权。身份法上的形成权一般都是基于法律规定而产生，其主要包括两类：一是纯粹身份上的形成权，包括婚约撤销权、婚约解除权等。二是身份财产上

的形成权，包括继承人或者受遗赠人对继承权或受遗赠权的抛弃、遗产分割权等。此种形成权尽管是基于身份而产生的，但它与财产还是有着密切的联系。[40]

（2）法定形成权和约定形成权

依据产生原因形成权可以分为法定形成权和约定形成权。法定形成权，是指基于法律规定直接产生的形成权，大多数形成权都是法定形成权。约定形成权，是指基于当事人双方的约定而产生的形成权，如双方约定在一定条件下，一方当事人享有合同解除权。无论是法定形成权还是约定形成权，其行使的效力都是由法律直接规定的，只不过是在约定的情况下，形成权产生的原因和行使的条件以及行使的期限等是由当事人约定的。

（3）非通过诉讼而行使的形成权和通过诉讼而行使的形成权

根据形成权行使的方式，形成权可以分为非通过诉讼而行使的形成权和通过诉讼而行使的形成权。所谓非通过诉讼行使的形成权，是指通过权利人单方行为而使法律关系发生变动，一般的形成权都是通过非诉讼的方式而使形成权发生效力。所谓通过诉讼行使的形成权，是指形成权必须要到法院提起诉讼，经过法院的确认才能发生权利变动的法律效果。例如，法定撤销权的行使，必须通过诉讼经过法院的确认，才能最终使合同撤销。法律之所以规定某些形成权必须通过诉讼的方式行使，一方面是因为这些形成权对第三人意义重大，另一方面是为了避免发生纠纷。

形成权对于相对人的影响特别重大，因此只有及时行使，才能使法律关系尽快明确。为此，需要在法律上为其规定除斥期间。形成权在一定的期限内不行使，将导致权利消灭。法律规定了一定期限的，该期限就是形成权的存续期限；如果法律没有规定其行使期间，则权利人应当在合理期限内行使，否则将发生权利消灭的后果。

形成权的行使必须遵循两项重要规则：一是形成权的行使不得附条件或附期限。形成权的行使目的在于迅速地使法律关系确定，“既然形成权相对人必须接受他人行使形成权的事实，那么不应该再让他面临不确定的状态了”[41]。二是形成权的行使不得撤销。因为形成权一旦行使，权利人的意思表示到达相对人，即发生法律关系变动的效果，所以形成权一旦行使，就不能撤销该意思表示。但在到达相对人之前，意思表示并未生效，自然可以撤回。[42]此外，形成权必须合理行使，民法上关于权利不得滥用的一般原理对于形成权的行使也应当适用。

三、绝对权和相对权

根据义务主体是否特定以及权利的特点，权利可以分为绝对权和相对权。所谓绝对权，是指权利人的权利无须通过义务人实施一定的行为，即可以实现，并能对抗不特定人的权利。[43]绝对权主要包括所有权、人身权、知识产权。因为绝对权的权利人对抗的是除他以外的任何人，所以绝对权又称为对世权。所谓相对权，是指权利人的权利必须通过义务人实施一定的行为才能实现，权利人的权利只能对抗特定的义务人。[44]最为典型的相对权就是债权。相对权的权利人对抗的是具体确定的义务人，因此，相对权又称对人权。[45]两者的区别主要表现在：

第一，从义务人的范围来看，绝对权也就是绝对法律关系中的权利，在此种关系中，权利人是特定的，但义务人是不特定的，除权利人之外，一切人都负有不得侵害其权利的义务和妨害其行使权利的义务；而相对权法律关系中，无论是权利人还是义务人，都是特定的。

第二，从权利义务是否对应来看，在绝对权法律关系中，权利人享有一定的权利，但并不负有相对应的义务，反过来，义务人对权利人承担一定的义务，但并不因此而享有权利；在相对权法律关系中，权利义务常常具有相对性。权利人享有权利的同时应当负担相应的义务，而义务人在负担相应义务的同时也享有相应的权利。权利人须通过义务人实施一定行为才能实现其权利。

第三，从权利是否具有排他性来看，绝对权具有排他性，这种排他性主要表现在权利是否具有对抗第三人的效力上，在绝对权遭受侵害的时候，权利人可以针对任何第三人提出主张和提起诉讼；但相对权是只能针对特定人产生效力的权利。

第四，从是否具有公开性来看，绝对权大多是公开的。对于所有权等权利来说，法律要求当事人必须通过公示的方法向社会公开，使第三人知道，才能够使该权利产生对抗第三人的效力。由于绝对权是公开的，所以它才能对权利人之外的一切人确立一种不得侵害他人权利的义务，从而能够起到行为规则的作用。而相对权都是一种不公开的权利，它仅在特定当事人之间具有拘束力。例如，合同债权仅对合同当事人具有法律拘束力，对合同当事人以外的人则不具有法律拘束力。

第五，从两种权利遭受侵害的补救来看，绝对权遭受损害后，首先应当考虑恢复原状，尽可能恢复权利人享有权利的状态，在难以恢复原状时才可以根据权利人的特别要求，可转换为赔偿损失。例如，侵害他人之物，首先应当适用排除妨害和恢复原状的补救方式，如不能采用这两种方式，则适用赔偿损失的救济方式。而对相对权的侵害，通常是采用损害赔偿的补救方式，其主要目的在于补偿损失。

当然，对于绝对权与相对权的区分，不能作绝对化的理解。一方面，从义务主体的范围上说，绝对权受到侵犯时，也会出现特定的义务主体，在此情况下，将会发生绝对权向相对权的转化。另一方面，即使是相对权，任何第三人也都不得侵害。所以债权在特殊情况下，也可以成为侵权的对象。^[46]尤其应当看到，随着民法的发展，绝对权和相对权出现了一种相互融合的趋势。例如，租赁权的物权化使债权具有对抗第三人的效力，从而使相对权也具有绝对权的一些效力。

四、主权利和从权利

根据民事权利之间的主从关系，民事权利可以划分为主权利和从权利。主权利是指在相互关联的几项民事权利中，不依赖于其他权利就可以独立存在的权利，也称为独存权。从权利则是不能独立存在而从属于主权利的权利，例如为担保债权的实现而设立的担保物权，相对于主债权是一种从权利，而主债权是主权利。由于从权利不能独立存在，而必须依附于主权利才能存在，所以也被称为附属权。^[47]区分主权利和从权利主要具有以下意义：

第一，主权利和从权利是一种相对的法律概念，只有在具有主、从权利的法律关系中，才存在这种划分，换言之，主、从权利关系的确定，必须在具有主、从地位的法律关系中才具有意义。例如，在担保法律关系中可以发生主权利和从权利的区别，但不能笼统地说物权或债权是主权利或从权利。

第二，主权利是从权利的基础和前提，从权利必须要依附于主权利而存在，所以主权利成立和生效，从权利才有可能产生和生效。如果主权利不存在或被宣告无效，那么从权利也相应地不存在或被宣告无效；如果主权利发生转让，那么从权利也应当依法发生转让。权利人不能在转让主权利的情况下单独保留从权利，也不能在抛弃主权利的情况下单独享有从权利。

第三，从主权利和从权利的区别中，相应地区分主权利法律关系和从权利法律关系，有助于确立不同的法律关系中的义务主体及其内容。例如在担保法律关系中，与主债权人相对应的是主债务人，而在保证合同中，权利人是债权人，义务人是保证人，两种法律关系中权利所指向的对象是不同的，而义务人也可能是不一致的。

五、既得权与期待权

根据权利成立要件是否全部实现，民事权利可分为既得权与期待权。

既得权是指成立要件已全部实现的权利，一般权利都是既得权。期待权是指成立要件尚未全部实现、将来有实现可能的权利^[48]，如附条件民事法律行为设定的权利在条件成就前就是期待权。继承开始前，

法定继承人享有的继承权，也属于期待权。

期待权是指权利人依据法律或合同的规定，依法对未来的某种权利享有一种期望或期待的利益。不过，尽管期待权体现为一种未来的利益，但这种利益仍然是可以实际取得的，而不是一种臆想的不可能实现的利益。[49]期待权主要包括如下几种类型：

一是在所有权保留的买卖中，买受人对标的物的所有权所享有的期待利益。在所有权保留的买卖关系中，卖方虽将标的物先交付给买方，并使其享有占有、使用和收益的权利，但在该标的物的价金一部或全部付清前，或者当事人之间其他债权债务关系清结前，卖方仍保留该标的物或其加工物及其转售所得之所有权[50]，此时，买方并不享有所有权，但对取得所有权享有一种合理的期待利益，对买方的这种期望或期待地位予以法律保护并赋予其权利性质，就产生了期待权。

二是附生效条件和附期限合同中，在条件尚未成就或期限尚未到来之前，尽管合同已经实际成立但未生效，当事人一方只能就合同所产生的债权享有一种期待的利益，还不能现实地享有合同债权。

三是保险合同中受益人的权利。因为保险合同成立与生效之后，受益人不能实际地获得保险利益，只有在法定的或者约定的保险事故发生之后，受益人才能实际地取得保险利益，从而产生受益人的期待权。

四是继承人的权利。在继承中有两种情况涉及期待权：一是在遗嘱成立之后，遗嘱继承人对遗嘱继承的财产享有期待权，必须在遗嘱人死亡这一法律事实发生之后才能使继承人实际取得继承权；二是在遗赠扶养协议成立以后，受遗赠人即便对遗赠人开始履行一些协议规定的义务，也不能对遗赠人用于遗赠的财产享有所有权，而只是享有一种期待权，只有在遗赠人死亡之后，此种期待权才转化为实际的权利。

区分既得权和期待权的意义主要表现在：

第一，区别权利人是否实际取得某种权利。对既得权而言，权利人已经现实地取得了某种权利；但对期待权而言，权利人不能够现实地取得某种权利，而只是期待将要取得某种权利。

第二，在某种法律事实是否实际发生上不同。既得权无须某种法律事实的实际发生就已经存在了，而期待权人必须在某种特定的法律事实实际发生之后才能实际地取得权利，从期待权向既得权的转化必须要求法定事实的发生才能完成。

第三，关于权利的可侵害性以及救济的方法上的区别。既得权显然具有可侵害性。但是对于期待权是否可侵害的问题，理论上存在争论。例如，恶意阻碍条件成就时，法律上视为此种条件已经成就，但这并不意味着期待权已经受到侵害。即便承认期待权能够受到侵害，但由于权利人享受的是一种未来的利益，具有不确定性，所以在确定救济方法时与既得权的救济也存在差别。

第三节 民事权利的主要类型

一、人身权

（一）人格权的概念和特征

人格权是指以主体依法固有的人格利益为客体的，以维护和实现人格平等、人格尊严、人身自由为目的的权利，包括生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。我国《民法总则》第109至110条对此作出了规定，其特征主要表现在：

第一，它是人身权的一种。人身权，是指以人身所体现的利益为内容的，与权利人的身份不可分的民事权利，包括人格权和身份权。人格权作为人身权的主要类型，其与财产权存在重要区别，即并不直接以财产利益为内容，且原则上不得转让和抛弃。[51]在此种权利受到侵害之后，一般不适用侵害财产权的救济方式（即损害赔偿），而主要采用非财产救济以及精神损害赔偿的方式。

第二，它是主体固有的权利。所谓固有，实际上表明人格权为专属性权利，它是与个人的人格始终伴随而不可分离的权利。[52]此种权利除法律另有特别规定以外，一般不能转让、抛弃，也不能继承。固有性是人格权与其他权利的重要区别。自然人一旦出生、法人一旦成立，就应该享有人格权。人格权不需要主体实施一定的行为去实际取得，自然人不论在其年龄、智力、社会地位等方面存在何种区别，不论是否实际参与各种法律关系，都应平等地享有人格权。

第三，它以主体享有的人格利益为客体。人格利益分为一般人格利益和个别人格利益。前者主要指自然人的人身自由和人格尊严；后者包括自然人的生命、健康、姓名、名誉、隐私、肖像等个别人格利益。人格利益大多体现为一定的精神利益，它一般不像财产利益那样具有有形的特征，尤其是名誉、肖像、隐私、自由等利益，都是有关行为与精神活动的自由和完整的利益，且以人的精神活动为核心而构成。

第四，它以维护和实现身体完整、人格尊严、人身自由为目的。人格权所体现的基本价值就在于对上述价值的维护和实现。[53]人格权存在的目的，就是要维护作为法律上的人所必须具有的权利，保障主体的依法独立。

（二）人格权的具体类型

我国《民法总则》规定的人格权包括如下两类：

在具体人格权中，又可以分为两大类：

一是自然人的人格权。《民法总则》第110条第1款规定：“自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。”该条是对我国《民法通则》的新发展，总结了我国的立法和司法经验。尤其是该条确认了隐私权，全面彰显了时代精神和时代特征。

《民法总则》第111条规定：“自然人的个人信息受法律保护。任何组织和个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。”所谓个人信息，是指与特定个人相关联的、反映个体特征的、具有可识别性的符号系统，包括个人身份、工作、家庭、财产、健康等各方面的信息。这一规定具有如下内涵：第一，宣示了个人信息受法律保护，虽然该条没有明确使用“个人信息权”的概念，但是在解释上也可以认为，其承认了个人信息权。另外，该条就个人信息的取得、收集、使用、加工、传输、买卖、公开，都宣示性地要求必须依法进行。这一规定实际是授权就个人信息保护制定单行法律或行政法规。第二，确认了个人信息取得的合法性和合目的性原则。该条中规定“依法取得”，表明任何机关和个人在收集他人个人信息时，都应当遵循合法性原则，保证收集的主体和手段必须合法。同时，个人信息收集必须要符合特定目的。例如，银行收集的个人信息只能限于银行内部使用，房屋中介收集的个人信息只应在交易过程中使用，交易后应当销毁，而不能在此目的之外使用相关信息。第三，强调保障个人信息安全，明确了个人信息收集后的妥善保管责任。个人信息收集后，应当有专人保管和负责。如果发生个人信息泄露后找不到由谁负责，这就很难有效预防个人信息的泄露。搜集的主体即特定的机构或个人，应当对个人信息搜集后的泄露承担责任。第四，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。在民法典中明确承认个人信息权作为基本民事权利，严格保护个人信息权，防止个人信息的非法泄露和利用，互联网才会健康发展，个人的生活才会幸福安宁，社会生活才会井然有序。

二是法人和非法人组织的人格权。《民法总则》第110条第2款规定：“法人、非法人组织享有名称权、名誉权、荣誉权等权利。”该规定是在总结《民法通则》立法的经验基础上所作的规定，对保护法人的人格权益意义重大。

一般人格权（das allgemeine Persönlichkeitsrecht），是相对于具体人格权而言的，它是指以人格尊严、人格平等、人身自由为内容的，具有高度概括性和权利集合性特点的权利（Auffangtatbestandsrecht）。[54]在德国，最早提出一般人格权概念的是基尔克，并为德国判例学说所普遍接受。《民法总则

》第109条规定：“自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。”该条在法律上确认了一般人格权，形成了对人格权进行保护的兜底条款，这既保持了人格权体系的开放性，为新型人格利益保护预留了空间，也为法官提供了裁判依据。从该规定来看，一般人格权仅适用于自然人，而不适用于法人。此外，该条还宣示了人格权保护的基本价值，即在判断权益能否作为人格利益进行保护时，如挖掘祖坟、砸毁墓碑、人格歧视等，就要看其是否体现了该条所规定的人身自由、人格尊严价值。依据该条规定，一般人格权的内容包括两项：

一是人身自由。许多学者认为自由权应该作为具体人格权，但实际上，自由的概念非常广泛，包括财产自由、人身自由、经济自由、竞争自由、行为自由、发展自由等内容。一般人格权中所说的自由，是作为具体人格权的人身自由权之外的自由利益。

二是人格尊严。人格尊严是指公民基于自己所处的社会环境、地位、声望、工作环境、家庭关系等各种客观条件而对自己和他人的人格价值和社会价值的认识和尊重。[55]人格尊严是一般人格权的重要内容，例如，在“超市搜身案”中，某超市的保安怀疑消费者偷拿财物，对其进行搜身，虽然没有侵犯原告的名誉权，但实际上侵犯了原告的人格尊严。[56]因为人格尊严是指人作为法律主体应当得到承认和尊重。人格尊严是人作为社会关系主体的基本前提，保护人格尊严就是要像黑格尔所说的，“让人成其为人，并尊重他人为人”。人格尊严是人格权的价值基础，人格权法律制度的根本目的在于保护个人的人格尊严，各项人格权都体现了人格尊严的保护要求。

一般人格权也具有源性性，即可以从一般人格权中派生出新的具体人格权，随着社会的发展，新的人格利益不断产生，一般人格权可以为这些新型人格利益的保护提供法律依据，一般人格权也能够起到兜底性条款的作用，从而能够对具体列举的具体人格权所未能涵盖的部分提供概括保护，为社会变迁中出现的新型人格利益确立请求权的基础。

（三）身份权

所谓身份权，是指为法律所保护的基于民事主体某种行为、关系所产生的与其身份有关的人身权利。[57]身份权是由一定的身份关系所产生的权利，权利人必须具有某种身份地位才能取得相应的身份权。例如，基于一定的血亲的身份而取得亲权等。《民法总则》第112条规定：“自然人因婚姻、家庭关系等产生的人身权利受法律保护。”人格权和身份权虽然存在一定共性，但二者是两类不同的权利，主要区别如下：

第一，从性质上看，人格权是指民事主体作为法律上的独立人格所必须享有的民事权利。这种权利为民事主体所固有，并为法律所承认。任何个人都享有平等的人格权，没有这些人格权，个人的主体资格将会受到影响。而就身份权而言，主体所享有的身份权并不完全相同，而且即便某个人不具备某种身份权，也并不一定会影响其民事主体资格。[58]

第二，在价值理念上，人格权主要强调对人格尊严、自由的保护，而身份权主要是为了维护一定的身份关系；人格权主要是从单个个体的角度对个人所享有的人格权利作出规定，而身份权则从一定的身份关系的视角观察个人所处的身份关系。

第三，从主体上来看，人格权不仅可以由自然人享有，亦可以由法人享有。例如，法人可以享有名称权和名誉权。而身份权因其主要是基于亲属法上的身份关系所产生的，因而只能由自然人享有。

第四，从客体上来看，人格权以人格利益为客体，人格利益包括维护自然人生理活动能力的安全利益，个人的某些人格标志（如姓名、肖像等），主体所获得的社会评价和自尊的利益等。而身份权的客体则是基于一定的身份所取得的利益，简称为身份利益。当然，身份权所支配的不是特定的人及其身份，而是基于身份关系所体现的利益。[59]

第五，权利的取得不同。人格权因主体的出生或成立而取得，并不需要主体实施一定的行为就可以取得。而身份权取得的原因则各不相同，行为人取得某些身份权不仅要有一定的行为能力，而且还要实施一

定的行为，如因结婚取得配偶权、因收养而形成养父母子女关系等。

第六，权利的存续期限不同。人格权的存续期限与主体作为独立人格的地位是联系在一起的，它因权利人的出生或成立而取得，因权利人的死亡或终止而丧失，人格权并没有特别的期限限制。而身份权则以一定的身份关系为存在前提，并以身份的存续为权利存续的前提。如夫妻关系消灭，配偶关系丧失，则配偶权即随之消灭；收养关系消灭，则养父母子女之间的亲权关系也随之消灭。[60]

《民法总则》第128条规定：“法律对未成年人、老年人、残疾人、妇女、消费者等的民事权利保护有特别规定的，依照其规定。”该条明确了在特殊群体人格权保护方面，应当适用特别法的规定。例如，我国《未成年人保护法》《妇女权益保障法》《老年人权益保障法》和《残疾人保障法》等法律中，都对特殊群体的人格权保护作出了特别规定。

二、物权

（一）物权的概念和特征

《民法总则》第114条第2款规定：“物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。”该条与《物权法》第2条第3款的规定基本相同。[61]该条在法律上明确了物权的概念，对于界定物权的内容和效力、区别物权和债权具有重要意义。与其他财产权利不同，物权主要具有如下法律特征：

1. 物权的主体是特定的权利人。在物权关系中，权利人是特定的，而义务人是不特定的第三人。权利人包括自然人、法人和非法人组织。我国《物权法》将物权的权利主体表述为权利人，这一概念具有高度的概括性，可以将各种民事主体纳入其中，如国家所有权人、集体所有权人、私人所有权人等。

2. 物权的客体主要是有体物。物权的客体具有独立性、特定性，如某辆汽车、某栋房屋。[62]除了法律有特别规定之外，集合物不能作为物权的客体。物权的客体主要是有体物[63]，包括动产和不动产，与知识产权等财产法律关系不同，物权一般不以无形财产、智力成果为客体，而主要以有体物作为其客体。当然，在例外的情形，可以为人力所支配的无形的自然能量（如电力、光波、有线电视信号等），也可以准用物权的保护。

3. 物权本质上是一种支配权。物权体现权利人对物的直接支配。所谓支配，是指法律上或事实上的管理或控制。物权的支配性决定了物权所具有的优先性、追及性等特点。所谓直接支配，强调主体对物的一种控制，这种控制状态既包括事实上的控制，也包括法律上的控制。当然，主体依据物权对物的支配，既包括对特定的动产和不动产的使用价值的支配，也包括对物的交换价值的支配。[64]

4. 物权是排他的权利。物权的排他性主要包括以下几个方面的含义：一是所有权的排他性。同一物之上不得存在两个所有权，即一物不容二主。二是他物权的排他性，即同一物之上不得成立两个在内容上相互矛盾的他物权。三是物权的对世效力。这就是说，任何人都负有不得侵害物权的义务。物权的效力可以对抗权利人之外一切不特定的人。[65]四是物权的不可侵害性。物权具有不可侵害性，物权人行使权利，有权排除他人的侵害和妨害，在物受到他人侵夺时，权利人还可以对行为人主张物权请求权。

（二）物权的客体

《民法总则》第115条规定：“物包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。”物权的客体是特定的物，所谓特定的物主要指的是动产、不动产。动产与不动产的区分，最早起源于罗马法。大陆法系国家都采纳了这种区分。

所谓不动产，是指依照其物理性质不能移动或者移动将严重损害其经济价值的有体物。所谓动产，就是不动产之外的物，是指在性质上能够移动，并且移动不损害其经济价值的物，如电视机、书本等。动产

与不动产可按照如下标准进行区分：一是是否可以移动。动产通常可以移动，而不动产则不能移动。当然在现代社会中，随着科技的发展，房屋也可以移动，但是这毕竟属于例外现象，而且将耗资巨大。二是移动是否在经济上合理。房屋等土地附着物也可能是能够移动的，但一旦移动耗资巨大，而动产通常可以移动。从物权法的发展趋势来看，动产和不动产呈现出相互渗透甚至相互转化的状况，因为一方面，由于不动产证券化趋势的发展，不动产具有动产化的趋向。不动产物权的证券化不仅有利于充分实现不动产的交换价值，也为物权人开辟了新的融资渠道。另一方面，某些动产，如船舶、航空器等也要在法律上采取登记方式，从而与不动产的规则完全一致。还要看到，在担保物权中，不动产抵押和动产抵押基本上采用相同的规则。正是由于这一原因，有一些学者认为应当使动产和不动产规则统一化。本书认为，尽管动产和不动产在某些方面应适用共同的规则（例如物权法的基本原则、物权请求权制度等对动产和不动产都是适用的），但也要看到，动产和不动产适用的仍然是两种不同的规则。

物权的客体主要是动产和不动产，但在例外的情形，可以为人力所支配的无形的自然能量（如电力、光波、有线电视信号等），也可以准用物权的保护。《民法总则》第115条规定：“法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。”这就是说，在法律有特别规定的情况下，权利也可以作为物权的客体。例如，《物权法》也规定了无线电频谱资源属于国家所有。知识产权等权利也可以作为质押权的客体。

（三）财产权的平等保护原则

《民法总则》第113条规定：“民事主体的财产权利受法律平等保护。”依据这一规定，财产权的主体在法律地位上是平等的，依法享有相同的权利，遵守相同的规定。民事主体的财产权受到侵害以后，应当受到法律的平等保护。首先，平等保护原则是民法基本原则在物权法中的具体体现。《物权法》第4条确立了平等保护原则[66]，该原则是物权法的首要原则，也是我国《物权法》中国特色的鲜明体现。《民法总则》第113条在《物权法》第4条的基础上，首次在法律上使用了“平等”二字，这是对《物权法》的重大完善。其次，将平等保护的适用范围由物权扩张为所有财产权，从而进一步扩张了平等保护的运用范围。有出现“平等”的表述。《民法总则》明确规定“民事主体的物权受法律平等保护”，彰显了民事法律“私权平等”的价值取向。

财产权平等保护原则对维护社会主义基本经济制度具有重要作用。我国是社会主义国家，按照《宪法》第6条的规定，我国目前处于社会主义初级阶段，在所有制形态上实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。因此，“以公有制为主体，多种所有制并存”构成我国的基本经济制度，财产权平等保护原则正是对这种基本经济制度的充分反映和具体体现，也是维护市场经济秩序所应遵循的基本准则。我国宪法明确规定“国家实行社会主义市场经济”，作为调整财产归属和利用关系的物权法，应当把保障一切市场主体的平等法律地位和权利发展作为其基本的任务和目标之一，为此，就必须确立财产权平等保护原则，保障所有参与市场经济活动的主体的平等地位，确立起点的平等，使每一主体能够进行平等的交易和公平的竞争。平等保护原则在法律上宣告，个人的财产可以置于和国家的财产同等的地位，从而奠定了我国法治的基础，体现了对民生的关注和对公民切身利益的保护，有利于鼓励人们创造财富、促进社会财富增长。

（四）物权法定原则

《民法总则》第116条规定：“物权的种类和内容，由法律规定。”该条确立了物权法定原则。所谓物权法定原则，是指物权的种类、内容应由法律明确规定，而不能由法律之外的其他规范性文件确定，或由当事人通过合同任意设定。物权法定是大陆法系各国物权法所普遍承认的基本原则。它对于准确地界定物权、定分止争、确立物权设立和变动规则、建立物权的秩序都具有十分重要的意义。物权法定主要包括两方面的内容：

1. 物权种类法定。所谓物权的种类法定，是指哪些权利属于物权，哪些不是物权，要由物权法和其他法律规定。此处所说的“法律”，必须是国家立法机关通过立法程序制定的规范性文件，才能产生普遍适用的效力。物权必须由法律设定，而不得由当事人随意创设。物权种类法定包含下述两层含义：一方面，物权的具体类型必须要法律明确确认，法律之外的规范性文件（如行政规章、地方性法规）不得创设物权，当事人不得创设法律所不承认的新的类型的物权。另一方面，物权种类法定既不允许当事人任意创设法定物权之外的新种类物权，也不允许当事人通过约定改变现有的法律规定的物权类型。例如，在“神农架林区阳日矿开发有限责任公司与神农架林区阳日镇人民政府用益物权确认纠纷上诉案”中，关于《物权法》第5条所确立的物权法定原则，法院认为，依据这一物权法定原则，物权的种类和内容均由法律作出强制性规定，自然人和法人只能依据法律的规定设立物权和行使物权的权利内容。[67]

2. 物权内容法定。物权的内容法定包括两个方面：一方面，物权的内容必须要由法律规定，当事人不得创设与法定物权内容不符的物权，也不得基于其合意自由决定物权的内容。例如，依据法律的规定，农村土地承包经营权的内容中的使用权能限于农业生产，当事人不能通过合同约定在土地上从事非农业的建设。另一方面，内容法定就是强调当事人不得作出与物权法关于物权内容的强制性规定不符的约定。例如，《担保法》第40条确认，当事人在设定抵押权的合同中，不得约定一旦债务人不能履行债务，抵押物的所有权就转归抵押权人所有。

物权法定原则应当具有强制性，这是保障该原则得以贯彻、遵循的基础，而这种强制性在很大程度上又体现在，如果违反了物权法定原则，将会引发法律上的不利后果。按照物权法定原则的要求，违反物权法定将导致设定与变动物权的行为无效，物权不能有效地设立与变动，但这并不影响合同的效力。[68]《物权法》第15条规定：“当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。”这就意味着，凡是违反了法定的公示方法的，应当认定物权不能有效设定，但并不影响设定和变动物权的合同的效力。

（五）征收、征用

《民法总则》第117条规定：“为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序征收、征用不动产或者动产的，应当给予公平、合理的补偿。”该条就征收和征用作出了规定，进一步强化了对私有财产的保护。

所谓征收就是指国家基于公共利益，通过行使征收权，在依法支付一定补偿的前提下，将单位或者个人的财产移转给国家所有。所谓征用是指国家因抢险、救灾等紧急需要而通过行使征用权，临时使用单位或者个人的财产。这两种方式都是对私有财产权进行合法限制的方式，但为了保障征收、征用的合法进行，依据上述规定，征收征用必须符合如下条件：

第一，征收、征用必须是为了公共利益。所谓公共利益，一般认为，是指有关国防、教育、科技、文化、卫生等关系国计民生的利益。为了防止政府行政权侵害公民和集体的财产权，法律要求政府行使征收权和征用权必须符合公共利益的需要。[69]事实上，政府之所以可以不通过磋商谈判方式而征收、征用个人或集体的财产，根本原因在于其是基于公共利益的需要。因此，公共利益也是行使征收权和征用权的正当性和合法性的前提。例如，在“赵某某等与桓仁满族自治县人民政府房屋征收决定纠纷申请再审案”中，法院认为：“在旧城区改造的过程中，市、县人民政府通过商业开发的形式来补充旧城改造资金的不足，其目的仍是为了改善被征收人的居住环境、提高生活品质。商业开发仅是房屋被征收后土地利用的一种手段，只要房屋征收补偿安置确保了被征收人获得回迁的选择权，就不能据此否定征收的公共利益目的。”[70]

第二，依照法律规定的权限和程序。征收和征用都必须依照法律规定的权限和程序进行。这就是说，政府必须在法定的权限范围内从事征收和征用，而且，征收和征用都必须按照法定的程序进行。《民法总

则》特别强调征收补偿必须依据法定的权限和程序，主要原因在于：一方面，这是充分保护公民财产权的需要。征收是永久性地剥夺公民的财产权利，征用也要限制公民的财产权，为了防止一些地方政府及其工作人员以公共利益为名，滥用征收和征用的权力，损害私人的利益，必须强调要遵循法定的程序。另一方面，在征收和征用中严格强调依据法定的权限和程序进行，有利于保障政府机关依法行政。程序是看得见的正义，只有保障程序公开、公正，才能保证征收和征用行为的合法性。

第三，依法作出公平合理的补偿。《宪法》第13条第3款规定，对公民的私有财产实行征收或者征用应给予补偿。因为征收、征用虽然在性质上不是交易，作出征收、征用的决定不是遵循自愿的原则来进行的，但它必须以补偿为前提，而不能在未支付任何补偿的情况下强制性地移转公民的所有权。法律作出此种规定的主要目的是充分保护公民和法人的合法权益。《民法总则》再次强调征收、征用必须给予公平、合理的补偿。因此，在征收和征用的情况下，国家必须对相对人予以补偿。例如，在“宋某某诉宿迁市建设局房屋拆迁补偿安置裁决案”中，法院认为，征收单位、个人的房屋以及其他不动产，应当依法给予拆迁补偿，维护被征收人的合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。[71]

三、债权

（一）债权概述

《民法总则》第118条第1款规定：“民事主体依法享有债权。”该条就宣示了民事主体可以依法享有债权。所谓债权，是指特定主体请求特定主体为一定行为或者不为一定行为的权利。债权是重要的民事权利类型，而且在市场经济社会具有日益重要的地位。债权具有如下特征：

第一，主体具有特定性。债是发生在特定主体之间的财产法律关系，债权不同于其他民事权利的特点在于：无论是权利主体还是义务主体都是特定的。正是由于这一原因，债的关系具有相对性，债权人只能请求特定的债务人履行债务，债务人也只需要向特定的债权人履行债务，债的关系仅在特定的当事人之间具有法律效力。[72]

第二，产生原因具有多样性。传统上，债的类型主要有合同之债、侵权之债、不当得利之债、无因管理之债、缔约过失之债等类型，但随着社会生活的发展，又出现了因法定补偿义务而产生的债、因单方行为产生的债等债的类型。而且，即便是传统类型的债的关系，随着社会生活的发展，其内容也在发展变化。依据《民法总则》第118条第2款的规定，债权的发生原因包括“合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定”。

第三，内容具有特殊性。“债”这个词实际上包含了债权人的权利和债务人的义务两个方面的内容。但按照一般理解，债的内容仅指债务人的特定行为，即债务人应当按照债的要求对债权人为一定的给付。而且作为债的标的的给付，既可以是作为，也可以是不作为。

第四，效力具有平等性。与物权等绝对权不同，债权在效力上具有平等性，在同一债务人负担多项债务的情形下，不论各项债权成立时间的先后，或者债权数额的大小，其效力上都是平等的，即当债务人的财产不足以实现全部债权时，享有担保物权的债权可以获得优先受偿，而其他普通债权原则上应当按照债权比例公平受偿。

第五，存续上具有期限性。任何债权都有其存续期限，法律上有永远存在的所有权，却不可能有永远存在的债权。因为债的关系对债务人而言是一种负担，如果允许债的关系长期存在，则可能对债务人的行为构成不当的妨碍。另一方面，债的产生一般是为了取得物权，或者是为了实现融资等目的，一旦上述目的的实现，债的功能也已得到了发挥。

第六，债具有动态性。债的关系是一个动态的发展和变动过程，债本身具有高度的变化性，它是随着时间的流逝而逐渐发展变化的。在债的不同阶段，债的关系的内容也存在一定的差异，债的发展变化性主

要体现在以下两个方面：一方面，债的关系在成立之后会因为债务的履行或不履行而发生变化。另一方面，在不同的履行阶段，债的关系的内容也不相同，随着债的关系的发展，债的关系可能发展出各种请求权、抗辩权、形成权等。[73]此外，依据诚实信用原则，债的关系当事人还应当负有一定的附随义务，在债的不同阶段，其内容也有所不同。

（二）合同之债

合同是债权发生的重要原因，而且是基于当事人的意思而产生的债权，属于意定之债的范畴。《民法总则》第119条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。”该条对合同的约束力作出了规定。合同的法律约束力是指依法成立的合同在当事人之间产生的法律效力，它反映了法律对当事人之间的合意的评价。只要合同具备了法定的生效要件（或称有效要件），法律就赋予该合同一定的法律约束力。当事人应当依据合同约定行使权利和履行义务，违反合同义务应当承担相应的责任。在合同发生争议以后，当事人的约定就具有优先于法律规定而适用的效力。简言之，合同的法律约束力就是当事人必须严守合同，否则应承担法律责任。市场经济的有序运行要求建立保护产权、严守契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管的法律制度，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，该条对合同的约束力作出规定，对于督促当事人严守合同、维护交易安全和交易秩序具有重要意义。

1. 依法成立的合同才能产生法律约束力

依据《民法总则》第119条的规定，只有依法成立的合同才能产生法律约束力。合同能够产生法律拘束力，从表面上看是当事人合意的结果，但从实质上看，合同的法律约束力或合同的效力，并非直接来源于当事人的意志，而是来源于法律的赋予。也就是说，因为当事人的合意符合国家的意志和社会利益，因而国家赋予当事人的意志以拘束力，要求合同当事人严格履行合同，否则，将依靠国家强制力强制当事人履行合同并使其承担违约责任。可见，合同的效力本身介入了国家意志，如果合同不符合国家意志，该合同将可能被宣告无效或被撤销。我国《民法总则》第119条实际上揭示了合同具有法律效力的依据。

首先，合同必须依法成立。依据该条规定，合同成立是其产生法律约束力的基础。合同生效就是法律对当事人合意效力的认可，如果说合同的成立主要是事实判断，那么，合同的效力则属于法律上的判断，这实际上是法律对当事人已经存在的合意的认可。

其次，依法成立的合同具有法律约束力。依据该条规定，依法成立是合同产生法律约束力的前提。合同对当事人之所以有法律拘束力，是因为当事人的意志与国家意志一致，因而国家赋予了当事人意志以法律效力。因此，对合同效力的判断不仅要考虑合同是否已经成立，还要确定合同是否依法成立：一方面，要考虑合同的内容是否违反法律法规的强制性规定和公序良俗；另一方面，要考虑合同的形式是否符合法定的形式要件的要求。只有依法成立的合同，才能具有法律拘束力。

2. 合同所具有法律约束力的内容

依据《民法总则》第119条的规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。此处所说的法律约束力，是一种私法上的效力。所谓私法上的效力，是指合同所产生的的是民法上的权利义务关系，违反合同将承担民事责任。合同关系只是一种民法上的权利义务关系，它不可能产生一种公法上的效果，在一方违约的情况下，另一方需要借助公权力的介入来要求对方履行合同，但是任何一方都不得对另一方实施行政处罚。至于国家机关也不得干涉合同内容，这是这种私法上的效果的体现。具体而言，合同的法律约束力体现为如下两个方面：

第一，合同的对内效力。所谓对内效力是指对合同当事人的约束力，这是合同效力的主要内容。具体表现在，一是合同依法成立后，将产生合同的权利义务关系，权利义务既是合同的内容，也是合同效力的体现，合同一旦生效，债权人依据法律规定和合同约定享有权利，同时，债务人也应当依据法律规定和合同约定负担义务。二是合同生效后，当事人必须严守合同，不得随意撤销或者解除合同。三是合同生效后

，当事人应当严格按照合同约定履行合同，否则即可能需要承担违约责任。合同权利义务就像一把“法锁”一样拘束着双方当事人。四是在不履行合同义务的情况下应当承担违约责任。违约责任是违反合同义务的结果，它既体现了对违约方的制裁，也是对非违约方的救济。

第二，合同的对外效力。所谓对外效力，是指对合同当事人以外的第三人的效力，对外效力是合同效力的扩张在主体方面的体现。根据合同相对性的原则，只有合同当事人才能享有基于合同所产生的权利，并承担根据合同所产生的义务，当事人一方只能向对方行使权利并要求其承担义务，不能请求第三人承担合同上的义务，第三人也不得向合同当事人主张合同上的权利和承担合同上的义务。从这个意义上说，合同不具有对第三人的拘束力。但近现代各国立法及判例，对上述原则已有突破，对传统合同效力加以扩张，使其效力范围不仅涉及于合同当事人，而且发生涉及第三人的效力，学理上称之为合同效力范围的扩张。在各国立法和判例中，主要表现为确认第三人利益的合同、确立债权保全制度、承租权物权化、债权不可侵犯性以及附保护第三人作用的合同等。[74]依法成立的合同所具有的效力，也包括排斥第三人的非法干预和侵害的效力。第三人不得非法引诱债务人不履行义务或采取拘束债务人等非法强制手段迫使债务人不履行债务，或者与债务人恶意串通损害债权人利益。

（三）侵权之债

“侵权行为”也称为侵害行为或过错行为，其本意是指侵害他人权利或利益的行为。侵权行为作为加害行为，不限于自己从事的加害行为，它还包括在法律上应当承担责任的“准侵权行为”，如雇员的加害行为、被监护人致人损害，以及物件致人损害的侵权行为等。[75]侵害的“权”不仅包括民事权利，而且包括受到法律保护的利益。因此，从其固有的含义而言，“侵权行为”是指一种侵害他人权益的行为以及造成损害结果的状态。《民法总则》第120条规定：“民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。”依据该规定，侵权行为是责任侵权承担的前提和依据，凡是实施了侵权行为的行为人，都要承担相应的后果。所谓侵权责任，是指侵权人因实施侵害或损害他人民事权益的行为而依据侵权责任法所应当承担的法律后果，它是民事责任的一种类型。因此，《民法总则》第120条使用了“民事权益受到侵害”的表述，以凸显侵权法保护客体的开放性。

当然，民事权益在受到侵害后，行为人并非当然需要承担侵权责任，只有在符合侵权责任构成要件时，受害人才能够请求行为人承担侵权责任。

侵权责任具有以下几项法律特征：

第一，侵权责任以侵权行为为前提。侵权行为是行为人承担侵权责任的前提，或者说侵权责任产生的法律基础是侵权行为。法律规定侵权责任的目的在于制裁侵权行为，保护公民、法人的民事权利，恢复被侵权行为破坏了的财产关系和人身关系。[76]当然，侵权行为可能不仅产生侵权责任，有些侵权行为也会产生行政责任，甚至是刑事责任，但是行为人承担行政责任、刑事责任并不能够免除其侵权责任，因为这些不同责任所产生的依据不尽相同。

第二，侵权责任主要是因侵害绝对权而产生的责任。《民法总则》第120条规定：“民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。”此处所说的“民事权益”主要是指合同债权以外的绝对权。一方面，侵权责任法所保护的权益主要限于绝对权。所谓绝对权，是指无须通过义务人实施一定的行为即可以实现并能对抗不特定人的权利。[77]绝对权主要包括所有权、人身权、知识产权。侵权责任法保护的对象主要是民事权益中的绝对权，而相对权主要在特定的当事人之间发生，且缺乏公示性，故通常多不在侵权责任法的保护范围内。[78]因为绝对权的权利人对抗的是除他以外的任何人，所以绝对权又称为对世权。对于尚未形成权利的权益，在法律上缺乏一种可预见性，人们并不知道何种行为会导致对他人利益的侵害以及将造成何种后果。所以，对侵害利益的侵权行为应当施加一定的限制，从而避免干涉人们的行为自由。另一方面，合同债权在性质上不是绝对权，故一般不应受到侵权责任法的保护。在特定的合

同关系中所产生的合同利益被侵害时，应当主要通过违约之诉来解决。[79]

第三，侵权责任以损害赔偿为核心，但又限于损害赔偿。侵权责任的主要功能在于对受害人提供补救，使受害人遭受的全部损失得到恢复。我国《侵权责任法》第15条中列举了8种侵权责任方式，因而侵权责任的范围大于损害赔偿之债的范围，它不仅包括金钱损害赔偿责任，也包括返还原物、恢复原状、赔礼道歉等。由于采用了多种责任方式，因而，不能说侵权责任都产生债的关系。当然，应当看到，在侵权责任法中，损害赔偿是其主要的责任方式，因此，侵权责任法主要体现了救济功能。这就表明，侵权责任虽以损害赔偿为核心，但并不局限于损害赔偿。

第四，侵权责任是对受害人所承担的责任。法律责任都是以国家强制力保障其实现的责任，但侵权责任不同于刑事责任和行政责任之处就在于，侵权责任是通过损害赔偿等方式，实现对受害人的直接救济。而刑事责任和行政责任则是行为人对国家所承担的责任，其虽然也可以间接地发挥保障受害人的作用，但毕竟无法直接给受害人提供救济。

（四）无因管理之债

所谓无因管理，是指没有法定或约定的义务，而管理他人事务的行为。其中，行为人称为管理人，被管理人称为本人（又称为受益人）。所谓“无因”，即是指无法律上的义务。[80]《民法总则》第121条规定：“没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。”依据该规定，无因管理的成立，必须符合如下条件：

第一，没有法定或者约定的义务。

无因管理中的“无因”，是指没有法律上的原因。构成无因管理的基本前提是，管理人没有法定或者约定的义务而管理他人的事务。具体来说，其包括以下两种情形：一是无法律上的义务。所谓法律上的义务，是指依据法律规定而产生的义务。例如，依据法律规定负有赡养、扶养义务，行为人履行相关赡养、扶养义务的，不构成无因管理。二是无合同上的义务。例如，当事人之间基于委托合同，一方当事人负担义务，则属于“有因”的管理。判断行为人管理他人事务是否无因，应当以开始管理事务之时作为判断的时间点。[81]例如，保姆依据合同约定为他人照顾孩子，但在该合同解除后，其继续照顾他人的孩子，从此时开始，该保姆的行为就构成无因管理。

第二，行为人实施了管理他人事务的行为。

构成无因管理，以管理人所管理的事务为他人事务为构成要件。管理事务的范围十分宽泛，包括处理、管理、保存、改良及提供各种服务和帮助等，只要是有利于避免他人损失，或有利于他人的行为，都属于管理他人事务的行为。在管理事务的过程中，管理人有可能确切地知道其是在为某个具体的人管理事务，也有可能不知道本人的具体身份，但这并不妨碍无因管理的成立。[82]例如，阳台上的花属于他人，管理人在下雨时将其搬进房屋，管理人不知道本人，并不妨碍无因管理的成立。

第三，管理人具有为他人利益进行管理的意思。

为他人利益进行管理的意思，简称为管理意思，也称为他人事务管理之意思（*animus aliena negotia gerendi*），它是指管理人具有通过管理活动为他人谋利，或将管理所获得的利益归属于他人的意思。[83]管理意思为无因管理成立的主观要件。无因管理的本质特点在于，其是在无法定或约定义务的情况下，为他人管理事务，而非为自己管理事务。在判断管理人有无为他人管理事务的意思时，通常要求在管理行为发生时，大体上知道事务属于他人。但是，这并不意味着，管理人必须明确地知道本人是谁，具体认识到本人的身份，而只需要管理人有为他人管理事务的意图即可。有关是否存在管理的意思，应当由管理人负有举证责任。[84]

第四，管理人不应违背本人明示或可得推知的意思进行管理。

构成适法无因管理，应当以管理人的管理行为符合本人明示或可以推知的意思为前提，这就要求管理人在从事管理事务时，如果知道本人的存在，而且可以联系到本人，则应当与本人联系，以确定本人是否愿意由他人管理其事务。如果本人事先已经明示了其事务管理的方法、管理的期限等，且管理人了解本人这一意思，则管理人不应违背本人的这一意思管理其事务，否则，管理人管理本人事务的责任将会加重。如果本人告知管理人，要求其停止管理，则管理人应当停止管理活动。无因管理制度既保护管理人的利益：鼓励助人为乐的行为，同时，也保护个人利益免受他人不当的干涉[85]，因此，如果管理人明知本人明示或可得推知的意思，则出于对本人私人事务的尊重，一旦本人要求管理人停止管理，管理人即不得再实施管理行为。

行为人未经本人许可而管理他人事务，将构成侵权，受害人有权请求行为人承担侵权责任，但在行为人的管理行为构成无因管理的情形下，该管理行为即具有阻却违法的效力。依据《民法总则》第121条的规定，管理人在管理本人事务时，虽然没有得到本人的允许，但不仅不构成侵权，管理人反而可以依法向本人请求偿还因管理事务而支出的必要费用，这就实际上肯定了无因管理具有阻却违法的效力。依据该条规定，管理人有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。这就是说，如果管理人因管理事务而支出了合理的费用，则其有权请求本人偿还。合理的费用包括两种：一是必要的费用，即因为事务管理而必须支出的费用，例如，因收留他人走散的耕牛而支出的饲料费。判断费用是否必要，应依社会一般人完成相同管理行为所需支出的费用为标准。另外，必要费用的返还也可以包括管理人因管理事务而使自己遭受损害的赔偿。二是有益的费用，即虽然不是必要的费用，但属于有益于被管理人的费用，例如，在收留迷路的儿童时，为其支出的教育费用。对于上述两项费用，管理人都有权请求本人偿还。

（五）不当得利之债

所谓不当得利，是指没有法律上的原因而获得利益，并使他人遭受损失的事实。例如，某人因不知道自己已经付款，又重复向出卖人支付了价款，出卖人所获得的第二笔价款就构成不当得利。《民法总则》第122条规定：“因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。”依据该条规定，不当得利的成立要满足如下条件：

第一，一方获得利益。不当得利是以一方获得利益为前提的。因为如果无人获得利益，也就不存在得利“当”与“不当”的问题。所谓获利，是指因为一定的事实而导致其财产的增加或不减少。[86]不当得利返还义务是用来回复不当得利事件发生时当事人之间所应当具有的利益状态，因此，不当得利制度主要维护财产的静态利益。[87]按照举证责任的一般规则，如果遭受损害的一方提出不当得利返还的请求，其应当就获利人的获利负担举证责任，否则，其请求无法成立。不当得利中的“获利”包括以下两种：一是积极的获利，即受益人在既有财产的基础上获得了一定的利益。通常来说，受利益都是受有财产利益，例如，因添附而导致所有权的客体范围增加。二是消极的获利，即受益人本应减少的财产而未减少，例如，房屋所有权上的抵押权消灭。

第二，无法律上的原因。不当得利中的“不当”是指没有法律上的原因。在不当得利中，受损人要求返还的利益必须有合法的基础，如果损害是由受损人的违法行为造成的，法律将不对此种损害提供救济。具有法律上的原因是受益人保有利益的权利基础，没有合法的权利基础就构成不当得利。不当得利的成立以获利人所获利益欠缺法律上的原因为前提，不当得利构成要件中“无法律上的原因”通常包含以下情形：一是当事人之间不存在有效的合同关系。这主要是指如果合同无效、被撤销、不成立或被解除，当事人获利不再具有法律上的原因，从而构成不当得利。二是不具有法律规定的原因。如果法律上规定了作为义务等，当事人因履行此种义务而遭受损害的，不得向受益人请求返还不当得利。例如，兄姐履行了扶养弟妹的义务，这属于法律义务，不能请求不当得利返还。三是无道德上的义务。法律上的原因也包括基于亲属关系等而产生的道德上的义务。在存在此种原因的情形下，也难以构成不当得利。例如，丧偶女婿对岳父母的赡养，虽然没有法律上义务，但有道德上的义务，因此也不构成不当得利。四是受损人并没有就其

遭受的不利表示同意。在受损人遭受损失后，如果其就所遭受的不利表示同意，则该同意的表示就可以成为“法律上的原因”，否则，获利人的获利即构成不当得利。[88]

第三，他方受到损害。所谓他方受到损害，是指一方当事人所遭受的财产上的损失。损害通常是指权利人遭受的人身或者财产上的不利益。根据《民法通则》第92条的规定，不当得利请求权的适用以“造成他人损失”为前提。该条所规定的“损失”应当是指财产损失，包括积极损失和消极损失两个方面。所谓积极损失，是指现有财产利益的减少。所谓消极损失，是指应该获得的财产而没有获得。当然，对不当得利中的损失应作宽泛的解释，不仅包括金钱价值的减少，还包括使用、收益等潜在价值的减少，受害人所遭受的损失应当由受害人举证证明。

第四，获利与受损之间具有因果关系。所谓获利与受损之间具有因果关系，是指一方获利是他方受损的原因，而他方受损就是由一方获利所造成的，在受损和获利之间具有原因和结果之间的关联性。只有受益人的获利与受害人的受损之间存在因果关系，才意味着法律需要对此种利益状态进行调整，此时不当得利返还请求权也才具有正当性，如果损失与获利之间毫无因果关系，则受损人向获利人主张返还不当得利就欠缺合理性基础。

依据《民法总则》第122条的规定，在成立不当得利时，“受损失的人有权请求其返还不当利益”，可见，不当得利的主要效力是在当事人之间产生返还义务，即受损的一方有权请求获益人返还其所受领的利益。具体而言，不当得利请求权返还的对象包括以下几类：

一是原物。在构成不当得利的情形下，受损的一方有权请求获益人返还原物。依据不当得利，受损人除有权请求获利人返还原物外，如果原物灭失或者获利人因原物而获有其他利益的，受损人也有权请求获利人返还该利益，此种情况称为价额返还。[89]这主要是指在原物灭失的情形下，如果受益人因此获得了代位物或者损害赔偿请求权，则受损人有权请求受益人返还该代位物或者移转该损害赔偿请求权。[90]例如，原物因保险事故灭失，获利人因此受有保险金的，或者原物被第三人损毁，获利人由第三人处获得的损害赔偿金等，受损人应当有权请求获利人返还该代位物，或者请求获利人移转其对第三人的损害赔偿请求权。[91]

二是原物产生的孳息。依据《民法通则意见》第131条的规定，如果在受益人占有原物期间，产生了孳息，则受损人也有权请求受益人返还该孳息。此处的孳息包括原物在获利人占有期间产生的天然孳息和法定孳息等。[92]如果当事人之间的合同被撤销或者被宣告无效，则标的物的所有权仍归属于出卖人，因而产生的孳息也应当归属于出卖人，受益人保有因原物而产生的孳息即欠缺法律上的原因，因此，受损人在向获利人请求返还不当得利时，除请求原物返还外，还有权请求获利人返还原物所产生的孳息。[93]

三是获利人通过原物而获得的收益，主要是指获利人通过将原物出租等方式而获得的收益。按照通说，此时，受损人也有权请求获利人返还该利益。[94]在行为人非法使用他人的房屋或者其他物件的情形下，行为人向权利人返还原物或者其他物件时，行为人仍获得一定的利益，受损人有权请求行为人返还该获利。在此情形下，如果行为人利用他人之物获得了租金，则应当返还该租金；如果没有获得租金，则应当按照租金或者使用费的标准返还，即比照租金或者使用费的标准予以返还。

四是受损人在请求受益人返还原物时，也有权请求受益人返还原物的权利证书、权属证明等证明文件。

当然，在确定不当得利的返还范围时，应当考虑受益人的主观状态，因为不当得利制度除了调整当事人之间欠缺法律原因的财产变动关系外，还具有剥夺行为人不法获利、预防不法行为的功能。因此，在确定不当得利返还请求权的返还范围时，一方面需要考察受益人获利与受损人受损之间的关系，另一方面还要考察受益人的主观状态，这也有利于平衡当事人之间的合法权益。在受益人是善意的情况下，受益人并不知道其所获利益欠缺法律上的原因，其可能没有消费该物的计划，更无法预见其所获利益被请求返还时

可能产生的后果，因此，其原则上只应当返还现存利益，如果课以其过重的返还义务，可能会不当加重其负担。而在受益人为恶意的情况下，其应当返还全部利益，即使在其所获利益不存在的情形下，受益人仍应当负担返还义务，因为受益人主观上具有恶意，而且其可以预见其所获利益被请求返还时可能产生的后果[95]，课以其较大范围的返还义务并不会过分加重其负担。

四、知识产权

知识产权，是指权利人对其智力成果和工商业标志享有的权利。《民法总则》第123条第1款规定：“民事主体依法享有知识产权。”《民法总则》作出这一规定，宣示了知识产权作为一种民事权利应当受到法律保护；同时，宣示了知识产权可适用民法典的规定。知识产权无疑是民法的重要组成部分，但这并不意味着它应成为民法典的独立一编，因其内容非常庞杂、复杂，且随着科技的进步需要频繁进行修改，应当将其在民法典之外作为特别法单独规定。但知识产权兼具人身性和财产性，其本质上仍属于民事权利的范畴，是私法上财产权利和人身权利的结合。在发生知识产权纠纷后，如果知识产权法未作出特别规定，可以适用民法典的规定。例如，侵害知识产权的责任，在知识产权法中缺乏规定时，可适用侵权责任法的规定。

《民法总则》第123条第2款规定：“知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。”从该条规定来看，其在规定知识产权的客体时，采用了具体列举与兜底规定相结合的方式，扩大了知识产权客体的范围，并为将来对新型知识产权保护预留了空间。作为知识产权客体的智力成果是没有外在形体的知识财富，非物质性是智力成果的本质属性，这也是其与传统意义上的所有权最根本的区别。[96]《民法总则》规定知识产权客体的意义主要在于：一是适应经济社会发展。相对于其他民事权利而言，知识产权受社会文化、经济发展、新技术革命影响更巨，总是处于不断发展变化之中，所以，在《民法总则》中有必要对其客体作出规定。二是授权特别法就这些客体之上的知识产权作出规定。三是明确了这些客体除了受知识产权法的保护之外，也应当受到民法典的保护。具体来说，知识产权的客体包括如下几种：

第一，作品。作品是作者创造性智力劳动的成果，是著作权的产生依据。著作权保护作者与作品之间精神和物质的联系，作者可以依据这种联系获得相关的人身和财产利益。依据《著作权法实施条例》第2条的规定，“著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”。依据《著作权法》第2条第1款的规定，“中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权”。依据《著作权法》第9条的规定，作者与作品之间的联系不得被非法侵害，作品的内容不得被非法修改，并不得被非法利用。

第二，发明、实用新型、外观设计。发明、实用新型与外观设计是专利权的客体，依据《专利法》第2条的规定，所谓发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；所谓实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；所谓外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。同作品一样，这些专利权客体也是专利权人创造性劳动的成果，但和作品不同，专利通常具有一定的技术性内容，人身属性相对较少，因此，对专利权人来说，专利权主要体现为财产利益。[97]

第三，商标。商标是商标权的客体，所谓商标，是指生产者或者经营者在其商品或者服务中使用的、用于区别商品或服务来源的、具有显著特征的标志。依据我国《商标法》《反不正当竞争法》等法律的规定，不论是注册商标，还是未注册商标，均受到法律保护。商标体现了生产经营者所提供商品或服务的区别性，这种区别性反映了商品或者服务的品质或口碑，商标权所保护的就是这种品质或口碑中所蕴含的经济价值。因此，当他人非法使用或者使用近似商标，足以导致消费者产生误解时，便侵害了商标权人的利

益。[98]

第四，地理标志。地理标志也是重要的知识产权客体，依据《商标法》第16条的规定，所谓地理标志，是指“标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。地理标志是TRIPs协定所确定的七大类知识产权之一，是重要的知识产权类型。[99]我国《民法总则》对地理标志作出规定，为我国将来完善地理标志的法律保护提供了依据。地理标志在广义上属于商标的特殊类型，其作用是标识商品产自某地区，具有特定质量、信誉或者其他特征，这种由于地域的特殊性所带来的经济利益也为法律所保护。[100]

第五，商业秘密。依据《反不正当竞争法》第10条第3款的规定，所谓商业秘密，是指“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息”。商业秘密的特点在于：第一，不为公众所知悉性。这就是说，商业秘密具有一定程度的秘密性，只是为少数人所知和使用，商业秘密也具有一定的新颖性，即已经达到了一定的技术水平。[101]第二，能为持有人带来经济利益。根据国家工商行政管理总局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条第3款的规定：“本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为权利人带来现实的或者潜在的利益或竞争优势。”这就是说，商业秘密具有一定的经济价值，并能够转化为商业上的利益。当然，此种价值应具有客观性，即除持有人认为有实用价值外，还必须在客观上确实具有实用价值。仅仅由持有人认为有价值而客观上没有价值的信息，不能构成商业秘密。[102]第三，具有实用性。实用性是指商业秘密的客观有用性，即商业秘密能够被实际运用，并通过运用可以为商业秘密的持有人创造出经济上的价值。既然商业秘密能为持有人带来一定的经济利益，当然应当具有实用性。无论是技术信息还是经营信息都会给所有人带来一定的经济利益，因此商业秘密应受法律保护。[103]第四，具有保密性，所谓保密性，是指商业秘密的持有人主观上将其持有的某种商业信息作为秘密对待，并在客观上采取了保密措施。商业秘密是否为一种权利，以及属于何种性质的权利，仍然存在争议。但毫无疑问，商业秘密作为一种知识产权的客体，应当获得法律保护。

第六，集成电路布图设计。集成电路布图设计也是重要的知识产权客体，我国《集成电路布图设计保护条例》对集成电路布图设计的保护作出了规定，依据该条例第2条的规定，所谓集成电路布图设计，是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置，或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。集成电路布图设计与集成电路的运行效率有密切联系，优秀的设计能够极大地提升集成电路的运行效率。因此，它具有重要的经济利益，也是设计者创造性智力劳动的成果，法律保护相关的设计者通过优秀设计获得相应利益的权利，并禁止他人的非法使用与拷贝。

第七，植物新品种。植物新品种是重要的知识产权客体，我国《植物新品种保护条例》对植物新品种的保护作出了规定，依据该条例第2条的规定，所谓植物新品种，是指经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种。植物新品种要获得专利的保护，其必须具备专利的条件，如新颖性、创造性和实用性。[104]

第八，法律规定的其他客体。除上述知识产权客体外，如果其他法律对知识产权客体的保护有新的规定，则该知识产权客体也受到法律保护。该条对知识产权的客体使用兜底式的规定，保持了知识产权客体的开放性，也为相关立法对新型知识产权客体的保护提供了依据。

五、继承权

所谓继承权，是指继承人依据法律规定或者遗嘱而取得被继承人财产的权利。广义上而言，继承权可以分为继承期待权和继承既得权两种。前者是指继承开始前，继承人享有的依照法律的规定或者遗嘱而继承被继承人遗产的资格；后者是指继承开始后，继承人实际享有的可以依照法律的规定或者遗嘱而继承被继承人遗产的资格。[105]继承权并不是单纯的财产权，也不是人身权，而是具有综合性的权利。[106]《

民法总则》第124条第1款规定：“自然人依法享有继承权。”这就在法律上确认了自然人享有的继承权。

《民法总则》第124条第2款规定：“自然人合法的私有财产，可以依法继承。”依据该条规定，一方面，继承的客体必须是合法的私有财产。如果财产是非法的，则应当依法被收缴或者退还权利人，不得成为继承的对象。另一方面，该条肯定了私有财产可以被继承，从而从继承的角度强化了对私有财产的保护。对私有财产的保护，不仅要在自然人的生前加以保护，而且还要明确在自然人死亡后可以由其继承人继承。这两者对于私有财产的保护是相辅相成、缺一不可的。我国《宪法》第13条明确规定，国家依照法律规定，保护公民的私有财产权和继承权。这就将继承权和私有财产权密切地联系在一起。

对继承权的保护主要是通过继承法来实现的。所谓继承法，是指调整因自然人死亡而发生的继承关系的法律规范的总称，换言之，是调整有关自然人死亡后将其遗留的财产转移给生者的法律制度。[107]从实质上看，公民的财产继承权不过是其财产所有权在死后的延伸，保护公民的财产继承权是对财产所有权的保护。因此，财产继承制度是民法的重要组成部分。我国1985年颁布了《继承法》，该法已经自成体系，但在内容上有待于进一步完善。未来民法典将其作为继承编收入其中时，应当进一步修改、充实。

六、股权和其他投资性权利

《民法总则》第125条规定：“民事主体依法享有股权和其他投资性权利。”该条规定了两项权利：一是股权。从广义上讲，股权是指股东可以向公司主张的各种权利；从狭义上讲，股权是指股东因出资而取得的，依法律或者公司章程的规定和程序参与公司事务并在公司中享受财产利益的，具有可转让性的权利。股权可以分为自益权和共益权。所谓自益权，是指股东为从公司获取财产利益而享有的一系列权利，主要包括股票的请求权、股份转让过户的请求权、新股认购优先权、分配股息红利的请求权、分配公司剩余财产的请求权等。[108]所谓共益权，是指股东参与公司决策、经营、管理、监督等而享有的一系列的权利，主要包括：出席股东会的表决权、任免董事等公司管理人员的请求权、查阅公司章程和账簿的请求权、要求法院宣告股东会决议无效的请求权、新股停止发行请求权等。[109]股权实际上是成员权或社员权的一种类型。对股权的内容，我国《公司法》已经作出了相关的规定。二是其他投资性权利。其他投资性权利主要是指民事主体通过各种投资行为而取得的权利，如通过购买基金、保险等取得的权利。[110]

七、其他合法权益

《民法总则》第126条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益。”该条实际上是一个兜底性的条款，不仅使民事权利的保护形成了完整的体系，而且使对私权的保护进一步地保持了开放性。一方面，无论是权利还是利益的具体列举，都可能是不周延的。“法条有限、世事无穷”，社会生活不断变化发展，列举权利和利益是不可能满足实践的发展的。通过开放性的规定，可以为法官提供裁判依据。另一方面，只有具体列举和兜底性的规定相结合，才能形成完整的体系。毕竟列举是有限的，如果没有兜底性的规定，就无法形成完整的体系。

为了适应21世纪互联网、大数据时代的需要，顺应高科技发展的要求，《民法总则》第127条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”该条对数据和网络虚拟财产的保护作出了规定，这些权益都是随着网络社会的发展而出现的新型民事权利。当然，新型民事权益的范围十分广泛，不限于上述数据权利和网络虚拟财产两种，随着经济社会的发展，合法权益的范围是不断变化的，一些新型权益将不断出现，《民法总则》第126条在规定受法律保护的民事权益范围时使用了“其他民事权利和利益”这一兜底条款，这就为将来新型民事权益的保护提供了法律依据，保持了受法律保护的民事权益范围的开放性。

第四节 民事权利的取得和变动

一、民事权利的取得

（一）概述

民事权利的取得，是指民事主体依据合法的方式或根据获得民事权利。《民法总则》第129条规定：“民事权利可以依据民事法律行为、事实行为、法律规定的事件或者法律规定的其他方式取得。”依据这一规定，民事权利的取得可以分为如下几种情形：

第一，依民事法律行为取得。依民事法律行为取得民事权利，主要是指当事人通过买卖合同、赠与合同等方式而取得民事权利。例如，当事人通过合同取得对标的物的所有权。我国《物权法》对基于法律行为的物权变动规则作出了规定，该规则就是依民事法律行为取得物权的规则。从实践来看，依民事法律行为取得民事权利是民事权利最为主要的取得方式。

第二，依事实行为取得。当事人也可以依据事实行为取得民事权利，我国法律也对此种民事权利取得方式作出了规定。例如，《物权法》第30条规定：“因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生效力。”该条所规定的因合法建造房屋而取得物权就是依事实行为而取得物权。

第三，依法律规定的事件或法律的其他直接规定取得。事件也可以成为民事主体取得民事权利的重要原因。例如，人的死亡可以使继承人取得继承遗产的权利；再如，基于添附而取得相关的民事权利等。除事件外，法律的直接规定也是民事主体取得民事权利的重要方式。例如，自然人因出生而获得人格权和身份权、财产权等基本的民事权利。

第四，依法院的判决取得。法院的判决也是民事主体取得民事权利的重要方式，我国现行立法对此种民事权利取得方式作出了规定。例如，《物权法》第28条规定：“因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者人民政府的征收决定等生效时发生效力。”当然，此种物权变动必须基于人民法院的生效判决或仲裁委员会的生效裁决，且此种判决和裁决必须针对物权变动而作出。

可见，民事主体取得民事权利的方式多种多样，但无论采取何种方式，民事权利的取得都必须合法。

（二）原始取得与继受取得

民事权利的合法取得方式可分为原始取得与继受取得两种。

所谓原始取得，是指根据法律规定或者民事法律行为，最初取得民事权利或不依赖于原权利人的意志而取得某项民事权利。在物权法领域，原始取得的根据主要包括：劳动生产、天然孳息和法定孳息、添附、没收、无主财产收归国有等。原始取得一般是基于法律规定取得，当然，在特殊情形下，原始取得也可能基于法律行为取得，如当事人通过加入社团而取得社员权。^[111]

继受取得又称传来取得，它是指通过某种法律行为从原权利人那里取得某项民事权利。这种方式是以原民事权利人对该项民事权利享有权利作为取得的前提条件的。继受取得的方式主要包括买卖、赠与、继承遗产、接受遗赠、互易等形式。

权利的继受取得还可作如下分类：

（1）单一继受取得，即对单一的权利的继受取得。如甲将公司卖给乙，则甲必须把该公司所有的财产，如土地、设备、专利等一一转让给乙。单一的继受取得可以进一步分为移转的继受取得和创设的继受取得。前者指一方移转权利而另一方取得权利；后者是指一方移转权利，并在该权利基础上创设了新的权利。

(2) 全部继受取得，即对一系列权利的全部取得。此种取得方式只有在法律允许的情况下，并根据法律的规定才能够进行。财产继承是最常见的，也是最重要的权利全部继受取得的情况。在企业发生整体转让以及分立、合并的情况下，原企业的债权等权利也由新的企业全部继受取得。

民事权利也可以经过法律的直接规定而取得，例如法定的优先权就是直接通过法律的规定而取得的权利，此种情况在学理上称为“依法律的规定而直接取得权利”[112]。但绝大多数民事权利是基于法律行为或其他法律事实而取得的，例如，所有权的取得、债权的取得等。但在依法律行为方式取得的权利中，有一些权利必须要法定化，不能由当事人随意创设，如物权；还有一些权利是直接通过当事人的约定而自由创设的，如合同债权。

二、民事权利的变更

导致民事权利变更的事实主要是：

1. 根据当事人的约定而变更民事权利，如通过合同对当事人之间的债权债务关系予以变更，或通过达成调解协议而使当事人的权利义务关系发生变更。

2. 基于法律规定的原因而发生的权利变更。如所有权因添附而变更、因设置留置权而受到限制，因当事人部分履行而使其债务范围缩小。基于法律规定的原因而变更的民事权利，可以分为两种类型：一种是基于法律的规定直接发生权利变更的效果；另一种是虽然出现了一定的法律事实，但还要请求法院通过诉讼程序来变更民事权利。

三、民事权利的消灭

民事权利的消灭，其原因可以分为两类：一是绝对消灭，如所有权因标的物的灭失而消灭。二是相对消灭，即权利主体变更，如所有权移转，对原权利人而言即为所有权的消灭。具体来说，民事权利消灭的原因主要包括如下几项：

1. 权利人抛弃权利。按照私法自治原则，民事权利的权利人在行使权利的过程中，只要不损害他人利益和社会公共利益，就可以将其权利予以抛弃。例如，放弃担保物权、免除债务人的债务、抛弃其财产等。抛弃行为完全是一种单方的行为，一旦实施便可以产生法律效果。

2. 转让，即权利人通过与他人订立合同将其权利移转给他人。通过转让使一方丧失了权利，另一方取得了权利。

3. 权利人死亡。权利是由特定权利人所享有的利益。一旦权利主体死亡，法律上不可能存在无主体的权利，因此权利将发生消灭。当然，财产权可以由权利人的继承人继承。需要指出的是，就一些特殊的权利而言，尽管权利人已经死亡，但利益仍然应当受到保护。例如，著作权在作者死后仍然应当受到法律保护。

4. 客体灭失。如果权利的客体因为消费、灭失等原因而不存在，权利失去了客体，该权利在一般情况下将不复存在。不过，在特别情况下，则可能发生物上代位，如抵押权的客体灭失，而获有赔偿金，则抵押权人可就该赔偿金优先受偿。

5. 超过一定的期限不行使权利，导致权利消灭。这主要指具有除斥期间限制的权利，如撤销权、追认权等形成权。

第五节 民事权利的行使

一、对于民事权利行使进行限制的必要性

民事权利的行使也就是民事权利内容的实现。权利人通过实施行使权利的行为，可以实现权利所体现的利益，以满足自身的需要。权利都是以一定的利益为内容的，权利人为满足自己的需要，要实现该利益，就必须行使自己的权利。行使权利是使权利中包含的行为的可能性成为现实性。当事人所实施的行为无非包括事实行为和民事行为两种，因此，权利行使的方式可以分为事实方式和法律方式两种。所谓事实方式是指权利人通过实施某种事实行为来行使权利，如所有人通过使用自己的财产来行使所有权。所谓法律方式是指权利人通过实施某种民事法律行为来行使权利，例如，所有人通过赠与来行使对自己财产的处分权。

任何权利的实现，不仅关涉权利人的利益，而且关涉义务人的利益以及国家和社会的利益，因此对民事权利的行使要作出必要限制。其理由在于：

1. 维护国家利益和社会公共利益。权利主要体现的是一种权利人的私人利益，但是这种利益有可能和社会公共利益发生冲突。例如，人格权的行使与舆论监督、舆论自由等会发生冲突和矛盾。所以，法律从维护社会公共利益考虑，需要对权利人的权利行使作出必要的限制。

2. 维持民事主体之间的利益平衡。民事权利常常涉及各个民事主体之间的利益冲突，任何人在行使权利时，对他人对其行使权利造成的不便，负有适当容忍的义务。

3. 提高经济效益。权利的行使，必须有利于增进社会效益和福祉。例如，土地使用权人在一定的期限内不使用土地，将造成社会财富的浪费。在此情况下，国家就可以提高土地的利用效率为由，收回土地使用权。

二、民事权利行使的原则

在我国，有关法律、法规对民事权利行使的限制较多，但在民事权利法中不可能对这些限制一一列举，而只能作出一些原则性的概括规定。具体来说，民事权利的行使应当符合如下原则：

（一）自愿原则

所谓权利行使的自愿原则，是指民事主体有权按照自己的意愿行使权利，不受他人的非法干涉。《民法总则》第130条规定：“民事主体按照自己的意愿依法行使民事权利，不受干涉。”权利行使的自愿原则是民法自愿原则的具体体现。依据这一规定，民事主体在行使民事权利时，首先可以选择行使或者不行使某种权利，权利本身就是赋予权利人一种行为自由。“法无禁止皆自由”，权利人有权依法从事某种民事活动和不从事某种民事活动。也就是说，在民事领域，除了法律另有规定之外，权利人是否行使某种权利，或者不行使某种权利，从事某种行为或不行为，完全应当由权利人自主决定。只要是在法律规定的范围内，权利人有权自主决定权利行使的内容、方式等。其次，民事主体依法行使权利的行为不受他人的非法干涉。也就是说，“自由止于权利”，权利本身界定了人与人之间行为自由的界限，权利人享有的权利也是他人不得非法逾越的行为边界，任何个人和组织，即便是政府机构，也不得非法干涉他人合法行使权利的行为。

（二）义务必须履行原则

民法本质上虽然是权利法，但我国民法在保障民事权利的同时，也注重义务的履行，从而构建了权利义务一体的法律规则体系。《民法总则》第131条规定：“民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。”依据这一规定，权利人在行使权利时，必须履行其应尽的义务，具体而言，包括两个方面：

一是履行法律规定的义务。法治是规则之治。法律规则是明确的、普遍的、公开的规范，是人们行为的指引，是行政执法和司法裁判的依据。法律规则是指经过国家制定或认可的关于人们行为或活动的命令、允许和禁止的规范。所以，在民法上，守法除了要求依法行使权利外，还意味着必须履行法律规定的义

务，必须将法定义务内化于心，外化于行。

二是履行当事人约定的义务。契约必须严守是合同法的基本原则，早在罗马法，债即被形象地称为“法锁”，其本意是强调合同必须严守。《法国民法典》第1134条规定：“依法成立的契约，在缔结契约的当事人间有相当于法律的效力。”这就确立了契约神圣的原则。我国古代就有“民有私约如律令”的说法，它不仅包含了严守合同、履行允诺的内涵，还将民间私契在当事人之间的效力与官府律令的效力等同起来，反映了契约神圣性的观念。重允诺、守信用也是我国优秀传统文化的重要内容。《合同法》第6条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”第8条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”上述规则都要求当事人在交易过程中严守合同，并且按照诚实信用原则履行合同，同时，在一方当事人违反合同约定时，对方当事人有权请求其承担违约责任，这也有利于保障当事人严守合同。《民法总则》第131条的规定，也是我国立法经验的总结。

（三）禁止权利滥用原则

所谓权利滥用，是指行使权利违背权利设定的目的，损害了他人利益。我国《宪法》第51条规定：“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”《民法总则》依据《宪法》的规定，于第132条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”这就确立了禁止权利滥用的规则。

权利意味着主体的意志自由，但这种自由是有一定的限度的。法律并不允许权利人以任何方式随心所欲地行使自己的权利，民事权利亦不例外。从权利行使角度来看，自由止于权利。任何权利的实现不仅关涉权利人的利益，而且涉及义务人的利益、国家和社会的利益。因此，各国立法无不对权利的行使规定了这样或那样的限制。在罗马法中，曾经有“凡行使权利者，无论于何人皆非不法”的规定。但近代以来，各国基本都认可了禁止权利滥用的规则。[113]例如，《德国民法典》第226条规定：“权利的行使不得只以加损害于他人为目的”。《日本民法典》规定“私权要遵守公共福利，行使权利和履行义务要遵守信义，忠实执行，不允许滥用权利。”这是因为“权利存在于将要实现其作用的范围内。超出这一范围，权利享有人便超出或滥用了这些权利。滥用权利的行为是一种与国家制度和精神不相符合的行为”[114]。禁止权利滥用是与法律赋予民事主体权利的目的相一致的。我国民法一方面鼓励权利人正当地行使权利，满足个人利益的需要，另一方面又为权利的行使划定了这些界限，禁止权利人超出这些界限侵犯他人和社会利益。我国法律、法规不仅通过许多强制性的规范确立了民事权利行使的目的和界限，《民法总则》的上述规定也确立了禁止滥用权利的规则。

在民法上，关于判断滥用权利的标准，各国立法规定和实践做法也是极不统一的，大致可分主观说和客观说两种。主观说以权利人行使权利的主观状态为标准，认为行使权利时有故意滥用的意志，就构成滥用权利。客观说以权利行使的客观结果为标准，认为只要行使权利时损害了他人和社会的利益，就为滥用权利。

本书认为，判断是否滥用权利应当坚持主客观标准的统一。滥用权利，应当具备如下条件：首先，要有权利的存在。如果根本就没有权利，也就谈不上“滥用”。其次，须损害了国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。损害他人利益是滥用权利的客观标志。权利的行使虽然是权利人的自由，但权利人应当在法律规定的范围内行使权利，即使对所有权人来说，也只能在法律规定的范围内享有所有权的各项权能。权利的行使必须要有合理的界限，这个界限就是不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。如行使权利造成他人损害，也构成滥用权利。再次，须行为人主观有过错。权利人行使权利中损害他人或社会利益的过错是构成滥用权利的主观标准。主观有过错，并不意味着一定要有损害的恶意，当然，滥用权利的过错在多数情况下表现为故意，但有时候也表现为过失。如实施正当防卫行为时的防卫过当，就不一定都是故意的。

滥用权利本身也是权利人在行使权利中实施的违反其应负的法律义务的行为。因此，滥用权利的行为将发生两方面的后果：一是不能发生行为人预期的法律效果。[115]例如，当事人利用订约自由，恶意诱使他人违约，则不能发生合同生效的效力。二是滥用权利造成他人损害，将承担法律责任。[116]滥用权利的行为常常以构成他人的损害为后果，因而，滥用权利往往同时也构成侵权，行为人主观上具有过错，因此，应当依据《侵权责任法》第6条第1款的规定承担侵权责任。

第六节 民事权利的保护

权利是由法律赋予的，也是受法律保护的。权利的法律保障的重要内容就是法律确认保护权利的种种措施。民事权利的保护措施按其性质可以分为自我保护和国家保护两种形态。法定的民事权利体系需要借助个人为权利而斗争的行为加以实现。1872年3月11日，德国法学家鲁道夫·冯·耶林在维也纳法律协会上作了一个《为权利而斗争》的演讲，这也是一篇震撼了全世界的、最畅销的、迄今为止流传最广的德语法学著作。[117]在民事权利遭受侵害的情况下，通过公权力救济民事权利虽然是必要的，但民事权利主要体现为私人利益，如果当事人不积极主张，公权力往往难以主动介入，这就不利于对权利的保护，因此需要民事主体自身为权利而斗争。权利观念其实就是法律观念，权利意识也往往就是法律意识，充分保障民事权利是构建法治社会的基础，因此，依法为权利而斗争就是为法律的实现而斗争。如果每一个民事主体在权利受到侵害时，都能积极捍卫权利、主张权利，也就更有利于权利乃至法律的实现。

一、民事权利的自我保护

（一）对私力救济的抑制

所谓民事权利的自我保护，是指权利人自己采取各种合法手段来保护自己的权利不受侵犯。这种保护措施是由当事人自己采取的，因此又称为私力救济或自我救济。采取自我保护手段受到法律的严格限制，权利主体只能以法律许可的方式和在法律允许的限度内保护自己的权利。

民事权利的自我保护还包括当事人通过协商解决争议。一般情况下，由于当事人的根本利益是一致的，没有什么根本性的利害冲突，因而，一旦权利被侵害，出现民事纠纷，当事人可以自行协商解决，或者在有关人员或单位的调解下通过非诉讼程序解决。但是，这绝不是说，一切民事纠纷，当事人都要自行解决。在任何时候、任何情况下，权利受到侵害的当事人都有权请求人民法院或其他国家机关依法给予保护。但在法治社会，应当对私力救济予以抑制，如《物权法》中保护占有，一个重要目的就是限制私力救济。抑制私力救济也有利于防止暴力冲突、维护社会正常秩序。

（二）自我保护的措施

民事权利的自我保护主要包括正当防卫、紧急避险和自助行为，对前两种情形，本书将在民事责任部分予以探讨，以下主要讨论自助行为。所谓自助（Selbsthilfe），是指权利人为保证自己的请求权的实现，在情事紧迫而又不能及时请求国家机关予以救助的情况下，对他人的财产或自由施加扣押、拘束或其他相应措施，而为法律或社会公德所认可的行为。例如，旅馆在客人住宿后不付住宿费时，有权扣留客人所携带的行李。自助必须是为保护自己的合法权益。情况紧迫意味着权利人若不在当时采取自助措施，则其权利难以实现。实行自助必须是为了保证自己的请求权的实现，且该请求权必须是可以强制执行的。自助行为不得超过保护请求权所必需的程度。通过扣押某项财产可以达到自助目的的，不得限制他人的人身。因自助超过必要限度，给债务人造成不应有的损害时，行为人应负适当的民事责任。在我国民法中，目前对自助行为尚无明文规定，但在日常生活中，自助行为是广泛存在的。行为人采取自助措施常常受到社会习惯和舆论的认可，因此，一方面需要承认某些必要的自助行为的合法性，另一方面，对于自助行为应当严格限制其适用的条件。

二、民事权利的国家保护

所谓民事权利的国家保护，是指权利受到侵犯时，由国家机关给予保护。这种保护手段是由国家机关采取的，所以又称为公力救济。公力救济的典型形式是权利人通过诉讼的方式，请求人民法院对权利予以国家保护。

由于民事权利的种类不同，受到侵害的方式不同，因而当事人提起诉讼请求保护的目的是要求也不同。一般来说，当事人提起的民事诉讼请求有如下三种类型：

1. 确认之诉，即请求人民法院确认某种权利是否存在的诉讼。请求确认的权利主要是绝对权，包括物权、知识产权、人身权等。至于相对权发生纠纷，如合同债权，一般是通过给付之诉来解决的。确认之诉的对象也主要是支配权，因为支配权本质上是对权利人特定的财产利益和人身利益的支配，一旦这种支配受到侵害或者在归属上发生争议，权利人就可以请求法院予以确认。各种权利的确认，常常是其他诉讼的前提，因为只有在权利归属明确以后，才能进一步解决侵权或者其他问题。例如，不能在权利尚未界定时就直接确认某种行为是否构成侵权或应当被宣告无效。

2. 给付之诉，即请求人民法院责令对方作出某种行为，以实现自己的权利，如请求交付财产、偿付违约金和赔偿金等。给付之诉针对的主要是请求权，请求权一般都具有可诉性，可以以诉讼方式行使，形成给付之诉。当事人提起给付之诉，必须要以请求权为基础，如不存在合法有效的请求权，就不能提起给付之诉。

3. 形成之诉，即请求人民法院通过判决变更现有的某种民事权利义务、形成某种新的民事权利义务的诉讼，如因请求分割共有财产、终止合同关系、解除收养关系、申请死亡宣告等而提起的诉讼。形成之诉，主要针对的是形成权，包括解除权、撤销权。这些权利通过一方的意思表示就可以使法律关系发生、变更和消灭，而义务人并不享有相对的权利，所以只要有形成权存在，通过形成之诉，使形成权实现就可以导致法律关系发生、变更和消灭。

上述各种诉讼形式本来应当属于民事诉讼法的范畴，但由于涉及不同的权利，所以通常也称为民事权利的诉讼保护方式。由于民事法律规范中有很大一部分属于任意性规范，所以在权利人的权利受到侵害以后，是否提起诉讼，可以由权利人依法自行决定。当然，对于一些涉及国家和社会利益的民事争议，国家有关机关应依法进行干预。

思考题

1. 试述民事权利的本质。
2. 简述民事权利的类型划分。
3. 简述民法请求权的体系。
4. 简述民事权利的行使原则。
5. 简述民事权利的保护形态。

[1] 夏勇. 中国民权哲学. 上海：上海三联书店，2004：4.

[2] 李贵连. 话说“权利”. 北大法律评论. 第1卷第1辑. 北京：法律出版社，1998.

[3] 转引自迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京：法律出版社，2001：62.

[4] [5] 耶林. 拿破仑法典以来私法的普遍变迁. 徐砥平译. 北京：会文堂新记书局，1915：18.

[6] 卡尔·拉伦茨. 德国民法通论. 上册. 王晓晔等译. 北京：法律出版社，2003：279.

[7]Enneccerus-Nipperdey, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 15. Aufl., 1959.pp. 429-430.

[8]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 65.

[9]申卫星. 构建公权与私权平衡下的中国物权法. 当代法学, 2008 (4) .

[10]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 65.

[11]平托. 民法总论. 澳门: 澳门法律翻译办公室, 1999: 88.

[12]魏振瀛主编. 民法. 4版. 北京: 北京大学出版社, 高等教育出版社, 2010: 37.

[13]参见最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第1条.

[14]谢怀栻. 谢怀栻法学文选. 北京: 中国法制出版社, 2002: 354.

[15]谢怀栻. 论民事权利体系. 法学研究, 1996 (2) .

[16]Vinding Kruse. The Right o f Property. Oxford University Press, 1953.p. 123.

[17]李宜琛. 民法总则. 台北: 正中书局, 1994: 47.

[18]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 98.

[19]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2001: 61.

[20]吴汉东, 胡开忠. 无形财产权制度研究. 北京: 法律出版社, 2001: 37.

[21]徐国建. 德国民法总论. 北京: 经济科学出版社, 1993: 22.

[22]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 101.

[23]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 67.

[24]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 101.

[25]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 67.

[26]王泽鉴. 民法债编. 第1册. 基本理论. 台北: 自版, 1990: 17.

[27]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2001: 69.

[28]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2001: 60.

[29]Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, Carl Heymanns Verlag, 1999.p. 6.

[30]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 69.

[31]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 104.

[32]王泽鉴. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 1998: 95.

[33]刘得宽. 民法诸问题与新展望. 台北: 三民书局, 1979: 478.

[34]施启扬. 民法总则. 修订8版. 北京: 中国法制出版社, 2010: 33.

[35]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 105-106.

[36]施启扬. 民法总则. 修订8版. 北京: 中国法制出版社, 2010: 33.

[37]迪特尔·梅迪库斯. 德国民法总论. 邵建东译. 北京: 法律出版社, 2001: 68.

[38]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 106.

[39]王泽鉴. 民法总则. 北京: 北京大学出版社, 2009: 108.

- [40]林诚二.论形成权.载杨与龄主编.民法总则争议问题研究.台北:五南图书出版公司,1998:74.
- [41]迪特尔特·梅迪库斯.德国民法总论.邵建东译.北京:法律出版社,2001:79.
- [42]王泽鉴.民法总则.北京:北京大学出版社,2009:107-108.
- [43]魏振瀛主编.民法.4版.北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2010:39.
- [44]史尚宽.民法总论.北京:中国政法大学出版社,2000:22.
- [45]郑玉波.民法总则.北京:中国政法大学出版社,2003:70.
- [46]郑玉波.民法总则.北京:中国政法大学出版社,2003:70.
- [47]史尚宽.民法总论.北京:中国政法大学出版社,2000:29.
- [48]郑玉波.民法总则.北京:中国政法大学出版社,2003:72.
- [49]申卫星.期待权研究导论.清华法学,2002(1).
- [50]刘郁武.所有权保留研究.法学家,1998(2).
- [51]马特,袁雪石.人格权法教程.北京:中国人民大学出版社,2007:11.
- [52]陈民.论人格权.法律评论,第28卷第8期.
- [53]施启扬.民法总则.台北:自版,1996:94.
- [54]尹田.论一般人格权.法律科学,2002(4).
- [55]王利明,杨立新,姚辉.人格权法.北京:法律出版社,1997:35.
- [56]“钱缘诉上海屈臣氏日用品有限公司搜身侵犯名誉权案”,上海市虹口区人民法院(1998)虹民初字第2681号民事判决书,上海市第二中级人民法院(1998)沪二中民终字第2300号民事判决书.
- [57]唐德华.民事审判若干理论与实践问题.长春:吉林人民出版社,2002:163.
- [58]杨立新.人身权法论.北京:人民法院出版社,2002:105.
- [59]杨立新.人身权法论.北京:人民法院出版社,2002:107.
- [60]王利明主编.人格权法新论.长春:吉林人民出版社,1994:209.
- [61]《物权法》第2条第3款规定:“本法所称物权,是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利。”
- [62]史尚宽.民法总论.北京:中国政法大学出版社,2000:254.
- [63]陈华彬.民法物权论.北京:中国法制出版社,2010:55.
- [64]谢在全.民法物权论.修订2版.台北:三民书局,2003:20.
- [65]申卫星.物权法原理.北京:中国人民大学出版社,2008:45.
- [66]《物权法》第4条规定:“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。”
- [67]参见湖北省宜昌市中级人民法院(2010)宜中民一终字第201号民事判决书.
- [68]梁慧星主编.中国物权法草案建议稿.北京:社会科学文献出版社,2000:103页以下.
- [69]《征收与补偿条例》第8条规定:“为了保障国家安全、促进国民经济和社会发展等公共利益的需要,有下列情形之一,确需征收房屋的,由市、县级人民政府作出房屋征收决定:(一)国防和外交的需要;(二)由政府组织实施的能源、交通、水利等基础设施建设的需要;(三)由政府组织实施的科技、

教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要；（四）由政府组织实施的保障性安居工程建设的需要；（五）由政府依照城乡规划法有关规定组织实施的对危房集中、基础设施落后等地段进行旧城区改建的需要；（六）法律、行政法规规定的其他公共利益的需要。”该条规定实际上是对公共利益内涵的一种表述。

[70]最高人民法院（2015）行监字第612号行政裁定书。

[71]最高人民法院公报，2004（8）。

[72]Fikentscher/ Heinemann, Schuldrecht, Berlin, 2006, S. 2.

[73]黄茂荣. 债法总论. 第1册. 增订3版. 台北：自版，2009：16.

[74]蓝承烈. 论合同效力的扩张. 学术交流，2000（6）。

[75]张新宝. 侵权行为法的一般条款. 法学研究，2001（4）。

[76]张新宝. 中国侵权行为法. 2版. 北京：中国社会科学出版社，1998：36.

[77]洪逊欣. 中国民法总则. 台北：自版，1992：61.

[78]胡波. 中国民法典编纂体例之我见——以绝对权与相对权的二元结构为中心. 河北法学，2007（4）。

[79]王文钦. 论第三人侵害债权的侵权行为. 载梁慧星主编. 民商法论丛. 第6卷. 北京：法律出版社，1997；朱晓喆. 债之相对性的突破——以第三人侵害债权为中心. 华东政法学院学报，1995（3）。

[80]王泽鉴. 债法原理. 北京：中国政法大学出版社，2003：416.

[81]Hans Brox, Besonders Schuldrecht, Muenchen, 2007, S. 418.

[82]江俊彦. 民法债编总论. 台北：新学林出版股份有限公司，2011：170.

[83]史尚宽. 债法总论. 北京：中国政法大学出版社，2000：62.

[84]王泽鉴. 债法原理. 2版. 北京：北京大学出版社，2013：315.

[85]黄立. 民法债编总论. 北京：中国政法大学出版社，2002：171.

[86]郑玉波. 民法债编总论. 北京：中国政法大学出版社，2004：92.

[87]黄茂荣. 不当得利. 台北：植根法学，2011：8.

[88]冯·巴尔等主编. 欧洲私法的原则、定义与示范规则：欧洲示范民法典草案. 第五卷至第七卷. 王文胜等译. 北京：法律出版社，2014：874.

[89]王泽鉴. 不当得利. 北京：中国政法大学出版社，2002：204.

[90]Hans Brox, Besonders Schuldrecht, Muenchen, 2007, S. 475.

[91]黄茂荣. 不当得利. 台北：植根法学，2011：230.

[92]Hans Brox, Besonders Schuldrecht, Muenchen, 2007, S. 474.

[93]郑玉波. 民法债编总论. 北京：中国政法大学出版社，2004：107.

[94]王泽鉴. 不当得利. 北京：中国政法大学出版社，2002：204.

[95]史尚宽. 债法总论. 北京：中国政法大学出版社，2000：94.

[96]吴汉东. 关于知识产权本体、主体与客体的重新认识——以财产所有权为比较研究对象. 法学评论，2000（5）。

- [97]王岩. 专利的价值及其运营. 知识产权, 2016 (4) .
- [98]彭学龙. 寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡. 法学研究, 2010 (3) .
- [99]王笑冰. 关联性要素与地理标志法的构造. 法学研究, 2015 (3) .
- [100]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 289.
- [101]戴建志, 陈旭主编. 知识产权损害赔偿研究. 北京: 法律出版社, 1997: 132.
- [102]孔祥俊. 合同法教程. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1999: 145.
- [103]孔祥俊. 商业秘密保护法原理. 北京: 中国法制出版社, 1998: 41.
- [104]管荣齐, 薛智胜. 从TPP知识产权规则审视植物新品种的可专利性. 知识产权, 2016 (3) .
- [105]史尚宽. 继承法论. 北京: 中国政法大学出版社, 2000: 92-93.
- [106]牟延林, 吴安新. 继承权应属于侵权法的保护对象. 天津商学院学报, 2001 (3) .
- [107]郭明瑞, 房绍坤. 继承法研究. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 前言.
- [108]范健, 王建文. 公司法. 北京: 法律出版社, 2008: 287.
- [109]范健, 王建文. 公司法. 北京: 法律出版社, 2008: 288.
- [110]石宏主编. 中华人民共和国民法总则条文说明、立法理由及相关规定. 北京: 北京大学出版社, 2017: 298.
- [111]朱庆育. 民法总论. 北京: 北京大学出版社, 2013: 490.
- [112]曾世雄. 民法总则之现代与未来. 北京: 中国政法大学出版社, 2001: 54.
- [113]我妻荣. 新订民法总则. 于敏译. 北京: 中国法制出版社, 2008: 33.
- [114]André Tunc. International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. 4. Torts. Chapter 2. Liability for One's Own Act, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck, Tübingen), 1975, p. 11.
- [115]我妻荣. 新订民法总则. 于敏译. 北京: 中国法制出版社, 2008: 33.
- [116]郑玉波. 民法总则. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 550.
- [117]鲁道夫·冯·耶林著, 奥科·贝伦茨编注. 法学是一门科学吗?. 李君韬译. 北京: 法律出版社, 2010: 编者前言第5页及该页注[5], 作者简介部分.